

JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI

**COMENTÁRIOS
AO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL** | **VIII**

ARTIGOS 485 AO 538

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

2019 - 10 - 15

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais **Juliana Mayumi Ono**

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chisley Figueiredo

Adaptação de capa: Linotec

Projeto gráfico: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

Analista de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis

2019 - 10 - 15

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

DEDICATÓRIA

Dedicatória

Aos meus queridos filhos, Rogério e Rafael, com quem tenho a felicidade de compartilhar os dilemas da profissão de advogado.

© desta edição [2018]

2019 - 10 - 15

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o Autor

Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1978), Mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo (1980) e Doutorado em Direito – Università di Roma – La Sapienza (1982). É Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dedicou-se ao estudo do Direito Processual Civil e da História do Direito Processual Civil.

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

ÍNDICE

PARTE ESPECIAL

LIVRO I - DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...]

TÍTULO I - DO PROCEDIMENTO COMUM [...]

CAPÍTULO XIII - Da sentença e da coisa julgada [Art. 485 a 508]

CAPÍTULO XIV - Da liquidação de sentença [Art. 509 a 512]

TÍTULO II - DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA [...]

CAPÍTULO I - Disposições gerais [Art. 513 a 519]

CAPÍTULO II - Do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa [Art. 520 a 522]

CAPÍTULO III - Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa [Art. 523 a 527]

CAPÍTULO IV - Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos [Art. 528 a 533]

CAPÍTULO V - Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública [Art. 534 a 535]

CAPÍTULO VI - Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa [Art. 536 a 538]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

PARTE ESPECIAL - LIVRO I. DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PARTE ESPECIAL - Livro I. Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença

1. Nota explicativa: conteúdo do Livro I da Parte Especial

Alterando formalmente a estrutura do CPC/1973, o novo diploma processual, com sistemática mais científica, rege, no Livro I da Parte Especial, o processo de conhecimento, disciplinando o procedimento comum e os procedimentos especiais, e, ainda, entre eles, as regras atinentes ao cumprimento de sentença.

O procedimento comum não mais se desdobra em ordinário e sumário, havendo assim um único procedimento de cunho residual, que deve ser seguido quando o processo de determinada demanda não for construído por normas procedimentais especiais.

O Título I, dedicado ao procedimento comum, é subdividido nos Capítulos I ao XIV, que regulamentam: as disposições gerais (Cap. I), a petição inicial (Cap. II), a improcedência liminar do pedido (Cap. III), a audiência de conciliação e mediação (Cap. V), a contestação (Cap. VI), a reconvenção (Cap. VII), a revelia (Cap. VIII), as providências preliminares e o saneamento (Cap. IX), o julgamento conforme o estado do processo (Cap. X), a audiência de instrução e julgamento (Cap. XI), as provas (Cap. XII), a sentença e a coisa julgada (Cap. XIII), e, por fim, a liquidação de sentença (Cap. XIV).

Cumprir recordar que o Capítulo IV, sob a rubrica *Da Conversão da Ação Individual em Ação Coletiva*, contendo o art. 333, recebeu veto presidencial.

O Título II disciplina o cumprimento de sentença, em seis capítulos, a saber: disposições gerais (Cap. I), cumprimento provisório da sentença condenatória de pagar quantia certa (Cap. II), cumprimento definitivo de sentença condenatória de pagar quantia certa (Cap. III), cumprimento de sentença por débito alimentar (Cap. IV), cumprimento de sentença condenatória de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública (Cap. V) e cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa (Cap. VI).

Este volume de comentários abrange os Capítulos XIII e XIV do Título I (*Do procedimento comum*) e os Capítulos I ao VI do Título II (*Do cumprimento de sentença*) do Livro I da Parte Especial, cobrindo os arts. 485 ao 538, desde as disposições gerais da sentença e da coisa julgada até o cumprimento da sentença em suas diversas modalidades, que apresentam inúmeras novidades e alterações importantes em relação ao CPC revogado e, por esta razão, ao analisá-las e optar pela melhor interpretação para cada uma delas, norteado pela minha experiência acumulada na Academia e no Foro por mais de 35 anos, apenas procurei apontar o caminho que, em princípio, pareceu-me mais compatível com as tendências da moderna ciência processual, ajustando-as ao espírito da nova legislação.

Tenho expectativa de que estes comentários possam auxiliar os operadores do direito na exegese e na aplicação cotidiana das novas regras do CPC.

Capítulo XIII. Da Sentença e da Coisa Julgada

Seção I

Disposições gerais

1. Introdução

O novo CPC, com estrutura formal bem diferente da legislação revogada, inaugura o Cap. XIII do Livro I da Parte Especial sob a rubrica *Da Sentença e da Coisa Julgada*.

As disposições que seguem, além de regerem o procedimento comum, a teor do parágrafo único do art. 318, aplicam-se subsidiariamente, no que for compatível, aos procedimentos especiais e de execução.

A sentença, no ambiente jurídico das mais diferentes experiências jurídicas do passado, sempre foi considerada o ato magno do processo, o ato jurisdicional por excelência, pelo qual o juiz emite o seu veredito, decidindo o litígio até então pendente entre as partes e conseqüentemente pondo termo à fase de cognição, ao menos em primeiro grau de jurisdição.

À época do direito romano clássico, diferentemente do que ocorria no âmbito das antigas ações da lei, no qual o juiz encontrava-se vinculado ao resultado da prova, no processo formular, vigorando a regra da livre convicção, o julgador, nos limites da fórmula, possuía certa discricionariedade para formar a *ratio decidendi*.¹

Na maioria das vezes, como revelam as fontes, a sentença era escrita, não significando, contudo, que fosse esse um requisito formal.

A sentença, tendo presente os termos da fórmula, limitava-se a declarar a procedência ou improcedência da *intentio*: *condemnatio* ou *absolutio*. Lembre-se de que a condenação era sempre pecuniária (*certa pecunia* – Gaio, I., 4.48).

Ressalte-se que a expressão *si paret* constante da fórmula volta-se à inteligência do juiz, cujo convencimento, nos limites daquela, pode formar-se livremente, não estando de modo algum vinculado por qualquer prescrição legislativa nem tampouco pela observância de provas formais, que são de todo estranhas ao processo clássico. O resultado da atividade lógica, pela qual o *iudex* chega a uma determinada convicção, nada mais é do que uma *sententia* na acepção normal e comum da palavra, que significa opinião. Mas o *iussus* do magistrado (pretor) não determina ao juiz para simplesmente formar uma opinião, todavia, impõe-lhe um comportamento (condenação ou absolvição) subordinado à formação da *sententia* num ou noutro sentido. O *si paret ... non paret* representa, pois, o elemento lógico, a *sententia*; o *condemna ... absolve* o elemento jurídico, o *iudicatum*.

Assim, jamais sendo motivada, a sentença do *iudex* supunha, em regra, uma simples declaração que tinha o condão de por fim à controvérsia e de fazer nascer uma nova relação jurídica entre os litigantes. Essa nova relação, denominada *res iudicata*, é que iria servir de fundamento da *actio iudicati*, pela qual o vencedor podia exigir o cumprimento da sentença que lhe fora favorável.

A *auctoritas rei iudicata* como produto imediato da sentença condenatória, na célebre definição de Modestino (*D. 42.1.1, libro VII pandectarum*), gerava então, dentre outros relevantes efeitos, a *obligatio iudicati* .

Da sentença, outrossim, emergia o efeito de permitir a inserção da *exceptio rei iudicatae* na fórmula de idêntica *actio* posteriormente ajuizada.

Como resposta ao anseio último das partes, o ideal sempre foi o de que a sentença examine o mérito da causa, evitando que eventualmente haja nova discussão, em sucessiva demanda, entre as mesmas partes. É dizer, interessa muito mais à pacificação dos jurisdicionados que seja proferida uma sentença de fundo, erradicando de uma vez por todas qualquer discórdia entre os litigantes.

Com efeito, no desenrolar da atividade judicante, a sentença – prestação jurisdicional ao pedido formulado pelo autor – constitui o ato mais relevante do processo. E é exatamente aquele que, na expressiva síntese de Alfredo Rocco, o Estado, por intermédio do juiz, aplica a norma legal, bem como, quando necessário, as demais formas de expressão do direito, ao caso concreto, declarando qual tutela processual o ordenamento jurídico concede a um determinado interesse.²

Todavia, nem sempre é possível ao órgão investido de jurisdição encerrar o processo de conhecimento por meio de provimento que julgue o objeto da controvérsia. Assim, tradicionalmente, a dogmática classifica as sentenças em: *a*) terminativas, com conteúdo meramente processual, que não enfrentam o *meritum causae* ; e *b*) definitivas, aquelas que julgam a lide.

O novo diploma processual, nesse particular, seguiu as mesmas diretrizes do CPC revogado, disciplinando, nos arts. 485 e 487, respectivamente, o regime das sentenças que não resolvem o mérito e daquelas que julgam o mérito.

É certo que em ambas as hipóteses o referido ato decisório não põe termo ao processo, mas, sim, à fase de conhecimento, seguindo-se, nos mesmos autos, a fase de cumprimento da sentença, ainda que se limite esta à execução das verbas de sucumbência, quando não adimplidas voluntariamente pelo vencido.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1.º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir

a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2.º No caso do § 1.º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4.º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5.º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6.º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7.º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Correspondência: art. 267 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 384 do NCPC francês, arts. 306 e 307 do CPC italiano, art. 207 da LEC espanhola, arts. 277 e 278 do CPC português, § 330 do ZPO alemão, art. 236 do SZO suíço

1. Aspectos gerais

O art. 485, que corresponde ao art. 267 do diploma revogado, dispõe exatamente sobre a sentença de natureza processual (terminativa), que deve ser proferida quando existir obstáculo intransponível, a impedir que o juiz possa dirimir o objeto material do processo.

Diante de vicissitudes meramente formais, o *caput* do artigo sob comentário prefere a expressão “ *não resolverá o mérito* ” ao invés de “ *extinção do processo sem resolução do mérito* ”, uma vez que as situações que arrola em seus dez incisos não ensejam, de fato, a extinção do processo,³ porquanto pode ainda ser necessário à parte vencedora deflagrar a denominada fase de cumprimento de sentença (arts. 513 e ss.), visando à excussão coercitiva do crédito relativo a custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência.

É exatamente por esta razão – observa José Roberto dos Santos Bedaque – que a sentença, no novel diploma processual, não mais guarda relação formal com o término do processo, a exemplo do que sucedia com a redação original do art. 162 do CPC/1973. A sentença, portanto, passa a ser o provimento mediante o qual o juiz, ressalvadas algumas exceções, põe fim à fase de conhecimento do processo ou à execução (art. 203, § 1.º), com ou sem julgamento de mérito (arts. 485 e 487).⁴

As situações que impedem a resolução do mérito encontram-se, pois, catalogadas no art. 485, sendo fundamental, por imperativo de economia, que o juiz proceda ao exame daquelas já na fase preambular da tramitação do processo. Deixar de resolver o mérito, por exemplo, com fundamento na inépcia da petição inicial, depois da instrução da causa, configura ocorrência absolutamente indesejável, que revela, quando nada, a falta de compromisso do juiz com exigência de eficiência da administração da justiça e, sobretudo, com o princípio fundamental da duração razoável do processo!

A prática evidencia, nesse particular, a existência de casos que chegam a ser até inusitados, nos quais a inépcia vem reconhecida apenas no Superior Tribunal de Justiça.⁵

2. Indeferimento da petição inicial (inc. I)

Ajuizada a demanda, antes mesmo de determinar a citação do réu, o sistema da nova matriz processual pressupõe o início da atividade saneadora do juiz, com o exame formal da petição inicial. Esta, que constitui o primeiro ato postulatório do processo, deve ser construída à luz do

modelo estabelecido nos arts. 319 e 320 do CPC. Caso contrário, ou seja, se a petição inicial não estiver em termos para ser admitida, seja do ponto de vista lógico, seja sob o aspecto técnico, deverá ser indeferida.

A rejeição da petição inicial é expressamente prevista nas hipóteses arroladas no art. 330, desde a inépcia, ilegitimidade de parte, ausência de interesse processual, até a incompatibilidade de pedidos. Verificada qualquer uma destas situações anormais, quando possível, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 dias, supra o defeito, sob pena de indeferimento (art. 321 e parágrafo único, CPC).

Não há se confundir a natureza da sentença terminativa aqui proferida, com aquela que decorre da improcedência liminar do pedido, segundo a regra do art. 332 do CPC, implicativa da prolação de sentença de mérito, que produz coisa julgada material.

3. Inatividade das partes (inc. II)

O Estado não tem a prerrogativa de se imiscuir *sponte propria* nas questões litigiosas pendentes entre os jurisdicionados (“*wo kein Klager ist da ist kein Richter*”),⁶ afigurando-se, pois, pelo princípio da demanda (art. 2.º CPC), sempre imprescindível a provocação dos órgãos do Poder Judiciário, a fim de que estes, substituindo a investida dos interessados, possam, de modo imparcial e independente, declarar o direito, satisfazer o direito declarado ou, ainda, assegurar o direito cuja declaração é invocada.

Com a ação da parte, fundada no exercício do direito à jurisdição, ativando os órgãos estatais, detentores da função judicante, na busca de tutela jurisdicional, irrompe também o monopólio de disposição, reconhecido ao demandante.

Com efeito, tal concepção, vigente na generalidade dos ordenamentos processuais democráticos, exprime a supremacia do litigante para instaurar o processo, determinar-lhe o objeto e a extensão.⁷ Em idêntico sentido, José Roberto dos Santos Bedaque escreve que a hegemonia da parte sobre a iniciativa do processo sempre está presente independentemente da natureza do objeto litigioso. Mesmo que indisponível o direito subjetivo material, persiste o princípio da inércia da jurisdição, pelo qual o interessado detém o monopólio da demanda. E se o Estado tem interesse direto ou indireto na relação jurídica em jogo, ainda assim não se atribui qualquer poder de iniciativa ao juiz.⁸

Isso tudo significa que o litigante tem *full control* sobre o seu direito material e as suas respectivas garantias processuais e, outrossim, bem revela o poder da parte de livre escolha para o exercício ou não exercício destas prerrogativas.⁹ O juiz, por outro lado, nos limites da lei, detém poderes de direção material do processo e de iniciativa probatória, simplesmente porque deve estar comprometido com a solução mais justa possível da controvérsia, guiado por certo pela duração razoável do processo.

Vê-se claramente que, de um lado, prevalece a atividade das partes que têm autonomia quanto às próprias relações jurídicas substanciais que o processo objetiva tutelar; e, de outro, sobrepuja o interesse público em prol da tempestividade da prestação jurisdicional. Coordenam-se, assim, dois conhecidos princípios: o da disposição das partes, designado *Verhandlungsmaxime* (princípio da discussão) ou *Prinzip der Passivität des Gerichts* (princípio da passividade do tribunal) e o da oficialidade, denominado *Prinzip der Aktivität des Gerichts* (princípio da atividade do tribunal).¹⁰

Contudo, há circunstâncias nas quais, a despeito do impulso oficial atribuído ao órgão jurisdicional (art. 2.º), o processo fica paralisado por manifesto desinteresse de ambos os litigantes, como, *e.g.*, aquela em que o juiz defere a produção de prova pericial, determinando que as partes depositem, cada qual, metade dos honorários do perito. Sobrevindo descumprimento à ordem judicial, não há como transpor o obstáculo. Ficando então sobrestado o processo por mais de 1 ano, diante da manifesta negligência mútua, o juiz proferirá sentença não resolvendo o mérito, se tal recalcitrância persistir mesmo depois de intimados pessoalmente os litigantes, não suprirem eles a falta no prazo de 5 dias (art. 485, § 1.º).¹¹

Nesse caso, preceitua o § 2.º do art. 485 do CPC que ambos os litigantes deverão pagar proporcionalmente as custas processuais.

4. Abandono do processo (inc. III)

4.1. Aspectos gerais

Situação aparentemente assemelhada, mas diferente, é a que vem contemplada em sequência, qual seja a inércia do autor da demanda.

É hipótese típica de abandono do processo, que se configura pela contumácia do demandante, decorrente de sua injustificada omissão, por prazo superior a 30 dias, para a prática de um determinado ato processual.

E isso, *ex vi* do disposto no § 1.º do art. 485, após a intimação pessoal do autor, a fim de que, no prazo improrrogável de 5 dias, supra a falta ou justifique o motivo pelo qual deixou de efetivar o respectivo ato processual.¹²

Nota-se, destarte, não ser suficiente a paralisação do processo, mas é indispensável que o demandante demonstre a intenção de abandoná-lo, o que não acontecerá se o ato ou diligência vier a ser realizado espontaneamente, mesmo depois de vencidos os 30 dias, ou logo depois de intimado nos termos do referido § 1.º.

Caracteriza-se, assim, o abandono por um elemento subjetivo de presumida intenção de dispensar a tutela jurisdicional pleiteada e, ainda, por um elemento objetivo, qual seja o lapso temporal em lei previsto, agravado pela renitência do autor em não praticar determinado ato do processo, após ter sido regularmente intimado.

Na verdade, como já tive oportunidade de frisar, os atos processuais imprescindíveis para o desenvolvimento do processo, cujo descumprimento pelo autor propicia a incidência do inc. III, ora sob análise, são especialmente os seguintes: *a*) adiantamento das despesas processuais (citação, intimação, perícia) para a realização de atos requeridos (inclusive pelo Ministério Público) ou determinados de ofício; *b*) não devolução dos autos ao cartório pelo procurador do autor; *c*) diligência ordenada pelo juiz; *d*) prestação de caução relativa às custas e aos honorários advocatícios pelo autor, nacional ou estrangeiro, que resida no exterior, ou deixar de residir no país ao longo da tramitação da demanda (art. 83 CPC).¹³

4.2. Correção de equivocada analogia construída pela jurisprudência

Observe-se que, uma vez constatada a hipótese de prescrição intercorrente no terreno do cumprimento de sentença ou do processo de execução, pela paralisação injustificada em decorrência da prolongada indolência do exequente, o juiz determinará a intimação das partes para que se manifestem no prazo de 15 dias (§ 5.º do art. 921 CPC). Esta providência assenta-se na exigência de contraditório efetivo, *ex vi* do disposto no art. 10 do novo diploma processual.

Injustificada a inércia do exequente, nada mais resta ao juiz senão extinguir a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

No entanto, mesmo inexistindo qualquer fundamento legal específico, passou a prevalecer de um modo geral na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente, a exemplo do que se verifica em sede de abandono do processo, fica condicionado ao desleixo após a intimação pessoal do exequente. Realmente, a 4ª Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.245.412-MT, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu, com arrimo em anterior acórdão, que: "(...) 'De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte' (AgRg no AREsp 131.359-GO, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. em 20.11.2014, *DJe* 26.11.2014). Na hipótese, não tendo havido intimação pessoal da parte

exequente para dar andamento ao feito, não há falar em prescrição”.¹⁴

No mesmo sentido, a 3ª Turma, ao ensejo do julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 228.551-SP, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou que: “Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a intimação da parte para dar andamento ao feito”.¹⁵

A 4ª Turma, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.407.017-RS, com voto condutor do Ministro Antonio Carlos Ferreira, já havia proclamado que: “A prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida pelas instâncias ordinárias, a despeito de a questão ter sido aventada somente na instância recursal. No caso concreto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não houve a interrupção da prescrição, uma vez que o recorrido sequer foi citado para responder ao processo ajuizado contra si. Consoante a jurisprudência desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente”.¹⁶

Acrescente-se que, com lastro em posicionamento mais antigo do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se muito mais precisa e jurídica a tese sustentada em acórdão da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, estampada, recentemente, no julgamento do Agravo de Instrumento 2128666-63.2015.8.26.0000, tendo como relator o Desembargador Campos Mello, ao pontuar que: “(...) Aqui, ao contrário, parou o andamento da cobrança executiva por motivos insondáveis. Só o credor é que poderia explicar o motivo de sua inércia. Após mais de 6 (seis) anos sem se manifestar é que o exequente finalmente lembrou-se da existência do processo. Só que a prescrição intercorrente já se consumara. Nem se diga que teria sido necessária prévia intimação pessoal do credor, pois que a prescrição é instituto de direito material, não sujeito aos ditames da lei processual para que possa incidir. A propósito, convém transcrever trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça: ‘Claro está, por exemplo, que não se haveria de reconhecê-la, caso decorresse todo o tempo com os autos conclusos ao juiz, aguardando decisão. Daí não se segue, porém, que se haja de proceder à intimação para que possa fluir o prazo de prescrição quando o feito não tenha andamento por negligência da parte. Isso se impõe para a extinção do processo, de que cogita a lei processual, não para a prescrição’ (REsp 15.261-0-SP, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, m. v., in RSTJ 37/481) (...)”.¹⁷

Pois bem, revendo a orientação então predominante, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Recurso Especial 1.522.092-MS, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, passou a entender que a situação de abandono do processo não se confunde com a inatuação do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desnecessária a intimação pessoal do devedor.¹⁸

Com efeito, deixou assentado o respectivo voto vencedor que: “a intimação para dar andamento ao feito, mencionada nos precedentes supracitados, diz respeito à extinção do processo por abandono da causa pelo prazo de 30 dias, conforme previsto no art. 267, III, do CPC [1973], hipótese que não depende da ocorrência de prescrição, como já alertava o Ministro Eduardo Ribeiro, nos primeiros julgados desta Corte sobre o tema. Como a extinção pelo art. 267, III, não depende da ocorrência de prescrição, infere-se que a jurisprudência atual ou rejeita a tese da prescrição intercorrente na execução, ou a subordina à caracterização processual do abandono da causa, criando assim uma hipótese *sui generis* de prescrição. Uma consequência indesejável desse entendimento é a possibilidade de pretensões executórias subsistirem indefinidamente no tempo, não obstante a inércia da parte interessada. Essa consequência, a meu juízo, não pode ser admitida com tamanha amplitude, pois atenta contra o objetivo principal do sistema jurídico, que é a pacificação dos conflitos de interesse. Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor (...) Esse objetivo de pacificação social não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo. Quanto a esse ponto, o caso dos autos é emblemático, pois a execução permaneceu suspensa por 13 anos (de 1999 a 2012), sem qualquer iniciativa da parte credora, quando então os devedores, pretendendo livrarem-se do débito, requereram a declaração da prescrição

intercorrente, que teria sido consumada após 5 anos de suspensão do processo, por se tratar de dívida líquida (cf. art. 206, § 5.º, I, do CC). Evidentemente, é mais salutar para o sistema jurídico manter a pacificação social, obtida pelo transcurso de 13 anos sem o exercício da pretensão, do que manter eficácia do crédito por tempo indefinido. Essa ponderação que conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente, embora seja vencida na jurisprudência desta Corte, ganhou fôlego com a recente promulgação do novo CPC. Pelo novo CPC, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica também a suspensão da prescrição, mas somente pelo prazo de 1 ano, após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente. A propósito, confira-se o disposto no art. 921. Cabe esclarecer que a intimação mencionada no § 5.º, desse dispositivo, diz respeito exclusivamente à observância do princípio do contraditório, nada tendo a ver com aquela intimação para dar andamento ao feito, mencionada nos precedentes desta Corte. Sobre esse novo dispositivo legal, merece referência a doutrina de Gilson Delgado Miranda, em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, dentre outros (*Breves comentários ao novo CPC* , Ed. RT, São Paulo, 2015, p. 2065): ‘Por quanto tempo o processo de execução ficará suspenso? Há prazo? 10 anos? 20 anos? Pode o exequente requerer o desarquivamento de uma execução suspensa há 70 anos?’ O NCPC resolveu esse claro dilema. Realmente, na vigência do CPC/1973 houve muita divergência sobre o tema. Em precedente antigo do STJ, o Ministro Sálvio de Figueiredo, relator do REsp 280.873, 4ª Turma, j. 22.03.2001, verberou: ‘estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional. Nunca concordamos com essa orientação, especialmente depois da edição da Súmula 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Em outras palavras, no nosso sentir não há foro de prosperidade para se distinguir a orientação adotada em execução fiscal e aquela prevista para se aplicar à execução civil. Não comungamos da ideia de que uma execução suspensa a 70 anos possa ser desarquivada para expropriar os bens do executado. Em suma, em prol da segurança jurídica, à evidência, viável a defesa da prescrição intercorrente’. Essa inovação trazida pelo novo CPC, a meu juízo, confere contornos mais precisos a questão, pois, em nosso sistema jurídico, a prescrição é a regra, a imprescritibilidade é a exceção. Desse modo, os casos de imprescritibilidade devem-se limitar aos expressamente previstos no ordenamento jurídico, não sendo adequado criar outras hipóteses de imprescritibilidade pela via da interpretação, como ocorre ao se afastar a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente na execução. É por esta razão que se propõe, desde já, uma revisão da jurisprudência desta Corte Superior, para revigorar o entendimento consolidado na Súmula 150/STF, aplicando esse entendimento ainda na vigência do CPC/1973. Nesse passo, observa-se que o Código em vigor não estabeleceu prazo específico para a suspensão da execução. A propósito, confira-se a redação dos arts. 791 e 793 do CPC. Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr do último ato do processo. Como o CPC em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de 1 ano previsto no art. 265, § 5.º, do CPC e art. 40, § 2.º, da Lei 6.830/1980. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. No caso concreto, consta no acórdão recorrido que o processo de execução foi suspenso, *sine die* , em 1999, a requerimento do credor, tendo ficado paralisado até 2012, quando os devedores peticionaram, requerendo a declaração da prescrição intercorrente. O prazo de prescrição começou a fluir em 2000, 1 ano após a suspensão, pelo prazo geral de 20 anos. Em 2003, com a entrada em vigor do novo Código Civil, recomeçou a contagem pelo prazo quinquenal, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular, estando fulminada a pretensão em 2008 (cf. art. 206, § 5.º, I, do CC). Correto, portanto, o entendimento do Tribunal de origem, que proclamou a prescrição intercorrente (...)”.

Diante dessa irrepreensível fundamentação, contendo inclusive precisa exegese do novo CPC, nada há a acrescentar no sentido de que o abandono do processo e a prescrição intercorrente são fenômenos que geram diferentes consequências no plano processual.

Configurado o abandono do processo, na fase de conhecimento, o juiz deverá determinar a intimação pessoal do autor, para, só então, se for o caso, proferir julgamento sem resolução do mérito (art. 485, III, CPC). Na execução, pelo contrário, constatado o descaso prolongado do exequente, alcançado o lapso de prescrição intercorrente, torna-se *despicienda* qualquer

providência ulterior para a imediata extinção do processo (art. 924, V, CPC).

4.3. Comportamento do réu

Segundo dispõe o § 6.º do art. 485, para a extinção se concretizar, desde que já apresentada a contestação, é imprescindível que o réu requeira a prolação da sentença por abandono do processo.

Paradoxalmente, o fato de o réu, tanto quanto o autor, em princípio, ter interesse no julgamento do *meritum causae*, é possível que aquele, a despeito da omissão do autor, desejoso de obter sentença definitiva, antecipe o pagamento de despesas processuais, evitando desse modo a resolução anômala do processo, ou seja, “removido o obstáculo à sua tramitação, caminhará este, normalmente, em direção ao julgamento da lide”.¹⁹

4.4. Ineficácia do abandono

De salientar-se, no entanto, que em algumas hipóteses a omissão do demandante afigura-se completamente irrelevante para o prosseguimento do processo. É o caso, por exemplo, de o autor deixar de atender à determinação de recolher as custas para a realização de uma determinada diligência por ele mesmo requerida. A inércia, nesta hipótese, simplesmente torna prejudicada a diligência e o processo segue o seu curso, em detrimento do direito do próprio autor.

4.5. Consequência da extinção do processo

Seja como for, configurado o abandono do processo e proferida a sentença, cessam, conseqüentemente, todos os efeitos processuais e materiais surgidos com o ajuizamento da ação, desaparecendo *ab initio* a situação jurídica por ela desencadeada: a interrupção do lapso prescricional, a litispendência e a litigiosidade da coisa, verificadas no processo extinto, nenhuma eficácia terão em relação a eventual demanda que o autor posteriormente venha a ajuizar.²⁰

O abandono do processo acarreta, ainda, por força do disposto no supra-apontado § 2.º do art. 485, a condenação do autor no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. E isso porque, pelo denominado princípio da causalidade, quem iniciou o processo deve arcar com o respectivo custo.

Desse modo, em princípio, nada mais justo que, tendo o réu se mobilizado para se defender, seja ressarcido das despesas que foi obrigado a efetuar.

Ressalte-se que, em consonância com os arts. 92 e 486, § 2.º, do CPC, o não pagamento das verbas atinentes à sucumbência constitui impedimento à repropositura da mesma ação pelo autor.

5. Ausência de pressupostos processuais (inc. IV)

5.1. Aspectos gerais

Visando à formação e ao desenvolvimento escorreito do processo, a lei processual estabelece determinadas exigências de natureza estritamente formal, que são, sob o ponto de vista técnico, denominadas pressupostos processuais.

Vale observar, com Fredie Didier Júnior, que a expressão consagrada – pressupostos processuais – merece censura, “na medida em que *pressuposto* é aquilo que antecede o ato e se insere como elemento indispensável à sua existência jurídica, enquanto *requisito* é o que integra a estrutura do ato e concerne à sua validade intrínseca. No entanto, a dicção pressupostos processuais *lato sensu* considerada, engloba tanto os requisitos de validade como os pressupostos processuais *stricto sensu* (somente aqueles concernentes à existência do processo)”.²¹

Há, portanto, duas ordens de pressupostos processuais – os de existência e os de validade do processo –, sendo certo que os primeiros devem coexistir para que este higidamente se constitua e, destarte, exista; e, os demais, imprescindíveis se tornam para que, não obstante bem formado,

possa o processo desenvolver-se regularmente até o momento da entrega da prestação jurisdicional pelo órgão competente.²²

Com efeito, a coexistência destes pressupostos evidencia que o processo se encontra formalmente em ordem para propiciar o resultado que dele se espera, isto é, a prolação de sentença de mérito. Os protagonistas do processo devem assim envidar esforços para que, após a tramitação do processo em seus sucessivos atos, que demandam dispêndio de tempo, dinheiro e energia, tudo não venha a se perder, com a percepção de que não está ele adequado para seguir até o seu desfecho normal.²³

Não há interesse algum, inclusive sob o ponto de vista sociológico, que o instrumento predisposto à assecuração da tutela jurisdicional do cidadão – o processo – esteja contaminado por alguma irregularidade – de maior ou menor gravidade –, que tenha a potencialidade de nulificar tudo quanto foi alcançado, em inúmeras ocasiões, muito tempo depois de a demanda ter-se iniciado. Daí decorre o poder judicial de constante direção do processo, velando pela sua duração razoável (art. 139, II, CPC), no sentido de “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais” (art. 139, IX).

5.2. Classificação dos pressupostos processuais

A doutrina processual, com algumas diferenças conceituais de menor relevância, classifica os pressupostos processuais da seguinte forma: *a*) pressupostos processuais subjetivos: a.1) juiz (órgão dotado de jurisdição, competente e imparcial); e a.2) partes (com capacidade processual e com capacidade de postular em juízo); *b*) pressupostos processuais objetivos intrínsecos: b.1) petição inicial apta; b.2) propositura da ação, b.3) instrumento de mandato, e b.4) citação válida; e, ainda, *c*) pressupostos processuais objetivos extrínsecos, ditos negativos, que concernem à inexistência de circunstâncias impeditivas da formação do processo: c.1) ausência de perempção; c.2) ausência de litispendência; c.3) ausência de coisa julgada material; c.4) ausência de arguição de convenção arbitral; e c.5) ausência de comprovação do pagamento de custas e honorários pelo autor quando anteriormente condenado (art. 92 CPC).

5.3. Viabilidade de correção do defeito

Ajuizada a ação, detectando o juiz alguma patologia quanto a estes pressupostos, é ainda possível, na maioria das vezes, corrigir o vício para se chegar ao fim último do processo. Dispõe, com efeito, o art. 321 e seu parágrafo único, do CPC, que o magistrado deverá determinar ao autor, no prazo de 15 dias, o suprimento do defeito, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Assim, se não for ele sanado, ou mesmo inviável a sua correção, o juiz não terá outra alternativa senão a de proferir julgamento sem resolução do mérito.

5.4. Possibilidade de repropositura da demanda

Nesse caso, desde que previamente atendidas as exigências disciplinadas no subsequente art. 486, §§ 1.º e 2.º, a demanda poderá ser reproposta.

6. Reconhecimento de perempção, litispendência ou coisa julgada (inc. V)

6.1. Introdução

Inseridas entre os pressupostos processuais objetivos intrínsecos, a constatação de perempção, litispendência ou coisa julgada material determinam a prolação de sentença sem resolução do mérito.

6.2. Perempção

A todo cidadão é assegurado o acesso à jurisdição, mas o Poder Judiciário não pode ficar à mercê do litigante desidioso.

Assim, se algum demandante abandonar o processo por três vezes, nos termos do art. 486, § 3.º, estará impedido de intentar nova ação, lastreada nos mesmos elementos objetivos (causa de pedir e pedido) em face do mesmo réu. A ação do autor restou perempta.

A perempção é ocorrência de natureza processual que atinge apenas a ação, restando incólume o direito deduzido, que poderá ser arguido como matéria de defesa (art. 486, § 3.º, CPC), ou, em última análise, ser voluntariamente satisfeito pelo obrigado.

Frise-se que, também sob a égide do novo CPC, a citação válida excepcionalmente não é interrompida quando extinta a fase de conhecimento com fundamento na perempção. De fato, à luz do diploma processual revogado, “o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a citação válida, excepcionando-se as causas do art. 267, II e III, do CPC [1973], interrompe a prescrição. Desta forma, apenas em raros casos a citação válida não interrompe a prescrição. Um deles é a perempção, fenômeno processual resultante da extinção do processo, por três vezes, por negligência do autor que, não promovendo os atos e diligências que lhe competirem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 267, III, CPC [1973]). O outro ocorre quando ficar o processo parado durante mais de 1 ano por negligência das partes (art. 267, II, da norma processual)”.²⁴

6.3. Litispendência

6.3.1. Conceituação

A litispendência, a seu turno, consoante a imprecisa redação do art. 337, § 1.º, do CPC, é verificada quando houver reprodução de ação anteriormente ajuizada.

Inadmissível afigura-se a coexistência de dois processos entre as mesmas partes e que tenham o mesmo objeto. O art. 337, VI, confere ao réu a exceção de litispendência para o fim de evitar, a um só tempo, a duplicação de esforços dos integrantes do processo e a contradição das decisões.

Assinala destarte a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 3.569-DF, relatado pelo Ministro Milton Luiz Pereira, que: “Anotada a repetição, com igual finalidade, da causa de pedir e, identificadas as mesmas partes, ocorrente a litispendência, o processo deve ser extinto”.²⁵

Detectada, pois, a repetição da demanda, à luz do critério da tríplice identidade, coloca-se termo ao processo posterior, de ofício (§ 5.º do art. 337) ou por provocação do réu, mediante exceção de litispendência.

6.3.2. Reconhecimento no processo coletivo

Exemplo atual desse fenômeno pode ser extraído da seguinte situação: em razão da prodigalidade que tem inspirado o nosso legislador em matéria de tutela dos interesses coletivos e difusos, é bem ver que, mesmo após a entrada em vigor do CDC, a teor do inc. II do art. 1.º da Lei 7.347/1985, a ação civil pública continua a servir como instrumento de defesa do consumidor. Assim, a despeito da tutela específica do consumidor encontrar-se inserida no apontado diploma, ocorre uma duplicidade de instrumentos processuais que se prestam à defesa dos direitos deste. Suponhamos, assim, que uma determinada associação legitimada ajuíze uma ação com base no CDC e, em seguida, o Ministério Público intente ação civil pública visando ao mesmo fim.

Parece-nos evidente que o réu, na segunda demanda, poderá arguir a referida *exceptio*. Pergunta-se: há tríplice identidade entre as mencionadas ações, isto é, na promovida pela associação legitimada, com arrimo no CDC, e na ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público? A resposta deve ser positiva, uma vez que, além da identidade de causa de pedir e de pedido, as partes também são as mesmas, tendo-se em vista a relação de direito material, pouco importando, no caso concreto, o legitimado ao ajuizamento da demanda. Deve ser feita, nesse passo, a distinção entre parte em sentido substancial e parte em sentido processual.²⁶ O segundo processo, portanto, deverá ser encerrado.

6.3.4. Identidade dos elementos da demanda

A operação lógica a ser desenvolvida pelo juiz, nestas situações, deve ter como ponto de partida o cotejo dos elementos da demanda anterior, ainda pendente, com os daquela sucessiva. Constatada a identidade dos *tria eadem*, partes, *causa petendi* e *petitum*, o processo da segunda ação não poderá prosseguir, devendo ser proferido ato decisório sem julgamento do mérito.

Interessam à compreensão dessa temática os termos de julgado da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1.423.063-DF, relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves,²⁷ no qual foi reconhecida a litispendência em virtude de ter sido detectada a identidade da pretensão deduzida pelo contribuinte por meio de dois diferentes meios processuais. Concluiu então a turma julgadora que: “Há litispendência quando a pretensão consistir na repetição de indébito de tributo idêntico, mas por modos de pagamentos distintos, ou seja, uma se pede a restituição via precatório e na outra, via compensação. Isso porque, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/1991, havendo sentença que condena a Fazenda Pública a devolver um tributo pago indevidamente, o contribuinte pode, em vez do precatório, preferir a compensação”.

6.3.5. Exame da litispendência nos domínios do STJ

Como se infere de vários precedentes, o Superior Tribunal de Justiça normalmente se posiciona no sentido de que a revisão do acórdão que reconheceu a litispendência implica reexame do material probatório, não se viabilizando no âmbito do recurso especial.

Secundando esta tese, v.g., a 2ª Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 7.950-SC, de relatoria do Ministro Castro Meira,²⁸ teve oportunidade de assentar que: “A modificação do decisório pretendida pela recorrente, no sentido de afastar a litispendência e a coisa julgada com base no que dispõem os §§ 1.º e 3.º do art. 301 do CPC [1973], demandaria o revolvimento das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é vedado nos estreitos limites do apelo raro, ante o óbice da Súmula 7/STJ”. Nesse julgado, ficou vencido o Ministro Cesar Asfor Rocha, com importante argumento exposto em voto-vista e que vale ser parcialmente transcrito: “É possível o exame da litispendência e da coisa julgada no âmbito do recurso especial na hipótese em que a questão posta é de direito e está prequestionada, ensejando, no máximo, o exame de peças processuais constantes de outros processos, cujas cópias foram juntadas nos autos, porque, no caso, o simples reexame de peças processuais como petição inicial, sentença e acórdãos, para mera comparação, não encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. Do contrário, esta Corte jamais poderia enfrentar a existência de coisa julgada e de litispendência, o que não parece razoável”.

Esta interpretação de cunho liberal, a meu ver, é a que apresenta fundamentação mais coerente com os pressupostos de admissibilidade do recurso especial.

6.4. Coisa julgada material

A mesma sorte ocorrerá com o reconhecimento da coisa julgada material, formada em precedente processo idêntico, para evitar que sobrevenha nova decisão de mérito acerca de controvérsia já encerrada. Depara-se, nesse particular, com grave problema, que compromete a segurança jurídica, quando se desconhece a precedente coisa julgada e outra sentença vem a ser proferida em sentido oposto à anterior. É exatamente por tal razão que se justifica, nesta indesejada situação, o cabimento de ação rescisória por ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, CPC).

7. Falta de legitimidade ou de interesse processual (inc. VI)

7.1. Aspectos gerais

Custou algumas décadas para que o legislador pátrio se adequasse à revisada posição de Liebman, restringindo as denominadas condições da ação à legitimidade *ad causam* e ao interesse processual. A teoria do mestre italiano passa assim a ser agora adotada pelo novo CPC, com a

inclusão, no rol das hipóteses que obstruem o juiz a resolver o mérito da causa, da ausência de qualquer uma das duas referidas condições de admissibilidade da ação.

Embora o direito de ação seja incondicionado, uma vez que garantido de forma irrestrita no importante art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, nada impede que o legislador, a exemplo das exigências impostas à forma processual, estabeleça condicionantes sobre a ação, tendentes a evitar atividades processuais que conspirem contra o princípio da duração razoável do processo. Nesta linha de raciocínio, explica, com clareza, Bedaque, que: “eventuais restrições impostas em sede infraconstitucional ao desenvolvimento do processo e à entrega da tutela jurisdicional não implicam limitação indevida à garantia constitucional. Assegura-se a todos, indistintamente, o poder de retirar o juiz da inércia e dar início ao devido processo legal. Mas é preciso observar as regras necessárias a que a via estatal de solução de conflitos possa atingir seus objetivos. Por isso, perfeitamente compatível com o sistema processual a existência de alguns óbices ao exame do mérito, como a ilegitimidade de parte e a falta de interesse processual. Não se retira do autor o devido processo legal. Apenas impede-se a solução da lide se o pedido não for deduzido por quem, segundo as circunstâncias da própria relação material controvertida, tenha direito de obtê-la”.²⁹

Cumprе salientar que a praxe forense tem demonstrado que o fenômeno da carência de ação não é uma questão puramente acadêmica. Na verdade, é mais comum do que se imagina. Questões de maior ou menor complexidade são recorrentes no foro, entre as quais, em particular, a aferição da legitimidade, que pode se transformar num problema bem mais complicado.

Veja-se, por exemplo, a dificuldade que emerge de precedente da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, provendo o Recurso Especial 1.280.470-SP, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti,³⁰ reconheceu a carência da ação, *in verbis*: “A corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários, que tenha atuado como intermediadora da aplicação em depósitos interbancários (DI), não detém legitimidade ativa para pleitear em nome próprio diferenças de correção monetária sobre importâncias depositadas, cabendo a ela exclusivamente remuneração prévia sob a forma de comissão. A natureza da operação implica a cessão automática do crédito ao depositante, conforme registro virtual na CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, particularidade que, entre outras, a distingue do certificado de depósito bancário – CDB, e da caderneta de poupança. Circunstância de direito que determina a ilegitimidade ativa da recorrida (...) Esse foi também o entendimento que prevaleceu no AgRg no REsp 1.281.771-SP, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, *DJe* 05.12.2013, outro processo em que a recorrida Interbank Investimentos e Participações igualmente postulava diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários, tendo sido enfatizada a distinção entre os negócios bancários indevidamente comparados, o certificado de depósito bancário e depósito interbancário. Caracterizada, portanto, a ofensa aos art. 6.º, do CPC [1973], segundo o qual ninguém poderá pleitear em seu próprio nome direito alheio, salvo quando autorizado por lei, e também ao art. 267, VI, do mesmo Código, dada a manifesta carência de ação. Em face do exposto, conheço do recurso especial e a ele dou provimento para decretar a carência de ação, por ilegitimidade ativa”.

7.2. Teoria da asserção/julgamento de mérito

Antevendo o juiz, no exame de admissibilidade da petição inicial ou instado pela contestação do réu, que há intransponível divergência entre a causa de pedir e os sujeitos da relação de direito material ou, ainda, que o processo é inútil ou tecnicamente inapropriado para que o autor alcance o seu objetivo, não se viabiliza a composição do litígio.

Desse modo, aferida pelo órgão jurisdicional, sempre no terreno do direito material, a ilegitimidade ativa ou passiva de um dos litigantes, vale dizer, quando não houver pertinência subjetiva entre a relação jurídica deduzida em juízo e pelo menos um dos participantes do contraditório, deverá ele proferir decisão sem resolver o mérito. Assim, se Antonio promover ação de despejo em face de Pedro, com fundamento num contrato de locação escrito, exibido, desde logo, com a petição inicial, no qual figura como locatário José Luiz, desponta manifesta *ilegitimatio ad causam* passiva.

Idêntico desfecho ocorrerá se for diagnosticada a ausência de interesse processual, vale dizer, a

desnecessidade objetiva do processo ou mesmo a sua inadequação para atingir o fim colimado pelo autor.

Frisa, a esse respeito, José Roberto dos Santos Bedaque que, considerada a dogmática processual, o único modo de traçar a distinção da categoria das condições da ação do mérito da demanda é pela profundidade da cognição, adotando-se a denominada “teoria da asserção”. Se, por exemplo, o juiz, após exame profundo do fato constitutivo afirmado na inicial, conclui pela ilegitimidade passiva do réu, na verdade, ele está julgando improcedente o pedido. “Essa visão do fenômeno ‘condições da ação’ amplia a possibilidade de o processo cognitivo terminar com sentença de mérito, afastando o grande número de falsas extinções por carência, que tantos problemas têm causado ao sistema”.³¹

Cumprir registrar que tal doutrina foi expressamente prestigiada em julgamento cujo voto condutor é da lavra da Ministra Nancy Andrighi, proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.157.383-RS, no qual restou decidido: “(...) Há de se ter em mente, no entanto, que em se tratando de condições da ação, não obstante a matéria seja formalmente considerada processual, ela na prática pode envolver a análise do próprio mérito da controvérsia. Diante disso, assume relevo a teoria da asserção, que ganha expressão na doutrina, secundada por juristas como Ada Pellegrini Grinover e Kasuo Watanabe. Para os adeptos dessa teoria, como é o caso também de José Roberto dos Santos Bedaque, na análise das condições da ação ‘se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão’ (*Direito e processo* , p. 78). Em outras palavras, sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigir a análise desta, haverá exame de mérito. Ainda que tacitamente, a teoria assertiva encontra respaldo em julgados desta Corte, nos quais entendeu-se que a decisão acerca das condições da ação implicou numa sentença de mérito. No que tange especificamente à legitimidade *ad causam* , sua verificação invariavelmente exige a análise da lide em concreto, havendo enorme dificuldade prática em separar tal questão do mérito da causa. Ainda que se admita o exame da legitimidade *in statu assertionis* , muitas vezes é no curso do processo que se chega à efetiva decisão sobre tal condição da ação, importando, dessa feita, na análise da relação jurídica de direito material. Na espécie não foi diferente. Verifica-se que o juiz de primeiro grau de jurisdição somente se pronunciou acerca da legitimidade passiva por ocasião da prolação da sentença, depois de toda a prova ter sido carreada aos autos”.³²

Com efeito, alvitando-se, no limiar do processo, a partir dos argumentos expendidos pelo demandante na petição inicial, a ilegitimidade de parte ou a falta de interesse, diante da assimetria extraída do confronto com a *causa petendi* , impõe-se julgamento sem a resolução do mérito.

Aduza-se que, nesta mesma hipótese, depois de instruída a causa, ainda que seja proferida sentença de natureza terminativa, na verdade, o tribunal enfrenta matéria de fundo.

Vale observar que, acerca dessa temática, em particular sobre as denominadas condições da ação, noticia Machado Guimarães que o próprio Liebman chegou a admitir, em conferência proferida no ano de 1949, que: “todo problema, quer de interesse processual, quer de legitimação *ad causam* , deve ser proposto e resolvido admitindo-se, provisoriamente e em via hipotética, que as afirmações do autor sejam verdadeiras; só nesta base é que se pode discutir e resolver a questão pura da legitimação ou do interesse. Quer isto dizer que, se da contestação do réu surge a dúvida sobre a veracidade das afirmações feitas pelo autor e é necessário fazer-se uma instrução, já não há mais um problema de legitimação ou de interesse, já é um problema de mérito”.³³

Nesse sentido, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 932.119-SC, de relatoria do Ministro Paulo Sanseverino, reexaminou situação na qual o tribunal de origem, por maioria de votos, reformou a sentença de primeiro grau, acolhendo os embargos à execução e extinguindo a execução por força de carência da ação. Em tal hipótese, o Superior Tribunal de Justiça destacou o cabimento dos embargos infringentes exatamente porque, “ao analisar a nulidade do título em razão do desvio de finalidade, o acórdão embargado realizou verdadeiro juízo de mérito (...)”.³⁴

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, quando do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 10.643-RS, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, seguindo esta orientação, decidiu, fazendo constar da respectiva ementa, que: “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há preclusão em relação às condições da ação, que devem ser apreciadas ainda que arguidas em sede recursal. 2. A indevida qualificação de defesa de mérito como condição da ação não transforma sua natureza jurídica. 3. No caso, a ré não interpôs apelação contra a sentença que acolheu o pedido do autor. Após, em petição avulsa, apresentou documentos e alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública. 4. Aplicando-se a teoria da asserção, não se está diante de argumentos relativos à falta de legitimidade (condição da ação), mas, sim, de defesa de mérito, pois, à luz das afirmações contidas na petição inicial, há pertinência entre as partes da relação jurídica de direito processual e as da relação jurídica de direito material”.³⁵

Vencida a fase postulatória, as condições da ação já não mais serão apreciadas *in statu assertionis*, visto que, conduzido o processo para momento reservado à produção das provas, aprofundada, portanto, a cognição judicial, o ato decisório a ser proferido, em sequência, é de mérito, com o reconhecimento da procedência ou improcedência do pedido.

Trilhando esta mesma posição, escreve, a propósito, Susana Henriques da Costa que, ao detectar a ausência de uma condição da ação, ao ensejo ou após o encerramento da fase instrutória, o julgador deverá, obrigatoriamente, reconhecer a improcedência do pedido, visto que respondeu em sentido negativo a uma questão de mérito, condicionando o acolhimento do pedido deduzido pelo autor.³⁶

Seja como for, abstração feita das inúmeras correntes teóricas, que propiciaram copiosa literatura sobre o tema, a verdade é que a extinção do processo, nas duas mencionadas situações de falta de legitimidade ou de interesse processual, inviabiliza a sua ulterior repropositura, seja pela inarredável preclusão, na primeira das hipóteses (carência); seja pela coisa julgada material, produzida pelo respectivo julgamento de mérito.

7.3. Inexistência de preclusão pro iudicato

Isso não quer significar que o juiz, após ter afirmado, por exemplo, na decisão declaratória de saneamento, a coexistência das condições da ação, não possa, depois da instrução da causa, reconhecer a falta de uma delas, diante da inexistência de preclusão *pro iudicato* acerca dessa matéria.

Posicionando-se nesse sentido, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.138.281-SP, cujo voto condutor foi lavrado pela Ministra Nancy Andrighi, deixou assentado que: “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação – matérias de ordem pública –, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias”.³⁷

O óbice que se apresenta ao juiz de rever anterior ato decisório concerne apenas a questões de direito disponível, uma vez que, consoante o disposto no art. 485, § 3.º, não abrange a matéria de ordem pública, que pode ser reexaminada, pelo próprio juiz da causa, até o momento de proferir sentença.

Ademais, é perfeitamente possível que o interesse processual, reconhecido no início da demanda, desapareça em momento posterior, determinando a prolação de ato decisório sem exame do mérito por perda superveniente.

8. Existência de convenção de arbitragem ou reconhecimento de competência pelo juízo arbitral (inc. VII)

8.1. Aspectos gerais

O art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, consagrando norma idêntica constante das anteriores Cartas Políticas do Brasil, encerra o princípio da reserva legal, também denominado da inafastabilidade da jurisdição, ao preceituar que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Observa-se que o *caput* do art. 3.º do novo CPC reitera essa mesma regra, reservando ao Estado-juiz o monopólio da jurisdição.

Isso significa que a ninguém é dado renunciar à defesa de seus direitos diante de uma potencial lesão futura! Daí porque desponta nulo e ineficaz qualquer *pactum de non petendo*, estipulado como cláusula de negócio jurídico, pelo qual os contratantes se comprometem a não recorrer ao Poder Judiciário caso surja algum litígio entre eles.³⁸

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e dos inúmeros textos legais que lhe seguiram (v.g. : CDC, reforma da Lei de Ação Civil Pública etc.), infundiu-se em cada brasileiro um verdadeiro “espírito de cidadania”. Os cidadãos passaram a ser senhores de seus respectivos direitos, com a expectativa de verem cumpridas as garantias que lhes foram então asseguradas.

Observe-se ainda que também foram incrementados, a partir do início dos anos 90, mecanismos processuais adequados a recorrer aos tribunais com maior efetividade, como, por exemplo, a ampliação do rol dos legitimados ativos a manejar as ações diretas de inconstitucionalidade, a ajuizar ações coletivas em prol dos interesses difusos, a consagração da autonomia e independência do Ministério Público e a opção determinada por um modelo de assistência judiciária e de promoção de acesso à justiça.

Diante desse importante fenômeno, houve, como era notório, um vertiginoso crescimento da demanda perante o Poder Judiciário. Os números alarmantes são de conhecimento geral. E isso tudo agravado pela circunstância de que a constitucionalização de um conjunto tão ousado de garantias, sem a consecução consistente de políticas públicas e sociais correlatas, tem propiciado, sem dúvida, maior judicialização dos conflitos.

Tem-se, outrossim, clara percepção da ineficiência das agências reguladoras de serviços que também contribuem para a intervenção judicial. O recurso aos tribunais para garantir o acesso a medicamentos e tratamentos médicos é constante. Não é crível que nos dias de hoje muitos brasileiros tenham de ir à justiça para obter indenização por atraso de voo e extravio de bagagem, ou, ainda, para forçar adequada prestação de serviço em várias atividades. O Poder Judiciário está se tornando um verdadeiro SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor.

O sistema judicial passa, assim, a suplantiar o sistema da administração pública, a quem, por óbvio, compete sancionar as referidas falhas.

Chega-se mesmo ao que poderíamos denominar de “banalização de demandas”, sem esquecer o papel de exator dos tribunais, na função substitutiva de ser o principal palco da cobrança de tributos, diante dos milhares de executivos fiscais que abarrotam os escaninhos dos cartórios forenses.

Com esse exagerado afluxo de demandas, os processualistas passaram a prestigiar outros meios adequados de solução de conflitos, como a arbitragem, a conciliação e a mediação. Estes mecanismos alternativos podem ser extrajudiciais, mas de qualquer forma visam a ampliar maior acesso à justiça.

8.2. Arbitragem como meio adequado de solução dos conflitos

A arbitragem consiste numa técnica de heterocomposição de controvérsias mediante a intervenção de um ou mais árbitros, escolhidos pelas partes, a partir de uma convenção de natureza privada. A sentença proferida pelos árbitros, que não comporta qualquer recurso, equipara-se à decisão judicial. A teor do disposto no art. 1.º da Lei 9.307/1996, o objeto da arbitragem recai sobre direitos patrimoniais disponíveis, de titularidade de pessoas capazes de contratar.

Para a instauração do processo arbitral é exigido um compromisso, pelo qual as partes

concordam em submeter a decisão do litígio a um árbitro. Verifica-se, destarte, que a convenção de arbitragem é delimitada, sob o aspecto subjetivo, pelas pessoas que a firmaram, na qualidade de contratantes ou mesmo de anuentes.

Se, sob a ótica objetiva, somente pode ser submetido à arbitragem o litígio envolvendo matéria atinente a direito disponível, do ponto de vista subjetivo, é apenas arbitrável o litígio entre as partes que subscreveram o instrumento em que presente a respectiva convenção e que sejam elas capazes.

Cumprе esclarecer, ainda, que o juízo arbitral somente pode ser instituído desde que presentes todas as pessoas que figuraram no instrumento no qual ficou estabelecida a cláusula compromissória. Como a arbitragem se circunscreve aos limites do contrato celebrado entre as partes, sob os aspectos subjetivo e objetivo, não pode ser deflagrada senão entre os protagonistas do respectivo negócio. A legitimidade de parte para o processo arbitral, por isso, só se estabelece entre os sujeitos contratuais. A única via de legitimação, ativa ou passiva, para quem queira participar, ou seja, chamado a integrar a arbitragem, condiciona-se à própria convenção arbitral.

Assim, se determinada pessoa não estiver subordinada a contrato com previsão de arbitragem, não pode ser ela acionada perante o juízo arbitral.

Se o processo arbitral se iniciar sem a presença de todos os sujeitos que firmaram o contrato, só restará ao árbitro encerrá-lo sem julgamento de mérito, sob pena de ser nula a sentença que eventualmente vier a ser proferida.

Tendo-se em vista os limites subjetivos da convenção arbitral, não há como se admitir que a imutabilidade do conteúdo decisório da sentença possa atingir terceiros.³⁹

Já, sob outro enfoque, de conformidade com o disposto no inc. VII da regra legal agora comentada, o juiz não resolverá o mérito na situação em que for acolhida a arguição “de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência”. A convenção, pois, sob a novel legislação, continua sendo classificada como um pressuposto processual negativo de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ainda, no que se refere à arbitragem, mais recentemente, diante da significativa importância que a participação econômica do Brasil passou a ostentar no mundo globalizado, a despeito de a atual lei, vigente há duas décadas, ser vitoriosa e inclusive prestigiada pelos nossos tribunais, entendeu-se oportuno a sua atualização, procurando alinhá-la aos regramentos contemporâneos mais avançados, já colocados à prova na experiência jurídica internacional.

A nova Lei 13.129/2015, que aperfeiçoou a lei mais antiga (Lei 9.307/1996), não trouxe qualquer alteração substancial quanto à arbitragem que pudesse influir na sistemática adotada pelo CPC/1973 e agora repetida pelo novo diploma processual.

8.3. Imprescindibilidade de requerimento do réu

A convenção de arbitragem – que tem como espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral – constitui óbice a que o tribunal estatal julgue o mérito da controvérsia. Eleita a arbitragem pelas partes, como meio adequado de solução de eventual conflito que possa surgir entre elas, irrompe o denominado efeito impeditivo ou negativo da respectiva convenção, que afasta o juízo estatal, derogando a sua jurisdição, vale dizer, impede que este examine e proceda ao julgamento do *meritum causae*.

Coerente com a regra do novel art. 337, X, que impõe ao réu o ônus de arguir a existência de convenção arbitral, o inc. VII do art. 485, supratranscrito, condiciona expressamente o acolhimento desse pressuposto processual negativo à existência de requerimento expresso do demandado. Com isso, o novo CPC eliminou de uma vez por todas a celeuma então existente quanto à viabilidade ou não de o juiz togado, havendo convenção arbitral, declinar a sua jurisdição de ofício (art. 485, § 3.º).

Em suma, o reconhecimento da convenção arbitral e o consequente julgamento sem exame do mérito será possível tão somente quando houver arguição pelo réu. Silente o réu em sua contestação, ocorrerá preclusão lógica e temporal, não podendo mais ser acolhida a *exceptio fori* que eventualmente venha ele alegar em momento posterior.

Ademais, a despeito da convenção arbitral estabelecida entre as partes, nada impede que submetam elas o litígio à apreciação do tribunal estatal. Explica, a respeito, Cândido Rangel Dinamarco que: “a convenção de arbitragem deixa de ser pressuposto (negativo) do julgamento do mérito sempre que ambas as partes renunciem a ela, o que é de absoluta compatibilidade com o instituto e associa-se à autonomia da vontade: a mesma liberdade negocial que está à base da legitimidade da convenção de arbitragem legitima também a renúncia a ela. Essa renúncia pode ser explícita ou decorrer da propositura da demanda em juízo por uma das partes e aceitação pela outra, sem invocar a convenção de arbitragem. Se o réu pedir ao juiz a extinção do processo com fundamento na cláusula arbitral, decidirá este a respeito, acolhendo ou rejeitando o pedido”.⁴⁰

8.4. Princípio da Kompetenz-Kompetenz

Saliente-se, outrossim, que, instituída a arbitragem, o árbitro passa então a ser juiz de fato e de direito, inclusive no que concerne ao reconhecimento de sua própria competência, e, ainda, no que se refere à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem (art. 8.º, parágrafo único, da Lei 9.307/1996).

Como bem observa Carlos Alberto Carmona, o chamado princípio da *Kompetenz-Kompetenz* (também denominado *compétence de la compétence*) consiste na prerrogativa do tribunal arbitral “para decidir a sua própria competência, resolvendo as impugnações que surjam acerca de sua capacidade de julgar, da extensão de seus poderes, da arbitrabilidade da controvérsia, enfim, avaliando a eficácia e a extensão dos poderes que as partes lhe conferiram tanto por via da cláusula compromissória, quanto por meio de compromisso arbitral”.⁴¹

Assim sendo, na dicção do inc. VII do art. 485, além da arguição, pelo réu, da existência de convenção de arbitragem, também haverá obstáculo imposto ao juiz togado quando o árbitro reconhecer, na arbitragem já instaurada, a sua competência (*rectius*: jurisdição).⁴²

Nessa situação, nada mais restará ao tribunal estatal senão proferir sentença sem resolução do *meritum causae*.

9. Desistência da ação (inc. VIII)

9.1. Introdução

A desistência da ação consubstancia-se na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo autor, após o seu ajuizamento, mas sempre antes do proferimento da sentença (art. 485, § 5.º, CPC).⁴³ Trata-se, à evidência, de ato voluntário abdicativo, que, em senso técnico, não pode ser confundido com a perda de faculdades e ônus processuais, causada pelo comportamento do autor, cujo efeito jurídico decorre da norma legal e não da vontade do sujeito.⁴⁴ É o que se verifica, por exemplo, com a preclusão.

9.2. Diferença entre desistência, abandono do processo e renúncia à pretensão

Assim, é de notar-se que, do ponto de vista intrínseco, a desistência, materializada num ato volitivo, também não guarda qualquer similitude com o abandono do processo, decorrente da inércia do autor.

Embora seja possível afirmar que os efeitos resultantes de ambas as situações são assemelhadas (julgamento sem exame do mérito), e até mesmo que o autor poderá elidir a desistência da ação recusada pelo réu, o abandono, na verdade, caracteriza-se por uma inatividade prolongada.

A desistência da ação difere ainda da renúncia à pretensão em que se funda a ação do demandante. Com a homologação desta, por força do disposto no art. 487, III, c, do novo CPC, verificar-se-á a resolução do mérito.

De tal sorte que, enquanto a desistência afeta apenas o processo, sem que haja efetiva composição do litígio, não impedindo a repropositura da mesma ação, a renúncia enseja que o direito subjetivo material reste de algum modo satisfeito.

O art. 285 do novo CPC português (Lei 41/2013), seguindo a legislação revogada, traça a distinção entre desistência do pedido (que equivale à nossa renúncia à pretensão) e desistência da instância (equiparada à nossa desistência da ação), determinando os respectivos efeitos: “1. A desistência do pedido extingue o direito que se pretendia fazer valer. 2. A desistência da instância apenas faz cessar o processo que se instaurara”.

Nessa mesma ordem de ideias, referindo-se à experiência processual italiana, aduz Alberto Massari que: “a renúncia à pretensão não incide propriamente sobre o processo, não constitui motivo de sua extinção, mas determina o conteúdo da sentença de improcedência do pedido (...), ao passo que a desistência provoca o término antecipado do processo, jamais repercutindo na esfera do direito substancial”, deixando incólume a possibilidade de ajuizar *ex novo* a demanda.⁴⁵

Isso significa que, com a manifestação da desistência, não se está abrindo mão do direito à tutela jurisdicional, mas, sim, do direito a um provimento judicial de mérito em determinado processo.

9.3. Natureza jurídica da desistência da ação

Afirma-se correntemente em sede doutrinária que, do ponto de vista estrutural, a desistência apresenta-se como ato unilateral tão somente reservado ao autor, enquanto não ofertada a resposta do réu, ou mesmo após o decurso *in albis* do prazo destinado àquela, e como ato bilateral a partir da resistência do demandado, uma vez que, neste caso, será imprescindível a concordância deste para a extinção do processo.⁴⁶

Alguns autores, contudo, entendem que a desistência, qualquer que seja o momento processual em que efetivada, deve ser considerada como ato unilateral.⁴⁷

Efetivada antes da contestação, corresponde mesmo a uma declaração unilateral.

Análise mais percutiente demonstra, outrossim, que, depois de oferecida a resposta, a manifestação de desistência do autor e a correspectiva aquiescência do réu ostentam diversa natureza. Vale dizer, enquanto a primeira das atitudes constitui a *causa efficiens* da produção de efeitos jurídicos, a segunda, da qual depende a plena eficácia daquela, consubstancia-se num fato extrínseco e accidental.

Parece-me não restar dúvida de que, nesta hipótese, a desistência da ação deve ser considerada como verdadeira convenção processual.⁴⁸ Faculdade exclusiva do autor, e, portanto, atuação unilateral, tem a sua eficácia, após a efetiva resposta do réu, condicionada, em princípio, ao consentimento deste e à subsequente prolação de sentença homologatória.

9.4. Exigência de aquiescência do réu. Resistência infundada. Desistência da execução

Costuma-se justificar a necessidade do consentimento do réu, nesta hipótese, em razão do interesse que possivelmente tenha ele no julgamento de mérito, preferindo ver desde logo julgada a lide. Assim, deduzida a desistência após a apresentação da resposta, ocorrendo a recusa do réu, não há, em princípio, como ser ela homologada pelo juiz.⁴⁹

Todavia, vislumbrada a ausência de fundamento da recusa, e, assim, havendo mero “capricho” do réu, poderá ser perfeitamente indeferida a injustificada recusa oposta pelo demandado.

No âmbito do processo de execução, as coisas se passam de outra forma. Diferentemente do que sucede no processo de conhecimento, mesmo que já tenham sido opostos embargos pelo devedor, afigura-se possível ao credor desistir da execução sem qualquer manifestação do executado (art. 775 CPC). E isso porque, dadas a natureza e a estrutura dessa espécie de processo, objetivando a tutela de uma pretensão insatisfeita, as partes não se acham em simétrica posição. Em face dos princípios que informam a execução, é ela realizada no interesse do credor, que tem amplo poder de disposição. Já o executado encontra-se em “estado de sujeição”.

Como anota Dall’Agnol Júnior, em ensaio ainda atual, se houver interesse do executado em continuar com a ação em que deduzidos os embargos à execução, “esta prosseguirá, mesmo que o objetivo oculto da desistência fosse o atingimento da ação de conhecimento”.⁵⁰

9.5. Legitimidade para a desistência

Cumpra registrar, por outro lado, que apenas a parte que deu início à demanda pode manifestar a intenção de não mais prosseguir com os atos do processo em curso. Legitimado à desistência, portanto, é o autor. Para ser considerada válida a desistência requer-se, pois, a mesma capacidade exigida pelas regras processuais para o ajuizamento da ação (*legitimatío ad causam*).

Assim sendo, nada obsta a que o substituto processual, postulando pretensão alheia, abdique da posição processual já alcançada, visto que lhe é defeso tão somente praticar nos domínios do processo atos implicativos de disposição do direito questionado, de titularidade, como é cediço, do substituído.

É de ter-se presente, no entanto, que, em alguns casos excepcionais, de legitimação extraordinária, dada a natureza do interesse em jogo, torna-se de todo inviável a desistência da ação incoada, em razão do dever de ofício outorgado ao órgão do Ministério Público.⁵¹

Note-se, sob outro enfoque, que, havendo alteração das partes durante o *iter* procedimental (e.g.: sucessão *causa mortis*), passa a ser legitimado à desistência o novo titular da faculdade de disposição processual no que concerne à tutela jurisdicional pleiteada pelo seu antecessor.

9.6. Litisconsórcio e desistência

Existindo pluralidade de partes, desde que não seja caso de litisconsórcio exigido pela lei ou, pela natureza da relação jurídica, a sentença não tiver de ser uniforme para todos os sujeitos (arts. 114 e 116 CPC), nada impede que a desistência da ação se restrinja a um ou alguns litisconsortes (art. 90, § 1.º).

Consoante o disposto no art. 117 (regra da autonomia dos colitigantes): “Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”.

Assim, diante desta inquestionável autonomia, na hipótese de cumulação subjetiva facultativa passiva (simples), se o autor desistir quanto a determinado réu ainda não citado, os demais demandados deverão ser intimados da homologação da desistência (art. 335, § 2.º, CPC).

Se os litisconsortes, já citados, ainda não tiverem oferecido resposta, haverá incidência da regra do § 4.º do art. 485 do CPC, não havendo óbice algum à desistência. Caso contrário, isto é, se já apresentada a contestação, somente aquele ou aqueles que forem visados pela desistência deverão ser ouvidos quanto ao intento do autor.

Tratando-se, por outro lado, de litisconsórcio fundado no art. 114 – litisconsórcio necessário – ocorrerá limitação à faculdade atribuída ao autor de desistir da ação. Com efeito, devido à incindibilidade da relação jurídica *sub iudice* , a validade e eficácia da sentença, neste caso, estão condicionadas à presença, no processo, de todos os litisconsortes.

Não se pode falar, assim, em homologação da desistência se esta recair sobre algum dos

litisconsortes necessários, colimando-se o prosseguimento do processo tão somente em face dos demais; e, de idêntico modo, se um dos autores necessários desistir da ação, visando a deixar no processo o seu litisconsorte. Em ambas as situações, dada a indispensabilidade do cúmulo subjetivo, carece aos litisconsortes, que então remanesceriam, legitimidade ativa ou passiva *ad causam*.

9.7. Desistência e responsabilidade pela sucumbência

Consoante o disposto no art. 90, homologada a desistência da ação, ao autor deverá ser carreada a responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários do patrono constituído pela outra parte, se esta já tiver apresentado contestação.

Sendo parcial a desistência, a responsabilidade pelas verbas de sucumbência será proporcional ao âmbito do ato de disponibilidade praticado pelo demandante (art. 90, § 1.º, CPC).

10. Intransmissibilidade da ação ajuizada pela parte falecida (inc. IX)

Normalmente, toda pretensão de direito material é transmissível, ainda que objeto de um processo judicial em curso.

Assim, é possível haver alteração subjetiva da demanda, em um dos polos, durante a tramitação do processo. Esta situação pode ser verificada por ato *inter vivos* ou *causa mortis*.

O cessionário sub-rogado ou o sucessor adquire, pois, ulterior legitimação *ad causam*, sempre que for possível à luz do direito material.

Quanto à modificação das partes por ato *inter vivos*, inúmeras são as regras específicas, como, por exemplo, a previsão do art. 109, § 1.º, do CPC, no âmbito da alienação da coisa litigiosa.

Já no que concerne à transmissão da pretensão *mortis causa*, torna-se necessário apenas que haja a respectiva habilitação, a teor do art. 687 do CPC: “A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo”.

Não obstante, há hipóteses de pretensões que não se transmitem, mesmo depois de já ter sido ajuizada a demanda. Geralmente, as denominadas “ações intransmissíveis” ou “não hereditárias” são aquelas referentes ao estado da pessoa, como, e.g., ação de divórcio, ação de anulação de casamento, ação de adoção, ação de reconhecimento da paternidade.

Falecido o autor, por ser personalíssima a pretensão deduzida, não se transmite ela aos sucessores do *de cuius*.

Importante precedente da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do Recurso Especial 832.330, relatado pelo Ministro Castro Filho, concluiu que: “O direito de reconhecer voluntariamente a prole é personalíssimo, e, portanto, intransmissível aos herdeiros, não existindo no direito positivo pátrio norma que atribua efeitos jurídicos ao ato pelo qual aqueles reconhecem a condição de irmão, se o pai não o fez em vida. Falecido o suposto genitor sem manifestação expressa acerca da existência de filho *extra matrimonium*, a pretensão de inclusão do seu nome no registro de nascimento poderá ser deduzida apenas na via judicial por meio de ação investigatória de paternidade”.⁵²

Igualmente, no terreno de alguns direitos absolutos, referentes a usufruto, uso, habitação, também não há transmissibilidade da pretensão deduzida em juízo.

É também o que ocorre nas ações de prestação de fato pessoal, como o mandato.⁵³

Em todos estes casos, falecido o demandante na pendência do processo, o juiz deverá proferir sentença sem resolução do mérito por ausência superveniente de pressuposto processual subjetivo, visto que impossível a sucessão do autor no polo ativo.

Importa ainda anotar, à guisa de mera ilustração, que existem ações híbridas, cuja titularidade é exclusiva de determinada pessoa. No entanto, uma vez ajuizada a ação, com a morte do autor, os seus sucessores podem habilitar-se como legitimados ativos. É a hipótese bem clara prevista no art. 1.601 do Código Civil, que atribui exclusivamente ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher. No entanto, dispõe o parágrafo único desta regra legal que, havendo resistência oposta pelo réu, os herdeiros do demandante “têm direito de prosseguir na ação”. Eis aí uma situação rara que bem diferencia o “direito de ação” do “direito de demandar”.

11. Demais hipóteses contempladas no CPC (inc. X)

José Roberto dos Santos Bedaque averba que, procurando evitar discussões, o legislador andou bem ao estabelecer que o juiz igualmente não poderá resolver o mérito em outras situações previstas no novo CPC, embora quase todas elas já inferidas dos incisos acima examinados desse mesmo art. 485.⁵⁴

As mais significativas são as seguintes: “1. Ação continente proposta antes da contida (art. 57). Trata-se de falta de interesse processual. 2. Irregularidade quanto à capacidade processual ou postulatória (art. 76) configura falta de pressuposto processual. 3. Não aditamento da inicial após concessão de prazo ou indeferimento de tutela de urgência (art. 303, §§ 2.º e 6.º): inépcia. 4. Omissão do espólio, do sucessor ou dos herdeiros quanto à sucessão processual do autor falecido (art. 313, § 2.º, II). A falta de habilitação pode perfeitamente configurar abandono. 5. Inércia do autor quanto à substituição de procurador falecido (art. 313, § 3.º): ausência de capacidade postulatória, modalidade de pressuposto processual. 6. Não realização de depósito (art. 542, parágrafo único). A omissão configura abandono. 7. Não indicação do valor devido na inicial de embargos fundados em excesso de execução (art. 917, § 3.º). Nesse caso, a petição é considerada inepta”.⁵⁵

12. Matéria cognoscível de ofício (§ 3.º)

12.1. Perante as instâncias ordinárias

Seguindo o mesmo regime do CPC/1973, o § 3.º do art. 485 possibilita ao juiz conhecer de ofício, “em qualquer tempo e grau de jurisdição”, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, as seguintes matérias: *a*) ausência de pressupostos processuais (inc. IV); *b*) existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (inc. V); *c*) ausência de legitimidade de parte ou de interesse processual (inc. VI); e *d*) intransmissibilidade da pretensão deduzida em juízo (inc. IX).

Nota-se, de logo, que a nova redação da regra em apreço, para eliminar qualquer discussão quanto ao momento limite para a cognição *ex officio* destas matérias, fixou aquele imediatamente anterior ao trânsito em julgado (alterando portanto a regra do art. 267, § 3.º do diploma revogado). Com isso, como são consideradas de ordem pública, mesmo sem qualquer provocação da parte interessada, o juiz ou tribunal de segundo grau poderá proferir decisão, de ofício, sem exame do mérito com fundamento em uma das referidas hipóteses.

Todavia – é sempre bom lembrar –, somente poderá fazê-lo com prévia observância do disposto no art. 10 do CPC, de meridiana clareza: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Verifica-se que o enunciado desse dispositivo constitui desdobramento do anterior art. 9.º, ao vedar, com todas as letras, o denominado “fundamento-surpresa” (ou “decisões-surpresa” – Überraschungsentscheidungen), ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Impõe-se, portanto, o contraditório, sob pena de nulidade do ato decisório.

12.2. Perante os tribunais superiores

Contudo, deve ser ressaltado que, a despeito da novel redação do indigitado § 3.º do art. 485, o

Supremo Tribunal Federal⁵⁶ e o Superior Tribunal de Justiça continuarão entendendo, com muita probabilidade, que a regra legal em apreço somente incide nas instâncias ordinárias, sendo, portanto, necessário que sobre aquelas matérias de cognição oficial haja o devido prequestionamento para serem admitidos os recursos extraordinário e especial.

Em outras palavras, as impugnações atinentes aos pressupostos processuais, condição da ação e, enfim, às nulidades absolutas têm de preencher o requisito do prequestionamento para serem apreciadas em sede extraordinária. Isso porque o prequestionamento é requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, sem o qual não se pode decidir sequer sobre matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias de origem, até o julgamento, quando caso, dos embargos infringentes⁵⁷ (ou, já agora, do incidente a eles equiparado, na hipótese de ausência de unanimidade no julgamento da apelação – art. 942 CPC).

Frise-se, por outro lado, que, admitido o recurso especial com fundamento na violação de um determinado texto legal, devidamente prequestionado no acórdão recorrido, nada obsta a que, por ocasião do respectivo julgamento, o Superior Tribunal de Justiça conheça, de ofício, por exemplo, a carência de ação por falta de interesse processual.

Com efeito, infere-se de julgamento da 1ª Seção, nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.149.424-BA, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o seguinte posicionamento: “(...) Ainda que tivesse a Corte *a quo* examinado diretamente a questão, não estaria impedido o Superior Tribunal de Justiça de proceder à sua análise, porque admitido o recurso especial quanto à matéria de fundo. Conforme jurisprudência assente desta Corte, o prequestionamento se faz imprescindível até mesmo para arguir as nulidades absolutas, porque não pode o Superior Tribunal de Justiça conhecê-las de ofício. Entretanto, a rigidez da observância veio a ser flexibilizada por alguns acórdãos que entendem possível ao Superior Tribunal de Justiça conhecer das matérias de ordem pública de ofício se, após ser o especial conhecido, com o prequestionamento de tese jurídica pertinente, depararem-se os julgadores com uma nulidade absoluta ou com matéria de ordem pública e que pode levar à nulidade do julgamento ou a sua rescindibilidade (...)”.⁵⁸

Nessa mesma direção, expressivo julgado proferido pela 1ª Turma, no REsp 869.534-SP, com voto condutor do Ministro Teori Albino Zavascki, ao prover o recurso, declarou a nulidade do acórdão proferido pelo tribunal de origem, *in verbis* : “Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo, já que cumprirá ao Tribunal ‘julgar a causa, aplicando o direito à espécie’ (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). Para assim proceder cabe ao órgão julgador, se necessário, enfrentar a matéria prevista no art. 267, § 3º e no art. 301, § 4º, do CPC. Em outras palavras, a devolutividade do recurso especial, em seu nível vertical, engloba o efeito translativo, consistente na possibilidade, atribuída ao órgão julgador, de conhecer de ofício as questões de ordem pública. No caso, provocado por agravo de instrumento para decidir sobre o cabimento de exceção de pré-executividade (que fora negado pelo juízo de primeiro grau), o Tribunal reformou a decisão e, indo além, decidiu o mérito, contra o recorrente. Houve, portanto, duplo *error in procedendo* : o do julgamento *ultra petita* e o da *reformatio in pejus* , o que acarreta sua nulidade”.⁵⁹

Diante da nova redação do § 3.º do art. 485, vejamos qual será a orientação a ser perfilada pelos tribunais superiores sob a vigência do CPC.

13. Retratação judicial no quinquídio (§ 7.º)

Como a extinção anômala do processo, sem resolução do mérito, não interessa a ninguém, o § 7.º do art. 485 do CPC oferece, como novidade, uma verdadeira chance para que o processo seja salvo, ainda perante o juiz de primeiro grau.

Realmente, uma vez interposta a apelação, em qualquer uma das hipóteses acima examinadas, o juiz poderá retratar-se no prazo de 5 dias, abrindo ensejo, se for o caso, a que a parte corrija o vício que fundamentou a extinção do processo.

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1.º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2.º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

§ 3.º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

Correspondência: art. 268 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 408 do NCPC francês, art. 310 do CPC italiano, art. 279 do CPC português, § 330 do ZPO alemão

1. Aspectos gerais

A sentença (terminativa) que não resolve o mérito não se reveste, como acima frisado, de coisa julgada material. Daí, porque facilmente se compreende a norma do *caput* do art. 486, que permite o rejuizamento da mesma ação.

Todavia, o § 1.º do art. 486, em algumas das situações de julgamento anômalo, estabelece certas providências que deverão ser tomadas pelo autor, antes de aforar a sucessiva demanda.

Assim, na hipótese de litispendência, para vir novamente a juízo, o demandante deverá demonstrar que não mais existe qualquer ação idêntica ainda pendente.

Além disso, segundo também preceitua o § 1.º, se o anterior processo foi extinto em decorrência do indeferimento da petição inicial ou da falta de pressuposto processual, o demandante deverá sanar o respectivo defeito, para só então intentar a nova ação.

Entendo realmente difícil ocorrer a hipótese de “correção do vício” atinente ao inc. VII do art. 485, simplesmente porque o autor não terá como superar a existência de convenção de arbitragem. No entanto, se, por exemplo, for desfeito o contrato no qual prevista a arbitragem, não haverá qualquer óbice ao novo ajuizamento da demanda perante o tribunal estatal.

Igualmente, parece-me equivocada a remissão ao inc. VI, que diz respeito à ilegitimidade *ad causam* e à falta de interesse processual. É certo que de duas uma: ou o autor repete a mesma ação e, novamente, será reconhecida a carência; ou, então, haverá juízo positivo quanto à legitimidade de ambas as partes ou à implementação superveniente do interesse de agir, e, nesse caso, tratar-se-á de outra ação, certamente não idêntica à anterior.

2. Comprovação do pagamento de custas e honorários advocatícios

Como antes observado, em sintonia com a determinação do art. 92 do CPC, a prova exigida pelo § 2.º do art. 486 constitui pressuposto processual objetivo extrínseco para que possa ser admitido o processamento da petição inicial da subsequente ação.

Caso não comprovada tal quitação, o juiz deverá conceder ao autor o prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 e parágrafo único, para que cumpra a determinação legal, sob pena de indeferimento da inicial.

Ressalte-se que, alterado um dos elementos da demanda, ainda que possa ela se assemelhar à anterior, cujo processo foi extinto sem julgamento de mérito, será *outra ação*, não se impondo, como pressuposto processual, a prova reclamada pelo § 2.º do art. 486.

3. Perempção

O § 3.º encerra a hipótese de perempção da ação, já examinada no comentário do inc. V do art. 485.

Configura-se a perempção quando o autor abandonar o processo por três vezes, nos termos do art. 485, III. Nesse caso, estará ele impedido de repetir novamente a ação.

Lembre-se que a perempção é fenômeno processual que afeta apenas a ação, restando intocado o direito deduzido, que poderá ser arguido como matéria de defesa (art. 486, § 3.º).

4. Rescindibilidade da sentença terminativa

Registre-se, por fim, que o art. 966, § 2.º, I, do CPC, introduz importante novidade na legislação promulgada, ao admitir ação rescisória da sentença que, embora não seja de mérito, impede a repropositura da demanda.

Assim, verificada a perempção ou descumprida a exigência contemplada numa das situações previstas no art. 486, o juiz deverá proferir sentença obstativa do novo ajuizamento provocado pelo autor. E, exatamente por esta razão, transitado em julgado esse ato decisório, é ele passível de impugnação por meio de ação rescisória.

Note-se que o direito de ação é público, incondicionado e abstrato. É muito provável que o legislador, para desenhar aquela verdadeira inovação, tenha se inspirado no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, que consagra o denominado princípio da reserva legal, assecuratório de amplo acesso ao Judiciário.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1.º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Correspondência: art. 269 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 450 do NCPC francês, art. 277 do CPC italiano, art. 207 da LEC espanhola, art. 607 do CPC português, § 300 do ZPO alemão, art. 236 do SZO suíço, art. 779 do CJ belga

1. Aspectos gerais

Apresenta-se o mérito como tema central do processo civil, de modo a ser enfrentado pela sentença definitiva, mediante a qual o órgão jurisdicional responde ao pedido deduzido pelo autor.

Haverá, pois, “julgamento de mérito” toda vez que, ultrapassado o exame das questões formais, o processo estiver escorrido para receber decisão sobre o objeto da controvérsia submetida à cognição do órgão jurisdicional.

Além da resolução do mérito propriamente dita, especificada no inc. I, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, e, ainda, na hipótese de reconhecimento da decadência ou da prescrição (inc. II), o dispositivo ora comentado ainda prevê três situações de atos compositivos do litígio, celebrados pelas próprias partes, diante das quais o juiz apenas profere sentença homologatória.

Na verdade, constata-se que o *meritum causae*, nos casos contemplados no inc. III do art. 487, não é resolvido por ato decisório do juiz, mas, antes, pelos sujeitos do processo, de sorte que, com a preclusão dos prazos para recurso, a sentença homologatória se sujeita, em princípio, à coisa julgada formal.

E isso porque, consoante o disposto no art. 966, § 4.º, do CPC: “Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

Assim sendo, a decisão interlocutória homologatória do reconhecimento parcial do pedido, da transação parcial, ou, ainda, da renúncia parcial à pretensão, ou mesmo a sentença meramente homologatória do reconhecimento do pedido, da transação, ou da renúncia à pretensão, somente pode ser desfeita por meio de ação anulatória de natureza constitutiva (negativa).

Esta demanda, regada pela disciplina do procedimento comum, viabiliza-se, se fundada em vício de consentimento, *ex vi* do art. 178 do Código Civil, no prazo decadencial de 4 anos, a partir do respectivo trânsito em julgado do ato decisório de homologação. Se, contudo, for lastreada em outro fundamento, de direito material (ausência de legitimação para a prática do ato) ou de natureza processual (falta de poderes especiais outorgados ao advogado), o prazo decadencial, já agora segundo o disposto no art. 179 do Código Civil, será de 2 anos. Ambos os prazos acima referidos, por serem de decadência, afastam a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas de sua respectiva fluência.

Tudo indica que a opção técnica pelo cabimento da ação anulatória foi mesmo intencional, até porque o legislador retirou do rol dos casos de ajuizamento da ação rescisória, catalogados no novo art. 966, qualquer vestígio do inc. VIII ⁶⁰ do art. 485 do CPC revogado.

Todavia, ainda que a atividade judicial, nas apontadas hipóteses, restrinja-se a referendar a vontade soberana dos litigantes quanto aos interesses em conflito, não se faz ela de forma automática, “mas, pelo contrário, necessariamente alomática, isto é, perquiridora da concorrência dos requisitos reclamados pelo ato homologando”. O juiz deverá também reprimir qualquer atuação contrária à dignidade da justiça ou de uso indevido do processo. ⁶¹ Nesse mesmo sentido, como adiante será melhor explicado, o órgão jurisdicional, ao invés de proferir sentença homologatória do reconhecimento do pedido formulado pelo autor, poderá, por exemplo, em caráter excepcional, resolver o mérito, com arrimo no art. 487, II, do CPC, declarando a ocorrência de prescrição ou mesmo julgar improcedente o pedido (art. 487, I, CPC).

2. Julgamento de mérito propriamente dito

Pedido (do latim *petitum*), no âmbito do processo civil, constitui vocábulo técnico designativo da pretensão do demandante. Não é possível conceber-se uma ação judicial sem a formulação do pedido, visto ser esse um de seus elementos estruturais, ainda, a própria razão da judicialização de um litígio.

Anote-se que a petição inicial deve conter, como exigência formal mínima, além da explícita referência às partes, a exposição da causa de pedir e a especificação do pedido.

Para dar início ao processo de conhecimento, cumpre, pois, ao autor provocar a jurisdição requerendo uma determinada espécie de provimento (*pedido imediato*), para tutelar um bem jurídico (*pedido mediato*).

A providência estatal que vem reclamada, quando acolhida, redundará em uma sentença que, dependendo do tipo de demanda proposta, será meramente declaratória, constitutiva ou condenatória, mas (em tese) sempre útil ao autor.

Não se perca de vista que toda atividade jurisdicional é programada com o objetivo último de enfrentar o mérito, decidindo se o pedido formulado no processo é procedente ou improcedente e, assim, se deve ou não ser admitido. É, aliás, exatamente esta a orientação da norma fundamental preceptiva que vem traçada logo no preâmbulo do novo CPC, no art. 4.º, ao dispor que: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

De forma genuína, pois, a teor do inc. I do art. 487 do CPC, o juiz resolverá o mérito quando for possível “acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção”.

2.1. Improcedência liminar do pedido: exceção à regra do art. 10

Sucedendo que, já no início do processo, pode o juiz constatar desde logo que se impõe a improcedência do pedido, porque, contra a tese articulada na petição inicial, conspira posição sedimentada na jurisprudência.

Assim, consoante a nova disposição do art. 332 do CPC, antes mesmo de determinada a citação do réu, poderá ser liminarmente proferida sentença de improcedência do pedido, quando este estiver fundamentado em argumentação jurídica que divergir de súmula, vinculante ou persuasiva, do Supremo Tribunal Federal, ou de enunciado sumulado do Superior Tribunal de Justiça (inc. I); de acórdão destes tribunais superiores proferidos em recursos repetitivos (inc. II); de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inc. III); ou, ainda, de súmula de tribunal de justiça sobre direito local (inc. IV).

Essa mesma técnica é aplicável se o juiz verificar, de plano, a ocorrência de decadência ou de prescrição, matéria cognoscível de ofício, a despeito do que preceitua o art. 10 do CPC, podendo excepcionalmente decretar a improcedência liminar do pedido (art. 487, parágrafo único), sem qualquer manifestação da parte contrária, até porque está sequer foi citada.

3. Reconhecimento da decadência ou da prescrição

O simples transcurso do tempo provoca inexorável consequência sobre as situações jurídicas, constituindo causa de aquisição ou extinção de direitos materiais ou processuais.

A decadência e a prescrição são fenômenos que se inspiram na exigência de segurança e de certeza do direito, cujo escopo é o de impedir que a possibilidade de judicialização da grande maioria dos litígios se eternize. São situações, pois, verificadas geralmente em momento pré-processual, que se configuram pelo decurso temporal.

Após a promulgação do Código Civil de 2002, não mais existe dúvida quanto à técnica escolhida, no que respeita às distinções entre decadência e prescrição. Com rigor dogmático, explica Humberto Theodoro Júnior que: “A falta de critério legal e a controvérsia doutrinária acerca da conceituação da prescrição tornavam tormentosa a diferenciação entre esta e a decadência. Para os que viam na prescrição a extinção apenas da ação, era mais fácil distingui-la da decadência, porque esta, ao contrário daquela, funcionava como causa de extinção do direito, que por sua própria natureza deveria ser exercido em certo prazo, sob pena de caducidade. Se, todavia, tanto a prescrição como a decadência se apresentam como causa de extinção de direito subjetivo, torna-se penosa e quase impossível uma distinção precisa entre as duas figuras extintivas. O Código Civil tomou posição no debate travado no direito comparado e optou por conceituar a prescrição como perda da *pretensão* (art. 189, CC), ideia que se aproxima da posição romana (*actio*) e que é a atual no direito alemão e suíço. Com isso, facilitada restou a configuração dos casos de decadência (art. 207, CC), aos quais se dedicou regulamentação separada (arts. 207 a 211, CC)”.⁶²

A despeito da garantia constitucional de acesso à tutela jurisdicional, a lei impõe prazos para

que alguém possa exercer a sua pretensão de direito material no plano processual.

Constata-se que, a exemplo do CPC revogado, a decadência é regida ao lado da prescrição, como tema próprio da resolução do mérito da causa.⁶³

O instituto da prescrição é contemplado no Código Civil como uma exceção de direito material que o réu pode arguir como matéria de defesa (art. 193 CC). Uma vez verificada, provoca a extinção da pretensão do autor (art. 189 CC).

Consoante o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce a pretensão para o seu titular, a qual é extinta, dentre outras razões, pela passagem de certo intervalo temporal. Este lapso é denominado prescrição ou prazo prescricional.

Já a decadência encerra disciplina completamente diversa, pois substancializa um espaço de tempo de existência de um direito potestativo. Não se trata de período no qual é possível exigir (pretensão) uma prestação. Cuida-se do tempo em que o direito existe na esfera jurídica de determinado sujeito. É por isso que, comumente, no vocabulário da praxe forense, diz-se que a prescrição fulmina a ação e a decadência extingue o direito.

Conclui-se que a prescrição é o interregno durante o qual o direito a uma determinada prestação pode ser exigido e a decadência é o íterim de existência do direito de alterar, modificar ou extinguir uma relação jurídica.⁶⁴

No alvitre preciso de Humberto Theodoro Júnior, na prescrição há um direito e uma obrigação em confronto, enquanto, na decadência, apenas um único sujeito se apresenta como titular de uma faculdade. Não se verifica aqui obrigação inadimplida. Daí porque é na seara dos direitos potestativos que tem lugar a decadência. Estabelecendo a necessária conexão entre o “direito subjetivo do titular de um direito potestativo com o sistema processual, ver-se-á que, na classificação das ações pela eficácia da sentença, a prescrição é aplicável às *ações condenatórias*, e a decadência, às *ações constitutivas*”.⁶⁵

Excepcionando a regra da eventualidade, preceitua o art. 193 do Código Civil que a prescrição pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, em qualquer espécie de processo. Bem é de ver, no entanto, que a cognição referente à prescrição constitui *quaestio facti*, e, por esta razão, o seu exame, em regra, descortina-se rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça.⁶⁶ Com efeito, não tem sido possível, pela via do recurso especial, rever a conclusão do tribunal de origem que aplicou a Súmula 106/STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo do serviço judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Isso porque tal revisão demandaria o reexame dos elementos fáticos insertos nos autos do processo, o que esbarra no óbice da Súmula 7.

Realmente, tal entendimento é extraído, e.g., dos seguintes precedentes: 4ª Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.470.883-MA, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti: “1. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, entendeu que a carta apresentada pelo credor não teve o efeito de interromper a prescrição, sendo posterior ao término do prazo de prescrição da ação executiva e também da ação de reparação civil. 2. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte”⁶⁷; 2ª Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.485.685-SC, relatado pelo Ministro Herman Benjamin: “Quanto à alegada prescrição, não seria possível analisar sua ocorrência, pois é tarefa que demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7 deste Tribunal”.⁶⁸

O mesmo tem prevalecido em relação à arguição de decadência: 2ª Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.396.715-MG, cujo voto condutor é da lavra do Ministro Humberto Martins: “Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que extinguiu o *writ*, em virtude da decadência do direito à impetração, julgando prejudicados o reexame necessário e a apelação. Hipótese em que a parte recorrente insurge-se contra o termo

inicial da decadência fixado no acórdão mediante prova documental. Reformar a ilação da Corte de origem encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”.⁶⁹

Pois bem, verificada a decadência ou a prescrição, no âmbito das instâncias ordinárias, o juiz não poderá proferir sentença sem antes propiciar a manifestação das partes (arts. 10 e 487, parágrafo único).

Ademais, deverá também julgar o mérito, proferindo sentença de improcedência liminar do pedido, quando, desde logo, reconhecer *ex officio*, a decadência ou a prescrição (art. 332, § 1.º, CPC).⁷⁰ E, nesta hipótese, segundo o parágrafo único do art. 487, como o réu ainda não foi citado, a sua oitiva faz-se prescindível.

Já sob outro enfoque, indeferida a tutela cautelar com fundamento na decadência ou na prescrição, o autor estará impedido de deduzir o pedido principal (art. 310 CPC).

Acrescente-se, por fim, que, em regra, não se aplicam à decadência as causas de interrupção da prescrição (arts. 202 e 207 CC).

3.1. Reconhecimento de prescrição intercorrente no processo de execução

Cumpra observar, como acima frisado, que o CPC disciplina com muita precisão a denominada prescrição intercorrente, que constitui causa de suspensão e de extinção da execução.

Dentre as situações que ensejam a suspensão da execução, previstas no art. 921 do CPC, encontra-se aquela que é provocada pela inexistência de bens penhoráveis de propriedade do executado (inc. III). O juiz, nesse caso, determinará a suspensão do processo de execução pelo prazo de 1 ano, “durante o qual se suspenderá a prescrição” (art. 921, § 1.º, CPC).

Dispõe o § 4.º do mesmo art. 921 do CPC que, transcorrido o lapso de suspensão, sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.

Atingido tal interregno temporal, o juiz deverá determinar a intimação das partes para que se manifestem no prazo de 15 dias (§ 5.º do art. 921). Justifica-se esta providência no princípio do contraditório efetivo, caro ao novo CPC (art. 10), evitando-se decisão escudada em fundamento-surpresa. O exequente, em particular, terá oportunidade de explicar o motivo de sua prolongada inércia.

Em seguida, considerando a manifestação das partes, sendo injustificável a paralisação do processo, o juiz, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, proferirá sentença extintiva do processo executivo.

Coerente com esse regime, o subsequente art. 924 prevê, entre as hipóteses de extinção da execução, a ocorrência de prescrição intercorrente (inc. V).

4. Sentença homologatória

4.1. Reconhecimento da procedência do pedido

Ajuizada a ação, o réu é citado para apresentar resposta. Todavia, poderá ele reconhecer a procedência do pedido formulado pelo autor, com o deliberado intuito de não opor qualquer resistência à pretensão que lhe é dirigida.

Caracteriza-se esse comportamento do demandado pela aceitação expressa dos fatos e das consequências jurídicas pretendidas pelo autor, declarando que a ação é juridicamente fundada. Consubstancia-se, assim, o reconhecimento por um ato unilateral, exclusivo do demandado, que não se subordina à aceitação pela parte que é favorecida. “Basta, para a sua validade, a manifestação de vontade do réu”.⁷¹

Na verdade, a eficácia do reconhecimento jurídico do pedido exige pelo menos dois requisitos:

a) capacidade jurídica do réu; e b) disponibilidade do direito, objeto do litígio.

Havendo litisconsórcio ativo necessário e/ou unitário (arts. 114 e 116 CPC), o reconhecimento é eficaz em relação a todos os autores, devendo o juiz proferir sentença. Se, por outro lado, o litisconsórcio ativo for facultativo simples (art. 113 CPC), no qual não se exige que a sentença seja uniforme para todos os demandantes, o juiz deverá proferir decisão homologatória do reconhecimento em relação ao litisconsorte cujo pedido foi reconhecido, devendo o processo prosseguir em relação aos demais.

Na hipótese de litisconsórcio passivo necessário e/ou unitário, o reconhecimento do pedido somente terá eficácia se for efetivado por todos os réus. Sendo caso de litisconsórcio passivo facultativo simples, o reconhecimento por um dos réus não atinge os demais; o juiz o homologa e o processo prossegue normalmente em relação a estes.⁷²

O reconhecimento do pedido implica concordância com a pretensão de direito material, não se identificando com a confissão do réu, que concerne à admissão da verdade dos fatos, contrária ao seu interesse. Enquanto a confissão é meio de prova, o reconhecimento diz respeito ao direito invocado pelo autor, cuja procedência é admitida, determinando a abreviação da marcha do processo.

Aduz, a propósito, o Ministro Marco Buzzi, em acórdão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Recurso Especial 1.366.156-SP,⁷³ que: “o reconhecimento do pedido não se confunde com a confissão, que é apenas meio de prova e se refere a um ou alguns fatos arrolados pela parte contrária, tampouco com a transação, considerada o ato pelo qual as partes, mediante concessões recíprocas, abrem mão do litígio. No particular, ressalta-se que o reconhecimento tem por objeto o próprio pedido do autor, com todos os seus consectários jurídicos. Trata-se de ato unilateral da parte, isto é, verdadeira adesão do réu ao pedido do autor, ensejando autocomposição do litígio e dispensando o juiz de dar sua própria solução de mérito”.

Discute-se se o reconhecimento jurídico do pedido acarreta restrição ao livre convencimento do juiz, exercendo influência imediata sobre o conteúdo da sentença, a qual, então, seria *sempre* de procedência.

Enfrentando esta delicada questão, Moacyr Lobo da Costa, em obra específica, defende a tese no sentido de que, a despeito do reconhecimento do pedido, o juiz pode muito bem julgá-lo improcedente. Essa doutrina tinha como primordial fundamento o sistema adotado pelo CPC/1973, que inseria, no art. 269, II, como julgamento de mérito (e não simplesmente homologatória), a sentença de extinção do processo na hipótese de reconhecimento do pedido. Afirmava, a propósito, Lobo da Costa: “O Código, no caso do reconhecimento do pedido, coloca a sentença na categoria das sentenças de julgamento de mérito, e o faz de maneira inequívoca (...) O juiz tem de julgar na mesma sentença o reconhecimento e a ação, isto é, o ato do réu e o pedido do autor. A sentença é una, encerrando dois julgamentos distintos. A validade, ou invalidade, formal do ato do réu, proclamada pelo juiz, não condiciona o acolhimento, ou a rejeição, do pedido do autor. O juiz pode admitir como fundamento válido o reconhecimento, e, não obstante, julgar improcedente a ação, quando a vontade da lei não conceder a tutela pretendida. Se o ordenamento jurídico não legitimar a pretensão do autor, o reconhecimento do pedido pelo réu será ineficaz”.⁷⁴

Com a modificação agora introduzida no art. 487, III, *a*, do CPC, a sentença proferida quando houver reconhecimento do pedido pelo réu tem natureza meramente homologatória, mas considerada título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC.

Não obstante, mesmo com essa importante alteração, a exemplo do que ocorre com a sentença que homologa a transação, o juiz terá de examinar, além da concorrência dos requisitos intrínsecos, acima aludidos, se o pedido, reconhecido pelo réu, adequa-se ao ordenamento jurídico vigente. Suponha-se que o autor ajuíze uma demanda de natureza condenatória, atingida pela prescrição. Citado, o réu reconhece a procedência da pretensão. Diante da flagrante perda do direito de ação, matéria cognoscível de ofício, estaria o juiz vinculado ao reconhecimento, devendo, mesmo assim, proferir sentença homologatória. Entendo que não. O juiz, nesse caso,

depois de colher a manifestação das partes (arts. 10 e 487, parágrafo único, CPC), convencido da ocorrência de prescrição, deverá prolatar sentença de improcedência do pedido, com fundamento no art. 487, II, CPC.

Saliente-se, por outro lado, que, segundo a regra do art. 90 do CPC, proferida a sentença homologatória, a responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários do patrono constituído pelo autor será imposta ao réu que reconheceu o pedido.

Sendo parcial o reconhecimento, a condenação a título de sucumbência será proporcional ao âmbito do ato de disponibilidade praticado pelo requerido (art. 90, § 1.º, CPC).

Prevalece aqui também, como se observa, o denominado princípio da causalidade, que vem inclusive expressamente admitido em acórdão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Recurso Especial 1.133.638-SP, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “O reconhecimento jurídico do pedido é ato unilateral pelo qual o demandado adere integralmente à pretensão do autor, sendo devidos honorários pela parte que reconheceu, tendo em vista o princípio da causalidade”.⁷⁵

Importa ter ainda presente a novidade introduzida no § 4.º do art. 90 do CPC, no sentido de que, reconhecida a procedência do pedido e, ao mesmo tempo, for integralmente satisfeita a pretensão deduzida pelo autor, “os honorários serão reduzidos pela metade”. É paradoxal notar que o legislador faz aí verdadeira “cortesia com o chapéu alheio”, porquanto, nesta hipótese, é o advogado do autor que tem o seu direito próprio e autônomo aos honorários (art. 85, § 14, CPC) diretamente atingido pela atitude do réu adimplente da obrigação.

É razoável admitir que tal norma legal, em tese, tenha algum sentido se o reconhecimento do pedido ocorrer já na fase postulatória, no momento reservado à oferta de contestação. Todavia, se for ele verificado, por exemplo, depois da fase instrutória, a evitar qualquer prejuízo ao advogado do autor, o juiz deverá considerar, com acentuado rigor, na fixação dos honorários, os critérios estabelecidos no § 2.º do art. 85 do CPC.

4.2. Transação

4.2.1. Conceito, requisitos e espécies

Após a eclosão da lide, que é um fenômeno metaprocessual, nada obsta a que os litigantes cheguem a um acordo, antes mesmo de terem buscado tutela jurisdicional ou na pendência de um processo judicial, seja de conhecimento, seja de execução. A transação, pois, é admitida em qualquer fase do processo de conhecimento, em plena tramitação do cumprimento de sentença ou do processo de execução.

Considerada como *equivalente jurisdicional* por Francesco Carnelutti,⁷⁶ a transação, judicial ou extrajudicial, importa recíprocas concessões dos litigantes.

É exatamente o que preceitua o art. 840 do Código Civil: “É lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

A transação pressupõe reciprocidade de concessões ou de sacrifícios de ambos os litigantes. Esse é o traço marcante que a distingue de outros atos de disposição, como, por exemplo, a renúncia, a desistência ou o reconhecimento do pedido. Para a validade da transação, que tem a natureza de negócio jurídico bilateral, não se exige que as recíprocas concessões tenham a mesma importância ou equiparação patrimonial.

Desenvolvendo tal raciocínio, sintetiza Pontes de Miranda que, preenchidos os pressupostos em lei exigidos, “a finalidade da transação é exatamente transformar em incontestável, no futuro, o que agora é litigioso ou incerto”.⁷⁷

Além da capacidade das partes, a transação somente pode ter como objeto direitos disponíveis.

Com efeito, repetindo literalmente o art. 1.035 do Código Civil/1916 revogado, dispõe o art. 841 do atual: “Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite transação”.⁷⁸ Há de exigir-se – elucida Pontes de Miranda – a *transacionalidade* do direito de que vai se abrir mão.⁷⁹

A teor do art. 842 do Código Civil, a transação reclama forma solene (escritura pública ou instrumento particular), podendo ser extrajudicial ou judicial. Celebrada na pendência de processo, a sua eficácia fica subordinada à homologação do juiz. Os advogados que assinarem a petição na qual estiverem especificados os termos da transação necessitarão de poder especial para transigir (art. 105 CPC). Sempre é aconselhável que as próprias partes também assinem a respectiva petição.

Mesmo quando a transação for extrajudicial, submetida a juízo para a devida homologação, a orientação que predomina no Superior Tribunal de Justiça é a de exigir a presença de advogado, como, e.g. , infere-se do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.123.817-BA, de relatoria do Ministro Humberto Martins: “Da análise do art. 7.º da Lei Complementar 110/2001, conclui-se pela possibilidade de o fundista transigir extrajudicialmente com a Caixa Econômica Federal a fim de que sejam aplicados os índices de correção monetária às suas contas. Somente a homologação é judicial e, nessa fase, necessária a presença de advogado”.⁸⁰

Oportuno esclarecer que os litigantes podem perfeitamente conciliar-se apenas em parte, à qual se restringirá a transação efetivada, e sem qualquer reflexo, de que natureza seja, sobre o restante da controvérsia, que deverá ser objeto de outra sentença, “também definitiva por ser respeitante ao *meritum causae* , no contexto intocado pela conciliação”.⁸¹

Ademais, o âmbito do acordo pode ser mais amplo do que o objeto do próprio processo, desde que respeitada a competência do julgador. Abstração feita da nova redação dos incs. II e III do art. 515 do CPC, dúvida não há de que a sentença homologatória, nessa hipótese, constitui título executivo judicial em toda a sua extensão subjetiva e objetiva.

Havendo litisconsortes, nada obsta também que o fim do litígio seja consumado apenas entre algumas das partes, até porque, segundo o disposto no *caput* do art. 844 do Código Civil: “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”.

Considerando essa questão, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.079.293-PR, assentou que: “Quando credor dá quitação parcial da dívida – mesmo que seja por meio de transação – tal remissão por ele obtida não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada”.⁸²

4.2.2. Transação como categoria dos negócios jurídicos processuais

Tradicionalmente, a legislação processual desenha um determinado procedimento, cujas regras, em princípio, sempre foram concebidas como cogentes, não podendo ser alteradas pelos protagonistas do processo, vale dizer, nem pelo juiz e muito menos pelos litigantes.

Essa premissa, contudo, jamais impediu que, no plano do direito material, as partes pudessem (como podem) por fim à controvérsia, mesmo depois de judicializada a pendência entre elas existente, por meio de inúmeros expedientes, entre eles, e.g. , a transação judicial ou, mesmo, extrajudicial.

Nesse sentido, procurando infundir a cultura da pacificação entre os protagonistas do processo, o novo diploma processual, em inúmeros preceitos, sugere a autocomposição. Dispõe, com efeito, o § 2.º do art. 3.º do CPC que: “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. Dada a evidente relevância social da administração da justiça, o Estado deve mesmo empenhar-se na organização de instituições capacitadas a mediar conflitos entre os cidadãos. No Brasil, o Ministério da Justiça preocupa-se em fornecer os meios necessários a várias Organizações Não Governamentais, que têm como missão precípua a instalação e gestão de sistemas alternativos de administração de controvérsias.

Aduza-se que o próprio CPC de 2015, comprometido com o sistema “multiportas” de solução dos litígios, de forma muito original, fomenta, no art. 174, a criação, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo.

Além destas importantes iniciativas, que seguem tendência mundial, o § 3.º do art. 3.º do CPC recomenda de modo expresso a solução amigável (autocomposição), que deverá ser implementada, na medida do possível e inclusive no curso do processo, “por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público”.

Tanto a mediação quanto a conciliação pressupõem a intervenção de uma terceira pessoa. Na mediação, esta tem a missão de esclarecer as partes, para que as mesmas alcancem a solução da pendência. Na conciliação, pelo contrário, o protagonista imparcial se incumba, não apenas de orientar as partes, mas, ainda, de sugerir-lhes o melhor desfecho do conflito.

Nesta significativa perspectiva, muito mais enfático do que o anterior, o novo CPC prevê ainda a criação de centros judiciais de solução consensual de conflitos, responsáveis pelas audiências de conciliação e mediação (art. 165 CPC); estabelece os princípios que informam a conciliação e a mediação (art. 166); faculta ao autor da demanda revelar, já na petição inicial, a sua disposição para participar de audiência de conciliação ou mediação (art. 319, VII, CPC); estabelece o procedimento da audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC); e recomenda, nas controvérsias de família, a solução consensual, possibilitando inclusive a mediação extrajudicial (art. 694 CPC).

Não é preciso registrar que, à luz desse novo horizonte que se descortina sob a égide do CPC, a efetivação de negócios jurídicos processuais, no plano do direito material, ganha inegável relevo.

Assim, uma vez passível de composição suasória o direito questionado, as partes, transigindo, podem celebrar acordos acerca do objeto litigioso, circunstância implicativa da extinção do processo, pela sua inarredável inutilidade superveniente.

Como acima frisado, judicial ou extrajudicial a transação, a sua eficácia se subordina à homologação judicial. É, pois, pela homologação que “o negócio jurídico se processualiza”.

Observa-se que, em época contemporânea, buscando racionalizar, a marcha do processo foi introduzida, em 1999, no sistema jurídico inglês, importante reforma – *The Woolf Reforms* –, que criou uma verdadeira comunidade de trabalho entre o juiz e as partes, visando a um maior dinamismo processual em prol da celeridade.

Cumprido salientar que nas hipóteses mais complexas, o procedimento a ser adotado pela Regra 29 das *Civil Procedure Rules* é o denominado *multi-track*, que confere ao tribunal ampla liberdade de atuação, admitindo alterações na consecução dos atos processuais, em consonância com a natureza, relevância e duração da demanda.

Para o início desse respectivo procedimento é prevista a realização de um significativo ato processual, informado pela oralidade, denominado *case management conference*, ou seja, uma audiência na qual, sob a direção do juiz, em franca cooperação, as partes convencionam os limites do litígio e estabelecem, de comum acordo, o cronograma e a sequência das provas a serem produzidas.⁸³

Na França e na Itália, igualmente, são atualmente admitidos, com peculiaridades próprias, acordos processuais sobre o desenrolar do procedimento.⁸⁴

Deve ter-se presente, nesse particular, que as convenções sobre os atos procedimentais têm natureza estritamente processual, não se confundindo com os negócios propriamente ditos, que ocorrem incidentalmente no âmbito do processo e que têm por objeto o próprio direito litigioso (como, p. ex., a transação).

Diante de tais premissas, sob o aspecto dogmático, o gênero negócio jurídico processual pode

ser classificado nas seguintes espécies: *a*) negócio jurídico processual (*stricto sensu*), aquele que tem por objeto o direito substancial; e *b*) convenção processual, que concerne acordos entre as partes sobre matéria estritamente processual.

As convenções almejam, pois, alterar a sequência programada dos atos processuais prevista pela lei, mas desde que não interfiram em seus efeitos. Enquanto há disponibilidade no modo de aperfeiçoamento dos atos do procedimento, a sua eficácia descortina-se indisponível, ainda que o objeto do litígio admita autocomposição.

Trilhando esse mesmo raciocínio, frisa Dinamarco que a escolha voluntária para reger o procedimento não vai além de se direcionar em um ou outro sentido, sem liberdade, contudo, para construir o conteúdo específico de cada um dos atos. Os seus respectivos efeitos são sempre os que resultam da lei e não da vontade das partes.⁸⁵

Assim sendo, é vetado às partes, por exemplo, estabelecerem que não se aplica a presunção de veracidade se algum fato não for contestado pelo réu, ou, ainda, atribuir peso/valor a determinada prova em relação a outro meio probatório.

Pois bem, dentre as novidades inseridas no CPC destaca-se aquela contemplada no *caput* do art. 190, que tem a seguinte redação: “Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”.

Ademais, o subsequente art. 191 do CPC dispõe sobre a possibilidade de o juiz em conjunto com as partes fixarem, de comum acordo, calendário para a prática dos atos do procedimento.

É certo que as convenções de natureza processual já existiam em nosso sistema processual (dispensa de audiência, suspensão do processo, distribuição do ônus da prova, critério para a entrega de memoriais, adiamento de julgamento em segundo grau), embora sem a amplitude que agora vem prevista no novel diploma processual.⁸⁶

Vale salientar que esta prerrogativa concedida às partes não pode ser identificada com os modos de solução consensual da controvérsia, que decorrem, como acima frisado, de verdadeiros negócios jurídicos, atinentes ao mérito da controvérsia.

As convenções processuais propiciadas pela regra do art. 190 do CPC encerram a possibilidade de as partes acordarem sobre a realização de atos procedimentais e, ainda, acerca de ônus, faculdades e deveres processuais, que vinculam o juiz e que não estão sujeitos à homologação (art. 200 CPC), mas apenas ao controle de sua respectiva higidez, sobretudo no que se refere às garantias processuais, que não admitem preterição em hipótese alguma.

Tais pactos, a exemplo do que se verifica no terreno da arbitragem, podem ser projetados antes mesmo da eclosão da lide ou celebrados incidentalmente já no curso do processo judicial. Não se afasta, pois, a possibilidade da ocorrência de mais de uma convenção processual entre as partes num mesmo processo.

Importa aduzir, em conclusão, a evitar qualquer dúvida, que as convenções processuais, amplamente admitidas pelo art. 190 do novo CPC, que ostentam natureza e conteúdo estritamente processual, não têm qualquer identidade dogmática com os negócios jurídicos processuais, de cunho substancial e que têm por objeto o direito controvertido.

4.2.3. Efeitos e objeto da transação

Encerrada a desavença no plano do direito substancial em decorrência do negócio jurídico consubstanciado na transação (*efeito material*), aflora, inexoravelmente, o seu *efeito processual* , que é, conseqüentemente, o de determinar a prolação de sentença homologatória, como se o próprio mérito tivesse sido examinado pelo órgão jurisdicional.

Quando da promulgação do CPC/1973, preceituava o art. 584 que dentre os títulos executivos judiciais encartava-se a sentença homologatória de transação, de conciliação, ou de laudo arbitral (inc. III).

Mais tarde, a Lei 8.953, de 13 de dezembro de 1994, ao introduzir inúmeras alterações no diploma processual, conferiu ao referido dispositivo a seguinte redação: “São títulos executivos judiciais: (...) III – a sentença homologatória de laudo arbitral, de conciliação ou de transação, ainda que esta não verse questão posta em juízo”.

Vê-se aí, em primeiro lugar, que o legislador persistira na atecnia constante do texto original, porquanto, tanto a conciliação quanto a transação, embora institutos que não se confundem, ensejam a autocomposição da lide com a necessária homologação por sentença (em qualquer uma das duas hipóteses) do respectivo termo de transação (que também pode ser materializada em petição conjunta). A rigor, não há em nosso sistema processual “sentença homologatória de conciliação”.

Tentando esclarecer a falha da lei, ressaltou Mendonça Lima que a conciliação, em *ultima ratio*, é uma transação, se bem que esse ato seja de exclusiva iniciativa das partes, enquanto a conciliação pressupõe o concurso de interposta pessoa, conciliador ou juiz.⁸⁷

Dúvida não há de que a nova redação do art. 515, II e III, do CPC, é bem mais aperfeiçoada, porque se refere respectivamente a autocomposição judicial e extrajudicial, de qualquer natureza.

O § 2.º do mesmo art. 515, a seu turno, possibilita a ampliação subjetiva e objetiva da transação, embora sem a mínima necessidade, visto que, tendo natureza de negócio jurídico bilateral, jamais se questionou, no âmbito da transação judicial, a ampliação dos limites do objeto do processo.⁸⁸

Traduzindo doutrina universal, assevera Francisco J. Peláez, que na transação *mista* ou *complexa*, na qual se alarga o objeto quanto às recíprocas concessões, as partes podem também dar ou prometer alguma coisa estranha à situação ou relação controvertida, geralmente com o propósito de por fim ao litígio.⁸⁹

Nessa mesma linha de raciocínio, segundo clássica lição de Pontes de Miranda, que, a propósito, merece ser repetida *ipsis verbis*: “a transação judicial tem conteúdo de direito material e só é processual o efeito de pôr termo ao processo, mas, para que tal efeito exista, é de mister que apanhe o objeto do litígio em seu todo, ou em parte quantitativamente determinada. Não lhe é empecilho ter de regular matéria estranha ao processo, ainda que sujeita a outra lide, ou ter de estar presente ao ato pessoa estranha ao processo, que assuma dívida própria, ou alheia, ou consinta, ou assinta, ou anua, ou dê autorização ou permissão para algum dos pontos de transação”.⁹⁰

A mostrar igualmente a acaciana redação do novo texto legal (art. 515, § 2.º, CPC), a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no Recurso Especial 4.371-SP, deixou claro que o caráter estritamente contratual da transação impede que o juiz, ao examinar a higidez do negócio, manifeste qualquer ingerência quanto ao seu objeto, livremente pactuado pelas partes, mas desde que não contaminado por qualquer vício de vontade ou ilicitude.⁹¹

Desse modo, na esfera do conceito “jurisdicionalista” da transação judicial, defendido por Carnelutti,⁹² o pleito de homologação pode ser indeferido pelo juiz, quando a transação apresentar qualquer irregularidade formal (e.g. : ausência de capacidade), ou, ainda, despontar manifestamente iniqua, incidindo, por exemplo, sobre pretensões ilícitas ou infundadas.

Todavia, não há se falar em *ultra, extra vel infra petita* na sentença que, sem nada acrescentar, restringir ou modificar no acordo das partes, homologa-o, porque seu objeto já não é o pedido inicialmente formulado, mas, como visto, a própria transação.

Não é raro, pois, que, no curso de ação condenatória na qual o autor pretende indenização a título de prejuízo material, as partes transijam, incluindo, nos termos do acordo, quitação

respeitante a eventual indenização por dano extrapatrimonial. É possível, outrossim, que um imóvel, estranho ao litígio, de propriedade do devedor, seja transmitido ao autor da demanda, em pagamento do crédito exigido, dação esta concretizada por meio da transação.

E, assim, diante desta circunstância, é possível surgir um problema com sérias repercussões futuras, que não pode passar ao largo da atenção judicial.

Com efeito, a distribuição da petição inicial, prevista no art. 285 do CPC, produz inúmeros efeitos materiais e processuais. Dentre aqueles, presta-se a certificar o ajuizamento de demanda em face de determinado sujeito de direitos. Assim, o registro das ações judiciais, a partir da distribuição, constitui importante subsídio para que se tenha conhecimento da situação jurídica do patrimônio pertencente à pessoa com quem se está entabulando algum negócio. É comum, pois, na praxe negocial, a extração de certidões pessoais do vendedor, entre outras, do cartório do distribuidor.

A citação válida, por sua vez, entre outros efeitos, “torna litigiosa a coisa” (art. 240 CPC).

Ajuizada uma demanda de baixa significância econômica, é certo que o pedido formulado em face do réu não produz potencialmente repercussão na situação financeira deste. É esta demanda que então constará da certidão expedida pelo distribuidor.

Encerrando-se o processo mediante transação, as partes podem perfeitamente incluir neste negócio jurídico quaisquer bens estranhos ao objeto da controvérsia, tornando impossível que algum terceiro, credor do réu que abriu mão de seu patrimônio, tenha conhecimento da dação em pagamento.

Daí a relevância do controle judicial quanto aos termos substanciais da transação, evitando-se, em última análise, que as partes ou, pelo menos, o devedor, recorra a tal mecanismo de autocomposição para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC).

Tenha-se ainda presente que, consoante a regra do art. 850 do Código Civil, a transação é nula na hipótese de ter como objeto controvérsia já decidida por sentença transitada em julgado, se desta não tinha conhecimento um dos transatores.

Se a transação não contiver qualquer disposição sobre o pagamento das despesas processuais em aberto, serão elas rateadas entre as partes (art. 90, § 2.º, CPC). Verificando-se que os litigantes transigiram antes de ser proferida a sentença de primeiro grau, ficarão dispensadas do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes (art. 90, § 3.º, CPC).

4.3. Renúncia à pretensão

Complementando as hipóteses que determinam a resolução do mérito, o inc. III, c, do art. 487 do CPC, refere-se à renúncia à pretensão deduzida na ação ou na demanda reconvencional.

Como antes anotado, diversamente do que sucede na desistência da ação, que acarreta consequências apenas no plano processual, na renúncia, o autor abre mão do direito subjetivo material, que constitui o objeto do processo, na medida em que formulado na petição inicial.

Ora, renunciando o demandante à própria pretensão, o réu ficará definitivamente liberado de suportar os efeitos do ajuizamento da ação e, ainda, de qualquer outra futura investida acerca do direito feito valer em juízo.

A renúncia, como ato exclusivo do autor, não reclama solenidade alguma, desde que expressa e inequívoca. A sua efetividade fica condicionada apenas à disponibilidade do direito renunciado.

Destaque-se, sobre o tema, a excelente síntese de Egas Dirceu Moniz de Aragão quanto aos requisitos para a validade e eficácia da renúncia: “quanto ao objeto, exige-se que o direito seja renunciável, pois alguns poucos há que não o são e, em tal caso, seria inadmissível a renúncia. Em havendo litisconsórcio, seja qual for, a renúncia, na medida em que cabível, afetará apenas o

direito do renunciante, não atingindo, de modo algum, o dos colitigantes. Quanto à extensão, o autor poderá renunciar no todo ou em parte. Se parcial a renúncia, o processo continuará em relação à parte não renunciada. Quanto às pessoas, é necessário que tenham, pela lei material, a capacidade para renunciar. Embora sejam idênticas, as restrições se aproximam das que afetam a capacidade para o reconhecimento e a transação”.⁹³

Os direitos inerentes ao estado da pessoa e os relativos a alimentos, por serem indisponíveis, não são passíveis de renúncia.

É possível, outrossim, admitir-se renúncia parcial, sobretudo quando houver cumulação objetiva de demandas. Normalmente, um único pedido singulariza uma única demanda. Trata-se, nesse caso, de pedido simples, como, por exemplo, a condenação à restituição do bem reivindicado; a rescisão do contrato de mandato etc. No entanto, norteadas pelos imperativos da economia processual e da harmonia de julgados, inúmeras legislações autorizam a cumulação de pedidos em uma mesma demanda.

O novo CPC brasileiro prescreve no art. 327 que: “É lícita a cumulação, um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”.

Havendo cúmulo de pedidos, o autor pode pretender a procedência de todos eles, ou, então, de pelo menos um dentre aqueles que foram formulados. Daí, a tradicional distinção doutrinária entre cumulação própria, que encerra as hipóteses nas quais é admitido o acolhimento conjunto dos pedidos, e cumulação imprópria, em que, por força de fatores peculiares ao direito material controvertido, a procedência de uma pretensão exclui a das demais.

E, nesta mesma proporção, poderá o autor renunciar a somente um (renúncia parcial), ou, mesmo, a todos os pedidos formulados (renúncia integral).

A renúncia deduzida pelo autor, por outro lado, não produzirá qualquer efeito em relação à reconvenção. Igualmente, se houver renúncia à pretensão formulada pelo réu-reconvinte, o processo prosseguirá em seus termos no que toca apenas à ação do autor.

Ademais, a renúncia não depende da concordância do réu, qualquer que seja a fase em que ela ocorra, podendo ser verificada até mesmo em sede de recurso especial, como se infere do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.011.237-RJ, julgado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, com voto condutor do Ministro Castro Meira: “1. Extinto o processo com resolução de mérito em decorrência da renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação, portanto, de modo favorável à parte ré, ora agravante, não subsiste o recurso especial por ela interposto. 2. Quanto aos honorários, são devidos exclusivamente pelo autor, em razão da renúncia, nos termos do que ficou decidido na sentença, já que não impugnada a verba advocatícia ali fixada por qualquer das partes”.⁹⁴

Seja como for, a exemplo do que ocorre no âmbito do reconhecimento do pedido e da transação, ao julgador, por outro lado, não é vedado examinar a legalidade formal e intrínseca do ato de disponibilidade manifestado pelo autor, podendo inclusive, por meio de ato decisório fundamentado, rejeitar o pleito de homologação da renúncia.

Por fim, é de aduzir-se que, consoante dispõe o art. 90 do CPC, proferida a sentença homologatória, a responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários do patrono constituído pelo réu será imposta ao demandante que renunciou à pretensão.

Sendo parcial a renúncia, a condenação a título de sucumbência será proporcional ao âmbito do ato de disponibilidade praticado pelo requerente (art. 90, § 1.º, CPC).

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Correspondência: art. 249, § 2.º, do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

A regra do art. 488, inspirada no valioso princípio de que não há nulidade sem prejuízo (*pas de nullité sans grief*) e conectada com os arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC/2015, enquadra-se no ideário instrumentalista na perspectiva de que o processo tem por precípua escopo o julgamento de mérito.

Como já observado, ao ensejo da *exegese* do art. 485, a atividade saneadora do juiz é permanente. Assim, antes mesmo de se preocupar com o julgamento de mérito, é necessário examinar se coexistem os pressupostos processuais e as chamadas condições da ação. Todo cuidado é pouco, uma vez que a ausência de um desses requisitos constitui óbice intransponível à resposta estatal alvitada pelas partes.

Reconhecendo o acerto do legislador quanto à precisão do dispositivo ora enfocado, assevera José Roberto dos Santos Bedaque que a sua interpretação extensiva “revela-se perfeitamente adequada e pode estender seu alcance a todas as hipóteses em que algum defeito processual não identificado no momento oportuno, seja ignorado, possibilitando o tão desejado pronunciamento sobre o mérito”.⁹⁵

Suponha-se, por exemplo, que um devedor, entendendo nulo negócio jurídico celebrado com dois cocredores, afora demanda de natureza declaratória apenas em face de um deles. O processo prossegue normalmente, a despeito do vício, e sobrevém julgamento de improcedência do pedido. Descoberto o vício quando não mais possível a desconstituição da decisão, irrompe ela plenamente eficaz, até porque a incidência cega da regra do parágrafo único do art. 115 (litisconsórcio necessário) afronta não só o princípio da economia processual, mas ainda a própria instrumentalidade do processo.⁹⁶

Há situações, pois, que a falta de um pressuposto processual ou qualquer outro defeito formal não prejudica a parte, porque esta, mesmo que inexistisse o vício, “não poderia obter uma tutela jurisdicional mais favorável”.

O art. 282, § 2.º, reproduzindo o art. 249, § 2.º, do CPC/1973, preceitua que não deve ser pronunciada a invalidade se o juiz vislumbrar que proferirá sentença de mérito em favor da parte que se beneficiaria do decreto de nulidade.

É isso que sucede sempre que faltar um pressuposto que protege o interesse do autor, mas o pedido possa ser julgado procedente, e, assim também, sempre que não se encontre preenchido um pressuposto favorável ao réu, mas o juiz possa julgar o pedido improcedente. Em qualquer destas situações, “o tribunal pode conhecer do mérito apesar da ausência do pressuposto processual. Por exemplo: se falta capacidade ao autor, o tribunal pode proferir uma decisão de procedência, porque, mesmo que essa incapacidade fosse sanada, o autor não poderia obter uma tutela mais favorável; ainda que falte o interesse processual e ainda que, portanto, a ação seja inútil, o tribunal pode proferir uma decisão de improcedência, porque essa decisão sobre o mérito é a que melhor protege os interesses do réu demandado. A situação é, no entanto, diferente quando falta um dos pressupostos destinados a acautelar os interesses da parte e o tribunal não pode proferir uma decisão que lhe seja favorável. Admita-se, por exemplo, que o tribunal verifica que o réu é incapaz e que os elementos do processo permitem proferir uma decisão de procedência favorável ao autor; nesta situação, o tribunal não deve julgar o pedido procedente, porque não se encontra preenchido um pressuposto cuja finalidade específica é a proteção dos interesses do réu...”.⁹⁷

Ressalve-se, no entanto, a experiente advertência formulada por Cássio Scarpinella Bueno, no sentido de que a interpretação da norma legal sob análise deve ser cautelosa, a impedir que processos maculados de vício em sua constituição ou em seu desenvolvimento recebam decisões de mérito que possam tisonar as garantias do devido processo legal.

2. Prevalência da decisão de mérito

Já tive oportunidade de frisar, nestes comentários, que qualquer óbice à resolução do mérito constitui circunstância de todo criticável, sobretudo quando o seu exame é relegado para uma fase adiantada do procedimento, pondo a perder atos processuais já aperfeiçoados, mas intrinsecamente viciados.

Note-se que o art. 6.º do novo CPC português (Lei 41/2013), prestigiando esta mesma orientação, institui o denominado “dever de gestão processual”⁹⁸, regido, como se extrai da respectiva exposição de motivos pelo “princípio da prevalência do mérito sobre meras questões de forma”, no sentido de que toda atividade processual é voltada a propiciar a obtenção de decisões que privilegiem o mérito ou a substância sobre a forma, cabendo sanar o vício ou irregularidade, para desimpedir o julgamento do objeto material do processo.

Para tanto, o n. 2 desse art. 6.º estabelece, a seu turno, que o juiz providenciará, mesmo oficiosamente, o suprimento da falta de pressupostos processuais suscetíveis de correção, determinando a realização dos atos necessários à regularização do processo ou, quando for necessária alguma modificação subjetiva, convidará as partes a providenciá-la. Verifica-se claramente que essa atuação judicial *ex officio*, saneadora de defeitos formais, tem por finalidade evitar a prolação de sentenças terminativas para favorecer, desde que possível, a apreciação do mérito.

Explica Fernando Pereira Rodrigues que o denominado princípio da prevalência da decisão de mérito consiste exatamente na faculdade outorgada ao juiz de, *ex officio*, providenciar o afastamento de obstáculos de natureza processual, para poder proferir decisão de fundo e, portanto, resolver a questão de direito submetida à cognição do tribunal.⁹⁹

Nos domínios da doutrina alemã de época contemporânea, a tese que prestigia o julgamento do mérito mesmo quando faltar um dos *Prozessvoraussetzungen* (pressupostos processuais) ou uma das *Zulässigkeitsvoraussetzungen* (condições de admissibilidade) não empolgou os processualistas, sendo sustentada apenas por uma minoria (*Eine Mindermeinung*).¹⁰⁰

Sobre esse tema, não se pode olvidar a existência de dois postulados que, em princípio, são opostos: o da segurança jurídica, exigindo um lapso temporal razoável para a tramitação do processo (“tempo fisiológico”), e o da efetividade deste, reclamando que o momento da decisão de mérito não se procrastine mais do que o tolerável (“tempo patológico”). Obtendo-se um equilíbrio desses dois regramentos – segurança/celeridade –, emergirão as melhores condições para garantir a justiça no caso concreto, sem que, assim, haja diminuição no grau de efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, obtempera Leonardo Greco que o direito processual visa a disciplinar o exercício da jurisdição por meio de princípios e regras em prol da mais ampla efetividade, ou seja, “o maior alcance prático e o menor custo possíveis na proteção concreta dos direitos dos cidadãos. Isso não significa que os fins justificam os meios. Como relação jurídica plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o processo em si mesmo deve formar-se e desenvolver-se com absoluto respeito aos direitos fundamentais de todos os cidadãos, especialmente das partes, de tal modo que a justiça do seu resultado possa ser alcançada pela adoção das regras mais propícias à ampla e equilibrada participação dos interessados, à isenta e adequada cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: um meio justo para um fim justo”.¹⁰¹

A tal propósito, lembro que Barbosa Moreira, de forma enfática, procurou sintetizar o desejo de todos os operadores do direito e, de modo particular, dos jurisdicionados, no sentido de que a prestação jurisdicional venha a ser mais eficiente do que realmente é; no entanto, “se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer preço!”¹⁰²

Omnia tempus habent (tudo tem seu tempo)!

3. Aplicação da regra legal

A adequada incidência do art. 488 exige exame das circunstâncias e peculiaridades da hipótese concreta, a fim de que possa ser aferido se o defeito que ensejaria a extinção do processo sem julgamento de mérito é passível de superação. Apenas nessa circunstância, “desde que possível”, ou seja, sem produzir qualquer prejuízo à parte contrária, é que então se abre a oportunidade para o proferimento de sentença definitiva.¹⁰³

Recordo que, verificada qualquer uma das situações anormais que implicam o indeferimento da petição inicial (art. 330), o juiz deverá determinar que o autor, no prazo de 15 dias, supra o vício (art. 321 e parágrafo único).

Descarta-se desse rol a incompetência absoluta, uma vez que em tal hipótese torna-se impossível o exame da lide, não admitindo-se cogitar de ausência de prejuízo. Nesta situação, “porque destinada a assegurar interesse do próprio Estado, não das partes, inadmissíveis a desconsideração do vício e o julgamento do mérito”.¹⁰⁴

Seção II

Dos elementos e dos efeitos da sentença

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I – o relatório, que conterà os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2.º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3.º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Correspondência: art. 458 do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 454 e 455 do NCPC francês, art. 132 do CPC italiano, art. 209 da LEC

espanhola, art. 607 do CPC português, § 313 do ZPO alemão, art. 238 do SZO suíço, art. 780 do CJ belga

1. Aspectos gerais

As legislações processuais de época contemporânea, de modo praticamente generalizado, estabelecem os requisitos estruturantes da sentença.¹⁰⁵ Como ato de vontade, a sentença (as decisões interlocutórias de mérito e, evidentemente, os acórdãos) deverá ser construída a partir de um modelo lógico-formal, contendo o relatório, a motivação e o dispositivo.

Esse modelo vem estabelecido, expressamente, no art. 489, I a III, do CPC.

2. Relatório

O relatório, como o próprio nome indica, destaca-se no preâmbulo da sentença, no qual o juiz deve consignar, além da identificação das partes e da natureza da demanda, o cerne das respectivas postulações, a síntese do objeto litigioso, com a especificação do pedido, o relato de eventuais incidentes, o resumo das provas porventura produzidas e tudo o mais que for reputado pertinente para a compreensão da controvérsia.

No desenvolvimento do relatório, o juiz apenas expõe todos os pontos mais relevantes do processo, não devendo emitir qualquer juízo de valor ou enfrentar alguma questão controvertida.

Não é possível aprioristicamente sugerir qual o conteúdo ideal do relatório. Depende sempre da experiência, disposição e do zelo do juiz e, ainda, do estilo adotado na narração dos episódios do processo. Relatórios longos são sempre desaconselháveis. A descrição objetiva e simplificada, contendo o necessário, será sem dúvida a melhor opção.

3. Motivação

3.1. Garantia constitucional da motivação

O dever de motivação dos atos decisórios está consagrado, pela lei e pela moderna doutrina processual, na esfera dos direitos fundamentais, como pressuposto do direito de defesa e da imparcialidade e independência do juiz.

Assinala, a propósito, Barbosa Moreira, que o pronunciamento judicial, destinado a firmar a inteireza da ordem jurídica, deve estar baseado no direito vigente; “e é preciso que esse fundamento se manifeste, para que se possa saber se o império da lei foi na verdade assegurado. A não ser assim, a garantia torna-se ilusória: caso se reconheça ao julgador a faculdade de silenciar os motivos pelos quais concede ou rejeita a proteção na forma pleiteada, nenhuma certeza pode haver de que o mecanismo assecuratório está funcionando corretamente, está deveras preenchendo a finalidade para a qual foi criado”.¹⁰⁶

Com efeito, considerando a dimensão de seu significado jurídico-político, desponta, na atualidade, a necessidade de controle (extraprocessual) “generalizado” e “difuso” sobre o *modus operandi* do juiz no tocante à administração da justiça. E isso implica, como bem observa Taruffo, que “os destinatários da motivação não são somente as partes, os seus advogados e o juiz da impugnação, mas também a opinião pública entendida em seu complexo, como opinião *quisque de populo*”.¹⁰⁷

Daí, porque, a exemplo da publicidade dos atos processuais, o dever de motivação dos atos decisórios vir catalogado entre as garantias do devido processo legal, estabelecidas nas Constituições democráticas, com a primordial finalidade de assegurar a transparência das relações dos jurisdicionados perante o poder estatal e, em particular, nas circunstâncias em que é exigida a prestação jurisdicional.¹⁰⁸

Vittorio Colesanti, com idêntico raciocínio, entende ser oportuno afirmar “que a garantia da motivação representa a derradeira manifestação do contraditório, no sentido de que o dever

imposto ao juiz de enunciar os fundamentos de seu convencimento traduz-se no de considerar os resultados do contraditório e, ao mesmo tempo, de certificar que o *iter* procedimental se desenvolveu mediante a marca da (possível) participação dos interessados”.¹⁰⁹

Embora a garantia do dever de motivação não tenha sido inserida no rol dos *Direitos e Garantias Fundamentais*, o legislador constituinte brasileiro a situou nas disposições gerais atinentes ao Poder Judiciário. Seja como for, foi ela contemplada na Constituição Federal em vigor como autêntica garantia processual.¹¹⁰

3.2. Significado e conteúdo da motivação

Findo o relatório, o juiz passará a externar a justificação de seu convencimento na motivação do *decisum*. É precisamente na fundamentação da sentença que o juiz examinará as questões de fato e de direito, fixando com tais premissas, a conclusão que se projetará na parte dispositiva.

Os fundamentos ou motivos dos atos decisórios em geral pressupõem um labor intelectual, de conteúdo crítico, lógico e metalógico (intuitivo), que engloba um conjunto de reflexões de fato e de direito do qual o juiz extrai o julgamento.

A exteriorização das razões de decidir revela, desse modo, o prisma pelo qual o juiz interpretou a lei e os fatos da causa, devendo aquelas, conseqüentemente, vir expostas com clareza, lógica e precisão, visando à perfeita compreensão de todos os pontos controvertidos, bem como do resultado da demanda.¹¹¹

Assim, com a exposição criteriosa dos elementos fáticos e do direito, na análise das questões preliminares e prejudiciais, sejam de natureza processual, sejam de ordem substancial e, quando possível, do exame acerca do mérito, o magistrado apresenta os motivos determinantes da decisão.

A despeito de não ter traçado a distinção entre as espécies de provimentos decisórios, a novel legislação, no que respeita o dever de motivação, a exemplo do regime anteriormente adotado, preocupa-se mais com a forma do que com o conteúdo.

O CPC, ao estabelecer os elementos essenciais da sentença, não repetiu a regra do art. 165 do diploma revogado, que, para os demais pronunciamentos judiciais, autorizava expressamente fundamentação mais concisa. A locução “demais decisões” englobava, em princípio, as interlocutórias e as sentenças ou acórdãos terminativos.¹¹²

Não obstante, não é preciso prescrever que, de fato, as decisões menos relevantes, proferidas no curso do processo, admitem motivação mais singela. Esta possibilidade, contudo, não significa ausência de fundamentação, mas, sim, motivação suficiente na medida da importância do *thema decidendum*, considerando-se, sempre, a situação concreta.

É de entender-se, portanto, que as decisões interlocutórias, as sentenças terminativas (i.e., “sem resolução do mérito”), os acórdãos interlocutórios e, ainda, as decisões monocráticas que admitem ou negam seguimento a recurso, comportam fundamentação mais singela, sem embargo da excepcional possibilidade de o juiz ou tribunal deparar-se com episódio que imponha motivação complexa.

As sentenças e os acórdãos definitivos (i.e., “com resolução do mérito”) devem preencher, rigorosamente, a moldura traçada no art. 489, ou seja, conter, no plano estrutural, os elementos essenciais neste exigidos.

Partindo-se, pois, da regra geral insculpida no art. 11, fácil é concluir que, a rigor, o CPC não admite pronunciamento judicial, de natureza decisória, despida de adequada fundamentação.

Reproduzindo, portanto, o disposto no art. 458, II, do antigo diploma processual, o novo impõe o dever de motivação como pressuposto de validade dos atos decisórios.

De resto, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial generalizado, prestigiando o

citado mandamento constitucional, a falta de exteriorização da *ratio decidendi* do pronunciamento judicial acarreta a sua invalidade. E nulas, do mesmo modo, serão as decisões administrativas dos tribunais, sempre que não fundamentadas, aplicando-se-lhes a cominação prevista no inc. IX do art. 93 da Constituição Federal e expressamente reiterada no já apontado art. 11 do CPC.

Resulta, ainda, importante esclarecer que o art. 10 veda, com todas as letras, o “fundamento surpresa”, ao estabelecer que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Essa regra robustece o princípio do contraditório ao assimilar a moderna exigência de cooperação entre os protagonistas do processo.¹¹³

Como escreve, a respeito, Daniel Mitidiero, nos domínios de um processo estruturado a partir da necessidade de colaboração, torna-se absolutamente indispensável que as partes tenham a possibilidade de manifestação sobre todos os aspectos da causa que possam servir de alicerce para a decisão, “inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício”.¹¹⁴

É evidente que essa importante premissa não se aplica nas situações em que o réu ainda não foi citado. Com efeito, não se entrevê qualquer antinomia entre o enunciado dos preceitos acima mencionados e a regra do art. 332, que continua autorizando a rejeição liminar da petição inicial, até mesmo antes da citação.

Ademais, sob diferente enfoque, o texto legal sancionado revela acentuada preocupação com o dever de motivação das sentenças em hipóteses pontuais. Mesmo preferindo incorrer em inescandível redundância, o legislador procurou ser incisivo, para deixar bem claro que, em determinadas ocasiões mais delicadas, o juiz deve estar atento para fundamentar os seus respectivos atos decisórios.

Vale destacar, nessa linha argumentativa, o disposto no art. 373, II, § 1.º, assim redigido: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do *caput* ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Observa-se aí situação típica de decisão interlocutória que impõe motivação mais elaborada, não sendo suficiente, em tese, aquela concisão típica dessa categoria de provimento judicial. Diante desta hipótese, o julgador terá de enfrentar “*as peculiaridades da causa*”, declinando as razões que o convenceram a determinar a inversão do ônus subjetivo da prova, legalmente distribuído nos incisos I e II do art. 373 do CPC.

Fundamentação complexa ou, no mínimo, mais trabalhada, também vem exigida pela regra do art. 298, *in verbis* : “Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso”.

Entende-se perfeitamente a *mens legislatoris* . É que, nestas situações, em princípio, o provimento jurisdicional, mesmo que reversível, poderá acarretar sérias e imediatas consequências na esfera de direitos da parte contra a qual aquele foi deferido.

3.3. Escopos da motivação

A motivação da sentença, concebida como um “ensaio de persuasão”,¹¹⁵ tem por fim imediato demonstrar ao próprio órgão jurisdicional, antes mesmo do que às partes, a *ratio scripta* que legitima o decisório, cujo teor se encontrava projetado em seu raciocínio. O juiz, portanto, é o primeiro destinatário da motivação.

Quanto ao aspecto subjetivo, visa ainda a motivação a persuadir o litigante sucumbente, mostrando-lhe que o resultado do processo não é fruto de sorte ou capricho, mas de verdadeira

atuação da lei. E isto porque, consoante precisa observação de Calamandrei, “o homem tem sentido a necessidade, para aceitar a justiça dos homens, de razões humanas”, sendo que a fundamentação constitui, pois, aquela parte da sentença que se presta a demonstrar que o julgamento é justo e por que é justo. ¹¹⁶

Sob o ponto de vista técnico, a alusão às razões de decidir, por outro lado, importa permitir o controle crítico da sentença, para a exata determinação do conteúdo da vontade do juiz e, conseqüentemente, para a verificação dos limites do julgado.

A motivação revela, sob esse prisma, eventual falha cometida pelo magistrado. Constitui, por isso – como aduz Calamandrei – relevante garantia de justiça, quando logra reproduzir fielmente, como num trabalho topográfico, o *iter* lógico que o juiz percorreu para encontrar o *decisum*, porquanto se estiver equivocado, é possível aferir-se, nas razões, em que altura do percurso o seu autor se desgovernou. ¹¹⁷

Como é de observar-se, somente tendo ciência dos fundamentos do decidido é que o interessado poderá interpor recurso de modo adequado. Assim também, nesse caso, o órgão *ad quem* pode controlar com maior rigor a legalidade e a justiça dos atos decisórios submetidos a reexame. ¹¹⁸

A motivação da sentença, ainda no plano técnico, resulta deveras importante como fator de uniformização da jurisprudência, servindo de tal sorte como valioso subsídio a todos os operadores do direito que contribuem para o aprimoramento e a aplicação do direito.

Além destas finalidades de conotação endoprocessual, firmou-se o entendimento de que o problema da justificação do dever de motivar coloca-se, como acima enfatizado, no quadro dos direitos fundamentais, “que devem presidir a disciplina da atividade estatal, *in genere*, e da atividade jurisdicional, *in specie*”. ¹¹⁹

Trata-se, no dizer de Barbosa Moreira, de conferir garantia ao direito que têm as partes de ser ouvidas e de ver apreciadas pelo Poder Judiciário as questões por elas suscitadas. ¹²⁰

Não só as partes, mas, igualmente, a sociedade é destinatária da fundamentação das decisões judiciais. Para que aquelas e esta entendam, na verdade, as sentenças, não as sintam como um corpo estranho, como um ato autoritário, como palavra de oráculo, importa que elas – as decisões – articulem-se de forma lógica, apoiem-se em processos discursivos válidos para todos. “Só assim racionalizada, motivada, a sentença realiza aquela altíssima função de procurar, ao menos ‘convencer’ as partes e a sociedade de sua justiça. É a própria ideia de função que exige que a decisão judicial não constitui puro arbítrio, que não é indiferente à coerência e ao raciocínio lógico, mas que procurou atingir a certeza por caminhos discursivos, válidos para todos”. ¹²¹

A motivação da sentença, pois, propicia formidável vetor de controle externo da atividade jurisdicional.

3.4. Decisões consideradas nulas por defeito de motivação

Acrescente-se, ainda, que, por outra perspectiva, o novo CPC contém original e importante regra no § 1.º do art. 489, que arrola determinadas situações – frequentes, diga-se de passagem –, nas quais a própria lei se adianta, antevendo ofensa ao disposto no inc. II do dispositivo ora comentado, que impõe fundamentação. Desse modo, preocupado ainda uma vez com o mandamento constitucional do dever de motivação, o novel diploma, de forma até pedagógica, estabelece os vícios mais comuns que comprometem a higidez do ato decisório, “seja ele interlocutório, sentença ou acórdão”.

Entidades de classe, contudo, como a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e a Associação dos Juizes Federais do Brasil – Ajufe, manifestaram-se contrárias à sanção desse dispositivo. Em resposta às críticas recebidas por parcela da doutrina, a Anamatra divulgou nota em que sintetiza do seguinte modo o seu inconformismo com os novos deveres de fundamentação a serem impostos aos

magistrados. Como asseverou tal Associação, a entrada em vigor dessa norma comprometeria a independência funcional dos juízes, prejudicaria a duração razoável do processo, restringiria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e tornaria vinculantes súmulas, teses e orientações jurisprudenciais, o que só o texto constitucional, segundo afirma, poderia realizar. Em sentido semelhante, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, João Ricardo Costa, afirmou que o dever imposto aos magistrados de analisar e justificar todas as alegações suscitadas pelas partes acabaria por burocratizar o processo e impediria o juiz de se valer de fundamentos outros que não aqueles suscitados pelos litigantes.

Pelo que representa em termos de respeito às prerrogativas individuais, afinal, a garantia do acesso a justiça só poderá ser considerada atendida se, a rigor, as alegações das partes forem levadas em consideração pelos juízes; e, ainda, pela inestimável contribuição proveniente de decisões jurídicas mais justas, porque mais pertinentes às características de cada caso. Não é exagero afirmar que o art. 489, tão atacado pelas entidades de magistrados, constitui uma das principais inovações do novo CPC, o que me estimula, portanto, a rebater as objeções contrárias à sua elogiável redação.

Na verdade, as aludidas novas determinações legais acerca do dever de motivação, inseridas no CPC aprovado, reforçam a ideia de que a moderna concepção de “processo justo” não compadece qualquer resquício de discricionariedade judicial, até porque, longe de ser simplesmente “*la bouche de la loi*”, o juiz proativo de época moderna deve estar comprometido e enviaar esforço, tanto quanto possível, para a observância, assegurada aos litigantes, da garantia do devido processo legal!¹²²

3.4.1. Nulidade decorrente de mera reprodução de fundamento legal (art. 489, § 1.º, I)

Não atenderá ao requisito de motivação suficiente o pronunciamento judicial que simplesmente reproduz texto legal, deixando de interpretá-lo à luz da controvérsia que se apresenta ao julgador. O processo hermenêutico de subsunção é imprescindível para que, de um lado, possa ser adequadamente interpretada a convicção do julgador e, ainda, de outro, ser feito o controle crítico do ato decisório.

Considerando, pois, a previsão normativa ora focada, é ainda válida – apenas para esse fim – lançar mão da ideia de que, sob o ponto de vista formal, a sentença pode ser equiparada a um silogismo, sendo a premissa maior a lei; a menor, o contexto fático-jurídico; e, por fim, a conclusão explicitada no dispositivo.

3.4.2. Nulidade decorrente da fundamentação genérica em “conceitos jurídicos indeterminados” (art. 489, § 1.º, II)

Mas não é só. O art. 489, § 1.º, II, do CPC, nas hipóteses de incidência de conceitos (*rectius* : termos¹²³) indeterminados – e, por certo, de cláusulas gerais e princípios jurídicos –, exige a exposição de raciocínio hermenêutico-axiológico mais pormenorizado, embasado muitas vezes pelo recurso à ponderação, para justificar a escolha, dentre as opções possíveis (lembre-se do juiz Hércules na problemática alvitada por Dworkin), daquela mais adequada para a situação concreta.

A esse respeito, escrevi, anos atrás, que o “novo Código Civil agasalhou expressamente, nos arts. 113, 421 e 422, o princípio da boa-fé objetiva. Cumpre notar, todavia, que, antes da posituação desse regramento, impunha-se ao julgador que o acolhia extensa motivação da sentença para justificar a adoção de preceito não contemplado em nosso ordenamento jurídico”.¹²⁴ Assim, por exemplo, quando o juiz se norteia pelo princípio da proporcionalidade, tem ele o mister de explicitar, tanto quando possível de forma objetiva, a razão pela qual aquele fundamento, nas fronteiras do caso concreto, determina a procedência ou improcedência do pedido.

3.4.3. Nulidade decorrente de fundamentação padronizada (art. 489, § 1.º, III)

No mesmo sentido, já agora a teor do art. 489, § 1.º, III, ao juiz é vedado valer-se de pseudofundamentação, vale dizer, “fundamentação artificial”, aparentemente padronizada, apta a justificar qualquer ato decisório.

Se de fato essa norma legal vingar, desde que observada com rigor, verifica-se facilmente que inúmeros provimentos judiciais, frequentes em nossa atual praxe judiciária, estarão eivados de inequívoca nulidade.

O paradigma mais típico desse criticável modelo de decisão descortina-se aquele que, há muitos anos, inadmite recursos especial ou extraordinário, no âmbito de competência do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em regra, tal ato decisório monocrático, de todo abstrato e lacunoso, emerge totalmente divorciado dos autos, fazendo até crer que, a rigor, não foram examinadas as razões deduzidas na respectiva impugnação.

No que toca, por exemplo, à interposição de recurso especial, com fundamento na violação à disposição de lei federal (art. 105, III, *a*, CF), afirmar, simplesmente, em inúmeras decisões padronizadas, que se “observa não ter sido demonstrada sua ocorrência, eis que as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão”, não é motivar; é, na verdade, apenas dissimular fundamentação.

Deparando-se com decisão idêntica a essa, a 2.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em expressivo pronunciamento, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1.264.053, proveniente do Tribunal de Justiça bandeirante, teve oportunidade de decidir que: “1. A matéria agitada no recurso especial, cuja caminhada foi obstada, merece ser reapreciada no âmbito desta Corte de Justiça. Diante disso, necessário se faz determinar a subida do recurso especial, sem prejuízo do juízo de admissibilidade definitivo que será oportunamente realizado neste Tribunal. 2. Ademais, o despacho de admissibilidade negativo, exercido pelo Tribunal de origem, é extremamente genérico. Este fato, por si só, prejudica o exercício do direito de defesa da parte, que fica impossibilitada de compreender quais os pontos específicos que obstaram a subida do apelo (...)”. De aduzir-se que, no corpo desse importantíssimo aresto, de relatoria do Ministro Humberto Martins, lê-se que: “(...) Por fim, não custa lembrar que quando o Tribunal de origem afirma que os fundamentos do recurso especial não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, ele acaba por adentrar na questão de fundo e a exercer juízo de valor que compete a esta Corte Superior”.¹²⁵

Igualmente, serão, ainda, “reprovados” alguns atos decisórios do Superior Tribunal de Justiça, visto que, à guisa de fundamentação, reportam-se ou simplesmente transcrevem a ementa de precedentes.

Vigente o novo CPC, estarão, também, acoimadas de inarredável nulidade decisões que forem lançadas com a seguinte matriz: “(...) Trata-se de recurso especial no qual se alega ofensa a dispositivos de lei federal e dissídio jurisprudencial. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Quanto à alegada vulneração aos dispositivos arrolados, observe-se não ter sido demonstrada sua ocorrência, eis que as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão. Ademais, o acórdão, ao decidir da forma impugnada, assim o fez em decorrência de convicção formada pela Turma Julgadora diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, sendo certo, por esse prisma, aterem-se as razões do recurso a uma perspectiva de reexame desses elementos. A esse objetivo, todavia, não se presta o reclamo, a teor do disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, suficiente para obstar o seguimento do recurso, quer pela alínea *a*, quer pela alínea *c* do permissivo constitucional. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial (...)”.

Simplesmente incrível: o que o permissivo da alínea *c* tem a ver com o enunciado da Súmula 7/STJ?

3.4.4. Nulidade decorrente de motivação insuficiente (art. 489, § 1.º, IV)

Tenha-se, outrossim, presente que a primeira parte do art. 141 do CPC preceitua que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (...)”, ou seja, terá de ser enfrentada toda a argumentação, de direito e de fato, expendida pelas partes.

Caso contrário, vale dizer, se a sentença deixar de considerar alguma questão, que potencialmente poderia ensejar diferente desfecho do processo, não será suficiente a respectiva *ratio decidendi*, porque conterá vício que inquina de nulidade o ato decisório.

Expressivo precedente da 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 47.169-MG, cujo voto condutor é da lavra do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou ser “nula a sentença que omite questão central posta na contestação”.¹²⁶

Assim, para que a motivação atenda às exigências legais, deverá abordar toda a matéria suscitada pelos litigantes, desde que juridicamente relevante para justificar a decisão. É evidente que, pela perspectiva lógica, não será necessário enfrentar os argumentos cuja apreciação estiver prejudicada pelo acolhimento de determinada preliminar. Desse modo, se, por exemplo, for acolhida a arguição de prescrição, o juiz não estará obrigado a examinar e decidir outras questões controvertidas que foram deduzidas pelas partes. Nesta hipótese, a sentença não poderá ser considerada viciada.

3.4.5. Nulidade decorrente de invocação impertinente de súmula ou precedente (art. 489, § 1.º, V)

A hipótese do inc. V reitera o que já está, de certo modo, previsto no precedente art. 489, § 1.º, III. Coíbe-se aqui a mera referência a súmula ou precedente judicial no corpo da sentença, sem que o juiz demonstre, de forma cabal, a sua pertinência com o objeto da controvérsia.

Em perfeita simetria com esta regra, dispõe o § 1.º do art. 927 que, na dinâmica da observância das decisões arroladas em seus vários incisos, os juízes e tribunais deverão considerar as regras dos arts. 10 e 489, § 1.º, isto é, ressaltar que a súmula ou precedente invocado se identifica com o cerne da tese debatida no processo.

Daí, porque, o juiz ou tribunal não poderá fundamentar o seu respectivo *decisum* baseando-se exclusivamente em precedentes pronunciamentos pretorianos, sem qualquer argumentação adicional, deixando de revelar fundamentação própria, conexa com o objeto do processo sob julgamento.

3.4.6. Nulidade decorrente do desrespeito injustificado a súmula, jurisprudência ou precedente (art. 489, § 1.º, VI)

Por fim, nota-se que o art. 489, § 1.º, VI, é vocacionado à proteção da confiança, quando impede que o juiz, ao proferir a sentença, despreze súmula ou precedente, colacionado como reforço argumentativo por uma das partes, não tomando o cuidado de explicar que o julgado paradigma não se aplica ao caso concreto, ou mesmo, que já se encontra superado pela obsolescência.

Entendo que, por força do importante aforismo, *iura novit curia*, mesmo que a tese jurisprudencial, embora relevante, não seja invocada pela parte interessada, a decisão desponta eivada de nulidade, se o juiz desprezá-la de forma injustificada.

Colocando de lado a polêmica acerca da natureza ontológica dos precedentes judiciais, quanto a ser ou não fonte primária de direito, Robert Alexy, em obra específica sobre argumentação jurídica, anota que a primordial justificação da utilização pragmática dos precedentes é ditada pelo “princípio da universalidade” ou da justiça formal, que impõe um tratamento isonômico para situações iguais.

A conciliação entre justiça e universalidade – segundo o referido jurista – pode ser alcançada, em regra, por meio da observância dos precedentes, sem embargo de admitir-se o abandono de

uma determinada orientação pretoriana, desde que sobrevenham justificadas razões. E, ocorrendo esta hipótese, o ônus da argumentação deve ser imposto ao órgão judicial que pretenda afastar-se do precedente. Alexy entende que, nesse particular, o princípio da inércia de Perelman é adequado, com sua exigência de que uma decisão só pode ser alterada se razões suficientes puderem ser aduzidas para tanto.¹²⁷

Ao preservar a estabilidade, aplicando o precedente nas situações sucessivas análogas, os tribunais contribuem, a um só tempo, para infundir a certeza jurídica e para reiterar a proteção da confiança na escolha do caminho trilhado pela decisão judicial.

Em conclusão, Alexy formula duas regras gerais do discurso jurídico para a utilização da jurisprudência dominante, a saber: *a*) quando vier invocado um precedente a favor de ou contra uma decisão, ele deve, em princípio, ser seguido; e *b*) quem pretender se afastar de um precedente, tem o ônus da justificação.¹²⁸

Conclui-se, pois, que, nos termos do analisado inc. VI do § 1.º do art. 489, configurando-se a hipótese aí prevista, o tribunal tem o ônus de justificar que a súmula ou precedente invocado pela parte não tem incidência no caso concreto.

3.4.7. Nulidade decorrente de motivação aliunde ou per relationem

Ressalte-se que esta hipótese continua sem previsão legal expressa, embora facilmente inferida do sistema adotado pelo CPC.

Os motivos do julgamento devem ser declinados de modo explícito, uma vez que constitui função própria e exclusiva do juiz da causa a de interpretar a lei, aplicá-la aos fatos da causa e, em conclusão, proferir a decisão.

Assim, como já tive oportunidade de afirmar¹²⁹, deixará de cumprir o seu dever funcional o julgador que se limitar a decidir, sem revelar como interpretou e aplicou a lei ao caso concreto, ou, mesmo, a fazer simples remissão a fundamentos expendidos em razões, pareceres, decisões, ou seja, em atos processuais produzidos em outro processo (motivação *aliunde*).

O art. 663 do atual CPC português, seguindo tendência já adotada no art. 15 do Decreto-lei 108/2006, autoriza ao tribunal, à guisa de motivação, simplesmente invocar precedente judicial que já tenha apreciado a matéria, juntando cópia da íntegra do respectivo acórdão. A doutrina, contudo, levanta dúvida sobre a constitucionalidade desta regra, que se apresenta como verdadeiro obstáculo a que as partes acompanhem o itinerário racional do pronunciamento judicial diante da questão concreta.¹³⁰

Observe que o novo diploma brasileiro, a esse respeito, perdeu a oportunidade de repudiar o disparatado permissivo, de motivação *per relationem*, constante do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim redigido: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Há, nessa indesejável técnica, manifesta ofensa à garantia consagrada no art. 93, IX, da Constituição Federal, embora (de certo modo) abonada pelo Superior Tribunal de Justiça.¹³¹

3.5. Exigência de justificação na hipótese de colisão de normas (art. 489, § 2.º)

Ao ensejo da prolação da sentença, em algumas circunstâncias específicas, o juiz terá de enfrentar o problema do conflito ou colisão de normas incidentes no caso concreto. Geralmente, considerando-se a hierarquia das leis, se houver incompatibilidade entre dois textos legais (antinomia), a questão pode ser resolvida à luz de três critérios hermenêuticos, quais sejam: *a*) o cronológico (*lex posterior derogat priori*); *b*) o hierárquico (*lex superior derogat inferiori*); e, ainda, *c*) o da especialidade (*lex specialis derogat generali*).

Todavia, a colisão de princípios, que se torna sempre mais intrincada e difícil, deve ser dirimida pela dimensão de peso e importância, aplicando-se o princípio da proporcionalidade.

Desse modo, assinala, com precisão, Leonardo Carneiro da Cunha,¹³² ocorrendo embate de princípios, sempre será necessário que o juiz esclareça, na fundamentação de sua decisão, qual o caminho para a solução do problema, “justificando a razão da utilização de determinado princípio em detrimento de outro, a capacidade de ponderação das normas envolvidas, os critérios gerais empregados para definir o peso e a prevalência de uma norma sobre a outra e a relação existente entre esses critérios, o procedimento e o método que serviram de avaliação e comprovação do grau de promoção de uma norma e grau de restrição da outra, bem como os fatos considerados relevantes para a ponderação e com base em que critérios eles foram juridicamente avaliados”.

3.6. Consequências da sentença considerada desmotivada

A própria lei – art. 93, IX, da CF – determina, de modo expresse, que a desatenção ao disposto no art. 489, II, do CPC, implica nulidade do pronunciamento judicial.

Cuidando desse tema, há alguns anos, afirmei que a ausência ou insuficiência de motivação, por ferir norma cogente, enseja a nulidade absoluta da sentença.¹³³

Todavia, com o declarado escopo de imprimir maior celeridade processual, sem desprezar as garantias do devido processo legal, o novo art. 1.013, § 3.º, reproduz a orientação do antigo § 3.º ao art. 515 do CPC/1973, autorizando, com todas as letras, o tribunal a proferir julgamento do mérito, desde que seja possível, mesmo quando reconhecer a carência de motivação. Nesse caso, passa a incidir, pois, a regra da convalidação prevista no art. 277 do CPC/2015.¹³⁴

Dispõe, a propósito, o inc. IV do § 3.º do art. 1.013: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada: (...) § 3.º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação”.

Dando ênfase à instrumentalidade, sob a égide do CPC em vigor, continua ampliada a extensão do efeito devolutivo da apelação, permitindo que o juízo recursal extravase o âmbito do dispositivo da sentença de primeiro grau e, por via de consequência, o objeto da impugnação.

Com isso, a apelação, regradada na novel codificação, deixa de ter natureza de *revisio prioris instantiae* e passa a ser concebida como um *novum iudicium*, no qual ao órgão jurisdicional superior é lícito o mais amplo reexame da causa, em todos os seus aspectos de fato e de direito, de modo a julgá-la *ex novo*: “tem-se, então, na consagrada expressão de Binding, uma *Zweite Erstinstanz*” (segunda primeira instância).¹³⁵

Devolvida a cognição da controvérsia ao tribunal *ad quem*, a causa poderá ser julgada pelo mérito em segundo grau. Bastará, para tanto, que o *thema decidendum* tenha necessária e efetivamente sido debatido sob o crivo do contraditório e que – na dicção do texto legal – esteja “em condições de imediato julgamento” (art. 1.013, § 3.º), isto é, não exija a produção de qualquer outra prova.

Seja como for, com a orientação que agora vem ainda mais dilatada, o recurso de apelação perde a sua função substitutiva, tendo-se em vista que nem sempre o novo julgamento se identificará com o objeto da sentença recorrida.

Não é preciso dizer que, caso não tenha sido conferida oportunidade para o réu se manifestar sobre questão não examinada em primeiro grau, dúvida não pode haver de que esta técnica do julgamento da apelação, acolhida no art. 1.013 do CPC, vulnera o princípio fundamental do *due process of law*. Habilitando o tribunal a proferir decisão acerca de tema que não foi objeto de debate no procedimento recursal, a referida regra afrontaria direito das partes, sobretudo do litigante que vier a experimentar derrota.

E evidente, pois, que a citada regra processual não deverá ser aplicada quando inviável o “julgamento imediato”. Nesse caso, decretada a nulidade da sentença por falta de motivação, os autos serão remetidos ao juízo de primeiro grau para que outra decisão seja proferida.

4. Dispositivo

O epílogo da sentença, denominado “dispositivo”, é o elemento mais importante do pronunciamento judicial. É aquele no qual o Estado, exteriorizando a vontade da lei, declara a tutela jurisdicional invocada pelos demandantes.

Neste seguimento final da decisão, “o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem” (art. 489, III), apresentando a conclusão das operações lógicas desenvolvidas na motivação. Tratando-se de sentença de natureza definitiva, é no dispositivo que “O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes” (art. 490).

Enquanto a ausência ou a insuficiência da motivação acarreta a nulidade da sentença, a falta de dispositivo implica inexistência do ato decisório.

Cumprir registrar que, em certas situações, diante da complexidade da demanda, torna-se difícil delimitar a motivação e a parte dispositiva da sentença, uma vez que, encerrado o relatório, poderá haver decisões atinentes a questões prévias, que não se encontram propriamente no dispositivo.

O dispositivo, outrossim, pode conter vários capítulos dependendo da amplitude das questões controvertidas, vale dizer, capítulos de natureza processual, aqueles que se pronunciam sobre a possibilidade do exame do mérito (presença ou ausência dos requisitos de admissibilidade do julgamento de mérito), e aqueles que concernem ao próprio objeto litigioso do processo, em especial, à antecipação da tutela.

A cisão lógica do dispositivo de uma decisão judicial em capítulos “é de extrema utilidade, porque repercute nos mais variados temas do direito processual, tal como na atribuição do custo financeiro do processo, na teoria dos recursos, na liquidação e efetivação das decisões que certificam direito a uma prestação e na própria teoria da decisão judicial”. ¹³⁶

Permito-me, nesse particular, chamar a atenção para a imprescindível importância da interpretação da sentença.

5. Interpretação da sentença a partir do princípio da boa-fé

O art. 489, § 3.º, ora comentado, dispõe que a interpretação da decisão judicial deve considerar todos os seus elementos e ser governada pela boa-fé.

É de Kelsen a exortação no sentido de que a interpretação é necessária à aplicação de toda e qualquer norma jurídica, incluindo-se “as normas individuais, *de sentenças judiciais*, de ordens administrativas, de negócios jurídicos...”. ¹³⁷

A exegese de um ato decisório constitui uma operação mental que visa a compreender o seu sentido intrínseco. Esse processo intelectual deve, pois, responder qual a vontade da norma individualizada e a sua respectiva extensão no mundo fático.

Como todo texto escrito – segundo precisa colocação de Dinamarco –, “a sentença ou acórdão é composto de palavras, que são símbolos convencionais pelos quais o redator procura expressar ideias. Para captar-lhe o significado e intenção, é indispensável buscar o significado desses símbolos e a ideia que eles expressam, seja isoladamente, seja no contexto da redação. Tanto quanto a lei, a sentença precisa sempre ser interpretada. Intérpretes das sentenças são o próprio vencedor e o vencido, os tribunais que julgam recursos interpostos contra elas, ações rescisórias etc., bem como o juiz que dirige sua liquidação em busca do alcance quantitativo das decisões e aquele que comanda a execução (...)”. ¹³⁸

Em tema de exegese da sentença ou do acórdão, não interpreta-se o dispositivo de forma isolada, dissociada dos fundamentos de decidir. O julgado, antes de tudo, é um texto que deve ser interpretado de forma que suas premissas se mostrem, o mais possível, um conjunto coerente e harmonioso, inclusive com eventuais decisões anteriores proferidas ao longo do processo.

Enfrentando essa mesma questão de hermenêutica, expressivo aresto do Supremo Tribunal de Justiça português, no julgamento do Recurso de Revista 356/02, decidiu que “a interpretação das sentenças obedece às regras da interpretação dos negócios jurídicos”, firme na seguinte argumentação: “para interpretarmos corretamente a parte decisória de uma sentença temos de analisar os seus antecedentes lógicos que a tornam possível e a pressupõem, dada a sua íntima interdependência. A interpretação da sentença exige, assim, que se tome em consideração a fundamentação e a parte dispositiva, fatores básicos da sua estrutura. De realçar, ainda, que, embora o objeto da interpretação seja a própria sentença, a verdade é que nessa tarefa interpretativa há que ter em conta outras ‘circunstâncias’, que funcionam como ‘meios auxiliares de interpretação’, na medida em que daí se possa retirar ‘uma conclusão sobre o sentido’ que se lhe quis emprestar (...)”.

Sobre esta temática, como se observa, há entendimento uníssono, no sentido de que, para a interpretação das decisões, o método sistemático é o mais indicado, segundo o qual os argumentos expendidos, especialmente na motivação do pronunciamento, têm como finalidade última tornar compreensíveis os horizontes da parte dispositiva. ¹³⁹

Na mesma linha principiológica, que marca as denominadas *Normas Fundamentais do Processo Civil*, constantes do preâmbulo do CPC, inspirando-se, por certo, na dogmática do direito privado, o legislador estabelece, no art. 5.º, uma cláusula geral de boa-fé processual, que deverá nortear, durante as sucessivas etapas do procedimento, a conduta de todos os protagonistas do processo: o juiz, as partes, os advogados, o representante do Ministério Público, o defensor público e também os auxiliares da justiça (serventuários, peritos, intérpretes etc.).

Sob tal perspectiva, o fundamento constitucional da boa-fé decorre da cooperação ativa dos litigantes, especialmente no contraditório, que devem participar da construção da decisão, colaborando, pois, com a prestação jurisdicional. Não há se falar, com certeza, em processo justo e equo se as partes atuam de forma abusiva, conspirando contra as garantias constitucionais do devido processo legal.

Eis a razão pela qual a interpretação a sentença deve considerar, em seu conjunto, o comportamento dos litigantes a partir do princípio da boa-fé.

A jurisprudência dos nossos tribunais, adiantando-se à novel legislação, tem preconizado que determinadas condutas, caracterizadas como abuso de direito, vulneram a boa-fé processual. Confirma-se: (i) “(...) Ocorre que, na hipótese, a apresentação da petição com essa finalidade logo após a concessão dos efeitos da tutela, teve a nítida intenção de esvaziar o cumprimento da determinação judicial, no momento em que o réu anteviu que o julgamento final da apelação lhe seria desfavorável, sendo a pretensão, portanto, incompatível com o princípio da boa-fé processual e com a própria regra que lhe faculta não prosseguir com o recurso, a qual não deve ser utilizada como forma de obstaculizar a efetiva proteção ao direito lesionado” ¹⁴⁰ ; (ii) “A jurisprudência do STJ é sedimentada em reconhecer a possibilidade da conversão do julgamento em diligência para fins de produção de prova essencial, como o exame de DNA em questão, principalmente por se tratar de ação de estado. Precedentes. 3. O processo civil moderno vem reconhecendo – dentro da cláusula geral do devido processo legal – diversos outros princípios que o regem, como a boa-fé processual, efetividade, o contraditório, cooperação e a confiança, normativos que devem alcançar não só as partes, mas também a atuação do magistrado, que deverá fazer parte do diálogo processual. 4. Na hipótese, deveria o julgador ter se mantido coerente com a sua conduta processual até aquele momento, isto é, proporcionado às partes a possibilidade de demonstrar a viabilidade na feitura de outro exame de DNA (preenchimento dos requisitos exigíveis) e não sentenciar, de forma súbita, o feito. 4. Além disso, acabou por conferir aos demandantes um direito à produção daquela prova em específico, garantido constitucionalmente (CF, art. 5.º, LV) e que não pode simplesmente ser desconsiderado pelo Juízo, podendo-se falar na ocorrência de uma

preclusão para o julgador no presente caso. 5. Diante das circunstâncias do caso em questão e da vontade das partes, ainda sendo supostamente possível a realização do exame de DNA pela técnica da reconstrução, é de se admitir a baixa dos autos para a constatação da viabilidade e realização da perícia pleiteada”¹⁴¹; (iii) “O formalismo desmesurado ignora, ainda, a *boa-fé processual* que se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com maior razão, do Estado-Juiz”.¹⁴²

Note-se que a boa-fé processual desdobra-se nos deveres de veracidade e de lealdade na realização dos atos processuais, contemplados nos arts. 77 e 142 do CPC. O descumprimento destes deveres caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, cujas sanções estão detalhadamente previstas nos arts. 77, 80, 81, 100, parágrafo único, 334, § 8.º, 536, § 3.º e 702, §§ 10 e 11, do novel estatuto processual.

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Correspondência: art. 459 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 277 do CPC italiano, art. 216 da LEC espanhola, arts. 609 do CPC português

1. Aspectos gerais

A regra legal ora enfocada realça a importância da parte dispositiva da sentença reservada ao julgamento das pretensões deduzidas pelo autor. Na verdade, a nota distintiva das sentenças de mérito das terminativas “é a eficácia de *definir substancialmente a causa* , acolhendo ou rejeitando a pretensão que do mundo exterior fora trazida pelo demandante em busca de acolhimento e satisfação”.¹⁴³

Toda petição inicial, segundo dispõe o art. 319, IV, deverá conter o pedido com suas especificações. Diante da amplitude da discórdia jurídica existente entre os litigantes, o autor pode deduzir um único pedido ou vários pedidos, em cumulação objetiva, como é expressamente permitido pelo art. 327: “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”.

Explica Araken de Assis que, dependendo da natureza do cúmulo de pedidos, o autor desejará a procedência de todos eles, ou, então, de pelo menos um dentre aqueles que foram formulados.¹⁴⁴

Daí, a tradicional distinção doutrinária entre *cumulação própria* , que encerra as hipóteses nas quais é admitido o acolhimento conjunto dos pedidos (art. 327), e *cumulação imprópria* , em que, por força de fatores peculiares ao direito material controvertido, a procedência de uma pretensão exclui a das demais (art. 326).

Naquela primeira categoria, marcada pela *simultaneidade* ou *multiplicidade* de pretensões, incluem-se as espécies de cumulação simples e cumulação sucessiva (o demandante busca o atendimento, ao mesmo tempo, de mais de um pedido); enquanto, na segunda, delimitada pela *singularidade* de pretensão, insere-se a tipologia de cumulação alternativa e cumulação subsidiária (o demandante deseja que o réu cumpra *uma* das prestações da alternativa; que a sentença acolha o pedido subsidiário caso não possa reconhecer a procedência do pedido antecedente).¹⁴⁵

De acordo com o regime do novo diploma processual, não há qualquer obstáculo a que o julgamento do mérito seja fracionado, podendo ser proferida, de acordo com o art. 332, decisão interlocutória de improcedência liminar de um dos pedidos formulados na petição inicial.

O art. 356 do CPC, a seu turno, autoriza expressamente o julgamento antecipado parcial do mérito, quando um ou mais pedidos formulados na inicial ou parcela deles forem incontroversos (inc. I) ou estiverem em condições de imediato julgamento (inc. II), dada a desnecessidade da produção de outras provas ou a revelia do réu (art. 355).

Todavia, como a praxe forense demonstra, normalmente, o pedido ou os pedidos são

examinados e julgados por meio de sentença definitiva, que poderá acolhê-los integralmente ou rejeitar alguns deles.

Externando o seu experiente ponto de vista, Dinamarco ¹⁴⁶ afirma ser muito raro que uma sentença contenha apenas o julgamento de uma única pretensão, vale dizer, apenas uma decisão. Bastaria aqui pensar na condenação do vencido nas verbas de sucumbência, a qual é fixada num preceito, inserido na parte dispositiva da sentença, que não se confunde com o julgamento do mérito. No mesmo ato decisório, o juiz julga a demanda e também se pronuncia sobre a responsabilidade pelo custo financeiro do processo.

2. Compreensão da sentença a partir da exegese de seus capítulos

Resultam deveras importantes, para a correta inteligência do objeto do julgamento, os subsídios ministrados pela denominada “teoria” dos capítulos da sentença. ¹⁴⁷

Os romanos empregavam o vocábulo *capita* para indicar as diversas questões que deveriam ser enfrentadas pela sentença: *tot capita tot sententiae*. Os praxistas lusitanos, igualmente, também conheciam os *capítulos* ou *artigos da sentença*.

Assim sendo, a despeito de o ato decisório ser formalmente único em seu aspecto material, poderá conter ele tantas sentenças diversas quantas forem as questões independentes sobre que versam. Os capítulos da sentença concernem aos capítulos das demandas objetivamente cumuladas.

Para Carnelutti – que foi, na Itália, o processualista que mais se aprofundou no estudo deste tema –, capítulo de sentença se identifica com a “decisão de uma lide”, sendo certo que a sentença com vários capítulos se traduz em julgamento que “decide mais lides”, ou seja, “a sentença proferida no processo cumulativo”. ¹⁴⁸

Assim, para a verificação da abrangência da sentença de mérito – “*acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes*” – é necessário examinar quais capítulos foram efetivamente providos e quais foram rejeitados.

Se o pedido (simples) consiste na condenação do réu na quantia de R\$ 10.000,00 e a sentença julga-o procedente, o autor sagra-se vencedor porque a sua pretensão foi integralmente acolhida. Se a condenação se restringe a R\$ 5.000,00, a procedência foi parcial, sendo que ambos os litigantes são considerados vencedores e vencidos, dada a evidente sucumbência recíproca.

Havendo cúmulo objetivo de demandas (e, portanto, de pedidos), por exemplo, de ressarcimento de dano material e de dano moral, cada qual é considerada um capítulo autônomo, podendo haver acolhimento das duas ou de apenas uma. Se reconhecida apenas a procedência do pedido de dano patrimonial, significa que aquele de dano moral foi rejeitado, e assim por diante.

De salientar-se, por outro lado, que a doutrina, de um modo geral, sustenta a existência de pedidos implícitos. Na verdade, a própria lei (art. 322, § 1.º, CPC) dispensa o autor de especificar, no pedido, a incidência de juros legais, correção monetária, custas e honorários, bem como em relação a prestações periódicas. A rigor, quando atribuídas estas verbas ao demandante, pode parecer, em princípio, que a regra da congruência foi violada. Não obstante, dúvida não há de que a falta de correlação entre o pedido e a sentença é apenas aparente. ¹⁴⁹

O mesmo deve ser afirmado em relação aos efeitos secundários ou anexos da sentença de procedência do pedido. Decorrem eles da própria lei e tampouco deverão estar declinados explicitamente no dispositivo da sentença, como, por exemplo: *a*) a hipoteca judicial (art. 495, § 1.º); ou *b*) a fixação de alimentos provisionais ou definitivos, como consequência da procedência do pedido de declaração da paternidade (art. 7.º da Lei 8.560/1992).

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de

juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I – não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II – a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1.º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2.º O disposto no *caput* também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

Em algumas situações, na esfera das ações de natureza condenatória, torna-se impossível para o autor especificar, no pedido, o valor exato de sua pretensão.

O § 1.º do art. 324 do novo diploma processual admite que o pedido, embora deva ser determinado, possa ser excepcionalmente formulado de forma genérica. É o que sucede: *a*) nas denominadas ações universais, como a de petição de herança, quando o demandante não tiver como *a priori* individuar os bens demandados; *b*) quando impossível delimitar prontamente a extensão do ato ou fato, para quantificar o montante do dano, como, v.g., nas ações individuais ou coletivas visando à recomposição do meio ambiente; ou, ainda, *c*) nas hipóteses em que a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, a exemplo da (agora denominada) ação de exigir contas (arts. 550 a 553, CPC).

É de ter-se presente que, a teor do § 1.º do art. 491, em todos estes casos menos frequentes, o valor exato da condenação será quantificado no subsequente incidente de liquidação.

Não obstante, apesar desta peculiaridade, a nova norma legal impõe ao juiz e ao tribunal o dever de especificar, na sentença ou no acórdão que impuser condenação (§ 2.º), tanto quanto possível, a extensão da obrigação, vale dizer, o valor líquido, e, ainda, os critérios da respectiva atualização, vale dizer, “o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros”.

Não é preciso dizer que a *mens legislatoris*, no sentido de evitar a prolação de sentenças ilíquidas, merece aqui os maiores encômios, simplesmente porque, com esta providencial determinação, evitar-se-á enorme e interminável discussão que, na maioria das vezes, eclode ao ensejo da liquidação acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, e que, não raro, chega a atingir a fase de cumprimento de sentença.

2. Impossibilidade de quantificação do valor da condenação

Ainda que formulado pedido genérico, deve entender-se por “extensão da obrigação” a fixação, na sentença ou no acórdão, do *quantum debeatur*.

Todavia, antevedendo insuperável obstáculo, a própria regra legal, nos incs. I e II, dispensa o julgador de fixar quantia líquida, quando: *a*) impossível a determinação do montante devido; ou *b*) a apuração deste depender da produção de prova muito demorada ou custosa, que possa comprometer o curso normal do processo.

Ainda assim, é de todo recomendável que o juiz decline, na sentença, ao menos os parâmetros particularizados que deverão nortear a posterior apuração do valor da condenação.

Note-se que, há muitos anos, esta orientação veio consagrada em precedente da 4.ª Turma do

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 285.630-SP, com voto condutor do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, ancorado na seguinte fundamentação: “O recurso especial está limitado ao aspecto processual da validade do julgamento proferido na ação civil pública, sob a alegação de que o pedido genérico de uma condenação a reparar o dano produzido pelos réus não permitiria prolação de sentença com valor certo, sob pena de ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC [1973], além de divergência. Ocorre que, na espécie, o egrégio Tribunal entendeu estar definida na petição inicial a pretensão indenizatória do autor, conclusão a que chegou a partir da leitura da exordial, já parcialmente transcrita no relatório. O pedido, assim como formulado, permitia ao juiz deferir a indenização pelo valor indicado, independentemente de liquidação de sentença. Portanto, inexistente ofensa ao disposto nos arts. 128 e 460 do CPC exatamente porque no pedido estava quantificada a pretensão condenatória. Também essa circunstância impede o reconhecimento da divergência, como bem explicado no parecer do douto MPF, uma vez que os paradigmas não apresentam a mesma peculiaridade. Ainda que superada essa questão, tenho que a formulação de pedido genérico, dependente de arbitramento, não impede desde logo o arbitramento judicial, evitando nova e demorada fase para alcançar-se uma conclusão à qual o Juiz pode desde logo estar habilitado a expressar. De qualquer modo, agora ou depois, caberá a ele definir a quantia da reparação; logo, a presença de informações suficientes justificam a imediata definição da verba condenatória (...)” ¹⁵⁰

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Correspondência: art. 460 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 218 da LEC espanhola, art. 609 do CPC português

1. Correlação entre o pedido e a sentença

O art. 141 do CPC visa a estabelecer um harmônico equilíbrio entre os limites objetivos da demanda e os poderes cognitivos do órgão jurisdicional, ao dispor que: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

O julgador não deve, pois, pronunciar-se sobre coisa não demandada, não podendo também deferir mais do que lhe foi postulado. Desse princípio, decorre que o exercício da função jurisdicional fica na dependência da manifestação de vontade do interessado para postular o seu direito, o que implica o dever do juiz de prover sobre o mérito, na medida de quanto foi efetivamente alegado e requerido, não podendo, porém, emitir provisão sobre questão para cuja resolução não haja pedido das partes. ¹⁵¹ Se o fizer, vale dizer, atribuir ao autor mais ou fora do que demonstrou pretender, irrompe, por certo, viciado o julgado. Diz-se que, nesta hipótese, a sentença, respectivamente, é *ultra*, *extra* ou *citra petita*.

Determina, com efeito, o art. 492, ora sob análise, que o juiz está proibido de prover sobre coisa diferente daquela pretendida ou mesmo de fixar condenação em montante superior ou em objeto diverso daquele que especificado na pretensão do autor.

Tal princípio, que impõe observância judicial entre o que foi pedido e o que foi decidido, impõe, pois, a proibição de um “julgamento assimétrico”. Haverá, destarte, vício de “ultra” ou “infrapetição” toda vez que o juiz, interferindo no poder dispositivo das partes, introduzir, de forma indevida, alteração na *causa petendi* ou no *petitum*, imediato ou mediato, deduzido na petição inicial, para extrair consequência jurídica diferente daquela alvitada pelo autor.

Como bem pontuou, a esse propósito, a 1.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 15.689-SP: “A prestação jurisdicional deve se materializar na decisão sobre aquilo que foi pedido, nem a menor, nem a maior, nem fora da postulação”. ¹⁵²

Nesse idêntico sentido, a 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 103.093-ES ¹⁵³, assentou que “I – O juiz deve, tendo em vista o princípio da correlação entre o pedido e a sentença, consagrado nos arts. 128 e 460 do CPC, decidir a demanda nos limites do pedido do autor e da resposta do réu; portanto, é vedado ao julgador proferir sentença fora do pedido (“extra petita”) (...)”.

A 2.^a Turma, a seu turno, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.089.020-RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, assentou: “2. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 128 do CPC). 3. Pelo princípio da adstrição ou congruência deve haver correlação entre o pedido e a sentença ou acórdão, o que não ocorre quando a parte postula repetição de indébito de imposto sobre a renda e o acórdão concede-lhe repetição de PIS, não pleiteada e sequer fundamentada”. ¹⁵⁴

Tenha-se presente que a regra em apreço é de ser igualmente observada no julgamento dos recursos.

Pelo novo art. 1.013, fica devolvida ao grau superior a matéria impugnada pelo recorrente. Ao tribunal, contudo, vem expressamente atribuída a prerrogativa de:

a) julgar “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (§ 1.º);

b) considerar fundamento não examinado pela sentença (§ 2.º); e

c) decretar a nulidade da sentença e julgar o mérito, desde que a causa esteja “madura” (§ 3.º).

É certo que em qualquer destas hipóteses há de prevalecer a regra do novo art. 492.

A despeito de ser um imperativo constante da legislação ordinária e não da Constituição Federal, registra José Roberto dos Santos Bedaque que o denominado princípio da congruência ou da adstrição é calcado nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa: “o motivo pelo qual o legislador processual não permite ao juiz decidir fora dos limites objetivos fixados na inicial, ou legitimamente ampliados, é exatamente preservar a integridade desses princípios”. ¹⁵⁵

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, acrescenta Marcelo Pacheco Machado ¹⁵⁶ que a atuação dos protagonistas do processo está sempre condicionada ao pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa. O objeto da demanda aforada deve ser apresentado ao réu, que deve ter condições efetivas de compreendê-lo (informação) e, se desejar, de realizar todos os atos pertinentes ao convencimento do juiz, a fim de que o rejeite (possibilidade de reação adequada).

Seja como for, é imprescindível que o ato decisório, como função última do juiz, circunscreva-se à pretensão do autor, exatamente da forma como foi ela deduzida.

2. Requalificação jurídica da demanda e observância do princípio da correlação

Embora o *nomem iuris* e/ou fundamento legal porventura declinado pelo autor na petição inicial possa influenciar a convicção do julgador, nada obsta, dada a incidência do aforismo *iura novit curia*, a que este requalifique juridicamente a demanda, emoldurando-a em outro dispositivo de lei ou mesmo em outra categoria jurídica (e.g. contrato de parceria para contrato de representação comercial), *desde que extraída a mesma consequência jurídica pretendida pelo autor*. O juiz tem, pois, o poder-dever de examinar os fatos que lhe são submetidos nos quadrantes de todo o ordenamento jurídico, ainda que determinada norma ou categoria jurídica não tenha sido mencionada pelas partes.

Na verdade, o limite da liberdade do juiz encontra-se naquele ou naqueles fatos que individualizam a pretensão do autor e a exceção oposta pelo demandado e que constituem, respectivamente, a *causa petendi* e a *causa excipiendi*: a qualificação jurídica desenhada pelo autor e secundada pelo réu nunca é definitiva e, por via de consequência, nada impede a livre

eleição dos motivos ou normas jurídicas que o órgão judicante entenda pertinentes.

Pode até mesmo suceder que, no processo hermenêutico de subsunção, o juiz entenda que à situação fática narrada de conformidade com a *lex generalis* sejam aplicáveis normas especiais de regência, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que não invocadas pelos demandantes; e vice-versa, ou seja, o autor invoca a *lex specialis* e o julgador aplica as regras do Código Civil. Tem-se aí verdadeira modificação da tipificação jurídica do fundamento fático exposto pelo autor.

Disso também decorre que as partes podem variar, durante as fases do procedimento, o fundamento legal que eventualmente tenha sido deduzido na petição inicial ou na contestação, sem acarretar modificação do objeto do processo.

Cumpre, portanto, reconhecer que essa orientação, sintetizada pelo velho brocardo *da mihi factum dabo tibi ius*, está a revelar que, no drama do processo, a delimitação do *factum* e a individuação do *ius* correspondem, em princípio, a atividades subordinadas à iniciativa de diferentes protagonistas. Enquanto a alegação e comprovação do fato são incumbência dos litigantes, a aplicação do direito é apanágio do juiz.

Verifica-se, assim, que essa concepção é largamente consagrada não só na doutrina, mas também, nos tribunais, em especial, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a 4.^a Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 870.624-SC, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, deixou assentado que: “Não há óbice ao reconhecimento da fraude a credores em razão da parte invocar dispositivos próprios da revogada Lei de Falências. Isso porque nas instâncias ordinárias vigoram os princípios *iura novit curia* e *da mihi factum dabo tibi ius*, pelos quais o julgador não se adstringe ao direito invocado pela parte, podendo aplicar norma jurídica diversa para o julgamento da causa”.¹⁵⁷

Em senso análogo, o mesmo órgão fracionário, ao ensejo do julgamento do Recurso Especial 1.046.497-RJ, com voto condutor do Ministro João Otávio de Noronha, decidiu que “Inexiste violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ratificando a sentença, examina as questões havidas como necessárias ao desate da lide, com a exposição dos elementos e premissas jurídicas que ensejaram as conclusões ali firmadas. Com base nos fatos narrados pela parte na peça preambular, cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio diante do princípio *iura novit curia*, pelo qual se pressupõe o seu conhecimento do direito, cuja relevância reflete postulado de igual matiz: *da mihi factum dabo tibi ius*. Não há ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC se a qualificação jurídica dos fatos difere daquela apontada pelos autores recorrentes”.¹⁵⁸

Exemplo didático pode ser extraído de importante precedente, da 1.^a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Rescisória 4.446-SP, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ao reconhecer que o tribunal, circunscrito à matéria controvertida, está autorizado a alterar o fundamento da ação rescisória, nos termos sintetizados na seguinte ementa: “1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão do STJ que, em julgamento de recurso especial, concluiu pela incidência do imposto de renda sobre verbas pagas ao requerente por mera liberalidade do empregador.. 2. pesar da ação desconstitutiva ter sido ajuizada com esteio no art. 485, V, do CPC, encontra-se o magistrado autorizado a conferir à hipótese narrada pelo autor a correta qualificação jurídica aos fatos expostos na exordial (decisão rescindenda fundada em suposto erro de fato – art. 485, IX, do CPC). Princípio do *iura novit curia*. 3. Ação rescisória julgada improcedente”.¹⁵⁹

Conclui-se, destarte, que, baseando-se no mesmo cenário fático, nada obsta a que o juiz altere o *fundamento legal*, o dispositivo da lei (de resto, irrelevante), ou ainda o *fundamento jurídico*, vale dizer, a tipificação jurídica que advém do fato ou dos fatos narrados. A qualificação da demanda, emergente do conjunto fático-jurídico constante dos autos, pode perfeitamente ser alterada pelo julgador. Trata-se de “requalificação jurídica” de ofício, desde que sempre preservada a integridade da pretensão visada pelo demandante.

Importa esclarecer, de logo, que não se delineia possível, para os propósitos da presente exegese, traçar um conceito unívoco para a expressão “requalificação jurídica”, visto que, dependendo da situação concreta, diferente será a extensão de suas implicações práticas na esfera de direito das partes.

Será suficiente conceber por “requalificação jurídica” o poder-dever que todo julgador tem de emprestar aos fatos narrados definição, categoria ou tipificação da relação jurídica diversa daquela eleita pelo autor e pelo réu, na fase postulatória da demanda.

Vejamos como as coisas se passam no terreno da casuística, valendo-me, como exemplo, da possibilidade de alteração da qualificação jurídica em matéria de responsabilidade civil.

Tenha-se presente que, em certas ações, como as que versam sobre responsabilidade civil (*fundamento global*), inúmeros fatos são passíveis de individualizar uma única pretensão, o que faz surgir séria celeuma quanto à possibilidade de intercâmbio do elemento causal da demanda no curso do processo.

Todavia, é certo que em relação a tais demandas, embora existam vários fundamentos jurídicos (v.g.: culpa contratual, culpa aquiliana) aptos a identificar um único pedido, é vedado ao autor alterar os elementos fático-jurídicos depois de estabilizado o objeto do processo.

Assim, se o demandante, pretendendo indenização por perdas e danos produzidos durante a condução da carga, é derrotado em ação fundada no contrato de transporte, poderá, sem dúvida, pleitear em seguida a mesma indenização com arrimo na culpa decorrente de ato ilícito, dada a manifesta imperícia do motorista do caminhão que transportava a mercadoria.

Como já tive oportunidade de escrever ¹⁶⁰, no âmbito do processo civil brasileiro, a regra da eventualidade e a respectiva substanciação da demanda (agora reafirmada no art. 319, III) dizem respeito exclusivamente ao *fato essencial*, ou seja, àquele delimitado pelo autor na petição inicial, de sorte que se houver outro fundamento independente, ainda que para idêntica pretensão, nova demanda poderá ser ajuizada, porque a primeira não se identifica com aquela sucessiva.

A despeito de ter sido muito debatida, nas cortes francesas, a possibilidade de coexistência, numa mesma ação, de *causa petendi* estribadas em diversas categorias de culpa, entre nós irreleva que sejam aquelas diferentes, fundando-se uma na culpa derivada de ato ilícito e outra radicando na responsabilidade contratual.

Forçoso é reconhecer, com Araken de Assis, que na “concorrência” entre responsabilidade contratual e aquiliana, dada a uniformidade do complexo de fatos, há tão-somente divergência acerca do enquadramento legal, uma vez que os fatos ou configuram a primeira ou a segunda ação. ¹⁶¹

Excelente trecho de voto de Philadelpho de Azevedo, quando Ministro do Supremo Tribunal Federal, presta-se a ilustrar o assunto ora examinado: “(...) As incertezas e deficiências de técnica dos arrazoados e da sentença, em face da origem da culpa e da natureza do contrato, foram apreciadas com severidade e, talvez, em detrimento do recorrente; erros de situação do problema jurídico não devem prejudicar as partes, eis que *ius novit curia* e as ações têm a mesma forma; aliás, a noção fundamental de culpa desafia distinções e enfraquece classificações, ainda que prestigiadas por uma longa tradição, de origem diversa, sem que se possa concluir que a preferência por um desses aspectos concorrentes envolva apreciação *extra* ou *ultra petita*, a despeito dos eruditos debates travados no Tribunal recorrido (...)”. ¹⁶²

Não há se falar, pois, em modificação da demanda quando, da narração fática levada a cabo pelo autor, for possível ao juiz produzir qualificação diversa daquela inicialmente declinada pelo demandante. É claro que, se o autor expuser na petição inicial os fatos que indicam a existência de culpa decorrente de ato ilícito, mas afirmar, por equívoco ou deficiência técnica, que se trata de responsabilidade advinda do contrato celebrado entre as partes, o juiz deve conferir a adequada qualificação jurídica ao conjunto fático jurídico deduzido na causa.

E, assim, desde que debatida a questão sob todos os ângulos possíveis, não incide à evidência a regra do art. 10 do CPC, visto que a requalificação jurídica da demanda não se descortina como um “fundamento-surpresa”.

Desse modo, pode ser afirmado que o juiz não só pode como deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o enquadramento jurídico que entender mais adequado. Daí porque, por exemplo, o tribunal poderá desprezar toda a discussão travada sobre a prova do ato culposo e, com base na responsabilidade objetiva, *sem modificar ou introduzir quaisquer fatos*, emprestar nova moldura jurídica aos mesmos, a partir do reconhecimento da culpa presumida do produtor demandado no âmbito de uma relação de consumo.

Suponha-se, por exemplo, que um demandante tenha ajuizado uma ação, pleiteando indenização com fundamento na culpa de preposto da Administração Pública, por ter agido com manifesta negligência. Todo o contraditório se desenvolve sobre tal questão. Todavia, guiado pelos princípios que regem a responsabilidade objetiva, o juiz, desconsiderando a prova efetiva do ato ilícito, profere sentença de procedência do pedido com fundamento na culpa presumida do Estado.

Nessa hipótese, a circunstância essencial, fundamental para a substanciação da demanda visando à indenização decorrente de atuação culposa de funcionário público, consubstancia-se precisamente no nexo causal entre o dano e o ato do agente. Ainda que deduzida pelo autor a culpa desse agente, não lhe é carregado o ônus da prova quanto ao ato comissivo.

Igualmente, na situação em tela, também não se aplica o disposto no indigitado art. 10 do novo diploma processual, simplesmente porque o fundamento que lastreia a sentença não constitui surpresa alguma, mas, na verdade, mera subsunção lógica do fato essencial ao ordenamento jurídico.

O mesmo ocorrerá se, por ilustração, as partes estiverem litigando com base em determinados fatos que configuram coação, embora todo o debate encontre-se centrado na alegação de simulação. Dúvida não há de que, apesar do “rótulo” (simulação) sobre o qual contendem as partes, o juiz possa julgar, requalificando o fundamento jurídico da demanda, reconhecendo ou não a existência de coação.

No entanto, a recíproca não é verdadeira, vale dizer, se o contraditório tiver como foco a possível existência de coação, é vedado ao juiz, sem possibilitar a manifestação das partes, proferir sentença declaratória de nulidade do negócio com fundamento na simulação, visto que diferente seria a base fática.

Assim também, se o juiz formar convencimento de que se operou a prescrição, não arguida e tampouco debatida durante toda tramitação do processo, não poderá extingui-lo, por meio de sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição, sem ouvir previamente as partes envolvidas. Justifica-se a manifestação dos litigantes, até porque poderá existir uma causa interruptiva da prescrição, não revelada pelo autor pela simples razão de não ter sido ela suscitada pelo demandado.

Ademais, há determinadas situações nas quais a alteração da qualificação jurídica dos fatos implica modificação do regime jurídico aplicável ao caso concreto. Não se trata aí, como se observa, de mera requalificação da demanda, mas, sim, de diferente imputação ou tipificação jurídica extraída do conjunto fático constante dos autos, que pode acarretar sérias consequências na esfera do direito material e processual das partes.

Explico-me: A empresa X ajuíza demanda de natureza ressarcitória com arrimo no art. 186 do Código Civil. A ré Y se defende, deduzindo apenas fato modificativo das circunstâncias alegadas na petição inicial.

Ao iniciar a fase instrutória, diante das postulações das partes, o juiz se convence de que a relação é de consumo, devendo ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, com todas as implicações substanciais e processuais daí decorrentes.

Não tenho receio de afirmar que, nessa hipótese, antes de prosseguir com a realização dos demais atos procedimentais, o juiz deve propiciar a manifestação das partes nos termos do art. 10 do CPC, a evitar futura decisão nula, escudada em “fundamento-surpresa”.

E isso porque a iniciativa judicial que comporta a requalificação jurídica dos fatos deduzidos deve compatibilizar-se com as garantias processuais das partes, de modo a assegurar a imparcialidade do juiz e a plenitude do direito ao contraditório.

3. Vícios da sentença por afronta ao princípio da correlação

Nem todos os vícios da sentença ou do acórdão, que vulneram a exigência de correlação, implicam a invalidade do ato decisório.

Por sua vez, o ato decisório que conferir mais do que pretendido pelo autor, a sentença desponta *ultra petita*, e assim igualmente está viciada, mas o réu terá de requerer a sua anulação perante o tribunal. A anulação nesse caso não contamina todo *decisum*, uma vez que se limitará ao montante que exceder o pedido.

Ensina, a esse respeito, Pontes de Miranda que, sob pena de nulidade: “O juiz não pode proferir sentença que não atenda às características do pedido, à sua quantidade e ao objeto a que alude a petição inicial”.¹⁶³

Examinando esta anomalia, a 6.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 876.514-MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, decidiu, à unanimidade de votos, que: “Há julgamento *ultra petita* se a Corte de origem concede a segurança impetrada para, além de anular o ato demissionário, nos termos do pedido formulado na inicial, determinar a aplicação, de ofício, da penalidade de suspensão do servidor (...)”.¹⁶⁴

Sendo *infra petita* a sentença, pelo fato de ter provido menos de quanto pleiteado, embora igualmente viciada, não haverá coisa julgada no tocante à parte do pedido que não foi objeto de decisão.

A esse respeito, tornou-se clássico o ensaio de Barbosa Moreira, intitulado *Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo*,¹⁶⁵ valendo transcrever a esclarecedora conclusão: “Não há necessidade de grande esforço dialético para demonstrar que em relação aos tópicos integrantes do *thema decidendum* e, apesar disso, sem solução no dispositivo, descabe cogitar de formação da coisa julgada”.

Por fim, se a sentença deixar de enfrentar fundamentos deduzidos pelo autor (*citra petita*) ou se basear em fundamentos estranhos (*extra petita*), restará nula.

Se a sentença ostentar natureza diferente da pretensão deduzida ou mesmo prover sobre coisa diferente será ela considerada *extra petita*, passível de impugnação por ambas as partes.

E isso, porque a sentença que julga improcedente o pedido também poderá ser excepcionalmente considerada *ultra* ou *extra petita*, quando, por exemplo, julgar contra alguém que não integrou o contraditório, ou escudar-se em fundamento surpresa, não debatido pelas partes, ou, ainda, prover sobre objeto diferente daquele pretendido pelo demandante.

4. Certeza da decisão e relação jurídica condicional

A função da sentença é a de produzir certeza jurídica.

Como ato magno do processo, destinado a gerar importantes consequências no mundo jurídico, o parágrafo único do art. 492 do CPC exige que a sentença seja revestida de certeza. E isso, ainda que decida relação jurídica condicional.

Decisão certa é aquela que expressa, no dispositivo, sem qualquer dificuldade de compreensão, a resposta à pretensão deduzida pelo autor.

Nada obsta, contudo, que a eficácia do *decisum* fique condicionada à superveniência de um evento futuro e incerto, como, e.g., aquele previsto no art. 98, § 3.º, pelo qual, embora a sentença imponha condenação na sucumbência ao beneficiário da gratuidade, o respectivo direito de exigir o pagamento fica suspenso pelo interregno de cinco anos, até que aquele tenha condições financeiras para arcar com a obrigação. ¹⁶⁶

Nesse sentido, apesar de antigo, vale ser invocado, a propósito, expressivo aresto da 4.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no julgamento do Recurso Especial 164.110-SP, no qual restou decidido: “I – Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão. II – A sentença condicional mostra-se incompatível com a própria função estatal de dirimir conflitos, consubstanciada no exercício da jurisdição. III – Diferentemente da ‘sentença condicional’ (ou ‘com reservas’, como preferem Pontes de Miranda e Moacyr Amaral Santos), a que decide relação jurídica de direito material, pendente de condição, vem admitida no Código de Processo Civil (art. 460, parágrafo único). IV – Na espécie, é possível declarar-se a existência ou não do direito de percepção de honorários, em ação de rito ordinário, e deixar a apuração do montante para a liquidação da sentença, quando se exigirá a verificação da condição contratada, como pressuposto para a execução”. ¹⁶⁷

Fiando-se nesse precedente, em época mais recente, a 1.ª Turma da mesma Corte federal, no julgamento do Recurso Especial 861.296-CE, relatado pelo Ministro Francisco Falcão, deixou patenteado que: “O ordenamento jurídico pátrio não veda que relações jurídicas condicionais sejam decididas pelo órgão julgador, como dispõe o art. 460, parágrafo único, do CPC [1973]. Exige-se apenas que a sentença seja sempre certa e, em regra, determinada. No caso *sub examine*, foram respeitados tais requisitos. Primeiro porque a prestação jurisdicional foi claramente definida no julgado, imputando-se a condenação à recorrente, sendo, portanto, certa a sentença. Ademais, o aludido julgado é determinado, visto que restou explicitado sobre quais verbas não deve incidir o imposto de renda, ainda que se refira a valores que serão recebidos pelos recorridos, pois, como já se falou, é permitida a regulação, pelo Estado-Juiz, de relação jurídica condicional. O que não é permitido pelo nosso sistema jurídico é a ‘sentença condicional’, que, no dizer do ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, ‘mostra-se incompatível com a própria função estatal de dirimir conflitos, consubstanciada no exercício da jurisdição’. Não pode o resultado do processo, se procedente ou improcedente o pedido, ficar pendente da ocorrência de evento futuro e incerto. Precedente: REsp. 164.110-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)”. ¹⁶⁸

Não se trata, como se observa, de sentença condicional, inadmitida, de resto, de um modo geral, pela doutrina ¹⁶⁹, porque a sua eficácia não se subordina à verificação de qualquer condição.

A sentença condicional, sob o ponto de vista técnico, como bem pontua Eduardo Talamini, em parecer inédito, constitui praticamente uma extravagância, uma teratologia, de rara ocorrência prática. Trata-se do pronunciamento que condiciona sua própria eficácia à ocorrência (ou inoccorrência) de um evento futuro e incerto. A sentença é proferida, mas apenas produzirá os seus efeitos se vier a ocorrer futuramente determinado fato (condição suspensiva). Ou, ainda, ela produz efeitos desde que não ocorra no futuro certo fato (condição resolutiva).

A patologia da hipótese dificulta até mesmo a apresentação de exemplos, podendo ser mencionado o antigo caso pontual da sentença *si iuraverit* – previsto no antigo direito lusitano. Informa-nos Lobo da Costa que esta espécie de sentença definitiva, condicionada a prestação posterior de um juramento, *si actor vel reus iuraverit*, teve ampla aplicação no direito medieval, por influência dos glosadores, que reputavam essa condição de constatação imediata para a pronta verificação da higidez da sentença. Mais tarde, a técnica deixou de ser acolhida pelos diplomas que posteriormente regeram o processo civil. ¹⁷⁰ Ao tempo das Ordenações Filipinas (1603), “toda sentença deve ser pura e não ter em si condição alguma (...)”. ¹⁷¹

A sentença é ato de comando e não mero juízo lógico, hipotético.

Mesmo quando investida de eficácia precipuamente (“puramente”) declaratória, a sentença jamais se resume a um mero ato intelectual. Ela há de ser um pronunciamento que incida direta e concretamente sobre uma posição jurídico-subjetiva. O provimento declaratório elimina a dúvida objetiva acerca da existência, inexistência ou modo de ser da posição jurídico-subjetiva ou sobre a autenticidade de um documento.

Seguindo esse mesmo raciocínio, merece destaque a lição de José Frederico Marques ¹⁷², referida no substancioso estudo de Eduardo Talamini, ao asseverar que: “Se na lei se contém um preceito abstrato e indefinido, há, no parecer do juriconsulto ou na interpretação do doutrinador, uma operação especulativa-prática tendente a concretizar, no tocante à *aplicabilidade*, o preceito abstrato da lei em vista de uma situação definida e individualizada. Na sentença, porém, a norma abstrata da lei se transforma em norma concreta entre as partes, pela *aplicação* a esse fato individualizado e definido; a sentença, portanto, além de conter o elemento lógico de que não prescinde o juízo prático, traz em si o elemento de realização existencial”.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Correspondência: art. 462 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 611 do CPC português

1. Aspectos gerais

Após o encerramento da fase postulatória, estabiliza-se normalmente o objeto litigioso, propiciando, em seguida, o proferimento de sentença ou de decisão de saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

Por força da regra da eventualidade, determinante da substanciação da demanda (agora reafirmada nos arts. 319, III, e 336), excetuando-se a hipótese prevista no art. 329 do CPC, torna-se praticamente impossível, pela inarredável preclusão, a alteração voluntária dos elementos subjetivos e objetivos da demanda, em particular, dos fatos e fundamentos então deduzidos, depois do encerramento da fase saneadora.

Instada a examinar questão de veras original, a 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça lavrou acórdão no Recurso Especial 1.305.878-SP, com voto condutor da Ministra Nancy Andrighi, consignando que: “De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a petição inicial não pode ser emendada depois de apresentada contestação, sob pena de malferir o princípio da estabilização da demanda. Ainda que essa perspectiva possa ser flexibilizada em situações excepcionais, o art. 264, parágrafo único, do CPC [atual art. 329] veda a alteração da causa de pedir após o saneamento do processo”. ¹⁷³

Todavia, não se pode esquecer que o desenrolar do respectivo procedimento, em suas várias fases, é marcado pela dinâmica, e, por isso, durante o seu curso natural, a realidade fática, inicialmente submetida pelos litigantes à cognição judicial, pode sofrer, de modo *involuntário*, profunda alteração, chegando até mesmo a influenciar o resultado da controvérsia.

Pontua, a propósito, Marco Antonio dos Santos Rodrigues ¹⁷⁴, que o novo desenho da demanda, em decorrência da ulterior modificação do estado de fato, consubstancia-se como uma circunstância inexorável, na maioria das vezes inesperada, que acaba mitigando o princípio da estabilidade do objeto litigioso.

Daí a inteligência da regra do art. 493, que repete, em linhas gerais, o velho art. 462, ao deixar claro que a sentença deve refletir o estado atual da controvérsia, e não como configurada à época

da propositura da demanda. ¹⁷⁵

É exatamente esse o entendimento que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai, v.g. , de acórdão da 3.^a Turma, proferido nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 621.179-SP, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que proveu recurso especial pendente de julgamento, diante da superveniência de coisa julgada material verificada, em processo que tramitou perante a Justiça Federal, cuja decisão implicou a improcedência de demanda indenizatória que havia sido aforada na Justiça Estadual. Eis a ementa do julgado: “1. O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. 2. O fato superveniente (art. 462 do CPC [1973]) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica. 3. No caso dos autos, o fato superveniente – consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação declaratória de nulidade de patente) – é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial, sob pena ofensa à coisa julgada”. ¹⁷⁶

2. Fato novo e fato superveniente

Distinção importante para a compreensão desse fenômeno de natureza temporal é aquela entre fato novo e fato superveniente. A intenção do legislador, segundo tudo indica, foi a de referir-se a “fato novo” como sinônimo de “fato superveniente”, até porque ambos acarretam, para a hipótese legal, a mesma consequência, vale dizer, apresentam-se como exceção ao dogma da estabilização da demanda.

Não há se confundir, entretanto, fato novo – que é aquele preexistente, mas que não foi ou não pode ser alegado nos autos no momento da fase postulatória – com fato superveniente – aquele que ocorreu posteriormente.

Como a produção da prova documental se faz possível durante todo o procedimento, em princípio, até o encerramento da fase instrutória, é admitida a alegação de fato novo, ou seja, daquele cuja prova se torna necessária para comprovar fatos ocorridos em momento posterior à fase postulatória, ou ainda para fazer prova contrária aos fatos alegados pelo outro litigante (fato novo propriamente dito).

Não se verifica, pois, preclusão quanto à alegação posterior de fatos supervenientes (“ocorridos após a petição inicial ou a contestação”) ou mesmo de fatos novos (“que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos”).

No tocante a estes “fatos novos” impõe-se à parte que os alegou o ônus de não apenas justificar como também de comprovar o obstáculo que a impediu de apontá-los no momento processual oportuno.

É claro que o juiz, como sucede em outras circunstâncias processuais, examinará a justificativa apresentada à luz da regra do art. 5.^o do CPC, ou seja, se a parte agiu sem malícia ou chicana; imbuída, portanto, de boa-fé.

3. Superveniência de efeitos produzidos por nova norma jurídica

O juiz, consoante dispõe o art. 493, no momento de proferir a sentença, deve considerar os fatos novos ou supervenientes que interfiram, de modo direto, no julgamento da causa, constituindo, modificando ou extinguindo o direito deduzido em juízo.

É de aduzir-se, outrossim, que o art. 342, I, do novo CPC, também admite a arguição, em princípio, pelo réu, mas igualmente pelo autor, de *ius novorum* . Faz-se possível tanto ao autor, quanto ao réu invocar os efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos produzidos por uma norma jurídica superveniente, seja de direito material, seja de direito processual, que tenha incidência sobre o caso pendente de julgamento.

Assim, quando sobrevier direito atribuindo ao fato originariamente narrado efeito constitutivo

ou modificativo diverso, ou ocorrer um fato, também posterior ao ajuizamento da demanda, que tenha o condão de constituir, modificar ou extinguir o fundamento jurídico do pedido (enfim, que coloque em crise a estabilidade do litígio), não poderá ele deixar de ser apreciado pelo órgão jurisdicional. É, aliás, o que rezam, respectivamente, os arts. 342, I, e 493 do CPC.

4. Inafastável influência no julgamento da causa

Como escreve Nelson Nery Junior, as condições de admissibilidade da ação, dentre elas a legitimidade das partes, “devem vir preenchidas quando do ajuizamento da ação e devem subsistir até o momento da prolação da sentença. Presentes quando da propositura, mas eventualmente ausentes no momento da sentença, é vedado ao juiz pronunciar-se sobre o mérito, já que o autor não tem mais direito de ver a lide decidida. Da mesma maneira, se ausentes quando da propositura da ação, mas preenchidas no curso do processo, o juiz deve proferir sentença de mérito”.¹⁷⁷

A experiência demonstra que o fato superveniente constitutivo faz nascer, para o autor, o interesse de agir, enquanto o fato extintivo o fulmina, impondo ao magistrado, a teor do art. 485, VI, do CPC, julgamento sem resolução do mérito.

Colhe-se, assim, em sede jurisprudencial, pronunciamento que considerou direito superveniente, para o fim de atribuir ao *mesmo fato* inicialmente deduzido efeito constitutivo que não possuía: “O advento da Lei 7.250/1984, que alterou a Lei 883/1949, permitindo o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio pelo cônjuge separado de fato há mais de cinco anos, representou mais uma evolução em favor do princípio da igualdade de filiação, agasalhado na Constituição de 1988 (art. 277, § 6.º). Devendo a tutela jurisdicional compor a lide como a mesma se apresenta no momento da entrega, incide no julgamento a regra do [antigo] art. 462 do CPC, pelo que autorizado estava o órgão de segundo grau a determinar a averbação no registro, negada na sentença proferida na vigência de sistema anterior”.¹⁷⁸

Em época mais recente, os tribunais passaram a aplicar aos processos pendentes a Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal brasileiro), que estabeleceu diferentes parâmetros em relação às áreas de preservação permanente (APP). Nesse sentido, a 2.ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo de Instrumento 2051727-13.2013.8.26.0000, relatado pelo Desembargador Paulo Ayrosa, assentou com muita lucidez que: “(...) Conforme se depreende dos autos, ajuizou o Ministério Público do Estado de São Paulo ação civil pública em face do réu com o fim de condená-lo às obrigações de fazer consistentes na demolição, em 180 dias, da residência e da piscina erigidas no terreno (...), pois localizadas em área de preservação permanente e na aprovação de Projeto de Recuperação Ambiental, após a demolição, tudo sob pena de multa diária, tornando definitiva a liminar inicial concedida. Conquanto tenha sido a ação proposta sob a égide da Lei 4.771/1965, vigente à época, necessário salientar a necessidade da aplicação da lei nova concernente à matéria sob exame (Lei 12.651/2012 e MP 571/2012), a teor do art. 462 do CPC [1973], já tendo decidido a respeito o Colendo STJ: ‘As normas legais editadas após o ajuizamento da ação devem levar-se em conta para regular a situação exposta na inicial’ (STJ-3ª T., REsp 18.443-0-SP EDcl-EDcl, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 29.6.93, DJ 9.8.93, p. 15.228). Com efeito, o conceito de Topo de Morro, previsto também na Lei 4.775/1961 como área de preservação permanente, mantém-se no novo Código Florestal, cujo art. 4.º, IX, traz todos os requisitos para a sua identificação, ao contrário da antiga lei, que era complementada pela Resolução 303 do CONAMA quanto a esta questão”.¹⁷⁹

Configura-se aí, como é fácil de entender, câmbio da *causa petendi* decorrente de *causa supervenies*, diante da eficácia constitutiva do *ius novorum*, que empresta novo fundamento jurídico à pretensão deduzida pelo demandante.

Situação análoga sucede, por exemplo, na hipótese de alguém reivindicar o domínio de bem imóvel sem, contudo, ter ainda logrado o registro na matrícula do respectivo título. Nesse caso, é justo que o ocupante apresente resistência. No curso do processo, entretanto, o autor consegue o registro e com isso, a defesa do réu passa a ser injustificada. Ora, ao proferir a decisão, não poderá o juiz ou tribunal deixar de levar em conta o fato superveniente, constitutivo do direito do autor.

Julgar o pedido improcedente, porque não era o demandante proprietário ao tempo em que a ação foi ajuizada, seria um lamentável desperdício, uma vez que, em imediata sequência, outra demanda seria incoada, cujo pedido certamente seria tido como procedente.

Tratando-se, por outro lado, de ocorrência superveniente de fato extintivo, a situação se apresenta assemelhada àquela prevista no art. 270 do novo CPC português, de “impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide”, decorrente da morte da parte ou da perda do objeto do processo, que pode acarretar a ausência de pressuposto processual ou a falta de interesse processual durante a pendência da ação.¹⁸⁰

Suponha-se que, aforada “ação de despejo para uso residencial de ascendente” (art. 47, III, Lei 8.245/1991), a genitora do autor, beneficiária da retomada, venha a falecer durante a fase instrutória. É evidente, nesse caso, a falta de interesse superveniente no despejo pretendido.

Lembra Ricardo Leonel que a desocupação voluntária de prédio locado pelo inquilino implica a perda do objeto da ação de despejo, diante da inarredável carência ulterior, ao menos quanto a esta pretensão, podendo subsistir a necessidade do prosseguimento do processo para o julgamento de outros pedidos, decorrentes do decreto de despejo que restou prejudicado.¹⁸¹

Aduza-se que a *causa superveniens* apenas será considerada na hipótese de guardar íntima relação como “fato inicialmente apontado como representativo do fundamento jurídico do pedido que é a causa de pedir, seja constituindo-a, seja modificando-a, seja extinguindo-a. Pois, se não participar de nenhuma dessas formas será demanda diversa”, incidindo, *in casu*, a proibição legal já referida.¹⁸²

No âmbito das denominadas ações personalíssimas, por não serem elas transmissíveis aos sucessores, a morte do autor no curso da demanda acarreta julgamento sem resolução do mérito.

Importante precedente da 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do Recurso Especial 832.330, relatado pelo Ministro Castro Filho, concluiu que: “O direito de reconhecer voluntariamente a prole é personalíssimo, e, portanto, intransmissível aos herdeiros, não existindo no direito positivo pátrio, norma que atribua efeitos jurídicos ao ato pelo qual aqueles reconhecem a condição de irmão, se o pai não o fez em vida. Falecido o suposto genitor sem manifestação expressa acerca da existência de filho *extra matrimonium*, a pretensão de inclusão do seu nome no registro de nascimento poderá ser deduzida apenas na via judicial por meio de ação investigatória de paternidade”.¹⁸³

Igualmente, no terreno de alguns direitos absolutos, referentes a usufruto, uso, habitação, também não há transmissibilidade da pretensão deduzida em juízo.

É também o que ocorre nas ações de prestação de fato pessoal, como o mandato.¹⁸⁴

Em todos estes casos, falecido o demandante na pendência do processo, o juiz deverá proferir sentença sem resolução do mérito por ausência superveniente de pressuposto processual subjetivo, visto que impossível a sucessão do autor no polo ativo.

5. Incidência em qualquer tempo e grau de jurisdição

O novo CPC, seguindo, nesse particular, a mesma técnica do diploma revogado, não estabelece qualquer limite temporal para que o juiz considere de ofício ou por provocação da parte, o fato superveniente capaz de interferir no julgamento do mérito. E, assim, nada impede que tal situação ocorra, em grau superior de jurisdição, antes do julgamento, por exemplo, da apelação ou do recurso especial.

Acerca desta questão, nos domínios do Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer que duas são as vertentes a serem consideradas:

i) a questão de direito que a parte pretende submeter à apreciação da Corte superior deve encontrar-se devidamente prequestionada, ou, se o fundamento do recurso especial for outro,

aquela somente será conhecida se a impugnação for admitida. E esta a orientação que se infere de julgamento da 1.^a Seção, nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.149.424-BA, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ao deixar patente que: “(...) Ainda que tivesse a Corte *a quo* examinado diretamente a questão, não estaria impedido o Superior Tribunal de Justiça de proceder à sua análise, porque admitido o recurso especial, quanto à matéria de fundo. Conforme jurisprudência assente desta Corte, o prequestionamento se faz imprescindível até mesmo para arguir as nulidades absolutas, porque não pode o Superior Tribunal de Justiça conhecê-las de ofício. Entretanto, a rigidez da observância veio a ser flexibilizada por alguns acórdãos que entendem possível ao Superior Tribunal de Justiça conhecer das matérias de ordem pública de ofício se, após ser o especial conhecido, com o prequestionamento de tese jurídica pertinente, depararem-se os julgadores com uma nulidade absoluta ou com matéria de ordem pública e que pode levar à nulidade do julgamento ou a sua rescindibilidade (...)” ¹⁸⁵ ; ou

ii) se fato superveniente ou texto legal, que possa influir no julgamento, verificar-se depois da interposição do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça dele deve conhecer de ofício ou mediante provocação da parte interessada.

Com efeito, a 1.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.296.267-RS, relatado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, assentou que: “Os arts. 687 e 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 2015, que repete as já consagradas proteções ao segurado dispostas em Instruções Normativas anteriores, dispõe que, se o postulante de uma prestação previdenciária preenche os requisitos legais somente após o pedido, o ente autárquico reconhece esse fato superveniente para fins de concessão do benefício, fixando a DIB para o momento do adimplemento dos requisitos legais. Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo judicial, nos termos do art. 462 do CPC [1973], segundo o qual a constatação de fato superveniente que possa influir na solução do litígio, deve ser considerada pelo Tribunal competente para o julgamento, sendo certo que a regra processual não se limita ao Juízo de primeiro grau, porquanto a tutela jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma como se apresenta no momento do julgamento”. ¹⁸⁶

Em senso análogo, a 2.^a Turma do mesmo Sodalício Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 775.018-BA, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu que: “O fato superveniente de que trata o art. 462 do CPC [1973] deve ser tomado em consideração no momento do julgamento, ainda que em sede recursal, a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica (cf. Edcl no AgRg nos Edcl, no REsp 621.179-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.^a Turma, *DJe* 05.02.2015; REsp 1.461.382-SP, 2.^a Turma, rel. Min. Og Fernandes, 2.^a Turma, *DJe* 13.10.2014)”. ¹⁸⁷

A 4.^a Turma, por sua vez, ao ensejo do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.288.636-SP, relatado pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, em prestígio ao entendimento consolidado, reafirmou que: “As disposições do art. 462 do CPC [1973] não se restringem às instâncias ordinárias, sendo possível também ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de fato superveniente, cujo surgimento seja posterior à interposição do recurso especial”. ¹⁸⁸

6. Cognição ex officio e imposição do contraditório

Determina o parágrafo único do art. 493 que: “Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.

O enunciado desse dispositivo, que utiliza a expressão “fato novo” como sinônima de “fato superveniente”, contém duas diversificadas regras, a saber: *a*) autoriza que a situação fática superveniente seja sobrelevada de ofício; e *b*) constitui desdobramento do art. 9.º, que veda, com todas as letras, o denominado “fundamento-surpresa”, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Fácil é verificar que esta derradeira determinação encontra-se afinada com a moderna ótica da ciência processual, que não admite, em hipótese alguma, a surpresa aos litigantes, decorrente de

decisão escudada em ponto jurídico fundamental, por eles não alvitado. O tribunal deve, portanto, dar conhecimento prévio da vertente que o direito subjetivo encontra-se em perigo, aproveitando apenas os fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dessa forma, é evidente que os litigantes terão oportunidade de defender o seu direito e, sobretudo, influir na decisão judicial. É certo que a liberdade outorgada ao tribunal, decorrente do aforismo *iura novit curia*, sobretudo no que se refere aos efeitos de nova norma jurídica que possam alterar a *causa petendi* da demanda pendente de julgamento, não dispensa a prévia manifestação das partes acerca da questão alvitada pelo juiz, em inafastável homenagem ao princípio do contraditório. Assevere-se que este cuidado do legislador não concerne apenas ao interesse das partes, mas encontra-se também voltado ao próprio interesse público, na medida em que qualquer surpresa, qualquer ocorrência inesperada, torna-se mais distante a credibilidade da sociedade na administração da justiça.

Verdadeiro “dever de consulta” do juiz, a cooperação aqui contemplada impõe ao tribunal conceder às partes a oportunidade de manifestação sobre qualquer questão de fato ou de direito. O juiz, antes de se pronunciar sobre determinada matéria não debatida, ainda que possa ser conhecida de ofício, deve abrir prazo para prévia discussão pelas partes, evitando, desse modo, que seja proferida decisão calcada em “fundamento-surpresa”, circunstância que acarreta a nulidade do pronunciamento judicial por violação à garantia da ampla defesa.

Não é preciso salientar que, quando se consegue a participação no *iter* de formação de um provimento decisório, daqueles que serão os seus destinatários, obtém-se evidente legitimação da tutela do direito litigioso.

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

Correspondência: art. 463 do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 462 a 464 do NCPC francês, art. 287 do CPC italiano, art. 214 da LEC espanhola, arts. 613 e 614 do CPC português, §§ 319 e 321 do ZPO alemão

1. Aspectos gerais

O novo art. 494, que repete textualmente o art. 463 do CPC revogado – e que continua – à evidência, tendo também aplicação em segundo grau de jurisdição,¹⁸⁹ determina que, publicada a sentença ou o acórdão, somente pode ser ele modificado para a correção de inexatidões materiais ou para retificar erro de cálculo, ou, ainda, por meio de embargos de declaração.

Há, contudo, pelo menos duas outras situações nas quais é possível a alteração do ato decisório, por meio de retratação do órgão jurisdicional que o prolatou, quais sejam: *a*) na hipótese de interposição de apelação contra decisão que não examina o mérito ou que julga liminarmente improcedente o pedido (arts. 485, § 7.º, e 332, § 3.º, CPC); e *b*) na hipótese de interposição de apelação contra sentença proferida em causas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, VII, Lei 8.069/1990).¹⁹⁰

2. Publicação da sentença e do acórdão

A sentença é publicada em audiência ou por meio de sua juntada aos autos do processo. Isso significa que a partir do momento em que se torna público o conteúdo do *decisum*, diz-se que o juiz exauriu o seu ofício jurisdicional.

Já no que se refere especificamente aos julgamentos colegiados, dispõe o art. 941, *caput* e § 1.º, do CPC, que: “Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. § 1.º O voto

poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído”.¹⁹¹

A partir então desse destacado limite temporal, o resultado do julgamento não mais poderá ser alterado.

Saliente-se que a 2.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de enfrentar esta questão, no julgamento do Recurso Especial 1.086.842-PE, com voto condutor do Ministro Mauro Campbell Marques, deixando consignado, com lastro em inúmeros precedentes, que: “(...) o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, nos órgãos colegiados dos tribunais, o julgamento se encerra com a proclamação do resultado final, após a coleta de todos os votos. Enquanto tal não ocorrer, pode qualquer dos seus membros, inclusive o relator, retificar o voto anteriormente proferido”.¹⁹²

Assim, “é defeso ao magistrado proceder, de ofício, à retratação de voto depois de anunciado o resultado do julgamento pelo presidente do órgão julgante”.¹⁹³

3. Correção de inexatidões materiais ou de erro de cálculo

A experiência forense revela que, em algumas situações, a sentença pode conter algumas imprecisões ou equívocos involuntários, atinentes ao nome das partes,¹⁹⁴ a valores expressos no dispositivo da decisão, ou ainda a cálculos aritméticos, que exigem correção.

Trata-se de defeito formal, perceptível de plano e cuja correção jamais implica alteração do conteúdo substancial do provimento jurisdicional.

Assim, por exemplo, se a sentença determinar, por engano, a incidência dos juros legais em 6% a.a., ao invés do percentual correto de 12%; ou impuser condenação ao réu na quantia equivalente ao valor atual de 200 salários mínimos, fixando-a em R\$ 14.800,00, quando, na verdade, o montante deveria ser de R\$ 17.600,00. Em todos estes casos, o próprio juiz que proferiu a decisão, *ex officio* ou a requerimento da parte interessada, poderá alterar o dispositivo, visto que não retratou ele o raciocínio que deveria ter sido exarado no pronunciamento judicial. Igualmente, a omissão da sentença, quanto à incidência de atualização monetária e de juros legais, também é considerada “erro material”, passível de ser corrigido pelo tribunal.

Todavia, não se admite a integração do julgado quando se evidencia irresignação da parte quanto aos critérios ou parâmetros do cálculo adotados pela sentença.

Com efeito, a 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.532.388-MS, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ao traçar a exegese do antigo art. 463, decidiu que: “1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omissos o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. O erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC [1973], é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética, que não pode ser confundido, como consabido, com a mera discordância do executado acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do *quantum debeatur*, tais como incidência de expurgos inflacionários, de índices de correção monetária e de juros”.¹⁹⁵

Esse mesmo posicionamento foi secundado pela 4.^a Turma, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 31.175-SC, relatado pelo Ministro Raul Araújo, textual: “Não é possível defender, no caso *sub examine*, a ocorrência de erro de cálculo, máxime porque o perito atendeu ao comando da sentença. Em verdade, insurge-se o recorrente contra o critério de cálculo adotado pelo perito. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ‘ocorre erro material quando há mero equívoco relacionado à grafia ou a cálculos consignados nos autos, o que não se confunde com discordância acerca dos critérios de cálculo a serem

utilizados na fixação do *quantum debeatur*, tais como incidência de expurgos inflacionários, de índices de correção monetária e de juros' (REsp. 702.073-PB, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.^a Turma, j. 23.5.2006, *DJ* de 3.8.2006, p. 254)". ¹⁹⁶

Aduza-se que, nas hipóteses contempladas pelo art. 494, o juiz está autorizado a corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, a inexatidão que exorna a sentença, mesmo depois do trânsito em julgado.

Realmente, firmando posicionamento que tem prevalecido em sede jurisprudencial, a 4.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 205.106-SP, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, teve oportunidade de decidir: "Entende esta Corte Superior que 'a correção de erro material disciplinado pelo art. 463 do CPC [1973] não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado. Precedentes.' (AgRg no Ag 1.333.013-RJ, por mim relatado, 4.^a T., j. 11.10.2011, *DJe* 24.10.2011)". ¹⁹⁷

A 2.^a Turma, a seu turno, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.545.852-SC, da relatoria do Ministro Humberto Martins, pronunciou-se, à unanimidade de votos, nos seguintes termos: "O Tribunal *a quo* decidiu de acordo com o entendimento, segundo o qual, consoante 'a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador' (AgRg no Ag 1.134.104-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.^a T., *DJe* 27.02.2014). Precedentes: AgRg no REsp 1.506.164-RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.^a Turma, j. 16.06.2015, *DJe* 23.06.2015; AgRg no AgRg no AREsp 606.491-RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2.^a Turma, j. 21.5.2015, *DJe* 04.08.2015; AgRg no REsp 1.335.753-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.^a Turma, j. 23.04.2013, *DJe* 26.04.2013". ¹⁹⁸

4. Alteração por meio de embargos de declaração

Mais graves, contudo, são as hipóteses de omissão ou contradição que irrompem do ato decisório, as quais, em certas circunstâncias, podem inclusive comprometer a sua integridade.

A despeito da polêmica doutrinária, ainda existente, quanto à natureza jurídica dos embargos de declaração – se *recurso* ou *mero incidente da fase decisória* –, o certo é que, mediante esse instrumento processual, qualquer uma das partes, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, procura reparar obscuridade ou contradição, bem como sanar omissão de ato decisório monocrático ou colegiado.

A despeito do disposto no inc. I do art. 494 do CPC, é certo que os embargos de declaração também se prestam a corrigir erro material, como, inclusive, já se pronunciou a 3.^a Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.376.499-SC, da relatoria do Ministro Félix Fischer: "São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do *decisum* embargado". ¹⁹⁹

Longe de ser um mecanismo para procrastinar a tramitação do processo, os embargos de declaração, na verdade, constituem um meio de evitar desarmonia entre aquilo que o julgador pretendeu dizer e o que foi efetivamente explicitado na decisão.

É que, como corolário do princípio da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário, todo litigante tem direito à prestação jurisdicional completa e efetiva, materializada em decisão que há de ser clara, precisa e devidamente fundamentada.

Vislumbrando o juiz ou tribunal que os embargos possuem caráter infringente, ou seja, que o seu eventual acolhimento altere o teor do ato decisório embargado, torna-se imprescindível a

intimação da outra parte, em atenção ao princípio do contraditório, para que esta possa se manifestar (art. 1.023, § 2.º, CPC).

Observe-se que, nesse ponto, o novo CPC também acolheu orientação pretoriana que de há muito já se encontrava sedimentada em nossos tribunais, determinativa da oitiva da parte contrária.

5. Embargos de declaração para corrigir equívoco de natureza processual

Tenha-se, outrossim, presente que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido os embargos de declaração para a correção de inobservância ou desatenção atinente a questões de natureza processual.

A evitar injustiça palmar, decorrente de ato decisório que não conheceu agravo regimental, a 3.ª Turma, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.420.674-PR, com voto condutor do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, entendeu que: “O acórdão embargado incorreu em erro material ao não conhecer do Agravo Regimental com fundamento na certidão de fl. 538 e na Súmula 115/STJ, porquanto à fl. 260 encontra-se substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso”.²⁰⁰

No mesmo sentido, a Corte Especial, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 37.499-MA, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, também entendeu que se mostra “possível a alteração da autuação para corrigir mero erro material, fazendo constar como agravo regimental petição que, nitidamente e sem dúvidas, foi interposta como agravo interno, embora classificada como agravo em recurso extraordinário”.²⁰¹

Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

§ 1.º A decisão produz a hipoteca judiciária:

I – embora a condenação seja genérica;

II – ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor;

III – mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo.

§ 2.º A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência.

§ 3.º No prazo de até 15 (quinze) dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato.

§ 4.º A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro.

§ 5.º Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos.

Correspondência: art. 466 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 2.117 do CC francês, art. 2.818 do CC italiano

1. Conceito e pressupostos da hipoteca judiciária

A hipoteca judiciária encontra justificativa na presunção de que a sentença condenatória assegura uma posição de vantagem à parte que venceu a demanda, ainda que tenha sido interposto recurso pelo vencido.

Como leciona Washington de Barros Monteiro, “a hipoteca pode ser convencional, legal e judicial (...) A hipoteca judicial, de origem francesa, é a que a lei atribui à sentença condenatória e consiste no direito real conferido ao exequente sobre bens do executado, em garantia da execução do julgado... Desde que obtenha decisão favorável, assiste ao autor o direito de fixar bens do réu, para vendê-los e assim obter suficientes recursos à satisfação do julgado. A procedência da hipoteca é, pois, jurisdicional”.²⁰²

Nesse mesmo sentido, afirma Maria Helena Diniz que a hipoteca judicial tem origem no direito francês. A doutrina de Planiol e Ripert a definem como sendo a hipoteca geral que a lei empresta a todo julgamento que condena um demandado a cumprir sua obrigação.²⁰³

Afirma-se em prestigiosa obra²⁰⁴ que se trata de uma hipoteca anômala, porquanto não assegurado o direito de preferência ao credor, ínsito às demais espécies de direito real sobre coisa alheia. Todavia, para espancar qualquer dúvida a esse respeito, o § 4.º do novo art. 495 do CPC é claro ao atribuir ao credor, uma vez constituída a hipoteca, “o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro”.

Enumerando os pressupostos da hipoteca judiciária ou judicial, Caio Mário da Silva Pereira arrola os seguintes: *a*) existência de uma sentença condenando a entregar coisa ou quantia ou a ressarcir perdas e danos; *b*) liquidez do ato decisório; *c*) trânsito em julgado; *d*) especialização; e *e*) registro na forma prescrita na Lei de Registros Públicos.²⁰⁵

Ressalte-se, de logo e como se verá em seguida, que o requisito do trânsito em julgado, catalogado pela doutrina civilista, afigura-se desnecessário.

2. Hipoteca judiciária como efeito da sentença condenatória

Havendo, pois, sentença de natureza condenatória, impondo ao réu o pagamento de quantia certa ou a obrigação de dar, fazer, não fazer, ou, ainda, de entregar determinada coisa, convertidas estas em prestação pecuniária, aflora para o autor o direito de constituição da hipoteca judiciária.

É o que preceitua o *caput* do novel art. 495 do CPC, ora comentado.

Examinando a regra análoga (art. 466 CPC), constante do velho diploma, explicava Moacyr Amaral Santos que: “do só fato de haver sentença de efeito condenatório resulta, por força da lei, hipoteca judiciária sobre os bens imóveis do condenado e, assim, o poder do autor de fazer inscrevê-la mediante simples mandado do juiz”.²⁰⁶

Escrevem, a propósito, Marçal Justen Filho, Eduardo Talamini e Egon Bockmann Moreira que a respectiva sentença constitui “imediatamente” a hipoteca judiciária, não importando qual seja o seu conteúdo e do que dela conste; “basta que traga em si alguma condenação pecuniária”.²⁰⁷

E, por isso, sustenta Theotonio Negrão *et alii*, à luz da norma revogada –, que a hipoteca judiciária, como efeito secundário da sentença condenatória, “é consequência imediata da decisão, pouco importando a pendência ou não de recurso contra esta”.²⁰⁸

Mesmo sendo genérica a condenação, vale dizer, despida de um valor pecuniário certo, e ainda que o vencedor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou que já tenha arrestado bem do devedor, a hipoteca judiciária pode ser efetivada, ficando a critério exclusivo do credor (cf. § 1.º do art. 495 CPC).

3. Procedimento para a constituição da hipoteca judiciária

A despeito de constituir importante instrumento preventivo de fraude à execução, verifica-se que, por não conter regulamentação procedimental específica, o instituto da hipoteca judiciária é de rara incidência prática.

Considerando a lacuna legal atinente ao procedimento a ser observado para a concretização dessa espécie de hipoteca, os doutrinadores pátrios têm procurado traçar algumas diretrizes básicas, sob pena de ser nula, *ipso iure*, a garantia almejada pela parte vencedora.

Examinando essa relevante questão sob a égide do CPC revogado, Luiz Alberto Hoff chamava a atenção para o fato de ter sido muito incipiente o tratamento atribuído à hipoteca judicial pela legislação processual, “e, por conseguinte, tão pouco lhe dedicou a doutrina, que aqueles que se deparam com o art. 466 do CPC [1973], embora tendo à sua frente a afirmação da lei de que a sentença produz a hipoteca, não se animam a postular a sua especialização e inscrição por falta de diretriz processual”.²⁰⁹

Para facilitar o *modus operandi*, o § 2.º do novo CPC art. 495 determina que a hipoteca judiciária pode ser constituída, de forma bem simples, bastando a apresentação de cópia da sentença ao oficial do cartório do registro imobiliário, “independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência”.

Cumprido ao credor, a teor do subsequente § 3.º, no prazo de 15 dias após a efetivação da hipoteca, informar ao juízo da causa, a fim de que seja cientificada a outra parte.

Observo que o legislador perdeu a oportunidade de estabelecer, de uma vez por todas, procedimento mais condizente com os novos rumos do direito processual, deixando de contemplar o prévio contraditório, que tem sido prestigiado pela doutrina e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

E isso, certamente porque a hipoteca judicial, como modalidade de constrição sobre o patrimônio do potencial devedor, acarreta-lhe evidente gravame.

4. Observância do devido processo legal: exigência de prévio contraditório

Não pode restar dúvida de que ao devedor – que vai sofrer o ônus emergente do direito real de garantia consistente na hipoteca judiciária – devem ser asseguradas, no *iter* procedimental, todas as garantias ínsitas ao devido processo legal.

Recorde-se, aliás, que o art. 5.º, LIV, da Constituição Federal, acolhendo tradicional princípio de justiça, reza que: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Despiciendo salientar que a garantia da plenitude da defesa reclama sejam os sujeitos parciais do processo cientificados de todos os atos praticados no desenrolar do procedimento, com a possibilidade de manifestar-se sempre, e no prazo legal, ou no fixado pelo juiz, sobre a atividade desenvolvida pelo antagonista.

Com efeito, a bilateralidade da audiência, ou contraditoriedade, assenta-se num importantíssimo regramento, dito princípio de justiça, e determinante da exigência de tratamento paritário das partes, de tal sorte que haja o mais perfeito equilíbrio entre as suas respectivas atividades processuais.

Traduzindo doutrinação universal, aduzem, a propósito, Mauro Cappelletti e Vincenzo Vigoriti que: “o direito de ação e defesa não está limitado ao pedido inicial ou à resposta, mas expressa também uma garantia geral do direito de ser adequadamente ouvido durante todo o procedimento. Cada fase do procedimento deve ser estruturada de tal modo que propicie às partes uma real oportunidade de defesa”.²¹⁰

Deflui, à evidência, dessa perspectiva, o fundamento lógico da regra do contraditório, moldado na vetusta máxima *audiatur et altera pars*.

E, como não poderia ser diferente, o novo CPC, em diversos dispositivos, assegura não só o direito de ser informado no momento da fase postulatória, como também a bilateralidade argumentativa ao longo de todo o desenrolar do procedimento. É, aliás, da própria sistemática do novel diploma que se infere, também para a instituição da hipoteca judiciária, a exigência de observância do princípio do contraditório.

Diga-se de passagem, que não há, no direito brasileiro, salvo engano, invasão patrimonial sem contraditório!

Realmente, se para a constituição da penhora – objetivando, igualmente, a garantir a efetividade futura de provimento condenatório – o devedor se manifesta a cada momento (arts. 829, 830 e 847, CPC), não pode restar dúvida de que, para a hipoteca em apreço, o devedor também deve ter oportunidade para ser ouvido.²¹¹

E isso, até porque, a teor do disposto no art. 805 do CPC: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

A exigência de prévio contraditório já vinha, com efeito, sendo perfilhada pelos pretórios brasileiros, em particular, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se infere, de julgamento da 3.^a Turma, no Recurso Especial 439.648-PR, relatado pelo Ministro Ari Pargendler: “Não obstante seja um efeito da sentença condenatória, a hipoteca judiciária não pode ser constituída unilateralmente; o devedor deve ser ouvido previamente a respeito do pedido”.²¹²

Invocando esse pioneiro julgado, mais recentemente, na mesma 3.^a Turma, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Especial 1.280.847-SP, coube ao Ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino explicitar a *ratio decidendi*, no seguinte sentido: “Eminentes Colegas, a questão que se entrega ao conhecimento deste colegiado condiz com a necessidade de, para se levar a efeito o direito previsto no art. 466 [atual art. 495] do CPC, consubstanciado na hipoteca judiciária em face da sentença condenatória, antes, permitir-se ao condenado (devedor) a prévia manifestação acerca do ato construtivo que incidirá sobre o seu patrimônio imobilizado. Ao dar provimento ao recurso especial, pautei-me em precedente específico desta Corte Superior, oriundo desta mesma 3.^a Turma, da lavra do e. Ministro Ari Pargendler. No referido precedente, este colegiado, naquela assentada, composto pelos Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Nancy Andrighi e Humberto Gomes de Barros, examinado acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mais exatamente o acerto da seguinte assertiva: ‘A hipoteca judiciária é consequência imediata da sentença, dispensável a formação de contraditório’, concluiu, com supedâneo em magistério de José Rogério Cruz e Tucci, pela necessidade de contraditório anterior... Em nada arrepia ao direito, senão o privilegia, a oportunização à parte, em exíguo prazo, manifestar-se acerca da pretensão formulada pela ex-adversa, ou seja, acerca da constituição da hipoteca judiciária sobre o seu patrimônio, pois certamente auxiliará o juízo na fixação dos seus lindes. O procedimento de especialização e registro que se instaurará poderá ser mais bem orientado pelo diálogo travado entre devedor, credor e juízo... É o conhecido contraditório prévio, que, na espécie, não se fizera presente e que, portanto, faz escorreita a decisão que dera provimento ao REsp (...)”.²¹³

Nesta idêntica senda, a 4.^a Turma proveu o Recurso Especial 1.120.024-SP, para anular hipoteca, ao argumento constante do voto do relator, Ministro Marco Buzzi, no sentido de que: “Não obstante constitua a hipoteca judiciária efeito secundário próprio da sentença (que condena o devedor à prestação em dinheiro ou coisa), instituindo-se independentemente do trânsito em julgado, afigura-se imprescindível sua especialização, como forma de individualização do bem a respaldar a obrigação e a oportunizar a intervenção do devedor nesse procedimento... Daí a necessidade imperativa, sob pena de nulidade, de se oportunizar ao alvo da medida gravosa sua escorreita participação na eleição do bem, em que incidirá o ônus, podendo impugnar a indicação feita pelo virtual credor, fornecendo base empírica para justificar a afetação de determinado imóvel em substituição a outro, seja diante da desproporção do encargo frente ao valor do bem imóvel, ou ante a existência de outra causa a comprometer sua expressão econômica...”.²¹⁴

Mas não é só.

Caio Mário da Silva Pereira, após apontar, como ressaltado, dentre os pressupostos da hipoteca judiciária, a *especialização*, ensina que por esta se impõe “referência precisa ao imóvel gravado e à dívida garantida”. Somente preenchidos todos os requisitos – complementa o civilista pátrio – é que se viabiliza a hipoteca judicial.²¹⁵

Sufragando idêntica opinião, esclarece Wellington Moreira Pimentel que o direito de sequele decorrente da hipoteca judiciária não engloba todos os bens do devedor. É imprescindível que se especialize, isto é, “que se individualize o imóvel, ou imóveis, sobre os quais recairá a hipoteca judicial para que possa ser oponível a terceiros”, e, por certo, para que possa ser registrada.²¹⁶

É nesse sentido que se pronunciou a 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 595.548-SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao assentar que: “Não se verifica a omissão apontada, pois ‘o aresto foi claro ao asseverar que há necessidade de procedimento próprio de jurisdição voluntária para registro da hipoteca judiciária, eis que é necessária a prévia avaliação dos bens indicados pela embargante, com a realização de prova técnica’(...)”.²¹⁷

Não obstante, a evitar indesejado dispêndio de tempo e dinheiro, o próprio juiz, contando com a colaboração das partes, poderá fazer uma estimativa aproximada do valor do bem [ou bens] sobre os quais recairá a hipoteca, até porque o art. 175, III, da Lei de Registros Públicos, de clareza notória, dispõe que se faz necessário, para o respectivo registro, “o valor do contrato, da coisa, da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver”.

Acrescente-se que, a rigor, seria necessária ordem judicial quando nada para atender ao disposto nos arts. 175, III, e 225, da referida Lei 6.015/1973.

Sendo assim, conclui-se que qualquer afronta, no procedimento de constituição da hipoteca judiciária, aos regramentos do contraditório e da publicidade dos atos processuais, bem como à Lei de Registros Públicos, implica, sem dúvida, a existência de vício insanável, cognoscível até mesmo *ex officio*, em virtude de macular preceitos de ordem pública.

5. Responsabilidade objetiva do credor

Se porventura, levada a cabo a hipoteca judiciária, a decisão condenatória (monocrática ou colegiada), afinal, restar “confirmada”, a constrição adquire conotação definitiva. Nessa situação, o bem hipotecado garantirá o débito no âmbito do sucessivo cumprimento de sentença.

Na verdade, surge problema na hipótese contrária, vale dizer, quando o pronunciamento judicial é revogado (reformado ou anulado), cujo efeito imediato é a cassação de qualquer eficácia do precedente ato decisório.

Nesse caso, dispõe o § 5.º do art. 495 do CPC que o então credor responde objetivamente pelas perdas e danos eventualmente experimentados pela parte contrária, advindos da consumação da hipoteca, efetivada com lastro num título executivo provisório.

É, aliás, o mesmo regime previsto para a reparação dos prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302 CPC)²¹⁸, do cumprimento provisório da sentença (art. 520, II, CPC) e da execução (art. 776 CPC), quando verificada, em momento posterior, a reforma da decisão.

Não há se falar, portanto, em presunção de culpa para justificar o dever de indenizar. O que se dá é, puramente, um caso de responsabilidade objetiva, à qual o elemento “culpa” é de todo estranho – ou dispensável.

Seção III

Da remessa necessária

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I – proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1.º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2.º Em qualquer dos casos referidos no § 1.º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3.º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I – 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II – 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III – 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4.º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I – súmula de tribunal superior;

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV – entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Correspondência: art. 475 do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Ofensa à isonomia processual

Como decorrência do enunciado do art. 5.º, e seu inc. I, da Constituição Federal, a todos os membros da comunidade devem ser garantidos os meios judiciais para a proteção dos respectivos direitos subjetivos materiais, com o máximo de igualdade que, inclusive, se faz ínsita à consecução do bem comum, pelo Estado.

Assegurando-se a todos os jurisdicionados, indistintamente, a proteção de seus direitos pelo Poder Judiciário, e por meio do processo, subsiste também no âmbito da ação judiciária, o princípio da isonomia, fazendo as partes que nele atuam por merecerem igual, paritário, tratamento, ou seja, “le medesime chances”, che si conseguia cioè una *Waffengleichheit*, uma autentica eguaglianza delle armi”.²¹⁹

Daí, porque, dúvida não pode haver no sentido de que a regra do art. 496 do CPC continua contendo flagrante ofensa ao princípio constitucional da igualdade das partes perante a lei.

Alfredo Buzaid, em antiga monografia, que se tornou clássica, sobre o denominado reexame obrigatório, teve oportunidade de frisar que existindo, no seio da organização judiciária do país,

órgãos especializados e suficientemente aptos para promoverem a defesa do fisco, “não há necessidade de se manter um recurso que João Monteiro, com muita razão, crismou com a denominação de “extravagância judiciária”. Convém, portanto, *a jure constituendo*, extirpá-lo do Código como um remédio de energia terapêutica negativa”. ²²⁰

Certamente por essa razão, a compulsoriedade do duplo grau de jurisdição veio abandonada, em 1964, no Anteprojeto Buzaid, com a seguinte justificativa: “suprimiu-se o recurso *ex officio*, admitido pelo CPC (art. 822) e por algumas leis especiais (Decreto-lei 960, arts. 53, 54 e 74, parágrafo único; Decreto-lei 3.365, art. 28, § 1.º, e Lei 1.533, art. 12, parágrafo único), reincorporadas no sistema do Código. Acerca do recurso *ex officio*, as opiniões divergem. Alguns eminentes autores não lhe regateiam louvores. ‘É ele’, escreve José Frederico Marques, ‘instrumento eficaz para evitar conluios pouco decentes entre juízes fracos e indignos desse nome e funcionários relapsos da administração pública. E ainda meio e modo para suprir a ação, nem sempre eficaz e enérgica do Ministério Público, em processos em que esta afeta a tutela ativa e militante de interesses indisponíveis’. Salvo os casos de sentença que decreta a nulidade de casamento e da que homologa desquite amigável (CPC, art. 822), todos os demais se referem a pleitos de que é parte a União, o Estado ou o Município. Ora, os argumentos utilizados pelos defensores do recurso *ex officio* não lhe justificam a necessidade, nem sequer a utilidade prática como meio de impugnação de sentenças; procuram explicar a sua manutenção unicamente pelo receio de conluio entre pessoas que figuram na relação processual ou por defeito da função, mas o órgão, cuja inexecução no cumprimento do dever merece ser punida pelos meios regulares de direito, e não por transferência ao Judiciário do controle de seu comportamento irregular. A missão do Judiciário é declarar relações jurídicas e não suprir as deficiências dos representantes da Fazenda ou do Ministério Público. Por outro lado, para obstar a formação do conluio entre as partes, no processo, confere o Código meios eficazes”. ²²¹

Infelizmente, todavia, durante a tramitação legislativa no Congresso Nacional foi o dispositivo incluído no Projeto, afinal convertido na redação original do CPC revogado, que contemplava, no art. 475, duas diversificadas situações: no inc. I, tida como de inexcusável importância a anulação do casamento por qualquer dos relevantes motivos estatuídos nos arts. 207 a 209 do Código Civil, *em razão da matéria*; e nos incs. II e III, quando a União, o Estado ou o Município, ou a Fazenda Pública, restem sucumbentes, *em razão da condição de pessoas* integrantes da relação jurídica tornada litigiosa.

No tocante à primeira delas, bem é de ver que, embora totalmente desnecessária, e até impertinente, a preceituação, ante o disposto no art. 129 do mesmo CPC revogado, não se podia visualizar qualquer antinomia com a Constituição Federal.

O mesmo, porém, não ocorria com as outras, em que estabelecido mais um, e, como os demais, inconcebível e inaceitável privilégio em favor das nomeadas pessoas jurídicas de direito público, especialmente no tocante à execução de dívida ativa, relativa, sempre, a direito patrimonial, sem nenhuma conotação de relevância social.

Daí, por via de consequência, a sua inconstitucionalidade, nesse particular. ²²²

2. Sucessiva reforma da remessa necessária

Não ousando acabar de uma vez por todas com esse odioso privilégio, a Lei 10.352/2001, calcada na mesma opção ideológico-legislativa, manteve no art. 475 o denominado reexame necessário, eliminando-o, no entanto, na hipótese de anulação de casamento. A justificativa óbvia para tal exclusão decorre da (já antiga) admissão, em nosso sistema jurídico da possibilidade de rompimento do liame matrimonial pelo divórcio.

Corrigiu-se, ainda, imperfeição técnica, uma vez que o dispositivo utilizava a expressão *improcedência da execução*, que foi corretamente modificada por *procedência dos embargos à execução*.

3. Alterações introduzidas

Fácil é verificar que o CPC manteve, em linhas gerais, a denominada “remessa necessária” praticamente nas mesmas situações do regime anterior.

Com algumas modificações pontuais, com o intuito de preservar os interesses do erário, tutelando o patrimônio público, infere-se facilmente que, segundo o *caput* do art. 496, a eficácia da sentença de primeiro grau se sujeita ao duplo grau em duas hipóteses: (i) quando proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 496, I, CPC); e (ii) quando julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal (art. 496, II, CPC).²²³

A teor do § 1º do art. 496 do CPC, caso não interposto o recurso voluntário pela entidade pública, o juiz da causa deverá determinar a remessa dos autos ao tribunal. Não atendida a exigência legal da remessa necessária, o presidente da corte de grau superior providenciará a avocação do processo, com o fito de assegurar o cumprimento da regra ora sob análise.²²⁴

Apresentando relevante inovação de natureza estritamente econômica, observa-se, por outro lado, que o legislador elevou o valor mínimo para que tenha incidência o disposto no *caput* do art. 496 do CPC.

Assim, consoante preceitua o § 3.º, não se atenderá, por exceção, ao reexame necessário quando a condenação ou o valor do proveito econômico resultante da sentença não ultrapassar a soma, certa e líquida, de: *a*) 1.000 salários mínimos nas causas em que for parte a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; *b*) 500 salários mínimos nas causas em que for parte os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e o Município, quando for a capital do Estado; e, ainda, *c*) 100 salários mínimos, para os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ademais, reafirmando a importância das súmulas, dos precedentes e, de um modo geral, da jurisprudência, o novo § 4.º, I a IV, do art. 496, determina que igualmente não se aplica a regra do reexame compulsório quando a sentença proferida em desfavor das referidas entidades estiver fundamentada em: *i*) súmula de tribunal superior; *ii*) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; *iii*) tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; e *iv*) tese convergente com orientação vinculante assentada na esfera administrativa do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Não é preciso salientar que, em todas estas hipóteses, o respectivo posicionamento pretoriano deve ser *atual* , vale dizer, deve ainda traduzir sobre a matéria controvertida o pensamento da maioria dos integrantes dos referidos tribunais superiores.

Importa mencionar, a propósito, os termos da Lei 10.552/2002, que atribuem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a faculdade de autorizar a não apresentação de contestação, de recurso e, até mesmo, de desistir daquele porventura interposto, quando, sobre o objeto da demanda, existir jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Providência elogiável, sob todos os aspectos, que, a um só tempo, evita, de um lado, a procrastinação indevida do processo e, de outro, contribui para celeridade da prestação jurisdicional.

É necessário ter-se também presente que resulta divergente a jurisprudência quanto à questão de ser possível à Fazenda Pública valer-se de recurso extraordinário e/ou recurso especial, contra acórdão de tribunal, mesmo que não tenha interposto apelação da sentença de primeiro grau.

A tese que se delineia atualmente majoritária sustenta que não ocorre preclusão lógica em relação à interposição de recurso especial contra acórdão que, em sede de remessa *ex officio* , manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o Estado não tenha interposto apelação contra a sentença que lhe foi desfavorável, pois a falta de interposição de apelo não configura a prática de um ato e nem a concordância com a sentença

contrária aos interesses da Fazenda, sendo que o reexame necessário tem o efeito de devolver ao tribunal toda a matéria em que sucumbiu a Fazenda Pública, operando também o efeito substitutivo da sentença, de forma que, em relação à matéria objeto do reexame, não há preclusão, nem trânsito em julgado contra a Fazenda Pública. ²²⁵

4. Omissão quanto à possibilidade de reformatio in pejus

Anote-se, por fim, que optando por manter o duplo grau necessário, o CPC perdeu ocasião para aperfeiçoar o instituto, eliminando algumas questões que constituem objeto de interminável celeuma doutrinária e jurisprudencial, como, v.g. , o problema da possibilidade de *reformatio in pejus* contra o Poder Público sem que tenha sido interposto recurso de apelação pelo adversário.

É certo que, consoante o enunciado da Súmula 45/STJ: “No reexame necessário, é defeso ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”. No entanto, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 686.751-MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que: “É lícito ao tribunal, em sede de reexame necessário, fazer incluir os juros legais em repetição de indébito, posto pedido implícito. Não há *reformatio in pejus* quando, em sede de remessa necessária, é aplicada a Taxa SELIC, a partir de 1.1.96, em substituição à correção monetária e aos juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado”. ²²⁶

Seção IV

Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Correspondência: art. 461 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 612 do CPC italiano, arts. 709 e 710 da LEC espanhola, art. 868 do CPC português

1. Aspectos gerais

Por meio da denominada ação mandamental ou executiva *lato sensu* procura-se obter tutela jurisdicional específica, em absoluta simetria ao bem da vida a que se obrigara o demandado ou, pelo menos, a alguma determinação que atenda, de forma equivalente, às expectativas do autor.

Em decorrência de novas exigências e do consequente aperfeiçoamento que permeia a ciência processual, os especialistas concluíram que o tradicional modelo da execução por meio de sub-rogação enseja, em muitas situações, enorme frustração ao credor vitorioso.

E, por isso, já há alguns anos, a nossa melhor doutrina influenciou o legislador pátrio a adotar, com maior ênfase, a técnica da tutela específica, para satisfazer, de forma efetiva, o interesse do credor.

No Brasil, o exemplo mais significativo desse desejo de superar as agruras da condenação em perdas e danos com a sucessiva sub-rogação estatal em bens do devedor, foi a possibilidade, introduzida pelo art. 84 do Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, pelos arts. 461 e 461-A do CPC/1973, de acesso à tutela específica, consistente na prestação de fazer, não fazer, ou dar coisa certa, visando a que o pronunciamento estatal não se revista de cunho simplesmente

ressarcitório do prejuízo experimentado pelo credor.

Como bem enfatiza Luiz Guilherme Marinoni, não há qualquer celeuma quanto à certeza de que a tutela específica atende de modo muito mais adequado ao direito material; a satisfação do credor na forma específica constitui remédio eficaz que, a um só tempo, de um lado, evita a monetização do dano, e, de outro, torna efetiva a reparação.²²⁷

Assim, uma vez acolhida a pretensão do demandante, consubstanciada na imposição de prestação específica, o provimento judicial deve recair exatamente sobre o bem da vida a que se obrigou o réu. Desrespeitado o comando, entram em cena as denominadas “medidas ou providências de apoio”, incluindo-se entre elas os meios coercitivos de pressão a fim de que seja cumprido o dever então imposto ao demandado.

Daí porque a técnica coercitiva, como corolário ínsito à tutela específica – na feliz reflexão de Talamini – torna-se “primordial à certeza e à segurança do direito”. A legitimidade deste mecanismo processual sempre pressupõe: *a*) o reconhecimento do dever cuja observância ele visa a assegurar; e *b*) a proporcionalidade entre a medida de coerção e o valor jurídico que se busca proteger.²²⁸

Desdobrando os arts. 461 e 461-A do antigo diploma processual, o novo CPC, sob a rubrica *Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, não fazer e de entregar coisa*, disciplina, nos arts. 497 a 501, o conteúdo da sentença referente à tutela específica.

Esclarece, nesse sentido, Cassio Bueno Scarpinella²²⁹ que, nitidamente, considerando as modalidades de obrigação (fazer, não fazer e entregar coisa), o legislador preferiu particularizar o conteúdo das sentenças que acolhem o pedido de tutela jurisdicional da forma de produção de seus efeitos. O conteúdo é regido pelos apontados dispositivos legais; já a eficácia das respectivas decisões vem disciplinada nos arts. 536 a 538, no capítulo atinente ao cumprimento da sentença (*Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa*).

2. Condenação na prestação específica

O *caput* do art. 497 do CPC contém duas importantes regras. Em primeiro lugar, reconhecendo a procedência do pedido, a decisão imporá um dever, infungível ou fungível, de fazer ou de não fazer, em consonância com a pretensão deduzida na petição inicial, concedendo, portanto, a prestação específica.

Esta é, de modo inequívoco, a forma mais plena e efetiva de proporcionar ao jurisdicionado a satisfação de seu direito. Diz-se, pois, que a tutela concedida pelo Estado-juiz é específica, porquanto, ao contrário das perdas e danos, corresponde, exatamente, àquilo que o autor pretende; daí sua natureza de especificidade, diferentemente das perdas e danos, que são fixadas quando não mais possível atingir-se o bem almejado.

Insere-se nesse contexto a célebre doutrina de Chiovenda²³⁰, ao exortar que: “o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir”.

Na verdade, em muitas situações só interessa ao contratante que a prestação venha cumprida exclusivamente pelo obrigado. Trata-se, à evidência, de uma prestação personalíssima. O artista que se nega a cumprir o contrato, cancelando a sua *performance*, dias antes, de forma abrupta e injustificada, irá se sentir compelido a se apresentar diante dos termos de decisão judicial coercitiva, que lhe imponha o dever de fazer, sob pena do pagamento de significativa multa. As *astreintes*, expressamente contempladas no § 1.º do art. 536 e, em particular, no art. 537 do CPC, constituem medida de execução indireta e são impostas em prol da expedita efetivação da tutela específica.

Ressalte-se, por outro lado, que, dependendo da natureza da prestação a ser cumprida, como,

por exemplo, o fornecimento de medicamentos, segundo decidiu a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.069.810-RS, sob o regime de recurso repetitivo, da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: “cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

231

À guisa de ilustração, lembra Marinoni ²³² que, nas hipóteses nas quais já foi industrializado, fabricado, importado ou exposto à venda produto de alto grau de nocividade ou periculosidade, ou dotado de defeito de concepção ou de fabricação, cabe igualmente tutela específica, por meio do ajuizamento da denominada “ação de remoção do ilícito”, com fundamento no art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, para que o produto seja apreendido ou inutilizado. Tratando-se de serviço, deve ser interditada sua comercialização.

3. Resultado prático equivalente

Ademais, a segunda regra que emerge do *caput* do art. 497 do CPC determina que, não sendo possível a concessão de tutela específica, o juiz deverá valer-se de medidas que possam assegurar “*resultado prático equivalente*”.

Isso significa que, embora não sendo exatamente aquilo que foi pleiteado pelo autor da demanda, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da prestação, a decisão judicial deve ao menos conceder algo que, de certa forma, possa também satisfazer o alvitre do demandante.

Avençada, por exemplo, uma decoração com flores e detalhes brancos, o contratante toma conhecimento, algum tempo antes do evento comemorativo, de que toda a ornamentação será em tom azul. Insatisfeito com o descumprimento da avença, o contratante ingressa em juízo pleiteando tutela específica, da forma como constou do pacto. Não obstante, constatada a efetiva impossibilidade de serem cumpridos os termos exatos do contrato, a sentença de procedência do pedido acolhe os pedidos subsidiários, formulados na petição inicial, determinando que a decoração seja produzida em tom verde, ou, sendo também impossível, que a prestação se converta em perdas e danos, de acordo com a regra do art. 499 do CPC.

Cumprе ressaltar que o resultado prático equivalente pode ser estabelecido de ofício ou ser objeto de cumulação subsidiária deduzida pelo autor (art. 326 CPC). Na primeira destas hipóteses, a evitar afronta ao princípio da adstrição, torna-se necessário colher-se a manifestação dos litigantes.

4. Inibição ou remoção de ilícito e irrelevância da prova de dano, de culpa ou de dolo

O parágrafo único do art. 497 do CPC dispensa o demandante da comprovação da ocorrência de dano ou da existência de elemento subjetivo – culpa ou dolo – no âmbito das ações inibitórias ou de remoção do ilícito.

Tenha-se presente que esta regra é inspirada na doutrina de Luiz Guilherme Marinoni.

A irrelevância da demonstração do dano ou do comportamento culposο ou doloso do agente, em tais situações, justifica-se porque estas demandas são dirigidas contra atuação contrária ao direito. Ao explicar o núcleo de seu pensamento, assevera Marinoni que, no caso da chamada ação de remoção, existindo regra jurídica estabelecendo um ilícito, a simples invocação da violação da norma é suficiente para permitir a coibir a ilicitude de eficácia continuada. “Os problemas das ações inibitórias e de remoção, nessas hipóteses, são justamente os dos limites da defesa do réu e o da extensão da cognição judicial. Ou seja, o que se pergunta é se, quando basta evidenciar a proibição de uma conduta, há como justificar a impossibilidade do réu discutir o dano e o juiz perguntar sobre ele nessas ações. Não temos dúvida que sim. No caso de direito absoluto, pouco importa o fato danoso, uma vez que o seu titular tem o direito de impedir qualquer ato que lhe seja contrário. O mesmo acontece em relação a normas que, embora relacionadas a direitos individuais, objetivam protegê-los através da vedação de condutas. Mas, o que mais importa são as

normas que, também por intermédio da proibição de condutas ou ações, protegem determinados direitos transindividuais (direito ao meio ambiente, direito do consumidor etc). Ora, se a norma objetiva dar tutela ao direito, impedindo certa conduta, ela foi editada justamente porque a sua prática pode trazer danos, e por isso deve ser evitada. Assim, ampliar a cognição das ações inibitória e de remoção do ilícito, viabilizando a discussão do dano, é o mesmo que negar a norma jurídica. Em outros termos: caso o réu pudesse negar a norma, afirmando que sua conduta não produziria dano, a norma não teria significação alguma. Do que adiantaria a norma proibir uma conduta, por entendê-la capaz de produzir dano, se o procedimento judicial abrisse oportunidade à discussão do que foi nela pressuposto? Pense-se, por exemplo, na norma que proíbe a venda de determinado remédio ou produto, reputados nocivos ao consumidor. Caso não existissem ações voltadas a impor a vontade da norma, sempre seria possível a comercialização de remédio ou produto afirmado nocivo pela legislação. Não existiria, nessa perspectiva, ação capaz de inibir ou remover o ilícito, pois o réu sempre poderia apresentar contestação dizendo que tal comercialização não iria trazer danos. Portanto, essas ações seriam reduzidas, no máximo, a uma ação contra a probabilidade de dano. E daí novamente apareceria a pergunta: qual a razão de ser das normas de proteção? (...)" ²³³

Assim, a alegação da possibilidade de ilicitude ou mesmo a verificação da prática de ato ilícito já é suficiente para garantir a tutela específica; se, contudo, demonstrada a existência de dano, de culpa ou de dolo, haverá, sem dúvida, maior razão para a sua respectiva concessão. ²³⁴

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Correspondência: art. 461-A do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 605 e 606 do CPC italiano, arts. 859 a 861 do CPC português, § 883 do ZPO alemão

1. Fixação de prazo para o adimplemento voluntário

No terreno da tutela específica, consistente na entrega da coisa objetivada pelo demandante, a decisão deverá conceder determinado prazo para que o réu possa adimplir a obrigação.

Considerando, pois, a natureza do objeto a ser entregue ao autor, diante da proposital omissão da lei, o juiz deve guiar-se pela razoabilidade, de modo que seja possível o cumprimento voluntário do comando judicial.

É certo presumir, por exemplo, que se tratando de coisa de grande dimensão (p. ex.: turbina para uma usina), exigindo a colaboração de terceiros, na logística de trânsito e estratégia de percurso, o prazo fixado deverá ser compatível com tais dificuldades.

Torna-se necessário outrossim considerar, no respectivo ato decisório, as regras dos arts. 327 e seguintes do Código Civil, relativas ao lugar do pagamento.

Acrescente-se que nos domínios de relação de consumo, o juiz não se encontra sujeito aos prazos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que são estabelecidos, nas diversas situações ali contempladas, para a substituição voluntária de partes viciadas ou do produto defeituoso.

Seja como for, consoante o disposto no art. 513, § 2.º, I, do CPC, inicia-se o prazo consignado na sentença a partir da intimação do réu na pessoa de seu advogado.

2. Individualização de coisa incerta

Tratando-se, por outro lado, de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o parágrafo

único do novo art. 498, aperfeiçoando a redação do § 1.º do revogado art. 461-A do CPC/1973, coerente com a exigência de que o pedido deve ser determinado (art. 324 CPC), impõe ao autor, cabendo-lhe a escolha, o ônus de individualizar, com a devida precisão, o bem pretendido.

A norma em apreço refere-se a coisa incerta, indicada apenas pelo gênero e pela quantidade ao ensejo da celebração do negócio (art. 243 CC), que se torna determinada por escolha no momento do pagamento. Coisa incerta, portanto, é aquela sujeita a determinação futura. A obrigação de dar coisa incerta que não se pode tornar certa “não é obrigação”. ²³⁵

Dependendo da natureza da coisa (p. ex.: café, açúcar), o processo de escolha, que pode inclusive ser atribuído a um terceiro, descortina-se complexo, exigindo a separação, pesagem, medição, contagem e expedição. A “concretização”, portanto, é a atividade que torna certo o objeto da prestação.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Correspondência: art. 461-A, § 1.º, do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Perdas e danos como sucedâneo da tutela específica

Inferre-se da sistemática adotada pela nova matriz processual, em particular, pelo art. 497 do CPC, que o legislador procurou estabelecer uma escala lógica de preferência, na qual sobressai a tutela específica; em segundo lugar, não sendo possível a concretização daquela, deve-se assegurar ao autor, ao menos, o resultado prático equivalente; ou, ainda, na impossibilidade deste, como último sucedâneo da tutela específica, a conversão em perdas e danos. ²³⁶

Assim, em princípio, a condenação será cumprida, visando, exatamente, ao que foi imposto pela sentença, convertendo-se em perdas e danos, se o credor assim o desejar ou, excepcionalmente, se impossível atingir aquele resultado.

2. Conversão em perdas e danos

Importa esclarecer que o próprio titular do direito lesado tem a faculdade de requerer, já na petição inicial, a condenação do réu em perdas e danos. Esta pretensão pode ser deduzida em caráter principal (e aí não mais estamos na esfera da tutela específica) ou – o que é mais plausível – como pedido subsidiário (art. 326 CPC), se, porventura, a prestação *in natura* não puder ser adimplida.

Ademais, a impossibilidade de cumprimento desta, por culpa do réu, pode ser constatada no curso do processo ou apenas no momento em que o seu implemento vier exigido.

Nestes casos, independentemente de requerimento do autor, a conversão em perdas e danos deve ser determinada pelo próprio juiz.

À luz do disposto no § 1.º do art. 461 do CPC revogado, a 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.293.365-RJ, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, teve oportunidade de se pronunciar no sentido de que: “Definida a obrigação pela prestação de tutela específica – seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa –, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente”. ²³⁷

Em senso análogo, a 2.ª Turma da mesma Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.450.223-SP, com voto condutor da lavra do Ministro Og Fernandes, patenteou que: “A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do art. 461, § 1.º, do CPC[1973], é medida excepcional cujo cabimento depende: *a*) ou do requerimento do credor; *b*) ou da impossibilidade

da tutela específica ou da obtenção do resultado prático correspondente”.²³⁸

Recente julgado do Tribunal de Justiça paulista, no Agravo de Instrumento n. 2013544-94.2018.8.26.0000, segue esse mesmo posicionamento ao interpretar o art. 499, ponderando que, considerada a superveniente falta de utilidade do estrito cumprimento da obrigação, converte-se esta em perdas e danos.

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Correspondência: art. 461, § 2.º, do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Imposição de multa coercitiva

Os arts. 536, § 1.º, e, em especial, 537 do novo diploma estabelecem o regime de fixação e incidência da multa coercitiva no âmbito das obrigações de fazer ou de não fazer.

A multa, nestas hipóteses, presta-se, como é cediço, para compelir o réu ao cumprimento específico da prestação que lhe foi imposta pela decisão judicial.

Já vimos que, primeiramente, deve-se buscar a tutela específica da obrigação, inclusive com a imposição da multa e/ou de outras medidas coercitivas complementares. Em último caso, visto que inócuas tais providências, converte-se a prestação em perdas e danos.

2. Cumulação da indenização com a multa coercitiva

A regra sob análise autoriza a cumulação dos danos com a multa fixada para alcançar o resultado específico, pressupondo, com acerto, que tais verbas têm diferente natureza.

Descumprida a obrigação determinada na sentença, incidirá a multa e o seu respectivo valor será devido pelo réu. Ademais, em decorrência do inadimplemento da tutela específica haverá conversão em perdas e danos.

É de ter-se presente, pois, que enquanto a multa é devida pela resistência ao cumprimento da decisão judicial, a indenização, no plano do direito material, decorre do prejuízo causado pelo descumprimento da obrigação.

Escreve Rinaldo Mouzalas²³⁹ que, em determinados casos, a despeito da incidência das *astreintes*, pode inexistir dano a ser reparado. Com efeito, no âmbito das ações inibitórias, por exemplo, a determinação judicial, num primeiro momento, vem desrespeitada, incidindo, portanto, a multa, embora não se constate dano algum, porque o próprio réu, em momento posterior, acabou desfazendo o ato que importaria prejuízo.

Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

Correspondência: arts. 466-A e 466-B do CPC/1973

Comparação jurídica: § 894 do ZPO alemão

1. Descumprimento da obrigação de prestar declaração de vontade

Celebrado um pré-contrato (compromisso de compra e venda, p. ex.), o vendedor, em momento posterior, descumpre a obrigação de prestar declaração de vontade relativa ao contrato principal, ou seja, nega-se ele a outorgar a escritura definitiva ao comprador.

Inadimplida, destarte, a obrigação de fazer consistente num ato pessoal do contratante, o

promitente comprador passa a ter interesse processual no ajuizamento de ação judicial visando à tutela específica, qual seja a de prestar declaração de vontade.

Julgado procedente o pedido e mesmo assim descumprido o comando judicial, a sentença produz todos os efeitos da declaração não emitida, afastando a possibilidade de ser arguido o princípio *nemo ad factum praecise cogi potest* (ninguém poderá ser coagido a prestar um fato).

Nesse caso, a teor da redação do art. 501 do CPC, a eficácia do provimento encontra-se condicionada ao seu trânsito em julgado, não se admitindo, portanto, antecipação da tutela e tampouco cumprimento provisório do título judicial.

2. Substituição da vontade não declarada

Cumpre registrar ser de todo desnecessário fixar prazo para que venha prestada a declaração de vontade, uma vez que a própria sentença já substitui plenamente a manifestação que deveria ter sido emitida pelo requerido.

Assevera, a propósito, Pontes de Miranda que basta, para o adimplemento, que o juiz diga o que a parte teria de dizer, tornando-se então possível a prestação *in natura*. Neste caso, é de todo despciendo coagir o demandado com a imposição de medidas coercitivas.²⁴⁰

Considerada a técnica eleita pelo legislador e partindo do pressuposto de que a execução é atividade para realizar os efeitos do ato – concluem Marinoni e Arenhart²⁴¹ – que não há certamente como admitir-se execução de sentença que imponha a tutela específica da obrigação de prestar declaração de vontade, uma vez que aí é o próprio ato decisório que produz os efeitos da prestação descumprida, inexistindo, pois, qualquer “atividade”.

Exatamente por esta razão é que não tem cabimento a cominação de multa na sentença de acolhimento do pedido, visto que se faz totalmente irrelevante qualquer colaboração do vencido para que o autor atinja o seu objetivo.

Assim, por exemplo, no caso de cancelamento de uma hipoteca, basta que o autor da demanda, após o trânsito em julgado, apresente a sentença no cartório de registro de imóveis, para que, substituindo esta a vontade do réu, seja providenciada a respectiva baixa do gravame.

Diante de tal premissa, bem é de ver que, nestas hipóteses, a própria sentença, por não admitir liquidação, já deve conter todos os dados necessários que individualizam o imóvel e sua respectiva matrícula.

Esta é a orientação que predomina no Superior Tribunal de Justiça, como se extrai de acórdão da 3ª Turma, proferido no Recurso Especial 1.033.893-RJ, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que: “A sentença de que trata os arts. 466-A e 466-B do CPC [1973] não pode constituir objeto de liquidação destinada à delimitação do objeto do contrato definitivo, pois deve conter, no momento de sua prolação, todos os elementos do título definitivo, de maneira a possibilitar o competente registro do imóvel”.²⁴²

Seção V

Da coisa julgada

1. Introdução

A ordem descortina-se essencial tanto à vida individual quanto ao convívio no seio da coletividade. Toda sociedade, independentemente de seu grau de evolução, pressupõe mínima organização, sem a qual de modo algum poderia subsistir. Conhecida é, a propósito, a exortação de Goethe, no sentido de que é preferível alguma injustiça à desordem, numa significativa demonstração de que ao seu sagaz espírito não passou despercebido que a existência normal do

ser humano impõe uma estabilidade que só a ordem permite proporcionar. Essa exigência de ordem, que traz implícita a noção de segurança, indispensável a qualquer modalidade de convivência, é de tal sorte profunda, que, ao longo do tempo, irrompe espontânea e natural.²⁴³

Com o desenvolvimento da sociedade, uma das principais funções das instituições públicas é a de construir estruturas de ordem e estabilidade para reger as relações entre os membros da comunidade. Cabe, assim, às normas jurídicas acrescentar a essa estabilidade ordenadora das instituições sociais, uma segurança específica e própria, à qual se costuma denominar de segurança jurídica.

Como bem destaca Arthur Kaufmann, na esteira, aliás, de secular concepção, um elemento indispensável da segurança jurídica é a força da coisa julgada das sentenças judiciais, significando que um provimento judicial que adquire tal *status* não mais pode ser impugnado pelos instrumentos jurídicos ordinários. “O processo se encontra terminado: *Roma locuta, causa finita*”.²⁴⁴

Com efeito, há certos institutos jurídicos que são predominantemente informados pela exigência de segurança e de certeza do direito. É o que se verifica, *e. g.*, no atinente à norma que fixa a maioria (e a capacidade para o exercício de direitos); àquelas regras que estabelecem prazos de prescrição e de decadência; que exigem determinadas formalidades para a validade ou para a prova de certos atos jurídicos; que procuram proteger a confiança ou a fé pública. Igualmente, um instituto como o da coisa julgada (insusceptibilidade de recurso contra as decisões judiciais transitadas em julgado) visa essencialmente a pôr um ponto final nos litígios. É famoso, a propósito, o brocardo *interest rei publicae ut sit litium finis* (...).²⁴⁵

Nos quadrantes do sistema jurídico brasileiro, nem mesmo a lei nova é passível de influir nos domínios da coisa julgada, como claramente se infere do disposto no art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal (“*a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*”), e no art. 6.º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“*A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada*”).

Tampouco a lei ou ato normativo considerado inconstitucional pela Suprema Corte, após a ocorrência do trânsito em julgado, pode infirmar a obrigação reconhecida em título executivo judicial (art. 525, §§ 12.º e 14.º, CPC).

A imutabilidade que passa a exornar o conteúdo decisório da sentença de mérito transitada em julgado, como expressivo e peculiar fenômeno da jurisdição, nos domínios do processo de conhecimento, tem por escopo, como é curial, de um lado, obstar à eternização dos litígios e, de outro, garantir a paz social, prestigiando a segurança jurídica, ainda que em detrimento da própria justiça.²⁴⁶

Com efeito, nesse sentido, ressalta Humberto Ávila²⁴⁷ que a coisa julgada funciona para conter a recorribilidade e a consequente reabertura da discussão da causa, ainda que a argumentação relacionada à justiça da decisão possa ser deduzida pela parte insatisfeita.

Importante decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello na Medida Cautelar no Mandado de Segurança 31.412-DF²⁴⁸ bem destaca, sob a ótica constitucional, a percepção que a nossa Suprema Corte tem acerca do instituto da coisa julgada, *in verbis*: “É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o instituto da *res iudicata*, que constitui atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro. Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas. Mostra-se tão intensa a intangibilidade da coisa julgada, considerada a própria disciplina constitucional que a rege, que nem mesmo lei posterior – que haja alterado (ou, até mesmo, revogado) prescrições normativas que tenham sido aplicadas,

jurisdicionalmente, na resolução do litígio – tem o poder de afetar ou de desconstituir a autoridade da coisa julgada. A necessária observância da autoridade da coisa julgada representa expressivo consectário da ordem constitucional, que consagra, dentre os vários princípios que dela resultam, aquele concernente à segurança jurídica. É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já fez consignar advertência que põe em destaque a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a consequente imprescindibilidade de amparo e tutela das relações jurídicas definidas por decisão transitada em julgado”.

É exatamente por tudo isso que, no âmbito do processo de conhecimento, para a formação da coisa julgada material – na pontual observação de Donaldo Armelin –, impõe-se (quase sempre ²⁴⁹) cognição plena e exauriente, não exigida em outras espécies de processo, possibilitando ao órgão jurisdicional a oportunidade de aprofundar-se no exame dos fatos e do direito, de modo que a imutabilidade outorgada pelo sistema jurídico à sentença possa produzir uma decisão que também preserve a justiça, evitando, tanto quanto possível, as consequências deletérias para as partes e para as próprias instituições, da deplorável situação na qual ocorra a dissociação desses valores fundamentais para a sociedade como são a justiça e a segurança jurídica. ²⁵⁰

É certo que a coisa julgada não é vetor essencial ao provimento judicial, mas possui indiscutível caráter preventivo, ao impedir que se retorne a discutir determinada matéria já submetida à apreciação do Judiciário.

Procurando destacar que o instituto da coisa julgada imbrica-se com a exigência de certeza nas relações jurídicas, assevera Chiovenda que: “são razões de oportunidade, concernentes à utilidade social, que determinam colocar um fim à cognição judiciária e considerar a sentença como lei irrevogável para o caso concreto”. ²⁵¹

A dogmática identifica, a propósito, a distinção entre coisa julgada formal, que caracteriza as “sentenças terminativas”, tornando-as imutáveis no respectivo processo em que proferidas, e coisa julgada material, que se forma sobre as “sentenças definitivas”, vale dizer, sentenças de mérito, cuja imutabilidade se projeta “para fora” do processo (pan-processual), impedindo qualquer ulterior contestação ao que restou decidido.

Escudado em abalizada doutrina, Sérgio Porto escreve que a expressão *coisa julgada formal* traduz-se na impossibilidade de novo julgamento pelas vias recursais, seja porque este já foi proferido por tribunal superior, seja porque transcorreu o prazo para recorrer sem que o vencido interpusse recurso, ou ainda porque se verificou a renúncia ou desistência da impugnação interposta. ²⁵²

Tendo como pressuposto lógico, a preclusão recursal (coisa julgada formal), a *coisa julgada material*, a seu turno, caracteriza-se pela imutabilidade do conteúdo decisório da sentença de mérito, tornando-o imutável e indiscutível aos litigantes a quem foi possibilitada a participação no contraditório. Na redação do novo art. 502, coisa julgada material é, sob a vertente técnica, “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Resta ainda acrescentar, nesta breve introdução sobre os aspectos mais significativos que emergem da teoria geral da coisa julgada, as duas importantes “funções práticas” que lhe são reservadas.

A função negativa, que obsta a repetição de demanda idêntica, caracterizada pela reprodução dos mesmos elementos subjetivo e objetivos (*tria eadem*) da ação anterior. A denominada função positiva, por outro lado, determina a situação jurídica das partes entre as quais foi proferida a sentença, que se encontram subjetiva e objetivamente vinculadas ao que foi definitivamente decidido.

2. Eficácia da sentença e delimitação da coisa julgada

Não se confunde a eficácia própria do ato judicial que tende à extinção da fase de conhecimento do processo com a imutabilidade do conteúdo declaratório da sentença que é

alcançada com o trânsito em julgado.

A eficácia sentencial, portanto, não se vincula à coisa julgada. Passada em julgado a sentença, adquire ela uma nota característica: a imutabilidade. Por esse prisma – anota Araken de Assis –, é preciso considerar a coisa julgada como instituto culminante de uma atividade, de uma atividade eminentemente teleológica, o processo. Desse modo, decisão imutável e indiscutível é aquela que atingiu estágio final de estabilidade, sob o ponto de vista do comando emitido por determinado órgão jurisdicional. A essência da coisa julgada reside exatamente na imutabilidade da sentença. E o interesse resguardado é o da paz social e segurança das relações jurídicas.²⁵³

Enquanto a sentença é a resposta ao pleito deduzido pelas partes, a coisa julgada material, por sua vez, coincide com o momento no qual a tutela jurisdicional é definitivamente prestada. Deriva desse fenômeno um duplo aspecto revestido de significativa conotação jurídica: de um lado, as partes não mais poderão submeter novamente a matéria decidida à apreciação do Poder Judiciário e, de outro, o Estado tem o dever de não reexaminar a controvérsia, já decidida, em sucessiva oportunidade.²⁵⁴

Foi no âmbito das vicissitudes do direito medieval que floresceu a ideia de traçar a distinção entre sentença e *res iudicata* pelo critério da impugnabilidade. Os juristas que desenvolveram o método da glosa aos textos romanos clássicos preconizavam que a expressão *res iudicata* era designativa da sentença não mais sujeita a qualquer recurso. Bártolo, expoente da Escola de Bolonha, doutrinava, em seus comentários, que a coisa julgada “*est causa quae finem controversie a sententia accipit*”.²⁵⁵

Assim como se orienta a moderna dogmática, o comando da sentença ficava imune a qualquer discussão futura apenas quando aquela não mais pudesse ser atacada por meio da apelação. No entanto, as fontes do direito comum certificam que, mesmo antes de passar em julgado, a sentença, em situações excepcionais, já poderia produzir efeitos.

Essa, aliás, tem sido a tendência nos sistemas processuais de época contemporânea (*e.g.* : art. 282 CPC italiano; art. 312, § 1.º, CPC do Vaticano; art. 514 NCPC francês; art. 1.398 CJ belga; art. 524 LEC espanhola).

Barbosa Moreira tratou amplamente desse assunto, lembrando que a eficácia dos atos jurídicos, em princípio, pode manifestar-se desde o próprio momento em que são celebrados, ficar diferida para uma ocasião ulterior, ou até mesmo reportar-se a momento anterior. E o mesmo ocorre com a sentença. À indagação: “quando começa a sentença a produzir efeitos?” não é possível responder senão à luz do direito positivo, visto que a produção da eficácia da sentença se inicia no momento determinado pela lei, ou por quem a lei autorize a fixá-lo. Observa, ainda, o processualista carioca que “a eficácia da sentença e sua imutabilidade suscitam duas ordens de questões inconfundíveis e, em linha de princípio, autônomas. Do ponto de vista conceptual, nada nos força a admitir correlação necessária entre os dois fenômenos... Fácil compreender, pois, que, embora a sentença se destine a produzir efeitos jurídicos, nem por isso se destina necessariamente a tornar-se imutável. A imutabilidade não é conatural à sentença – e isso continuaria a ser verdade mesmo que porventura não existissem, nem jamais tivessem existido, sentenças indefinidamente passíveis de modificação. Se as leis em regra excluem tal possibilidade e fazem imutável a sentença a partir de certo momento, o fato explica-se por uma opção de política legislativa, baseada em óbvias razões de conveniência prática”.²⁵⁶

Examinando a questão à luz do direito processual brasileiro, aduz Dinamarco que, em certa medida, a nossa legislação libera os efeitos da sentença, ou, pelo menos de alguns deles, mesmo antes da coisa julgada. Contudo, adverte ser prudente “condicionar em tese a eficácia da sentença à sua imutabilidade, embora essa correspondência não é necessária nem constante porque há também razões para liberar a primeira, em alguns casos, antes que ocorra a segunda. Eficácia e imutabilidade são conceitos distintos (Liebman)”.²⁵⁷

Os efeitos principais da sentença de procedência do pedido devem guardar conformidade com a manifestação de vontade nela especificada e, em princípio (art. 1.012, 1ª parte), não se produzem

se a decisão for impugnada por meio de recurso recebido no efeito suspensivo. No entanto, tais efeitos podem ser liberados, *ope legis*, independentemente do trânsito em julgado. Os arts. 1.012, 2ª parte, do novo CPC; art. 58, V, da Lei 8.245/1991; e art. 14 (*a contrario sensu*) da Lei 7.347/1985, contemplam algumas das exceções à regra.

Ainda que caracterizada pela natural instabilidade, a sentença impugnada, quando provisoriamente executada deve produzir efeitos apenas entre as partes, primeiras destinatárias do ato decisório, mas, pode também repercutir na esfera do direito de um terceiro. Não há confundir, em tal situação, a eficácia própria da decisão com os efeitos (secundários) de atos materiais daquela decorrentes, como, por exemplo, a constituição da hipoteca judiciária (art. 495).
258

3. Conceito legal de coisa julgada material

Afastando-se do sábio conselho do jurista romano de época clássica Javoleno Prisco, no sentido de que *omnis definitio in iure civili periculosa est*, o art. 467 do CPC/1973 definiu os contornos da coisa julgada material, circunstância que, a meu ver, deu ensejo a infrutífera polêmica e copiosa literatura.

A partir do clássico conceito de coisa julgada desenhado por Liebman, então constante do art. 507 do Anteprojeto Buzaid, acabou sendo mutilado o texto original, uma vez que, como bem elucida Araújo Cintra ²⁵⁹, sofreu ele inúmeras emendas e alterações durante a tramitação legislativa.

Embora reputando mais adequada a redação que acabou vingando no art. 467 do CPC/1973, Barbosa Moreira, em vários ensaios, sempre a censurou, ao mostrar que os efeitos da sentença passada em julgado são programados para se modificarem no mundo fático. Desse modo, não se destinam eles a perdurar indefinidamente, visto que “o efeito executivo da sentença condenatória, v.g., destina-se, em princípio, à exaustão: acaso restará dele algum vestígio, por exemplo, depois da execução forçada? O efeito da sentença constitutiva que se identifica com a nova situação jurídica gerada, é obviamente passível de futuras modificações, e até de completo desaparecimento, caso as partes, sendo possível, se disponham a restaurar, por acordo de vontades, a situação anterior. A sentença meramente declaratória ‘certifica’ em caráter oficial a existência ou a inexistência de uma relação jurídica; mas é claro que, após o trânsito em julgado, pode extinguir-se a relação jurídica declarada existente, ou nascer a relação jurídica declarada inexistente – e com isso, à evidência, cessa o efeito ‘certificativo’ da sentença”. ²⁶⁰

Anote-se que em escrito anterior, Barbosa Moreira ²⁶¹ já havia enfrentado a doutrinação de Liebman, contestando a tese de que a imutabilidade é uma qualidade que atinge todos os efeitos da sentença transitada em julgado.

Ovídio Baptista da Silva, a seu turno, ao travar intenso debate teórico com Barbosa Moreira, assevera que a imutabilidade que reveste a decisão jurisdicional, identificável com a coisa julgada material, somente se conecta ao efeito declaratório da sentença, “que diz respeito exclusivamente às partes figurantes da relação jurídica processual”. ²⁶²

Na esteira do ponto de vista externado por Botelho de Mesquita, entendo que, após o desenvolvimento da atividade lógica, o julgador, ao proferir a sentença, passa então a declarar a vontade da lei, num ato que transpõe os limites do processo e influi diretamente no julgamento da lide. É nesse momento que o juiz dá a resposta à pretensão das partes, consubstanciada na determinação judicial, no dispositivo da sentença.

Segundo difundida lição de Chiovenda, o julgador, *enquanto razoa* (ato de inteligência), não representa o Estado; representa-o enquanto lhe afirma a vontade. A sentença é unicamente a afirmação ou a negação de uma vontade que assegura ao demandante um bem da vida no caso concreto; e só a isto se pode estender a autoridade do julgado (vontade da lei); com a sentença só se consegue a certeza da existência de tal vontade e, pois, a incontestabilidade do bem reconhecido ou negado. ²⁶³

A eficácia desse comando jurisdicional se projeta fora do processo, incidindo diretamente sobre a lide. E é essa parte da sentença que, afinal, fica imune a futuras discussões entre as partes que se submeteram ao contraditório.

Verificado, pois, o trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível a sentença: “não a sentença toda, mas o seu elemento declaratório e a manifestação de vontade a que se vincular o efeito pretendido pelo autor, ou o juízo de improcedência da ação”.

Aduza-se que, segundo Botelho de Mesquita, a imutabilidade e a indiscutibilidade são efeitos que o direito positivo atribui à conclusão (dispositivo) da sentença, ao ensejo do trânsito em julgado, independentemente de qual seja o conteúdo do elemento declaratório. “A esse efeito se denomina coisa julgada material”, que se diferencia da coisa julgada formal, marcada pela mesma indiscutibilidade e imutabilidade, mas apenas “dentro do próprio processo em que foi proferida” (art. 473 CPC/1973).

A consequência prospectiva da imutabilidade da sentença caracterizada pelo trânsito em julgado consiste exatamente, como acima frisado, no óbice de uma nova ação idêntica àquela já definida por sentença imunizada pela autoridade da coisa julgada.

De modo diferente, a indiscutibilidade repercute em quaisquer processos, nos quais o julgamento do pedido deduzido pelo autor depender do julgamento de questão prévia, que tenha sido decidida *principaliter* em precedente processo, pendente entre as mesmas partes.

Como enfatiza Botelho de Mesquita, o juiz do processo sucessivo está obrigado a tomar como premissa de sua decisão o resultado do processo anterior.

Assim sendo, “a imutabilidade e a indiscutibilidade atuam de modo diverso: a imutabilidade impede que o juiz posterior se pronuncie sobre a ação já decidida por sentença transitada em julgado. Cria a exceção de coisa julgada. A indiscutibilidade obriga o juiz posterior a decidir em conformidade com o decidido pela sentença transitada em julgado”.

Assinala, ainda, Botelho de Mesquita, que a “indiscutibilidade decorrente do trânsito em julgado opera apenas entre as partes, enquanto o efeito declaratório vincula tanto as partes como terceiros; assim, terceiros interessados têm plena liberdade para discutir em processo futuro a conclusão da sentença anterior transitada em julgado, mas não podem se opor ao vínculo criado pela declaração pronunciada na sentença de procedência de uma ação declaratória (*e. g.* , a declaração de falsidade do documento)”. ²⁶⁴

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Correspondência: art. 467 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 500 do NCPC francês, art. 2.909 do CC italiano, arts. 207 e 222 da LEC espanhola, art. 619 do CPC português, § 322 do ZPO alemão, art. 336 do SZO suíço, art. 23 do CJ belga

1. Aspectos gerais

Esta nova regra legal procurou eliminar a redação imprecisa do supra referido art. 467 do CPC/1973, que culminou gerando toda a celeuma acima sintetizada, abandonando o vocábulo “eficácia”. No entanto, valendo-se ainda uma vez da doutrina de Liebman, o novel dispositivo reveste a coisa julgada material com o atributo de “autoridade”, para apontar a qualidade soberana que se agrega à decisão de mérito, consistente na sua ulterior imutabilidade e indiscutibilidade.

Coerente com a classificação dos provimentos jurisdicionais catalogados no art. 203 do CPC, o art. 502 alude à expressão “decisão de mérito”, em substituição a “sentença”, visto que o novo CPC admite expressamente, no art. 1.015, II, a prolação de decisões interlocutórias de mérito.

Assim, por exemplo, caso o pedido reconvençional, nos termos do art. 332, seja julgado liminarmente improcedente, a respectiva decisão tem natureza interlocutória (de mérito), passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II).

Sob a perspectiva histórica, bem é de ver que o novel diploma processual restabeleceu (provavelmente, de forma involuntária), a velha categoria, provinda do direito reol, das “decisões interlocutórias com força de definitivas”!

2. Confronto entre a estabilidade da tutela antecipada e a coisa julgada material

O art. 304, alterando a técnica do diploma de 1973, institui a denominada “estabilização da tutela antecipada”, caso o requerido não interponha agravo de instrumento (ou mesmo apresente contestação ²⁶⁵), situação que implica a extinção do processo, com a ratificação do provimento antecipatório, sem, contudo, enfrentar o mérito.

Não obstante, o respectivo pronunciamento judicial antecipatório continua sendo proferido no âmbito de cognição sumária e caracterizado pela provisoriedade, uma vez que fica na dependência de posterior confirmação, no bojo de ato decisório de mérito, para que seus efeitos se produzam, depois do trânsito em julgado, de forma definitiva.

Ademais, a teor do disposto no § 5.º da apontada norma legal, extingue-se o direito de ajuizar ação autônoma, visando a “*rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada*”, após o transcurso de 2 anos, a partir da intimação da decisão que pôs fim ao processo. Esse lapso temporal tem natureza decadencial, de sorte que futura demanda ajuizada além desse prazo está sujeita à extinção do processo com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Trata-se, como se observa, de técnica análoga àquela que se verifica no procedimento monitório, com a inversão do ônus de demandar. Com efeito, uma vez expedido o mandado de pagamento, de entrega de coisa móvel ou imóvel, ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700), descumprida a determinação judicial e não opostos os embargos no prazo legal, a decisão liminar torna-se estável.

Sob a égide do Código revogado, no âmbito do respectivo cumprimento de sentença em sede monitória, sempre defendi a tese de que o devedor poderia deduzir matéria de mérito na impugnação que vier a oferecer (matéria essa que poderia ter sido já alegada nos embargos ao mandado de pagamento ou de entrega, não opostos em tempo hábil). ²⁶⁶

Todavia, diante do contexto desenhado pelo novo CPC, o § 3.º do art. 701 prevê o cabimento de ação rescisória contra a decisão determinativa da expedição do mandado, que se converte de pleno direito em título executivo judicial, quando inadimplida a obrigação ou não opostos os embargos (art. 701, § 2.º). O referido provimento judicial é, ao menos para o legislador, considerado decisão de mérito, produz coisa julgada material e, portanto, delineia-se passível de rescisão.

Já na esfera do procedimento da tutela antecipada o regime é diferente, até porque o novo diploma não é suficientemente explícito.

Em primeiro lugar, bem é de ver que o efeito ou efeitos antecipados se estabilizam por força de presumido conformismo das partes.

Contudo, exatamente por não alcançar a imutabilidade e a indiscutibilidade, atributos peculiares à coisa julgada material, o fenômeno que aqui se observa não se subordina a qualquer eficácia preclusiva, podendo a questão litigiosa ser reexaminada na impugnação eventualmente apresentada, pelo devedor, em sede de cumprimento da decisão estabilizada, ou ainda em futuras demandas entre as mesmas partes.

Nesse sentido, Heitor Sica escreve, em minuciosa investigação crítica, que a decisão estabilizada não parece ter a função positiva (típica da coisa julgada material) de influir sobre a sentença a ser proferida em processo futuro, instaurado entre os mesmos litigantes. ²⁶⁷

Por fim, cabe enfatizar que, não produzindo coisa julgada material, a tutela antecipada já estabilizada não é passível de ser atacada por meio de ação rescisória. Essa conclusão não causa qualquer perplexidade, até porque a parte, que deixou transcorrer o prazo de 2 anos para ajuizar ação autônoma de impugnação da decisão estável, não poderia mesmo ser premiada com mais um biênio para tentar rescindi-la: *dormientibus non succurrit ius* !

3. Coisa julgada sobre decisões parciais de mérito e inconstitucionalidade do art. 975 do CPC

É da tradição da doutrina processual brasileira, firme na melhor literatura italiana, sustentar que pode existir no mesmo processo mais de uma decisão de mérito, rescindíveis por meio de autônomas ações rescisórias. Partindo das teorias da cumulação de demandas e dos capítulos da sentença, nada obsta a que, por exemplo, a parte, condenada nos dois pedidos formulados pelo autor, recorra apenas de um deles.

Nunca houve dúvida de que o capítulo da decisão de mérito que restou irrecorrido, ao transitar em julgado, é passível de desconstituição via ação rescisória, cujo biênio decadencial se inicia a partir do respectivo trânsito em julgado. Lembro-me inclusive de antigo e pioneiro ensaio escrito pelo saudoso Professor Alcides de Mendonça Lima,²⁶⁸ que defendia, com muita acuidade, sob a égide do CPC/1973, o cabimento de ação rescisória contra decisão interlocutória de mérito, sendo o *dies a quo* do lapso de 2 anos computado da respectiva preclusão.

Ademais, como acima referido, o novo CPC admite expressamente a prolação de decisões interlocutórias de mérito.

Não obstante, a despeito da sólida construção doutrinária e jurisprudencial acerca dessa questão, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no famoso julgamento, ocorrido em 2003, dos Embargos de Divergência 404.777-DF, de relatoria do ministro Peçanha Martins, por apertada maioria e de forma inusitada, passou a sufragar o entendimento de que: “Sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial. Consoante o disposto no art. 495 do CPC [1973], o direito de propor a ação rescisória se extingue após o decurso de 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa”. Tem-se, pois, como evidente o indevido acréscimo à regra do art. 495: “da última decisão proferida na causa”.

Afirmava, com razão, Rui Barbosa que a alteração abrupta de um preceito normativo ou a modificação de uma orientação jurisprudencial sedimentada tem a potencialidade de derrubar uma biblioteca inteira! E, ainda – permito-me acrescentar – de destruir o princípio da confiança!

Foi exatamente o que ocorreu, com a posterior edição da Súmula 401/STJ, que secundou o supra referido *leading case*: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”. E isso porque, com toda certeza, tal princípio sumulado conspirava contra a lei (art. 495 CPC/1973), a melhor exegese e, ainda – o que é muito pior –, contra a garantia da coisa julgada (art. 5.º, XXXVI, CF), e, conseqüentemente, punha em xeque a segurança jurídica.

Com efeito, suponha-se o reconhecimento parcial da prescrição decidido, por exemplo, há 7 anos, numa decisão interlocutória de saneamento de um processo ainda em curso. Ora, segundo o enunciado da indigitada Súmula 401, o prazo decadencial de 2 anos, para o ajuizamento da ação rescisória contra aquele ato decisório, ainda não se iniciou!

Como advogado militante curvei-me ao equivocado posicionamento hermenêutico do Superior Tribunal de Justiça sobre esta importante questão, mas, como estudioso do processo, sempre fui um fervoroso crítico.

Pois bem, passado o tempo, aquele mencionado acórdão proferido nos Embargos de Divergência 404.777-DF foi impugnado pelo Recurso Extraordinário 666.589-DF, distribuído, no Supremo Tribunal Federal, ao Ministro Marco Aurélio.

Observe que a 1ª Turma, ao julgar em 25 de junho de 2014, tal impugnação, cujo fundamento

deduzido foi a ofensa ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal (“intangibilidade da coisa julgada”), o proveu, à unanimidade de votos, com a seguinte e expressiva ementa: “Coisa julgada – Pronunciamento judicial – Capítulos autônomos. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória”.

Reconhecendo o valor da doutrina e da própria jurisprudência da Suprema Corte, lê-se no corpo do acórdão que: “Está em jogo definir o momento preciso em que ocorre o fenômeno da coisa julgada para efeito de assentar o início da fluência do prazo decadencial relativo à propositura de ação rescisória, considerado processo revelador de pedidos cumulados, mas materialmente divisíveis, em que as decisões concernentes a cada qual se tornaram definitivas em momentos distintos. A controvérsia envolve saber se é possível cogitar de trânsito em julgado individual das decisões autônomas e a implicação dessa cisão para a contagem do prazo de decadência da rescisória. O Superior Tribunal de Justiça, apontando o caráter unitário e indivisível da causa, consignou a inviabilidade do trânsito em julgado de partes diferentes do acórdão rescindendo, devendo o prazo para propositura de demanda rescisória começar a partir da preclusão maior atinente ao último pronunciamento. Com essas premissas, deu provimento a especial do Banco Central para admitir pedido rescisório, afastada a decadência reconhecida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O acórdão impugnado está em desarmonia com a melhor doutrina sobre o tema e com a jurisprudência do Supremo, encerrando violação à garantia da coisa julgada, prevista no art. 5.º, XXXVI, da Carta da República. Consoante a circunstância de haver capítulos dos pronunciamentos repercute, necessariamente, sobre a determinação do objeto possível dos recursos, seja quanto ao conteúdo, seja no tocante ao legitimado recursal. Unidades autônomas de pedidos implicam capítulos diferentes que condicionam, objetiva ou subjetivamente, e sem prejuízo do princípio da unicidade recursal, as vias de impugnação disponibilizadas pelo sistema normativo processual — recursos parciais ou interpostos por ambos os litigantes em face do mesmo ato judicial formalmente considerado. O caso concreto descreve muito bem o fenômeno — a cláusula do acórdão relativa aos danos emergentes foi desafiada por especial do Banco Central, a alusiva aos lucros cessantes, atacada por recurso da PEBB Corretora de Valores. Pressupostos diversos questionados mediante recursos interpostos por partes adversas em razão de fragmentos autônomos do mesmo acórdão. Essa distinção provoca reflexos no cumprimento do ato — que pode ser realizado de modo independente —, assim como — e esta é a questão central deste processo — no trânsito em julgado, que se mostra passível de ocorrer em momentos separados presentes os capítulos autônomos da decisão. É nesse sentido o entendimento do Supremo, como ficou decidido na 11ª Questão de Ordem na Ação Penal 470-MG, relator ministro Joaquim Barbosa, julgada em 13.11.2013, *DJ* de 19.02.2014. Na ocasião, o tribunal, por unanimidade, concluiu pela executoriedade imediata dos capítulos autônomos do acórdão condenatório, declarando o respectivo trânsito em julgado, excluídos aqueles objeto de embargos infringentes. Considerada a implicação apontada pelos mestres de ontem e de hoje, deve ser recusada qualquer tese versando unidade absoluta de termo inicial do biênio previsto no art. 495 do CPC. O prazo para formalização da rescisória, em homenagem à natureza fundamental da coisa julgada, só pode iniciar-se de modo independente, relativo a cada decisão autônoma, a partir da preclusão maior progressiva. Nas palavras de Humberto Theodoro, revelada a presença de capítulos diferentes e de recursos parciais, ‘não há como fugir da possibilidade de contar-se o prazo da rescisória a partir do trânsito em julgado de cada um dos capítulos em que se dividiu a sentença, se nem todos foram uniformemente afetados pelos diversos recursos manejados’ (*Curso de direito processual civil*, vol. 1, 52ª ed., 2011, p. 745-746). Os fundamentos até aqui desenvolvidos revelam, a mais não poder, que o acórdão atacado implicou transgressão ao art. 5.º, XXXVI, da Carta. A rescisória dirige-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, confirmando condenação quanto a danos emergentes, cujo trânsito em julgado ocorreu em 8 de fevereiro de 1994. Essa é a data a corresponder ao termo inicial do prazo decadencial, e não aquela, referente à preclusão maior da última decisão — 20 de junho de 1994 —, envolvido especial do recorrente e versados lucros cessantes, matéria que não é objeto da demanda rescisória. Devem ser reconhecidos, sob pena de afronta à garantia constitucional, dois momentos distintos do trânsito em julgado, sendo apenas o primeiro relevante para a formulação do presente pedido rescisório. Tendo sido formalizada a ação em 6 de junho de 1996, evidencia-se a decadência do pleito. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao extraordinário para reformar o acórdão recorrido,

assentando a decadência do direito e negando seguimento ao pedido rescisório”.

Conclui-se, assim, pela superveniente insustentabilidade da Súmula 401/STJ, diante de sua flagrante inconstitucionalidade por violar a coisa julgada material, reafirmando-se, destarte, a supremacia da segurança jurídica em prol da sociedade!

Contudo, a despeito desse recente e judicioso pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, de modo surpreendente e, a meu ver, sem qualquer justificativa plausível, ao ensejo da tramitação perante a Câmara dos Deputados, foi introduzida a esdrúxula redação do *caput* do art. 975 do novel diploma processual, ²⁶⁹ que já desponta natimorto, dada a sua manifesta inconstitucionalidade.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1.º O disposto no *caput* aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I – dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2.º A hipótese do § 1.º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Correspondência: arts. 468 e 325 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 480 do NCPC francês, art. 621 do CPC português

1. Aspectos gerais

Com o trânsito em julgado, o conteúdo declaratório da sentença ou da decisão interlocutória de mérito torna-se imutável e indiscutível. Este fenômeno, de natureza processual, traz repercussões no plano subjetivo, porque vincula os litigantes que potencial ou efetivamente participaram do contraditório (limites subjetivos), e, também no plano objetivo, visto que delimita o objeto material do julgamento (limites objetivos).

O art. 503, ora sob apreciação, encerra os denominados limites objetivos da coisa julgada.

Importa esclarecer que a expressão “força de lei”, constante do *caput*, significa trânsito em julgado, a evidenciar que não mais é passível de discussão o núcleo decisório da sentença.

No entanto, o novo preceito afastou-se da redação do art. 468 do CPC/1973, dispondo agora, que o provimento de mérito, total ou parcial, faz coisa julgada exclusivamente em relação à “questão principal”, ²⁷⁰ vale dizer, aquela ou aquelas decididas *principaliter*.

A “questão principal”, isto é, o objeto litigioso, pode ser simples ou complexo, a depender dos capítulos que integram a pretensão deduzida pelo autor. Em simetria com o disposto no art. 356 do CPC, não há óbice a que o julgamento do mérito seja cindido, podendo o juiz proferir ato decisório antecipado, julgando parcialmente um ou mais dos pedidos, que integram a “questão principal”, quando reputados incontroversos, nas hipóteses em que a matéria dispensar a produção de prova ou, ainda, em que houver revelia, tudo nos termos do art. 355, I e II, do CPC.

Estabelecendo que o pronunciamento judicial não extravasa os limites da questão principal expressamente decidida, o novo CPC adotou, no art. 504, a teoria que restringe a coisa julgada à

parte dispositiva da sentença, não abrangendo, portanto, as questões prejudiciais e tampouco os motivos que serviram de alicerce à decisão.

Assim, por exemplo, a improcedência do pedido formulado em ação anulatória de escritura pública de reconhecimento de filiação não impede o subsequente ajuizamento de ação declaratória de inexistência da relação de paternidade, fundada na ausência do vínculo biológico, a ser demonstrada por prova pericial hematológica. E isso porque, como explica Ada Pellegrini Grinover, “o objeto do processo instaurado pela ação anulatória, de um lado, e o objeto do processo sucessivo, de outro lado, são diversos, de tal sorte que os limites objetivos da coisa julgada formada em torno daquele não abarcam os limites do objeto do processo da ação declaratória subsequente”.²⁷¹

Ademais, o órgão jurisdicional não só precisa ater-se aos lindes do objeto litigioso como deve abster-se de conhecer de ofício fatos que importem a ampliação da controvérsia (*ne eat iudex ultra petita partium*). O novo art. 141 (= art. 128 CPC/1973) procura, com efeito, ministrar um harmônico equilíbrio entre os horizontes da demanda e os poderes cognitivos do órgão jurisdicional: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas e a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Todavia, sendo esse igualmente o regime que prevalecia nos arts. 5.º, 325 e 468 do CPC revogado, a técnica apta a contornar os inconvenientes da estreiteza dos limites objetivos da *res iudicata*, estendendo a coisa julgada às questões prejudiciais, de sorte a permanecerem elas insuscetíveis de discussão, após o encerramento do processo e transitada em julgado a sentença, era o ajuizamento da denominada ação declaratória incidental, que tinha exatamente a finalidade de permitir que se decidisse com força de coisa julgada determinada questão logicamente subordinante daquela que constituía fundamento do pedido.

Entrava então em cena, pois, a “lide prejudicial”, aquela que – no dizer de Buzaid –, embora pudesse ter constituído objeto de processo autônomo, poderia ser ajuizada por qualquer das partes, mediante ação declaratória incidental.²⁷²

O art. 503, sob análise, pretendeu, ao que tudo indica, extinguir a previsão desta demanda do novel diploma.

2. Questão principal, questão autônoma e questão prejudicial

Em anterior estudo, tive oportunidade de afirmar que a regra da eventualidade, mantida no art. 508 do CPC, e a respectiva substanciação da demanda dizem respeito exclusivamente à questão principal, ou seja, àquela delimitada pelo autor na *causa petendi* da petição inicial, de modo que se puder ser deduzida diferente questão, ainda que para o mesmo pedido, não haverá óbice algum para a propositura de outra ação, uma vez que esta não será idêntica à primeira.²⁷³

Trata-se, como se observa, de questão autônoma, que poderá ser deduzida, em cumulação, no mesmo (art. 327 CPC) ou em outro processo.

Esta questão autônoma (e, portanto, principal) poderá igualmente, numa determinada demanda, ser prejudicial ao julgamento da questão principal. O teor da solução desta (prejudicada) depende do resultado daquela (prejudicial), como sucede, por exemplo, em relação à existência da obrigação principal, debatida na ação de natureza condenatória ajuizada em face do fiador.²⁷⁴

Adverte, a propósito, Fredie Didier Júnior²⁷⁵ que “a questão prejudicial pode ser principal ou incidental – *nem toda questão prejudicial é incidental*. Quando a questão prejudicial é o próprio objeto litigioso do processo (questão a ser resolvida *principaliter*), a doutrina costuma referir-se à causa prejudicial, ao invés de ‘questão prejudicial’, expressão que ficaria restrita à situação em que o exame da questão fará parte apenas da fundamentação da decisão – ou seja, quando a questão prejudicial é incidental”.

Barbosa Moreira ²⁷⁶ anota, no entanto, que a questão prejudicial pode também ostentar natureza estritamente processual, como, *e. g.*, aquela sobre o valor da causa, em relação à questão sobre o recurso cabível da decisão que julga o respectivo incidente. Dúvida não há de que a questão subordinante só tem sentido no âmbito de determinado processo, não se admitindo que possa constituir objeto de apreciação judicial autônoma, em outro processo.

3. Questão prejudicial expressa e incidentalmente decidida e coisa julgada

Preceitua o art. 503, § 1.º, que a coisa julgada abrange a solução da questão prejudicial incidental, expressamente decidida na sentença. É um exemplo típico de que o dispositivo desta decisão não estará, do ponto de vista formal, na parte final da sentença. Localizar-se-á, em regra, entremeadado na motivação do ato decisório.

A coisa julgada material, em tal hipótese, irá se estender não apenas ao dispositivo atinente à questão principal, mas, igualmente, àquele que resolveu, expressa e incidentalmente, a questão prejudicial.

A opção legislativa aqui regrada autoriza, portanto, que se decida também com força de coisa julgada determinada questão jurídica logicamente subordinante daquela que constitui a questão principal, como, *v.g.*, o reconhecimento de união estável, numa demanda em que se visa a partilha de bens comuns.

O importante, como em seguida será frisado, é que a prejudicial seja determinante do julgamento do *meritum causae*.

A expansão da coisa julgada, ditada pelo art. 503, § 1.º, independe de pedido das partes. Isso significa que tanto o autor quanto o réu, na fase postulatória, podem suscitar a questão prejudicial.

Na verdade, como ainda esclarece Didier Júnior, “há uma ampliação do objeto da coisa julgada por determinação legal”, como, aliás, assentou o Enunciado 165 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Independentemente de provocação, a análise de questão prejudicial incidental, desde que preencha os pressupostos dos parágrafos do art. 503, está sujeita à coisa julgada”. ²⁷⁷

4. Requisitos para a extensão da coisa julgada à questão prejudicial

Em princípio, como se infere do *caput* do art. 503, apenas o julgamento da questão principal é que se subordina à coisa julgada material.

Todavia, também pode ser abrangida pela coisa julgada a questão prejudicial, expressa e incidentalmente, decidida, quando, cumulativamente, preencher os pressupostos exigidos pelos incs. I a III do § 1.º do art. 503, quais sejam: *a*) de sua resolução depender o julgamento da questão principal (prejudicada); *b*) que sobre o *thema decidendum* da prejudicial tenha ocorrido efetivo contraditório, excluindo-se, portanto, a hipótese de revelia; e *c*) o juízo perante o qual pende a demanda for também competente, *ratione materiae* e *ratione personae* para resolver a questão prejudicial.

Note-se que o debate prévio travado entre as partes constitui, segundo adverte Thiago Ferreira Siqueira, “condição de existência da coisa julgada”, de sorte que, vulnerado o contraditório, não há se falar em coisa julgada acerca de julgamento de questão prejudicial, sendo, inclusive, absolutamente desnecessário o ajuizamento de ação rescisória. ²⁷⁸

Novidade inserida no Anteprojeto e no Projeto do Senado, verifica-se que o legislador não descuro das garantias processuais nesta situação, que acaba gerando séria consequência na esfera de direitos dos litigantes.

5. Incontornável problema prático

A distribuição da petição inicial, prevista no art. 285 do CPC, produz inúmeros efeitos materiais e processuais.

Dentre aqueles, presta-se a certificar o ajuizamento de demanda em face de determinado sujeito de direitos. Assim, o registro das ações judiciais, a partir da distribuição, constitui importante subsídio para que se tenha conhecimento da situação jurídica do patrimônio pertencente à pessoa com quem se está entabulando algum negócio. É comum, pois, na praxe negocial, a extração de certidões pessoais do vendedor, entre outras, do cartório do distribuidor.

Ora, ajuizada uma demanda de natureza meramente declaratória, é muito provável que o pedido formulado em face do réu não produza potencialmente qualquer repercussão na situação financeira deste. É esta demanda que então constará da certidão expedida pelo distribuidor.

Sob a égide do regime processual anterior, o ajuizamento das ações incidentais, como, por exemplo, a reconvenção, a ação declaratória, era devidamente comunicado ao distribuidor para anotações. Passavam assim a constar da respectiva certidão.

Com o novo modelo, agora instituído, somente com a prolação da sentença é que será possível diagnosticar o raio de abrangência objetiva da coisa julgada, podendo acarretar gravíssimo problema, de ordem econômica, se porventura a sentença transitada em julgado tiver alguma repercussão patrimonial, decorrente da questão prejudicial expressa e incidentalmente decidida.

Não se afasta até mesmo a indevida utilização da técnica processual instituída no § 1.º do art. 503 para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC).

6. Situações excluídas: restrições probatórias e limitações à cognição

Dispõe ainda o § 2.º do art. 503 que a hipótese excepcional de extensão dos limites objetivos da coisa julgada material à questão prejudicial, disciplinada no precedente § 1.º, não se viabiliza quando houver restrições à produção da prova, como, v.g., verifica-se na ação de mandado de segurança, que admite apenas prova documental pré-constituída. A exemplo do que sucede no caso de revelia (art. 503, § 1.º, II), aqui também há óbice legal para a ampliação alvitrada.

Igualmente, o mesmo ocorre em algumas espécies de tutela jurisdicional diferenciada, que se afastam do procedimento comum, nas quais a própria legislação impõe restrições à liberdade de iniciativa do autor quanto à demarcação da *causa petendi*.

As ações possessórias configuram exemplo típico de demandas cujo conteúdo objetivo sofre limitação *ex lege*. A cognição sumária, que caracteriza tais demandas, obsta a que o autor deduza causa de pedir fundada em domínio.

O art. 525, § 1.º, do novo CPC, que cataloga o rol de fundamentos passíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença condenatória, do mesmo modo, delimita acentuadamente o âmbito de cognição deduzível pelo devedor.

Em todas estas situações, pois, diante da sumarização do objeto de cognição, vem também afastada a coisa julgada sobre o julgamento de qualquer questão prejudicial.

7. Arguição incidental da falsidade de documento

Saliente-se que, sob a vigência do CPC/1973, o art. 391 e seguintes, diante da arguição de falsidade de documento, autorizava o ajuizamento incidental de ação declaratória, que era julgada por meio de sentença.

O art. 430 do atual diploma continua admitindo a arguição de falsidade na contestação ou na réplica, devendo ela ser resolvida como questão incidental. Todavia, se a parte interessada o requerer, será ela decidida como questão principal (art. 430, parágrafo único).

O art. 433 não deixa margem para dúvida quanto à extensão da coisa julgada à respectiva

decisão que enfrentar tal questão *principaliter*, ao dispor que: “A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada”.

8. Viabilidade (ainda) da ação declaratória incidental

Como é sabido, a ação declaratória incidental, no CPC/1973, por razões de economia processual, visava a ampliar os limites objetivos da coisa julgada material, uma vez que a questão prejudicial passava a ser decidida *principaliter*, integrando o dispositivo da sentença (arts. 5.º, 325 e 470 do velho CPC). Deixava de ser simples fundamento do *decisum* e se transformava em objeto do julgamento de mérito.

A despeito da nova disciplina agora reservada a essa matéria, continua subsistindo interesse processual para o ajuizamento de ação declaratória incidental pelo menos nas duas hipóteses sugeridas por Didier Júnior, vale dizer: *a*) a ação declaratória incidental de falsidade de documento (art. 430); e *b*) a reconvenção de natureza declaratória, ajuizada pelo réu, que poderá ter por objeto a questão prejudicial incidental controvertida. ²⁷⁹

9. Incidência imediata das regras de direito processual

É de ressaltar-se, com Carlo Francesco Gabbia, ²⁸⁰ ser princípio geralmente admitido o de que as leis novas referentes às formas processuais aplicam-se aos processos iniciados e não concluídos sob o império das leis anteriores.

Paul Rubier, a seu turno, reportando-se à doutrina medieval de Bártolo, assevera que as regras jurídicas processuais constituem leis atinentes à forma, e, portanto, devem ser observadas tão logo passem a vigorar. ²⁸¹

Correspondendo, certamente, à imediata incidência da lei, qual seja, a aplicação normal, automática desta, o mencionado princípio do efeito imediato (que não deve ser considerado como um *ens tertium* entre a retroatividade e a irretroatividade) identifica-se, a rigor, com a exigência de segurança jurídica: “se a lei nova regulasse os fatos já concluídos sob o domínio da lei anterior, *modificando os seus efeitos*, qualquer certeza seria inócua e o direito, antes que uma ordem, seria um caos. Não se trata, na verdade, de *respeito ao passado*, como, com vaga intuição, sustenta Pace, mas, sim, de uma específica garantia da certeza e, com esta, da estabilidade e segurança dos efeitos jurídicos”. ²⁸²

Segundo os arts. 14 e 1.046 do CPC, duas são, sobre este importante tema, as regras fundamentais derivadas da aplicação do princípio *tempus regit actum*, a saber: *a*) *irretroatividade* da nova lei processual, de sorte que os atos realizados em conformidade com as disposições da antiga permaneçam válidos; e *b*) *imediaticidade* da nova lei processual, que passa a disciplinar o desenvolvimento restante do processo.

Como bem esclarece Ponte de Miranda, “enquanto a relação jurídica não se estabelece, ou não se extingue, a lei nova pode intervir. É princípio que os elementos sucessivos têm cada um a sua lei, o seu momento legal, mas é decisiva a lei do último momento, que é a do último elemento necessário”. ²⁸³

No entanto, dada a relevância da novidade introduzida pelo art. 503, o subsequente art. 1.054 excepcionou a regra legal, procurando infundir segurança jurídica, ao determinar que: “O disposto no art. 503, § 1.º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5.º, 325 e 470 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973”, ou seja, do CPC/1973.

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Correspondência: art. 469 do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Distinção formal entre motivos e dispositivo

Como anteriormente foi ressaltado, com redação mais aprimorada do que a anterior, o art. 489 do CPC, de forma didática, disciplina a estrutura formal da sentença, dispondo que: “São elementos essenciais da sentença: I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”.

Na elaboração progressiva da sentença ou do acórdão (art. 204), em regra, após o resumo (relatório) indicativo das fases e dos aspectos relevantes do processo, o juiz deve passar a expressar os fundamentos de fato e de direito (*sources de la motivation* ²⁸⁴), revelando a sua convicção, isto é, no já referido ensinamento de Chiovenda, ²⁸⁵ a “vontade” íntima do órgão investido de jurisdição, para passar, no dispositivo, a explicitar a “vontade da lei”.

Os fundamentos ou motivos dos atos decisórios em geral pressupõem um labor intelectual, de conteúdo crítico, lógico e metalógico (intuitivo), que engloba um conjunto de reflexões de fato e de direito do qual o juiz extrai o julgamento.

É, por assim dizer, o “jornal de viagem” de seu raciocínio, a exposição, expressa na sentença, das razões fáticas e jurídicas que o conduziram a determinada conclusão. ²⁸⁶ A sentença não pode encerrar-se no esquema do silogismo lógico clássico, que alçava a norma jurídica aplicável ao caso examinado como premissa maior e as *quaestiones facti* como premissa menor para chegar-se à conclusão resultante do ato decisório de mérito. Como ensina Calamandrei, a sentença “não se confunde com uma operação aritmética: é um ato muito mais complicado e misterioso, que tem as suas raízes na consciência moral e não se explica com as abstratas leis dos números”. ²⁸⁷

A propósito, há uma passagem genial na obra *La genesi logica della sentenza civile*, na qual Calamandrei procura demonstrar, de modo claro e direto, a complexidade que envolve o ato de julgar, vale dizer a difícil tarefa de subsunção, privativa do magistrado: “(...) limitar-se a ver na operação mental, que por excelência é efetivada pelo juiz, um simples silogismo, do qual a lei é a premissa maior, constitui esquematização simplista acerca de uma operação que, pelo contrário, é muito laboriosa e complexa. Prescindindo-se do fato de que raramente num processo a consequência jurídica emerge de um único fato e de uma única norma abstrata, ordinariamente o juiz deve fazer, antes de chegar à pronúncia da sentença, uma complicada série de deduções concatenadas, que, quando se arma a sentença como um único silogismo, alvitra-se apenas o momento final da atividade mental do juiz (...) Reduzir a um simples cálculo aritmético o ofício do juiz seria deveras fácil e deveras pobre aquele mister. Pelo contrário, a parte mais árdua desse ofício é aquela pela qual o juiz chega a fixar diante de si as ‘cifras’, que devem embasar o seu cálculo, as premissas, que devem servir ao silogismo... Incumbe ao juiz encontrar a premissa maior (norma) e de verificar se esta realmente comporta a consequência jurídica que a parte pleiteia (...)”. ²⁸⁸

De assinalar-se, por outro lado, que, na prática, dado o estilo pessoal de muitos magistrados, ou, mesmo, a complexidade da causa, nem sempre resulta tarefa fácil, do ponto vista formal, demarcar as fronteiras entre a motivação e a parte dispositiva do julgado, uma vez que, em certas hipóteses, encerrado o relatório, sucedem inúmeras “decisões culminantes com o dispositivo mas, aparentemente, sem nenhuma interrupção lógica”. ²⁸⁹

A distinção em tais situações, consoante Botelho de Mesquita, ²⁹⁰ deve ser efetuada com atenção à função que a cada um destes tópicos está reservada na sentença, bem como nas decisões

interlocutórias de mérito. Tendo-se em vista que a motivação prende-se a *causa petendi* e o dispositivo ao seu pedido, será suficiente para separar um do outro que o intérprete se reporte à petição inicial que, se não estiver contaminada pela inépcia, deverá mencionar com clareza e precisão a causa de pedir e o pedido. Terá, então, nestes elementos da inicial, e, ainda, da *causa excipienda*, deduzida pelo réu em sua contestação, o caminho seguro para proceder à separação entre a motivação e o dispositivo da sentença, pois encerram, respectivamente, as respostas às razões do autor e à sua pretensão, e, outrossim, às questões suscitadas pelo requerido.

Em tais hipóteses, exige-se do intérprete cuidadosa análise do conteúdo da decisão.²⁹¹

Apontando as dificuldades para a correta interpretação da sentença, frisa, a propósito, Garbagnati, que, por exemplo, a decisão de uma questão preliminar de mérito, mesmo não inserida no dispositivo de uma sentença definitiva integra o próprio ato decisório, não no sentido de que esta constitua mera fração de sua respectiva motivação, mas, na verdade, contendo igualmente dispositivo, concorre a formar a parte decisória da sentença.²⁹²

Na verdade, apesar de o ato decisório ser formalmente único em seu aspecto material, poderá conter ele tantas sentenças diversas quantas forem as questões autônomas debatidas. Os capítulos da sentença se identificam com os capítulos da demanda. Como elucida Luiz Machado Guimarães, “há sentenças monocelulares – de um só capítulo –, como há sentenças pluricelulares – de diversos capítulos”.²⁹³

Como antes afirmado, se, por exemplo, o acórdão prestigia a sentença monocrática, deve ser analisado qual o âmbito de abrangência daquele em relação a esta, para o fim de, a um só tempo, compreender o sentido do ato decisório colegiado e, ainda, na esteira do sistema desenhado no CPC, diagnosticar qual a extensão subjetiva e objetiva da coisa julgada.

Aduza-se que a parte dispositiva, do ponto de vista formal, não fica adstrita exclusivamente ao final da sentença, porquanto, poderá excepcionalmente haver decisão sobre alguma questão, como acima esclarecido, no comentário ao art. 503, § 1.º, em outras passagens do pronunciamento judicial.

2. Função instrumental dos motivos

Importa ressaltar que, sob o regime do velho Código de 1939, tema que despertava a atenção dos processualistas concernia à extensão da imutabilidade da motivação, por força do preceituado no parágrafo único do art. 287, cuja redação era inspirada no art. 290 do Projeto Mortara: “Considerar-se-ão decididas todas as questões que constituam premissa da conclusão”.

Assim, além da parte dispositiva da sentença, as premissas ou motivos necessários à conclusão eram, em princípio, atingidos pela coisa julgada.

A tese remonta à elegante construção de Savigny, segundo a qual é possível vislumbrar-se, na discussão que conduz o juiz à decisão, duas espécies distintas de motivos: os *objetivos*, ou elementos integrantes da relação jurídica controvertida, que fazem coisa julgada (*werden rechtskräftig*); e os *subjetivos*, aqueles que se destinam à formação da convicção do juiz, a respeito dos primeiros, que não se subordinam à coisa julgada (*werden nicht rechtskräftig*).²⁹⁴

Bonaccorso, escudado, por certo, na formulação de Liebman, examinou o problema, a partir da teoria de Savigny, averbando que para a determinação dos limites da *res iudicata* não se devia levar em consideração a distinção, extrínseca e formal, entre motivo e dispositivo, ou seja, a “exclusão dos motivos da coisa julgada não há que ser concebida no sentido formalístico, de que só passa em julgado aquilo que está escrito no dispositivo da sentença: porque, ao contrário, para determinar-se o alcance da coisa julgada, é, muitas vezes, necessário remontar aos motivos a fim de poder-se identificar a ação com a análise da *causa petendi*”.²⁹⁵

Nessa linha de raciocínio, dúvida não há de que a fundamentação da sentença tem uma função lógico-instrumental, a qual, em última análise, presta-se à compreensão do *decisum*.

O juiz, no dispositivo, cinge-se a decretar que julga procedente ou improcedente o pedido do autor. Pergunta-se: o que foi efetivamente julgado? Daí, porque a interpretação da sentença exige que se recorra à fundamentação, porque esta, na verdade, é imprescindível “ *para determinar o alcance da parte dispositiva* ” (art. 504).

A generalidade dos ordenamentos processuais contemporâneos exige que toda sentença ou acórdão contenha elementos mínimos de validade (*Entscheidungsnormen*), quais sejam, o relatório, a motivação e o dispositivo (art. 489 CPC).

Na elaboração progressiva da sentença, normalmente, após o resumo da causa e das ocorrências processuais (relatório), o juiz ou tribunal deve passar a expressar os fundamentos de fato e de direito (motivação), para concluir a atividade jurisdicional, com o julgamento da demanda (dispositivo).

A motivação do *decisum* , portanto, é a parte do julgado que deve conter, ainda que entremeadas, a exposição dos fatos relevantes para a solução do litígio e a exposição das razões jurídicas do veredito.

Isso significa que, do ponto de vista de sua estrutura interna, a motivação da sentença, concebida como uma operação lógica do juiz, apresenta-se como verdadeira justificação das circunstâncias fáticas e jurídicas que determinam a individuação das razões de decidir.²⁹⁶

Os motivos da sentença têm por escopo imediato, de um lado, iluminar e tornar compreensível a parte dispositiva da decisão, e, de outro, permitir o controle crítico da sentença, para a exata determinação do conteúdo da vontade do juiz e, conseqüentemente, para a verificação dos limites do julgado.

Como bem ensina Pontes de Miranda, a motivação presta-se, em particular, para esclarecer o ato decisório.²⁹⁷

Botelho de Mesquita²⁹⁸ , sustentando tese original, atinente à imutabilidade instrumental (endoprocessual) dos motivos da sentença, assevera que estes têm a precípua finalidade de realizar, na prática, a fixação e a compreensão do resultado do processo, que se materializa no dispositivo.

As razões de decidir, pois, atuam como elemento informador de aferição do raio de alcance da parte dispositiva da sentença.

É assim por esta razão que, embora não abrangidos pela coisa julgada, pode-se vislumbrar certa estabilidade dos motivos, que não possuem existência autônoma. Saliente-se aliás que não seria mesmo admissível haver coisa julgada sobre a “vontade do juiz”, vale dizer, sobre as premissas que simplesmente revelam a convicção do órgão jurisdicional, como preparação lógica para o julgamento da causa.

3. Motivação e coisa julgada

Secundando o modelo adotado no diploma processual revogado, o novo CPC também consagrou, nesse art. 504, a teoria restritiva, pela qual a autoridade da coisa julgada circunscreve-se ao dispositivo da sentença, não abrangendo, portanto, os motivos que serviram de alicerce à decisão.

Cumprе esclarecer que estes fundamentos devem necessariamente guardar pertinência com o *thema decidendum* , não podendo ser lançados de forma genérica, aptos “ *a justificar qualquer outra decisão* ”. Se isto for constatado, a teor do disposto no art. 489, § 1.º, III, do CPC, a decisão será considerada despida de motivação adequada, e, assim, nula (arts. 93, IX, CF, e 11 CPC).

A *ratio decidendi* atua, portanto, como antes pontuado, como elemento informador para aferir-se, com precisão, o círculo de alcance da parte dispositiva da sentença, ou seja, constitui ela “causa de convicção e não de existência”.²⁹⁹

Bem é de ver, com Cássio Scarpinella Bueno, que, igualmente, não são atingidos pela coisa julgada, os dispositivos das decisões de questões prejudiciais, quando não preenchidos os pressupostos do já comentado art. 503, § 1.º; e, ainda, da decisão incidental declaratória de falsidade documental (arts. 430, parágrafo único, e 433).³⁰⁰

Partindo do pressuposto de “ter a autoridade da coisa julgada a finalidade de *assegurar o resultado prático do processo*”, como diz Liebman, não há porque comunicá-la aos motivos, pois estes não necessitam, já que não integram a cadeia de fatos onde eclodiu a lide. Sua função é formar a convicção do julgador e para cumpri-la não necessitam receber a autoridade da coisa julgada. Os motivos esgotam sua eficácia no processo, e a autoridade da coisa julgada é necessária para que os fatos fora do processo, e após o processo, tenham um determinado curso”.³⁰¹

4. Veracidade dos fatos

Observa-se, ademais, que a verdade dos fatos, fixada nas razões de decidir, também resta excluída dos limites objetivos da coisa julgada.

O novel legislador, a exemplo do anterior, parece não se ter dado conta de que as conclusões fáticas, a partir da valoração dos elementos probatórios, constantes dos autos, integram, por certo, a motivação da sentença.

Desnecessária – e até redundante –, pois, a alusão à “verdade dos fatos”, uma vez que já incluída no âmbito do inc. I do art. 503.

Acrescenta, com absoluta propriedade, Egas Moniz de Aragão, que se os motivos não são abrangidos pela coisa julgada, muito menos a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença pode se subordinar àquela. Daí, porque “nenhum juiz, em outro processo, ficará vinculado ao que a sentença houver admitido como verdade; ao proferir o seu julgamento qualquer juiz poderá e deverá reapreciar livremente os fatos para formar o seu convencimento”.³⁰²

A probabilidade de verossimilhança avaliada pelo juiz alimenta apenas e tão-somente a sua convicção num ou noutro sentido, diante da prova que foi produzida pelas partes.

Em página memorável de sua prestigiosa obra *La prova civile*, Cernelutti já advertia que todo processo contencioso encerra, ao menos, quatro verdades: a verdade do autor, a do réu, a do juiz, e, simplesmente, a verdade verdadeira!³⁰³

Diante dessa experiente percepção da realidade do processo judicial, não há mesmo como se admitir a autoridade da coisa julgada sobre a “verdade dos fatos”.

Desse modo, se em demanda posterior entre os mesmos litigantes, o fato jurídico, tido como existente naquela (p. ex.: vício oculto no bem adquirido), sobre ele terá a parte interessada de produzir prova, visto que não há coisa julgada sobre a sua respectiva veracidade.

A esse respeito, sob a perspectiva da praxe forense, a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento unânime da Apelação 20121010083593, deixou assentado, que, segundo o art. 469, II, do CPC/1973, “a verdade dos fatos não faz coisa julgada, razão pela qual, em ação reivindicatória, não está o julgador adstrito a fundamento de decisão prolatada no bojo de anterior ação de reintegração de posse entre as mesmas partes”.³⁰⁴

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.298.342-MG, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, discutiu a ocorrência ou não de ofensa à coisa julgada, tendo em vista que, no âmbito de sucessiva demanda entre as mesmas partes, não foi constatado o pagamento a maior, reconhecido na decisão proferida no precedente processo.³⁰⁵

O respectivo voto condutor destacou que a lei processual não exige que conclusão fática seja idêntica, visto que o art. 469 do CPC/1973, a exemplo do art. 504, II, do novo diploma, ressalva que a verdade dos fatos estabelecida como fundamento de sentença não faz coisa julgada. O acórdão

unânime tem a seguinte fundamentação: “A coisa julgada material, qualidade de imutabilidade e de indiscutibilidade que se agrega aos efeitos da sentença de mérito, atinge apenas a carga declaratória contida no dispositivo do *decisum*. Não fazem coisa julgada: ‘II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença...’ (art. 469 do CPC). O fato de a sentença proferida em determinado processo judicial adotar como verdadeira premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a prolação de sentença havida em processo anterior estabelecido entre as mesmas partes, conquanto incomum, não ofende a autoridade da coisa julgada”.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II – nos demais casos prescritos em lei.

Correspondência: art. 471 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 222 da LEC espanhola, art. 619 do CPC português, § 323 do ZPO alemão

1. Aspectos gerais

Comentando o art. 471 do diploma revogado, correspondente a este dispositivo, praticamente com a mesma redação, Moniz de Aragão esclarece serem duas as suas finalidades: uma atinente à coisa julgada e outra à preclusão.³⁰⁶

É até intuitivo que, diante da segurança jurídica assegurada com a formação da coisa julgada, o que foi definitivamente decidido não é passível de ser novamente objeto de julgamento. E isso deve ocorrer não apenas no âmbito do mesmo processo, como, igualmente, em processo sucessivo.

Saliente-se, inicialmente, que a expressão “questões decididas” imbrica-se à doutrina de Carnelutti, relativa à distinção entre “processo integral” (contendo toda a lide) e “processo parcial” (contendo apenas parte da lide), sempre dependendo do poder de disposição do demandante quanto à delimitação do objeto litigioso.³⁰⁷

No entanto, sobretudo com a expressa admissão, pelo novo CPC (art. 203, § 2.º), de decisão interlocutória de mérito, é possível que esta se torne, no curso do processo, indiscutível, diante da preclusão.

Não sendo ela impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC), transita em julgado, adquirindo o *status* de coisa julgada material. Outro regime é reservado às questões de natureza processual. Apreciadas e julgadas estas no curso do processo, não são mais passíveis de reexame, porque cobertas pela preclusão, salvo se impugnadas por meio de recurso. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, o juiz poderá revê-las, enquanto não exaurida a sua jurisdição, diante da inexistência de preclusão *pro iudicato*.

Enfatiza Sérgio Porto que, embora indiferente a natureza do ato decisório, sentença ou interlocutória, sendo de mérito, toda a matéria que tenha se caracterizado como questão controvertida e que tenha provocado julgamento, não sendo impugnada ou não sendo mais passível de recurso, adquire estabilidade, vedando nova decisão, por incidência da coisa julgada material.³⁰⁸

2. Inexistência de preclusão pro iudicato acerca de questão de ordem pública

Sob outra perspectiva, dentre as espécies de preclusão, em relação aos protagonistas do processo, há ainda a denominada preclusão *pro iudicato*, pela qual é vedado ao juiz decidir questão já julgada.

Assim, a preclusão, normalmente, atinge a atividade das partes, mas, igualmente, pode também

ocorrer em relação ao órgão jurisdicional, impondo-lhe o obstáculo de não mais poder decidir matéria de direito disponível, a qual, nos termos do *caput* do art. 505, foi objeto de precedente julgamento.

Cumpra deixar claro que a vedação no sentido de desautorizar o juiz a rever anterior ato decisório concerne apenas questões de direito disponível, uma vez que, consoante o disposto no art. 485, § 3.º, do CPC, não alcança a matéria de ordem pública, que pode ser reexaminada, pelo próprio juiz da causa, até o momento de proferir sentença.

Fredie Didier Júnior, enfrentando esta questão já sob as novas regras processuais, sustenta diferente opinião, trazendo inúmeros argumentos que convidam à reflexão. Embora entendendo que o art. 485, § 3.º, do CPC, autoriza a cognição em qualquer grau e tempo de jurisdição da matéria ali especificada, isso somente ocorrerá se não tiver sido precedentemente examinada: “convém precisar a correta interpretação que se deve dar ao enunciado do § 3.º do art. 485 do CPC. O que ali se permite é o conhecimento, a qualquer tempo, das questões relacionadas à admissibilidade do processo – não há preclusão para a verificação de tais questões, que podem ser conhecidas *ex officio*, até o trânsito em julgado da decisão final, mesmo pelos tribunais. Mas não há qualquer referência no texto legal à inexistência de preclusão em torno das questões já decididas”.³⁰⁹

Se fosse consistente esta linha de raciocínio, quando já decidida, por exemplo, em primeiro grau uma preliminar de natureza processual, não impugnada a decisão por meio do recurso cabível, o tribunal estaria impedido de reexaminá-la de ofício, porque coberta pela preclusão. Na verdade, o tribunal não só pode como deve enfrentar as questões de ordem pública, visto que não há se falar em preclusão *pro iudicato* sobre esta matéria.

Atualmente, vinga esse posicionamento em nossos tribunais, como, v.g., colhe-se em acórdão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.377.422-PR, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “Nos termos da jurisprudência desta Corte as matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo”.³¹⁰

Em senso análogo, a 2.ª Turma, a seu turno, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.483.180-PE, com voto condutor do Ministro Herman Benjamin, assentou, à unanimidade de votos, que: “Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que as matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo”.³¹¹

Tive oportunidade de examinar esta problemática sob a égide do CPC revogado, valendo-me da lição de Galeno Lacerda.³¹² Na verdade, há ensinamentos que se perpetuam. Como a redação do atual *caput* do art. 505 é praticamente a mesma da anterior (art. 471), invoco mais uma vez a doutrina do insigne processualista gaúcho, ainda atual, ao refutar a posição de Liebman, no sentido da impossibilidade de ser reavivado, no curso do processo, o exame acerca de questões cujo deslinde já havia sido coberto pela preclusão.

Com efeito, após sistematizar as nulidades processuais e tentar solucionar os problemas que defluíam da atividade saneadora do juiz, Galeno Lacerda afirmava que: “a violação de normas imperativas, ao contrário do que ocorre com a anulabilidade, deve ser declarada de ofício pelo magistrado. Enquanto, porém, a ofensa à lei reclamada pelo interesse público provoca nulidade insanável, a infração de preceito imperativo ditado em consideração a interesse da parte impede o juiz a tentar o suprimento, antes de declarar a nulidade. Ora, o problema da preclusão de decisões *no curso do processo* é substancialmente diverso do problema da preclusão das decisões *terminativas*. Enquanto nestas o magistrado esgota a jurisdição, extinguindo a relação processual, naquelas ele *conserva a função jurisdicional*, continua preso à relação do processo. Em face desta premissa, a pergunta se impõe: Pode o magistrado, que conserva a jurisdição, fugir ao mandamento de norma imperativa, que o obriga a agir de ofício, sob pretexto de que a decisão interlocutória precluiu? Reconhecido o próprio erro, poderá a falta de impugnação da parte impedi-lo de retratar-se? Terá esta com sua anuência, tal poder de disposição sobre a atividade

ulterior do juiz? A resposta, evidentemente, no caso, deve ser negativa. Se o juiz conserva a jurisdição, para ele não preclui a faculdade de reexaminar a questão julgada, desde que ela escape à disposição da parte, por emanar de norma processual imperativa. Daí se conclui que a preclusão *no curso do processo* depende, em última análise da disponibilidade da parte em relação à matéria decidida. Se indisponível a questão, a ausência de recurso não impede o reexame pelo juiz. Se disponível, a falta de impugnação importa concordância tácita à decisão. Firma-se o efeito preclusivo não só para as partes, mas também para o juiz, no sentido de vedada se torna a retratação”.³¹³

Desse modo, também sob a vigência do novo CPC, se no curso do processo, enquanto não esgotada a jurisdição, entender o juiz que se equivocara em decisão sobre as matérias arroladas nos incs. IV, V, VI e XI do art. 485, impõem-lhe a função de dirigente do processo e o dever de velar pela duração razoável do processo (art. 139), reexaminá-la e resolvê-la novamente. É o que determina o art. 485, § 3.º, no sentido de autorizar ao juiz conhecer de ofício das supra aludidas matérias, até que, à evidência, não tenha exaurido a sua própria jurisdição.³¹⁴

Aduza-se, que esta mesma orientação tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, como se infere de aresto da 2.ª Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 560.793-MG, de relatoria do ministro Humberto Martins, ao decidir, com base em precedente da Corte Especial (REsp 1.450.361-RN), que: “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não ocorre preclusão *pro iudicato* a análise de matéria de ordem pública”.³¹⁵

3. Coisa julgada e relação jurídica de trato continuado

Repetindo quase que literalmente o inc. I do art. 471 do CPC/1973, o novo diploma, no art. 505, I, perdeu a oportunidade de eliminar de uma vez por todas uma regra legal absolutamente desnecessária, que conspira contra a boa técnica processual.

Escrevendo em tom crítico sobre o tema, Talamini, com apoio na doutrina de Liebman, resume as impropriedades da norma anterior, num primoroso trecho, que vale ser transcrito: “O disposto no inc. I do art. 471 não constitui exceção à coisa julgada, nem propriamente versa sobre coisa julgada submetida à cláusula *rebus sic stantibus* (a não ser que se pretenda dar essa qualificação a toda e qualquer hipótese de coisa julgada). A parte poderá pleitear nova sentença precisamente porque a alteração de fato e ou de direito vem a estabelecer uma *nova causa de pedir*, diversa daquela em relação à qual operou a coisa julgada. Vale dizer: o fenômeno que se apresenta nessa hipótese não é essencialmente diverso daquele que se põe em qualquer outra situação em que, pela evolução dos fatos, surja uma nova causa de pedir, que estará, portanto, fora dos limites objetivos da coisa julgada anterior (p. ex., a ação de declaração de inexistência de débito fundada em pagamento ocorrido depois do trânsito em julgado da sentença condenatória do mesmo crédito). Não se pedirá para rever a coisa julgada anterior, formular-se-á uma *nova pretensão*, inconfundível com aquela que ficou acobertada pela *res iudicata*. Na situação descrita no art. 471, I [CPC/1973], a peculiaridade não reside na coisa julgada, mas na natureza da relação jurídica ‘continuativa’, que, em vista de seu caráter dinâmico e sua duração continuada no tempo, dá ensejo à constituição de novas causas de pedir no seu próprio curso”.³¹⁶

É até elementar ressaltar que mesmo no âmbito das demandas que têm por objeto relações jurídicas de trato continuado a coisa julgada material não oferece qualquer peculiaridade.

Com efeito, diante da alteração fática verificada na demanda sucessiva, outra será a causa de pedir próxima, a justificar o pedido de nova tutela jurisdicional (e não de revisão da anterior). Ora, alterado em substância o respectivo fundamento jurídico, não se estará, à evidência, diante de ação idêntica. É exatamente por esta razão que os limites objetivos da precedente coisa julgada não se estendem à “nova questão”, posta na segunda demanda.

Tenha-se presente, à guisa de típico exemplo, as situações que derivam da relação jurídica alimentar entre ex-cônjuges, que se projeta no tempo. Neste caso, a própria lei resguarda à parte interessada, o ajuizamento de ação revisional, visando ao proferimento de nova sentença. É a

denominada “ação de modificação”, aludida por Pontes de Miranda, que tem natureza constitutiva, cujo escopo é o de fazer cessar os efeitos da sentença anterior transitada em julgado, diante da ulterior alteração no estado de fato ou de direito.³¹⁷

Já em outras situações, nas quais o ordenamento jurídico não exige o ajuizamento de uma ação específica, a eficácia da precedente decisão expira-se automaticamente, sem qualquer outra providência da parte interessada.³¹⁸

Assim sendo, na sucessiva ação, não é oponível a exceção de coisa julgada, simplesmente, porque não se verifica, em tal hipótese, a função negativa que àquela é reservada, a obstar a repetição de demanda idêntica, caracterizada pela reprodução dos mesmos elementos subjetivo e objetivos (*tria eadem*) da ação anterior.

4. Previsão legal determinante da revisão da coisa julgada

O inc. II do art. 505 excepciona ainda a intangibilidade da *auctoritas rei iudicatae* quando houver autorização legal. Conquanto não seja novo, o dispositivo continua merecendo crítica porque tem uma redação deveras genérica para disciplinar matéria de extrema relevância.

Cumprido destacar que, nos sistemas processuais contemporâneos, a decisão de mérito, mesmo depois de transitada em julgado, pode ainda ser revogada em hipóteses excepcionais.

Costuma-se justificar esta técnica na necessidade de prevalência de um interesse que transcende aqueles das partes à realização de justiça, uma vez que a decisão definitiva poderá apresentar um vício tão nocivo à ordem pública que propicia a sua revogação inclusive após ter-se operado a preclusão dos prazos para a interposição de quaisquer recursos.

Os mecanismos processuais instituídos para esse fim são tradicionalmente de duas espécies – ação autônoma ou recurso –, ambos considerados de natureza especial em razão de seu escopo, que se destaca das vias ordinárias de impugnação e supera o da generalidade das ações.

É, aliás, o que se verifica nos ordenamentos processuais da Itália e da Alemanha, que consagram no *ricorso per cassazione* e na *Nichtigkeitsklage* uma espécie de ação de revogação da sentença; e da França, Espanha e Portugal, que disciplinam um recurso de revisão da sentença também já tangida pela coisa julgada.

Ação ou recurso, pouco importa, a finalidade destes institutos é uma só: a desconstituição da eficácia do *decisum* coberto pela coisa julgada, com fundamento em um dos motivos taxativamente enumerados na lei.³¹⁹

Em nosso sistema processual, tal *remedium iuris*, tendo como antecedente histórico mais próximo o recurso de revista do velho direito lusitano,³²⁰ é a denominada ação rescisória, que constitui o meio pelo qual se pleiteia a desconstituição da decisão interlocutória de mérito, da sentença, ou do acórdão, quando transitados em julgado, com possibilidade de re julgamento, ato contínuo, da matéria já apreciada, isto é, do *meritum causae* (art. 966 e ss. CPC).

Ostenta, assim, a natureza de ação constitutiva, destinada ao pronunciamento da anulação de ato decisório de mérito.³²¹

5. Alusão à denominada flexibilização da coisa julgada

No final dos anos 90, o dogma da coisa julgada passou a ser reapreciado por alguns juristas brasileiros, à luz de um valor ínsito à tutela jurisdicional, qual seja, o da justiça das decisões. A doutrina e a jurisprudência começaram então – como destacou Dinamarco – a despertar para a necessidade de revisar a garantia constitucional e o instituto técnico-processual da coisa julgada material, na crença de que “não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização de incertezas”.³²²

Essa posição não poderia deixar de suscitar ampla polêmica na nossa literatura,³²³

questionando a insegurança jurídica gerada pela revisão de sentença de mérito, mesmo depois do transcurso do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, e consequente desprezo à coisa julgada.

Não obstante, importante orientação jurisprudencial, de forma excepcional, passou a *relativizar* a coisa julgada material em casos extremados, envolvendo direitos da personalidade ou fundamentais (investigação de paternidade) ou a moralidade pública.³²⁴

Hoje, contudo o tema, embora relevante em época não tão distante, passou a plano secundário, visto ter demonstrado a experiência que as hipóteses de flexibilização se restringiram àquelas duas aludidas situações.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Correspondência: art. 472 do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 222.3 da LEC espanhola, art. 621 do CPC português, § 325 do ZPO alemão

1. Aspectos gerais

Esta regra legal, estabelecendo os denominados limites subjetivos da coisa julgada, é análoga ao art. 472 do CPC/1973, tendo agora a nova redação o grande mérito de ter eliminado um notório equívoco histórico.³²⁵

Importa ressaltar que a harmonia das decisões judiciais e a posição dos terceiros em relação a uma sentença, proferida *inter alios*, constituem problemas que sempre foram objeto de grande preocupação na história da coisa julgada civil.

Com efeito, na experiência jurídica romana, as fontes revelam que a jurisprudência clássica, visando a inibir o ajuizamento de nova ação com idêntico objeto, passou a elaborar uma série de critérios pelos quais se aferia a reprodução de uma demanda já finda (*eadem res*). Tais critérios são conhecidos por meio de inúmeros preciosos fragmentos que foram conservados, especialmente, no livro 44 do Digesto.

Como esclarece Giovanni Pugliese, a noção de *eadem res* “já havia possivelmente sido esboçada no processo *per legis actiones*, em relação à proibição de *rem actam agere*; todavia, ganhando expressão o processo *per formulas*, vem ela delimitada e aprofundada com específica referência à *litis contestatio* e ao seu primordial efeito”.³²⁶

Se porventura fosse ajuizada a mesma ação entre as mesmas partes, o réu poderia valer-se da exceção de coisa julgada. Era essa a doutrina de Juliano, invocada por Ulpiano: “*exceptionem rei iudicatae obstare, quotiens inter eadem quaestio inter easdem personas revocatur*”.³²⁷

As fontes clássicas ainda comprovam que os juristas tinham consciência de que a sentença que colocava termo ao processo, gerando imediata *res iudicata*, somente deveria produzir efeitos *inter partes*, não podendo prejudicar terceiros.

Realmente, num famosíssimo fragmento do Digesto, Macro inicia o texto com um princípio de direito que já era conhecido: “*Saepe constitutum est, res inter alios iudicatas aliis non praeiudicare*” (D. 42.1.63).³²⁸ Com formulação idêntica ou assemelhada, o mesmo postulado encontra-se em muitos outros passos da mesma época: “*Quum res inter alios iudicatae nullum aliis praeiudicium faciant*” (D. 44.2.1);³²⁹ “*... nec inter alios res iudicata alii prodesse, aut nocere solet*” (D. 20.4.16);³³⁰ “*Modestinus respondit, res inter alios iudicata aliis non obest*” (D. 44.1.10);³³¹ “*... non potuisse inter alios iudicando alterius ius mutare*” (D. 33.2.31).³³²

Para Betti, a concepção romana sobre a delimitação subjetiva da coisa julgada é bem clara: a sentença proferida *inter partes* é juridicamente irrelevante em relação aos terceiros estranhos ao

processo. A sentença gera, assim, entre as partes, aquela eficácia própria e vinculante que é denominada *res iudicata*; eficácia que, segundo as fontes romanas, tornava certo e indiscutível em qualquer processo futuro contra o mesmo adversário a relação jurídica que foi objeto de contestação e de decisão.

Todavia, esclarece Betti: ao escrever “*aliis non praeiudicare*” – que pode ser traduzido por “irrelevância jurídica aos terceiros” –, o jurista Macro, na verdade, procurou destacar que os terceiros não se sujeitam à coisa julgada. Mas, nada leva a concluir que a sentença proferida *inter alios* não possa, de qualquer modo, projetar alguma espécie de eficácia ou mesmo interferir no direito alheio.³³³

Daí a relevante distinção entre coisa julgada, que sempre se forma exclusivamente entre as partes, e eficácia da sentença, que, em princípio, atinge apenas os litigantes, mas excepcionalmente pode muito bem repercutir na esfera de direito de terceiros.

A regra do art. 506 passou por inúmeras vicissitudes durante o processo legislativo.

Inicialmente, no Anteprojeto e nos sucessivos Projetos a redação continuava sendo a mesma do velho art. 472, no sentido de que a sentença não pode acarretar benefício e tampouco pode prejudicar terceiros.

Pela compreensão do equívoco que tal disposição continha, o legislador, em algum momento da tramitação do Projeto na Câmara dos Deputados, acolheu sugestão que formulei, visto não existir qualquer dúvida de que a eficácia da sentença transitada em julgado, em muitas situações, beneficia terceiros. Não pode haver prejuízo! Contudo, nada obsta a que a posição jurídica de terceiros seja efetivamente beneficiada pela eficácia da decisão de mérito.

2. Conceito processual de parte e de terceiro

O estudo dos limites subjetivos da coisa julgada no âmbito do processo civil assume real importância, tanto mais quanto se tenha na devida conta que uma de suas mais significativas características é a de ser um processo de partes. Sintetizando, a esse respeito, o entendimento dominante na moderna doutrina processual, precisa José Frederico Marques³³⁴ que, em virtude de o processo constituir, em seu desenho estrutural, um *actus trium personarum*, o juiz, o autor e o réu apresentam-se como os principais protagonistas da relação processual, por encarnarem, pelo ângulo subjetivo, individualizando-as de forma devida, a jurisdição, a ação e a defesa.

Daí, a necessidade de, num primeiro momento, estabelecer o conceito de parte, para, em seguida, determinar o de terceiro, e a sua respectiva sujeição à eficácia da sentença e, excepcionalmente, à coisa julgada.

Como bem ressalta Chiovenda, a formulação do conceito de parte não se restringe a simples questão de ordem teórica, mas se presta, fundamentalmente, à solução de sérios problemas de natureza prática.³³⁵ De fato, para o fim de dirimir questões atinentes ao impedimento e à suspeição do juiz, ao litisconsórcio e à intervenção de terceiros, à litispendência e aos limites subjetivos da coisa julgada, delineia-se necessária a elaboração de um conceito de parte abstraído de qualquer liame com a situação de direito material.

Tornou-se famosa a definição de Chiovenda, que é centrada no aspecto formal: parte é aquele que demanda, aquele em cujo nome se demanda e aquele em face de quem se demanda a atuação da vontade concreta da lei. Ressalte-se, porém, que tal proposição encontra-se imbricada, de forma até excessiva, à demanda pendente e ao objeto do processo, “pecando ainda pela falta de associação ao princípio do contraditório”.³³⁶

A noção de *parte* admite variantes de conformidade com a perspectiva adotada, apresentando-se, pois, como um conceito polissêmico.

Garbagnati propõe um desdobramento do conceito de parte em três categorias. Partes são: a) os

sujeitos dos atos processuais; b) os sujeitos destinatários dos efeitos jurídicos puramente processuais; e c) os titulares da relação jurídica litigiosa, sujeitos, portanto, dos efeitos da sentença.³³⁷

Mais recentemente, Proto Pisani, baseando-se nas acepções utilizadas pelo legislador, aceita essa tripartição e preleciona que *partes* são: a) os sujeitos dos atos processuais; b) os sujeitos dos efeitos do processo; e c) os sujeitos dos efeitos da sentença.³³⁸

Note-se que o significado desse derradeiro campo semântico do conceito de parte – *titulares da relação jurídica deduzida em juízo, sujeitos dos efeitos da sentença* – engloba, *tout court*, sem qualquer distinção, todas aquelas pessoas que, embora ausentes do processo, sofrem a eficácia da sentença. Há, nesse enfoque, uma visível aproximação entre a concepção de partes, *em sentido processual*, com a dos denominados *legitimi contradictores*, vale dizer, das *partes legítimas*. Propicia ele, ainda, desnecessária confusão entre os conceitos de parte e de terceiro...

Ao destacar a *lide* como polo metodológico central de sua exposição, Carnelutti assevera: “exatamente porque o conflito de interesses relevante para o direito tem dois sujeitos, cada um destes recebe o nome de parte... A noção de parte, que é própria do conflito juridicamente relevante, é comum tanto ao direito processual quanto ao direito material e assim ingressa na teoria geral do direito: certamente fala-se de parte também em relação ao contrato”.³³⁹

Mas é importante advertir, sobretudo para o contexto do presente comentário, que o conceito de parte não pode ser aferido nos domínios da relação jurídica de direito material.

De modo claro e preciso, Liebman escreve que “as partes são os sujeitos contrapostos na dialética do processo instaurado perante o juiz”. E, por lógica exclusão, arremata: “*tutti coloro che non sono parti sono, rispetto a quel processo, terzi*”. A própria essência do contraditório – explica Fazzalari – exige que do processo participem ao menos dois sujeitos, um interessado e um contrainteresado: em relação a um deles, o provimento final é destinado a produzir efeitos favoráveis, e, no tocante ao outro, efeitos prejudiciais.³⁴⁰

É de Liebman a afirmação no sentido de que a imutabilidade produzida pela coisa julgada vale “apenas entre as partes”.³⁴¹ Observo que já na vigência do atual Código Civil italiano e, portanto, do respectivo art. 2.909, que alude a *partes* como destinatárias da coisa julgada (“*L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti...*”), Liebman reitera o mesmo ponto de vista, ao destacar que os sujeitos que ficam adstritos à coisa julgada, são as “*parti del processo*”, no qual a sentença foi proferida, e não da relação jurídica substancial.³⁴²

Além do autor e do réu, também adquirem a “qualidade” de parte (*eadem condicio personarum* – D. 44.2.12) todos aqueles que forem citados, substituindo a parte originária (sucessor), ou que intervenham, defendendo direito próprio (oposente), ou em auxílio da parte, figurando como titular das diversas posições ativas ou passivas inseridas na dinâmica da relação jurídica processual (interveniente litisconsorcial), ou ainda por provocação de uma das partes originárias (denunciado, chamado ou nomeado). Também passa a ser parte aquele que sofre os efeitos da desconsideração incidental da personalidade jurídica.³⁴³

Como enfatiza Dinamarco, o conceito estritamente processual de parte desponta como o único apto a explicar, nos quadrantes do sistema, “a contraposição parte-terceiro, sem as distorções próprias das inconvenientes ligações com fenômenos de direito substancial ou com o objeto do processo”.³⁴⁴

Ressalte-se que tal conceituação, a toda evidência, não merece qualquer reparo na órbita das ações de espectro coletivo.³⁴⁵

Em suma: a identificação de parte em senso substancial, como sujeito da lide, é de todo espúria ao sistema de direito processual civil. A denominada parte em sentido substancial, quando não guarda coincidência com a parte que atua no processo, é apenas um *terceiro*.³⁴⁶

Ademais, por força de imperativos de natureza técnica e política, no que toca aos limites subjetivos, a sentença e a coisa julgada devem projetar eficácia apenas entre as partes.

Todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (*parte*) é considerado *terceiro* . Não integrando o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. Ora, por não terem participado dos atos que precedem e preparam o julgamento final, os terceiros não podem sofrer os efeitos da sentença de mérito e muito menos se vincularem à coisa julgada material.

A tradicional regra da limitação subjetiva da coisa julgada vem agora consagrada nesse art. 506.

Ocorre que a interdependência das relações negociais e a complexidade do comércio jurídico acabam rompendo as fronteiras do denominado *princípio da relatividade da coisa julgada* ³⁴⁷ e, com isso, torna-se inexorável a projeção, ainda que por via reflexa, dos efeitos da decisão e, às vezes, em caráter excepcional, da própria expansão da autoridade da coisa julgada a terceiros.

Apesar de raro, nada há de inusitado nesse fenômeno, até porque o nosso novo CPC fornece reiterados indícios de sua ocorrência no plano da dinâmica processual. O texto codificado traz um capítulo sobre a oposição (arts. 682 a 686); disciplina a nomeação à autoria (art. 339), a denunciação da lide (arts. 125 a 129) e o chamamento ao processo (arts. 130 a 132); atribui legitimidade ao *terceiro* juridicamente interessado para ajuizar ação rescisória (art. 967, II); reconhece ao *terceiro* prejudicado interesse para recorrer (art. 996); e institui os embargos de *terceiro* para aquele que, “ *não sendo parte no processo, sofre turbção ou esbulho na posse de seus bens* ” (art. 674). A legislação extravagante, no mesmo sentido, oferece outras tantas hipóteses de extensão *ultra partes* dos efeitos da sentença e da coisa julgada.

No último estudo que escreveu sobre esse tema, pondera Liebman que a limitação da coisa julgada às partes foi considerada, ao longo dos tempos, ora mais, ora menos rigorosa, segundo a concepção que prevalecia, num determinado momento histórico, sobre os direitos individuais ou sobre a exigência de coerência lógica das decisões judiciais. Nos dias de hoje, contudo, é possível acreditar, por inúmeros motivos, que as normas jurídicas estejam mais sensíveis à solidariedade social, que torna cada um de nós responsável pelos seus próprios atos em relação aos outros membros da sociedade, ressaltando sempre que todos podem defender os seus próprios direitos, como garantido expressamente pelos textos constitucionais modernos. ³⁴⁸

Realmente, no prosclênio de uma ciência processual dominada por regramentos éticos e políticos, de tendência marcadamente democrática, repugna a ideia de que um sujeito de direitos, sem que se lhe seja assegurado “ *o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes* ” para que possa, na condição de parte, apresentar as suas próprias razões, venha a ser privado de seus bens por força de decisão judicial transitada em julgado. Quando nada, haveria inarredável afronta à letra dos incisos LIV e LV do art. 5.º da Constituição Federal.

No efetivo equilíbrio dos pressupostos e exigências que regem a delimitação subjetiva da eficácia da sentença e da extensão da coisa julgada, parece-me que se encontra a chave para a solução da problemática que dela decorre, em perfeita sintonia com o ideário dos tempos atuais.

3. Terceiros beneficiados pela eficácia da sentença transitada em julgado

Em primeiro lugar, deve ser dito que é a eficácia da sentença transitada em julgado que não pode prejudicar terceiros.

Não se afasta a possibilidade da repercussão menos ou mais intensa da eficácia da sentença a um terceiro. Esse fenômeno, de todo excepcional, poderá acarretar prejuízo de fato a algumas pessoas (*terceiros titulares de um interesse de fato*). Assim, credores do réu derrotado na ação reivindicatória não poderão insurgir-se contra a sentença que reconheceu o domínio ao demandante, porque a decisão não lhes trouxe senão prejuízo prático ou meramente econômico. Não se descortina qualquer incompatibilidade entre o direito dos credores e o direito de propriedade declarado na sentença. ³⁴⁹

Todavia, há outros sujeitos que sofrem prejuízo jurídico decorrente da eficácia da sentença *inter alios*, quando são titulares de um interesse incompatível com o objeto da decisão (*terceiros juridicamente interessados*), como, por exemplo, os verdadeiros proprietários de um imóvel, Antonio e Luiz, diante do trânsito em julgado da sentença que reconhece o domínio de João, sobre o mesmo bem, na ação que promoveu contra Pedro. Ou, ainda, para ficar no exemplo clássico, o sócio que tem interesse na validade de deliberação societária anulada por provimento judicial. Não há dúvida de que foi ele prejudicado pela eficácia da sentença que decretou a anulação do ato social.

Saliente-se, por outro lado, que alguém, estranho ao processo, pode ser beneficiado pelo resultado nele determinado. E aqui também há de fazer-se a distinção entre os *terceiros beneficiados de fato*, que, de forma indireta, acabam sendo favorecidos, e. g., os credores, pela vitória do devedor comum numa ação reivindicatória; e os *terceiros juridicamente beneficiados*, que se subordinam à autoridade da coisa julgada. Nessa derradeira situação, a extensão *ultra partes* geralmente ocorre porque o terceiro, no plano do direito material, situa-se na mesma posição jurídica de um dos demandantes ou então é titular de relação conexa com a *res de qua agitur*.

É mais do que suficiente, para esclarecer tal hipótese, o enunciado do art. 274 do CC: “O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes...”.

Conclui-se, assim, que enquanto a eficácia da sentença pode trazer prejuízo ao terceiro, a imutabilidade da decisão vincula-o tão somente quando lhe propiciar benefício.

Esse fenômeno ocorre toda vez que a situação subjetiva do terceiro for favorecida pela sentença proferida em processo *inter alios*. A coisa julgada, em tais casos, fulmina o potencial interesse de agir de alguém que, embora não tenha integrado o contraditório travado num determinado processo, acabou sendo privilegiado pelo respectivo desfecho.

Nessas condições, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente imutabilidade do comando que dela emerge, não se vislumbra, em relação ao terceiro, qualquer violação, necessidade de modificação ou estado de incerteza atual, que possa lhe gerar interesse processual para agir contra a coisa julgada que o favorece. Em suma: não se configura aí a possibilidade de o terceiro pleitear em juízo o reconhecimento de direito algum.

O litisconsórcio facultativo, que se caracteriza pela reunião de duas ou mais pessoas no lado ativo e/ou no lado passivo da relação que se materializa no processo, tem a sua razão de ser na exigência de economia processual. A coexistência de sujeitos que aí se verifica é absolutamente voluntária e, em regra, concerne a relações jurídicas litigiosas que demandam tutela declaratória ou condenatória de natureza ressarcitória. Abstração feita de algumas raras exceções, nessa espécie de litisconsórcio a regra do art. 506 do CPC sempre prevalece. Aqueles que não figuraram como parte não são atingidos pela eficácia da sentença e muito menos pela imutabilidade do comando da decisão.

Há situações, pelo contrário, em que é a própria lei, *propter opportunitatem*, que impõe o litisconsórcio, sobretudo para preservar a harmonia de julgados e por isso resta vedada a legitimidade de um só sujeito para, isoladamente, demandar ou ser demandado. E existem ainda hipóteses nas quais, pela natureza da relação jurídica debatida, que geralmente reclama tutela constitutiva, é exigida a participação de mais de um réu ou mais de um autor no processo, ou seja, de todos que são titulares de um mesmo direito subjetivo ou ligados por um único vínculo jurídico, sendo a obrigatoriedade do litisconsórcio definida, não pelo direito processual, mas pelo direito material controvertido (*secundum tenorem rationis*). Nesses casos, sobrepondo-se à autonomia da vontade dos litigantes, o litisconsórcio desponta necessário (art. 114 CPC).

Se o litisconsórcio for necessário, seja por força da lei, seja pela natureza incindível da relação jurídica, toda vez que o processo não for integrado pela totalidade dos sujeitos da relação de direito material litigiosa haverá ilegitimidade de parte.

Sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a teor do disposto no art. 115, parágrafo único, do CPC, não sanado o defeito que contamina o processo no prazo determinado, porque não providenciada a citação de todos os litisconsortes, deverá ser proferida sentença não resolutória do mérito, com fundamento na carência da ação, pela flagrante ilegitimidade passiva. Como bem destacou Ovídio Baptista da Silva, a incompleta formação do litisconsórcio necessário e unitário constitui uma questão de *legitimatío ad causam*, sob a consideração de que, sendo única a relação litigiosa, a presença de todos os seus protagonistas é condição prévia para que se possa sobre ela controverter, pela simples razão de que a lide é igualmente uma e única. ³⁵⁰

No entanto, se apenas no momento da sentença vem detectado o vício, nada impede que o julgamento seja de improcedência, superando-se, assim, a falta de condição de admissibilidade da ação e a nulidade daí originada, até porque o resultado do processo favorece o terceiro cuja presença era obrigatória. A ausência deste no processo me parece irrelevante, visto que foi alcançado o resultado pretendido pela parte demandada isoladamente. ³⁵¹

Procurando temperar o indesejado formalismo, José Roberto dos Santos Bedaque, ao considerar essa mesma questão, desenvolve detido exame das variantes que ela oferece. Coerente com a proposta formulada no início de seu já clássico estudo, voltado, de modo obstinado, mas seguro, à adequação da técnica a serviço da efetividade do processo, Bedaque, como logo se observa, rompe com o dogma da ineficácia absoluta em tema de preterição de litisconsorte necessário. Para tanto, inicia o seu raciocínio partindo da circunstância de que, num suposto caso concreto, o juiz não se deu conta do vício na formação do litisconsórcio passivo e proferiu julgamento de improcedência do pedido. Assevera, com razão, Bedaque, que essa sentença é válida, porque, observado o resultado do processo, o defeito tornou-se irrelevante, e, portanto, também apta a produzir todos os seus efeitos em relação às partes e aos terceiros. ³⁵²

Visando a mostrar a coerência do raciocínio desenvolvido, fornece ele, como exemplo, a situação, aliás, bem plausível, na qual um devedor, entendendo nulo o negócio jurídico celebrado com dois cocredores, afora demanda de natureza declaratória apenas em face de um deles. O processo prossegue normalmente, a despeito do vício, e sobrevém julgamento de improcedência do pedido. Descoberto o vício quando não mais é possível a desconstituição da decisão, irrompe ela plenamente eficaz, até porque a incidência cega da regra do parágrafo único do art. 115 do CPC afronta não só o princípio da economia processual, mas ainda a própria instrumentalidade do processo. ³⁵³

É bem de ver que, nessa hipótese, mesmo antes do transcurso do biênio para a ação rescisória, a sentença é hígida e eficaz para todos, porque somente o beneficiado, ou seja, o litisconsorte preterido, é que teria interesse de agir em busca da rescisão daquele provimento judicial. Esse terceiro nem mesmo terá necessidade de manifestar expressa aquiescência ao julgado. A sua sujeição, não apenas aos efeitos, mas à própria *auctoritas rei iudicatae*, decorre do sistema, porquanto, ainda que em tese seja possível a sua irresignação, carece ele de interesse processual para discutir o *decisum*.

Ademais, importa esclarecer que, com o trânsito em julgado da decisão de improcedência, o autor não poderá ajuizar, com expectativa de sucesso, nova demanda em face do litisconsorte necessário ausente, uma vez que teria de inserir, no polo passivo, o outro ou outros que, por terem participado do precedente processo, poderiam opor-lhe exceção de coisa julgada. “Como o processo não pode prosseguir sem a presença de todos os litisconsortes necessários, não há alternativa senão sua extinção sem exame do mérito”. ³⁵⁴

Nessa perspectiva, além de não haver qualquer atrito com o valor constitucional do direito de defesa, o importante escopo – preconizado e muito caro à ciência processual contemporânea – da máxima eficiência processual (*processo de resultados*) irrompe preservado, porquanto a sentença – é lícito dizer – pode perfeitamente ser considerada *utiliter data*. Nem se argumente que o litisconsórcio necessário é instituído para atender ao interesse do autor, no sentido de coarctar decisão inútil... Afinal, a sentença lhe foi desfavorável!

Verifica-se, também, que, nas demandas que têm por objeto obrigações solidárias, a coisa

julgada, na hipótese de ser reconhecida a procedência do pedido, beneficia os credores que não foram parte no processo.

O tema, que parece simples, merece, no entanto, um exame mais aprofundado.

O art. 274 do Código Civil, com a redação alterada pelo art. 1.068 do CPC, ao que tudo indica, inspirando-se na redação do art. 531 do Código Civil português, reza que: “O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo da exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles”.³⁵⁵

Repetindo a regra do art. 898 do Código Civil revogado, o diploma atual preceitua, no art. 267, que: “cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”.

No tocante à 1ª parte do art. 274 do Código Civil, caso a ação tenha sido ajuizada apenas por um ou alguns dos credores (litisconsórcio facultativo, *ex vi* do art. 113, I, CPC), tem-se que ela se afina com a regra geral estabelecida no ora comentado art. 506 do CPC, porque, se o resultado for desfavorável ao demandante, é ele ineficaz em relação aos demais credores que não participaram do processo. Estes poderão, em sucessiva demanda, buscar a condenação do devedor comum. O mesmo ocorrerá em caso de solidariedade passiva, vale dizer, a sentença proferida na ação aforada pelo devedor, visando à declaração de inexistência do débito, cujo pedido foi julgado improcedente, não influi na esfera de direito dos outros devedores, estranhos do processo.

Acrescente-se, ainda, que a parte final do art. 274 do Código Civil, na hipótese de julgamento favorável ao credor demandante, prevê a extensão da coisa julgada aos credores estranhos ao processo.

Talamini posiciona-se em sentido contrário, imaginando que os terceiros, contemplados na regra examinada, são atingidos pela eficácia da sentença e não pela *auctoritas rei iudicatae*.³⁵⁶ Bem examinada a questão, é a imutabilidade do conteúdo da sentença que acaba vinculando os credores estranhos, porque poderão opor, em futura demanda porventura ajuizada pelo devedor, exceção de coisa julgada. Ademais, o julgado forma título executivo também em favor dos credores que não participaram do processo!

Insustentável, outrossim, o ponto de vista que entende ser o devedor acionado substituto processual dos outros, subordinando-se todos eles ao vínculo da coisa julgada.³⁵⁷

Não há que falar também aqui na denominada coisa julgada *secundum eventum litis* como pareceu a Barbosa Moreira, porque, reconhecida a procedência do pedido na demanda ajuizada por um ou alguns dos credores solidários, os demais serão beneficiados pelo sucesso, “sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles” (art. 274, 2ª parte, CC).

Com razão, nesse particular, Talamini explica que o escopo do regime contemplado pelo art. 274 do Código Civil é exatamente o de preservar a posição dos demais credores solidários, garantindo-lhes, em caso de derrota na ação ajuizada por um deles, que não estarão os demais impedidos de promover ação em face do devedor, fundada em idênticos elementos objetivos (causa de pedir e pedido).³⁵⁸

Em caso de vitória, poderão, os demais, valer-se do título judicial que beneficia a todos.

Acrescente-se, pois, que qualquer credor solidário que não participou do processo encontra-se credenciado (i. é, está legitimado) a promover o cumprimento da sentença. Importa, porém, esclarecer que nenhum outro cocredor, além do autor da demanda condenatória constará do título executivo judicial.³⁵⁹

Torna-se assim imperioso harmonizar a pertinência subjetiva dos outros credores solidários com o enunciado do art. 778 do CPC, que cataloga os legitimados ativos à execução. E o único modo

de fazê-lo é “admitir que o art. 274 do Código Civil criou mais uma hipótese de legitimação ativa à execução, a acrescentar-se às contempladas no estatuto processual. O credor estranho ao feito poderá promover a execução invocando a sentença favorável ao seu consorte”.³⁶⁰

Mas isso somente será possível se a fundamentação da sentença não se escudar em algum argumento de ordem pessoal (p. e. a suspensão da prescrição exclusivamente em face do credor autor), que não possa aproveitar aos credores ausentes. Daí, por certo, a relevância do exame da motivação do *decisum* para ser admitida a extensão da coisa julgada, nos limites ditados pela regra do art. 274 do Código Civil.

Como já ressaltado, a despeito da lacuna da lei brasileira, mas pelo examinado princípio da isonomia processual, a coisa julgada que emerge da sentença de procedência do pedido favorável ao devedor que litigou sozinho, no âmbito de ação (des)constitutiva, também beneficia os demais devedores solidários, estranhos ao processo, se fundada em argumento comum a todos os devedores. Estes poderão opô-la à nova investida de eventuais credores comuns.

De aduzir-se, por outro lado, que o devedor condenado, depois de satisfeita a obrigação, sub-rogando-se no crédito reconhecido pelo título executivo, poderá demandar os codevedores, que terão a faculdade de defender-se deduzindo exceções pessoais e ainda argumentos que poderiam ter ensejado a improcedência do pedido do credor. “Não se poderá pretender opor-lhes a coisa julgada, nem a correspondente eficácia preclusiva, uma vez que permaneceram como terceiros em relação ao processo anterior”. E, por essa razão, é plausível a ocorrência de julgados contraditórios. Para afastar esse inconveniente, os arts. 130 a 132 do CPC disciplinam o instituto do chamamento ao processo, pelo qual o devedor, réu na ação condenatória, provoca a intervenção de todos os demais obrigados solidários. Além disso, tal solução para a hipótese de solidariedade passiva seria assemelhada para todas as outras situações de pretensão de natureza regressiva, como, por exemplo, do segurado em face do segurador, do credor no caso de evicção. É evidente que, em nenhuma delas, o réu da ação de regresso estaria adstrito, por força da coisa julgada, ao que fora decidido no processo em que condenada a sua contraparte. Para afastar o inconveniente de julgados contraditórios, nesses casos de obrigações regressivas, a denunciação da lide ao garantidor é o mecanismo adequado.³⁶¹

De todo elogiável, diante do exposto, a redação do art. 506 do CPC, que representa um passo importante, prestando-se, a um só tempo, para resgatar a verdade histórica e atender à própria evolução da ciência processual!

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Correspondência: art. 473 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 619 do CPC português

1. Aspectos gerais

Segundo o alvitre de Egas Moniz de Aragão, quanto ao dispositivo análogo do CPC revogado (art. 473), o presente art. 507 guarda simetria com a regra do art. 505. Enquanto o art. 507 tem como destinatário os litigantes, cujas faculdades vêm limitadas (não podem “*discutir, no curso do processo, as questões já decididas*”), o outro é dirigido ao juiz, que tem seus poderes coarctados (não “*decidirá novamente as questões já decididas*”). Ambos, portanto, visam a imprimir estabilidade às diversas questões resolvidas no curso do processo, variando, no entanto, a sua intensidade.³⁶²

2. Indiscutibilidade das questões já decididas

Traçando a distinção entre processo e procedimento, João Mendes de Almeida Júnior, em clássica lição, anotava que “o *processo* é uma direção no movimento, o *procedimento* é o *modo* de mover e a *forma* em que é movido o ato. *Omnis operatur motus dicitur ...*”. Enquanto aquele

corresponde ao *movimento* no seu aspecto extrínseco, este é o mesmo *movimento* visualizado, todavia, em sua forma extrínseca, “tal como se exerce pelos nossos órgãos corporais e se revela aos nossos sentidos”.³⁶³

A dinâmica do processo, sob a perspectiva lógica, não aceita “retrocesso” e, por esta razão, os atos do procedimento tendem a se estabilizar, a partir de um determinado momento.

A preclusão, como se sabe, é um instituto de natureza endoprocessual, destinado a gerar efeitos dentro do processo, vinculados aos direitos, ônus, poderes e sujeições das partes.

De forma generalizada, desde a doutrina pioneira a esse respeito de Chiovenda, a literatura processual arrola como espécies de preclusão: a) *preclusão temporal* : que se verifica pelo transcurso do tempo. Como a própria noção de processo é dinâmica, a realização de seus respectivos atos se subordinam a prazos contínuos e peremptórios. Consoante disposto no art. 223 do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial...”; b) *preclusão lógica* : verificada diante da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se pretendia também praticar; e c) *preclusão consumativa*: é aquela prevista no art. 507, que obsta à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas.³⁶⁴

Heitor Sica, em primoroso estudo, descarta esta classificação, preferindo falar em preclusão dirigida à atividade das partes em contraposição à preclusão atinente à atividade do juiz (*preclusão pro iudicato*).³⁶⁵

Considere-se que o atual CPC, a teor dos arts. 1.009, § 1.º, e 1.015, alterou profundamente a sistemática da preclusão temporal, atinente à impugnação das decisões interlocutórias, quando irrecuráveis por meio de agravo de instrumento.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Correspondência: art. 474 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 400 da LEC espanhola

1. Aspectos gerais

O enunciado do art. 508 encerra a denominada eficácia preclusiva da *res iudicata* material, que somente tem relevância em sucessivo processo no qual vem questionada a autoridade da coisa julgada formada sobre sentença anterior.

É ampla a literatura processual sobre o famoso art. 474 do estatuto revogado, que é correlato a esse ora comentado, merecendo, destaque, entre outros, o ensaio de Barbosa Moreira, intitulado *A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro* ,³⁶⁶ o qual, à época em que veio a lume, fez escola entre os seus pares.

Apenas por ilustração, o preceito em tela continua tendo como fonte inspiradora o art. 305 do CPC do Vaticano, e se conecta, no âmbito do nosso modelo processual, à regra da eventualidade, que impõe aos demandantes o dever de expender, em momento processual único, todos os seus respectivos argumentos relacionados ao fato essencial, ou seja, aquele que tem o condão de delimitar o *thema decidendum* .

Como enfatiza Liebman, o processo civil brasileiro, fiel às suas origens lusitanas, manteve dois postulados herdados do processo comum medieval: “o de uma ordem legal necessária das atividades processuais, como uma sucessão de estádios ou fases diversas nitidamente separadas entre si, e o princípio da eventualidade, que obriga as partes a propor ao mesmo tempo os meios de ataque ou de defesa, ainda que contraditórios entre si”.³⁶⁷

2. Âmbito de abrangência da eficácia preclusiva da coisa julgada

Depois de terem apresentado as suas respectivas postulações, na fase preambular do processo, ressaltando-se o disposto no art. 342 do CPC, os litigantes não mais poderão acrescentar alegações e defesas, vale dizer, fatos e fundamentos que poderiam ter sido deduzidos em prol de suas respectivas razões. Estabilizado o objeto litigioso, o processo então caminha para fase subsequente. Desse modo, transitada em julgado a sentença, aqueles fatos e fundamentos são reputados como se efetivamente tivessem sido invocados e decididos. É, pois, a essa técnica de hermenêutica, de natureza processual, que se denomina *eficácia preclusiva da coisa julgada*.

A eficácia preclusiva, por inferência lógica da autoridade da coisa julgada, veda a alegação, em outro processo, entre os mesmos litigantes, de fundamentos fáticos e jurídicos, respeitantes aos mesmos elementos objetivos (*causa petendi* e *petitum*) da precedente demanda.

Liebman, a seu turno, ao examinar o problema dos limites objetivos da coisa julgada, anota que estes abrangem todas as questões pertinentes ao objeto do processo que foram ou não debatidas: “se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser”.³⁶⁸

O fenômeno da eficácia preclusiva, como frisa Talamini,³⁶⁹ , não quer significar que ocorre *julgamento implícito* , até porque este ofenderia a garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5.º, XXXV, CF), dado que impediria o litigante de deduzir em juízo uma pretensão que de fato não formulara anteriormente. Ademais, qualquer decisão que não seja *explícita* vulneraria a garantia do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais (arts. 93, IX, CF e arts. 11 e 489 CPC).

Essa perspectiva – que escuda a extensão da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio na jurisprudência.

Tampouco na fase de cumprimento da sentença tem lugar a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada material.

Nesse sentido, a 1.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 915.907-SC,³⁷⁰ relatado pelo Ministro Luiz Fux, assentou que: “(...) À luz do contexto decisório afere-se que o tribunal negou à parte o próprio direito material à compensação, gerando a eficácia preclusiva do julgado. Conforme cediço na doutrina: a preclusão veda a rediscussão da causa noutro processo idêntico – isto é, com identidade dos elementos de identificação das ações (sujeito, pedido e *causa petendi*) – ou noutra demanda onde se vise, por via oblíqua, a infirmar o resultado a que se chegou no processo anterior. É a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada retratada pelo art. 474 do CPC [1973] e consubstanciada na máxima *tantum judicatum quantum disputatum vel quantum disputari debebat* . Em regra a preclusão é incondicionada: opera-se objetivamente, independente do resultado do processo. Assim é que a eventual discussão incompleta da causa não influi no grau de imutabilidade do julgado, tanto mais que o compromisso da coisa julgada é com a estabilidade social e não com a justiça da decisão ou sua compatibilidade com a realidade, porque esta não se modifica pela sentença. A realidade é a realidade. O juízo é de veracidade ou de verossimilhança, conforme a coincidência do que se repassou para o processo em confronto com a vida fenomênica”.

Todavia, tratando-se de outro contexto fático, ainda que ancorado em idêntica causa de pedir

remota, não há se falar em efeitos preclusivos, uma vez que a segunda demanda não se identifica com a anterior.

Deixando-se impressionar pela envolvente doutrina de Schwab,³⁷¹ na literatura pátria, Ovídio Baptista da Silva, ao analisar o art. 474 do CPC/1973, sustentou que os horizontes da eficácia preclusiva da coisa julgada alcançaria a solução de todas as “questões pertinentes” à lide, decididas explicitamente na sentença (art. 468 CPC/1973 [atual art. 503]), ou mesmo não apreciadas por não terem sido deduzidas pelas partes (art. 474 [atual art. 508]).³⁷²

Assevera, com manifesto acerto, Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes que o jurista gaúcho “ampliou o conceito de causa de pedir ao ponto desta passar a abranger situações que, individualizadas, comporiam *causae petendi* distintas. Portanto, não está com a razão ao afirmar, por exemplo, que numa ação que vise à rescisão de um contrato de parceria agrícola com fundamento em danos à colheita, ocasionados por culpa do lavrador, estaria acobertada pela coisa julgada a decisão quanto à ocorrência dos danos culposos à colheita, como também, de todas as possíveis causas que possam dar lugar à rescisão do contrato sob a alegação de inadimplemento culposo por parte do demandado, e outras ‘questões pertinentes’. Tudo sob o efeito da coisa julgada previsto no art. 474 do CPC [1973]. Ficaria à mercê da equidade do julgador enquadrar a questão como ‘pertinente’ ou ‘discrepante’, quando, então, se aplicaria, ou não, o efeito preclusivo da coisa julgada”.³⁷³

Observa-se, outrossim, que esse problema foi amplamente examinado pela doutrina alemã de época mais recente, cuja respectiva discussão é deslocada para o campo do objeto litigioso. De salientar-se, com Castro Mendes, que os juristas alemães referem-se a efeito preclusivo (*Präklusionswirkung*) para designar a eficácia da sentença segundo a qual não se pode formular a mesma pretensão processual no futuro com base em fatos pretéritos.³⁷⁴

Escreve, a propósito, Albrecht Zeuner, em sua *Habilitationsschrift* , defendida na Universidade de Hamburgo, que o objeto do processo, estritamente considerado, não é sempre o único fator de identificação da *res iudicata* . Além dele, a autoridade da coisa julgada pode estender-se também às relações prejudiciais quando, de um ponto de vista teleológico, entre os efeitos jurídicos emergentes do primeiro e do segundo processo, houver uma relação material, isto é, quando subsistir uma conexão material (*Sinnzusammenhang*) entre ambos.

Atento à exigência de harmonia de julgados, Zeuner reconhece, por exemplo, tal necessária interdependência entre uma demanda tendo por objeto uma prestação e outra tendo como objeto a respectiva contratação em caso de avença sinalagmática: a questão prejudicial referente à existência ou não de um contrato de compra e venda, em um processo concernente à entrega de coisa vendida, vinculará o juiz de um novo processo, no qual se discuta sobre o pagamento do respectivo preço.³⁷⁵

Castro Mendes, por sua vez, apontou o inconveniente da teoria erigida por Zeuner, no sentido de não fornecer ela um critério seguro de distinção entre os fundamentos que estarão, no futuro, abrangidos, e os que, apenas aduzidos como simples argumentos (fatos secundários) ou até mesmo não alegados, ficam a salvo da eficácia preclusiva.³⁷⁶

Seja como for, consoante as coordenadas de nossa novel legislação processual, continua prevalecendo a orientação no sentido de que a regra da eventualidade e a respectiva substanciação da demanda concernem exclusivamente ao fato essencial, ou seja, àquele delimitado pelo autor na petição inicial, de sorte que – repita-se – se puder ser deduzido diferente fundamento, ainda que para o mesmo pedido, não haverá óbice algum à propositura de outra ação, uma vez que esta não será idêntica à primeira. Não incide, portanto, nesta hipótese, a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Na verdade, a eficácia preclusiva da coisa julgada não interfere no âmbito da matéria imunizada pela *res iudicata* . A imutabilidade não se estende aos argumentos deduzidos ou dedutíveis. A eficácia preclusiva impede o ajuizamento de demandas incompatíveis com a situação jurídica definida, na precedente sentença transitada em julgado, “na exata medida da

incompatibilidade e sem haver a extensão dos limites objetivos da coisa julgada à situação jurídica incompatível”.³⁷⁷

Válida, portanto, a síntese conclusiva de Barbosa Moreira, no sentido de que “tão preclusas quanto as questões *efetivamente apreciadas* ficam, com o trânsito em julgado da sentença definitiva, em qualquer outro processo sobre a mesma lide ou sobre lide logicamente subordinada: a) as questões que, passíveis de conhecimento *ex officio*, de fato *não hajam sido examinadas* pelo juiz; b) as que, dependentes da iniciativa da parte, hajam sido *suscitadas mas não apreciadas* na motivação da sentença; c) as que, também dependentes da iniciativa da parte, *não hajam sido suscitadas nem, por conseguinte, apreciadas*”.³⁷⁸

NOTAS DE RODAPÉ

1

Embora com o *iussus iudicandi* que lhe era outorgado pelo magistrado (pretor) o juiz devesse proferir a sentença, também na órbita do processo formular não se encontrava ele obrigado a julgar. Seguindo a importante narração de Aulo Gélíio, verifica-se que, desempenhando ele a atividade de *iudex*, instaurou-se um processo no qual um cidadão reclamava certa quantia resultante de mútuo, sendo que o réu afirmava já ter pago. O autor, pessoa que gozava de comprovada idoneidade, não produzira qualquer prova que corroborasse o fato então alegado. O demandado, por sua vez, tinha fama de espertalhão e reputação discutível. O seu advogado insistia a Gélíio que o demandante provasse como de costume, isto é, por meio de documento ou testemunha, a existência da dívida; caso contrário, deveria absolver o cliente e condenar o autor por ter cometido calúnia. Diante do impasse, Gélíio determina a suspensão do processo e se reúne com o seu *consilium*. Expondo o caso ao filósofo Favorino, pergunta-lhe se o juiz poderia julgar com base no conhecimento privado ou estava obrigado a cingir-se aos elementos de convicção constantes do processo. Favorino, então, respondendo à consulta, invoca antiga opinião de Marco Catão, segundo a qual se um sujeito pretende alguma coisa de outrem, se os litigantes têm a mesma dignidade social e não produziram qualquer prova em abono de suas alegações, deve-se acreditar na versão daquele contra o qual foi formulada a pretensão. Portanto, diante do caso concreto, Favorino sustenta a condenação do réu que não granjeara estima social. Todavia, retomando curso o processo, Gélíio, não se sentindo seguro para proferir sentença com base num juízo puramente moral, pronunciou um *non liquet* (cf. Aulo Gélíio, *N. A.*, 14.2.25). V., sobre o tema, P. W. Duff, “Non liquet”, *Butterworths South African Law Review*, p. 39-40; Pietro De Francisci, La prova giudiziale (a proposito di Gellio, *N. A.*, 14.2), *Helikon*, p. 591-605; Umberto Vincenti, *Duo genera sunt testium*, p. 99-100.

2

La sentenza civile, p. 28.

3

A despeito da aludida alteração conceitual, o § 6.º desse art. 485 continua a utilizar a expressão “*extinção do processo*”.

4

5

Cf., v.g., 2ª Seção, EDcl no AgRg no AREsp 524.026-PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, m. v., *DJe* 25.03.2015: “1 – Necessidade de explicitação, na petição inicial, ‘ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas’ (REsp 1.231.027-PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2012). 2 – Acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para, dando provimento ao agravo regimental, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial para decretar a extinção do processo, em face da inépcia da petição inicial”.

6

Cf. conhecida máxima cunhada por Nicolaus T. Gönner, *Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses*, vol. 1, p. 180.

7

Robert Wyness Millar, *The Formative Principles of Civil Procedure*, p. 14.

8

Poderes instrutórios do juiz, p. 99. Enfatiza, a propósito, Hélio Tornaghi que, em nosso sistema processual civil, “o juiz, além de não poder tomar a iniciativa do processo (*ne procedat iudex ex officio*) e de ficar na dependência da do autor (*nemo iudex sine actore*), também deve conformar-se ao que foi pedido, sendo-lhe defeso conhecer de matéria estranha à demanda e à contestação” (*Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 399).

9

V., a respeito, J. A. Jolowicz, *The Active Role of the Court in Civil Litigation, Public Interest Parties and the Active Role of the Judge in Civil Litigation*, p. 199 e s.

Quanto à orientação oposta, seguida pelos sistemas jurídicos totalitários, nos quais, em muitas hipóteses, são consideravelmente ampliados os poderes do juiz, em detrimento da liberdade de disposição das partes, v. Corrado Ferri, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, p. 61 e s.; M. A. Gurvich, *Profilo generali del processo civile sovietico, Ricerche sul processo – 1. Il processo civile sovietico*, p. 15 e s.; V. K. Poutchinski, *Princípios de processo civil da URSS e das Repúblicas Federadas*, p. 45 e s.; Rafael Grillo Longoria, *Derecho procesal civil, – I (Teoría general del proceso civil)*, p. 82 e s.; Mauro Cappelletti, *Le grandi tendenze evolutive del processo civile nel diritto comparato, Processo e ideologie*, p. 182 e s.

10

Cf., a propósito, Leo Rosenberg, Karl Heinz Schwab e Peter Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 492 e ss.

11

V., a propósito, ainda válido para a hipótese vertente, STJ, REsp 1.463.974-PR, 2ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, v. u., *DJe* 21.11.2014: “1. Conforme o disposto no art. 267, II, e § 1º, do CPC [1973], extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a extinção só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1.º, do CPC, é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado”.

12

V. Alma Wilson Gallardo, *Del abandono del proceso*, p. 71, para quem há suspensão do prazo que configura o abandono, nos casos de força maior, caso fortuito, dolo, e, em geral, em todas as circunstâncias nas quais o autor esteja impossibilitado de atuar por motivos totalmente alheios à sua vontade.

13

Cruz e Tucci, *Abandono do processo*, Temas polêmicos de processo civil, p. 24. V., nesse sentido, Pereira de Souza, Abandono da causa, *Revista de Processo*, p. 126-128; Araújo Cintra, Abandono da causa no novo Código de Processo Civil, *Revista Forense*, p. 172-173.

14

V. u., *DJe* 31.08.2015.

15

V. u., *DJe* 23.06.2015.

16

V. u., *DJe* 24.02.2014.

17

M. v., *DJ* 28.09.2015.

18

V. u., *DJe* 13.10.2015. Saliente-se que este importante precedente já passou a fazer escola no TJSP. Confira-se, a propósito, 4ª Câm. Dir. Privado, Ap. 0076664-35.2001.8.26.0100, rel. Des. Ênio Zuliani, v. u., j. 28.01.2016: “Ação de cobrança em fase de execução – Sentença que decreta a prescrição intercorrente e extingue o processo – Inconformismo – Hipótese em que o feito permaneceu arquivado por quase seis anos, sem qualquer providência dos apelantes para execução do julgado – Controvérsia a respeito da necessidade de intimação pessoal antes do reconhecimento da prescrição intercorrente que não foi sumulada – Falta de razoabilidade de se atribuir eficácia ao crédito por tempo indefinido, sob pena de

desestabilização da segurança jurídica pelo decurso de tempo – Prescrição bem reconhecida”; 16ª Câ. Dir. Privado, Ap. 0053985-73.2003.8.26.0002, rel. Jovino de Sylos, v. u., j. 28.01.2016: “Aplicando-se a Súmula 150 do STF: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação’ bem como considerando no caso o art. 206, § 5.º, I, do CC/2002, a prescrição quinquenal incide desde a suspensão do processo em fevereiro de 2005, de modo que independentemente de intimação do credor ou do desarquivamento, aliás continuando a instituição financeira sem indicar bens à satisfação do crédito e sem qualquer providência nesse sentido, afigura-se inexorável a extinção do feito, sendo inadmissível a sua eternização”.

19

Cf. Rogério Lauria Tucci, *Do julgamento conforme o estado do processo*, p. 169-170.

20

Pereira de Souza, *Abandono da causa*, p. 129.

21

Pressupostos processuais e condições da ação, p. 105-106.

22

Cf. Rogério Lauria Tucci, *Do julgamento conforme o estado do processo*, p. 91.

23

V., nesse sentido, José Roberto dos Santos Bedaque, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.211.

24

AgRg no REsp 806.852-PR, 5ª Turma, rel. Min. Gilson Dipp, v. u., *DJ* 08.05.2006.

25

V. u., *DJ* 05.12.1994.

26

É evidente que, no tocante ao elemento subjetivo da demanda, a análise da identidade de partes deve considerar a *qualidade jurídica* pela qual o litigante se apresenta, podendo haver, no plano processual, alguma assimetria, embora ser ele o mesmo sujeito no plano do direito material, como pode ocorrer, p. ex., no âmbito da sucessão *inter vivos* ou *causa mortis*.

27

V. u., *DJe* 29.06.2012.

28

M. v., *DJe* 12.03.2012.

29

Breves comentários ao novo Código de Processo Civil, p. 1.214.

30

V. u., *DJe* 10.11.2014.

31

Efetividade do processo e técnica processual, p. 258.

32

V. u., *DJe* 17.08.2012.

33

Carência de ação, *Estudos de direito processual civil*, p. 102.

34

V. u., *DJe* 24.05.2011.

35

V. u., *DJe* 22.05.2013.

36

Condições da ação, p. 97. V., em senso análogo, Luiz Guilherme Marinoni, *Novas linhas do processo civil*, p. 211-212; Fredie Didier Júnior, *Pressupostos processuais e condições da ação*, p. 220-221. V., em sentido contrário, refutando a chamada teoria da asserção, Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, 2, p. 324: “Uma condição da ação é sempre uma *condição da ação* e por falta dela o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, que o autor já descreva uma situação em que ela falte, quer dissimule a situação e só mais tarde os fatos revelem a realidade”.

37

V. u., *DJe* 22.10.2012.

V., nesse sentido, TJSP, 16ª Câm. Dir. Priv., Agravo de Instrumento 2194531-67.2014.8.26.0000, rel. Des. Miguel Petroni Neto, m. v., j. 17.03.2015: “(...) O acordo que foi formalizado veio a constituir novo título executivo – se trata de instrumento de confissão de dívida – de forma que se a execução é sobre o novo pacto e incidente sobre o valor principal, constante da cláusula 2ª (conforme cláusula 8ª), ele não poderia afastar o direito de defesa do devedor, uma vez que após a transação pode ter surgido fato que justifique a defesa. Assim, é nula a cláusula 16ª por violar o princípio legal da defesa (...)”.

Esta é, outrossim, a orientação consolidada da jurisprudência de nossos tribunais, como, e. g. , infere-se do julgamento da Apelação 0116341-91.2009.8.26.0100, proferido pela 26ª Câm. de Dir. Priv. do TJSP: “(...) A substituição da Corte de arbitragem pela via judicial não implica ofensa ao princípio do *pacta sunt servanda* , porque os réus não foram partícipes do contrato, objeto da demanda. Bem por isso, não há como deixar ao encargo do Tribunal Arbitral o exame das questões discutidas, excluindo-se a participação do Poder Judiciário, isso sem falar que na arbitragem prevalece a regra da relatividade, ou seja, a instituição do compromisso arbitral, sob o aspecto subjetivo, é restrito às pessoas que firmam a cláusula compromissória. Sua extensão subjetiva não pode produzir efeitos senão em relação aos signatários. Segundo entendimento doutrinário, dentre as condições gerais da ação arbitral inserem-se a legitimação das partes e o interesse de agir. Na arbitragem, a legitimação das partes fica grandemente simplificada na medida em que só pode invocar juízo arbitral quem tiver firmado a convenção de arbitragem ou tiver saído vitorioso na ação de instituição de arbitragem. A Lei de Arbitragem fala em ‘parte interessada’ referindo-se à dupla qualidade de quem é parte no contrato e titular do interesse envolvido na controvérsia resultante dele (...) Em suma, são sujeitos do litígio arbitral, única e exclusivamente, os que firmaram a convenção de arbitragem (...)”. Em senso análogo, a 11ª Câm. de Dir. Priv. do mesmo Tribunal bandeirante, ao apreciar o recurso de Apelação 990.09.373821-0, deixou assentado, à unanimidade de votos, que a arbitragem somente pode ser considerada válida se todos os contratantes e intervenientes participarem da mesma: “não se pode impor a eficácia da cláusula compromissória contra quem não manifestou a vontade de aderir a essa forma de solução de conflito”.

Instituições de direito processual civil , 3, p. 196. V., nesse exato sentido, TJSP, 34ª Câm. Dir. Priv., Apelação 0225451-25.2009.8.26.0100, v. u., rel. Des. Nestor Duarte: “(...) Suas teses partem de uma mesma premissa: a existência de cláusulas de arbitragem nos contratos, os quais deram ensejo à emissão das cédulas de produto rural, impede o ajuizamento de execução. No caso sob análise, contudo, a cláusula de arbitragem não determina a extinção anômala da execução porque ambas as partes renunciaram a ela, implicitamente, ao ajuizarem ações para fazer valer seus respectivos direitos oriundos do contrato no qual ela está inserida, isto é, os agravantes ajuizaram ação revisional do contrato e a agravada execução para entrega de coisa (...)”.

Arbitragem e processo , p. 175.

Recente julgado da 3ª Turma do STJ, no AgRg. no Agravo em Recurso Especial 371.993-RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, m. v., *DJe* 06.11.2014, entendeu, com acerto, que o recurso especial não poderia ser processado sob o regime da retenção, diante dos seguintes fundamentos: “A controvérsia instaurada no recurso especial, retido na origem, consiste justamente em saber se há cláusula de convenção de arbitragem, circunstância que, caso reconhecida, tem o condão de derrogar, a princípio, a própria jurisdição estatal, de modo a tornar inócua toda a atividade que venha a ser desenvolvida no processo. A simples constatação de previsão da convenção de arbitragem – objeto de discussão no recurso especial – enseja o reconhecimento da competência do juízo arbitral, que, com precedência ao Poder Judiciário, deve decidir, nos termos do parágrafo único [do art. 8.º] da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996), de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Guardadas as particularidades de cada caso, não se pode deixar de considerar, inclusive, que a jurisprudência do STJ, estribada na preservação e utilidade dos atos processuais, reputa igualmente descabida a retenção do recurso especial, na hipótese em que a questão interlocutória nele encerrada refere-se à própria competência para conhecer e julgar a ação proposta. Ressai evidenciado, assim, a necessidade de se exaurir, com precedência de qualquer outra questão, a discussão acerca da existência de convenção de arbitragem, a considerar que a verificação desta, como assinalado, tem o condão de tornar inútil, a princípio, a atuação jurisdicional do Estado. Agravo regimental provido, assim como o agravo a ele subjacente, para afastar a retenção do recurso especial determinada na origem, impondo-se à Corte local que proceda ao processamento da insurgência recursal, e, posteriormente, ao juízo de admissibilidade, como entender de direito”.

Diante da omissão do CPC/1973 quanto ao momento derradeiro no qual permitida a desistência da ação, defendi, em trabalho específico, a viabilidade de ser ela efetivada mesmo quando o processo estivesse pendente em grau de apelação (*Desistência da ação* , p. 22), posição essa expressamente acolhida em decisão monocrática, proferida pelo Des. André Fontes, do TRF da 2ª Região, na Apelação 2001.02.01.018253-6: “No segundo grau de jurisdição é admissível a desistência da ação, desde que com aquiescência da parte contrária, arcando o requerente com as custas e honorários de advogado (...)”. Mais adequada se afigura a nova disposição do § 5.º do art. 485, uma vez que, proferida a sentença de mérito, se procedente o pedido, o autor não terá interesse na desistência; se improcedente, tendo ele interposto recurso e desejar desistir da ação, o réu, que venceu, certamente, se insurgirá contra o pleito. O mesmo ocorrerá se o processo for resolvido sem julgamento do mérito.

Cf. Gian Antonio Micheli, *La rinuncia agli atti del giudizio* , p. 10.

Rinunzia agli atti del giudizio, *Novissimo digesto italiano* , 15, p. 1.157. Reporto-me nesse tópico ao meu anterior estudo, antes citado, sobre a *Desistência da ação* , p. 5.

Cf. Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil* , p. 338; Antonio Janyr Dall’Agnol Júnior, *Da*

47

Luigi Raggi, Unilateralità delle renuncie processuali, *Rivista di diritto processuale* , p. 46.

48

A evitar qualquer dúvida, esclareça-se que as convenções processuais, amplamente admitidas pelo art. 190 do novo CPC, que ostentam natureza estritamente processual, não guardam qualquer similitude dogmática com os negócios jurídicos processuais, de natureza substancial e que têm por objeto o direito controvertido, como, p. ex., a transação.

49

Cf., nesse sentido, STJ, REsp. 1.318.558-RS, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, v. u., *DJe* 17.06.2013: “1. Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação de coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendido como motivação relevante a impedir a extinção do processo (...)”.

50

Da desistência do processo , p. 81.

51

V., a respeito, Francesco Carnelutti, *Sistema di diritto processuale civile* , 3, p. 506.

52

V. u., *DJ* 02.04.2007.

53

Cf. Alcides de Mendonça Lima, Intransmissibilidade da ação, *Dicionário do Código de Processo Civil brasileiro* , p. 339.

54

Breves comentários ao novo Código de Processo Civil , p. 1.218.

55

Cf. José Roberto dos Santos Bedaque, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.219.

56

V., a respeito, STF, RMS 24.857-ES, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, v. u., *DJ* 11.03.2005.

57

STJ, AgReg no Agr em REsp 1 196.928-CE, 3ª Turma, rel. p/ac. Min. João Otávio de Noronha, m. v. *DJe* 06.04.2015: “Das matérias de ordem pública referentes às condições da ação e aos pressupostos processuais o julgador pode conhecer nas instâncias ordinárias, ainda que em embargos infringentes”.

58

V. u., *DJe* 14.09.2010.

59

V. u., *DJe* 10.12.2007.

60

“(…) VIII – houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença”.

61

V., nesse sentido, Rogério Lauria Tucci, *Do julgamento conforme o estado do processo*, p. 223.

62

Comentários ao novo Código Civil, vol. 3, t. 2, p. 150.

63

V., a respeito, Humberto Theodoro Júnior, *A exceção de prescrição: aspectos substanciais e processuais*, As novas reformas do Código de Processo Civil, p. 41.

64

Cf., por todos, Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, *Revista dos Tribunais*, 300, p. 7-37.

V., ainda, quanto à possibilidade de reconhecimento da decadência e da prescrição perante os tribunais superiores, os comentários sob n. 13.2, ao § 3.º do art. 485, *supra*. V., também, Humberto Theodoro Júnior, *Comentários ao novo Código Civil*, p. 205-206.

V. u., *DJe* 24.06.2015.

V. u., *DJe* 05.06.2015.

V. u., *DJe* 25.08.2015.

Segundo doutrina, Humberto Theodoro Júnior (*Comentários ao novo Código Civil*, p. 374-375), ao examinar o art. 210 do CC (“Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei”): “Quando se trata de fruto da autonomia negocial, não cabe ao juiz conhecer da decadência, senão quando arguida pela parte, porquanto tem esta disponibilidade a respeito do direito que nela se funda. É, por exemplo, o caso do prazo de arrependimento previsto em contrato e que foi ultrapassado pelo alienante. O adquirente não discute o arrependimento tardio, mas apenas pretende se indenizar dos prejuízos advindos. O juiz não pode manter o contrato e invalidar o arrependimento porque ocorrido após o prazo de decadência convencional. As partes têm disponibilidade desse tipo de decadência, que envolve apenas interesses individuais. Não cabe ao juiz sobrepor-se à vontade dos interessados em terreno dominado pela disponibilidade dos direitos. Se, todavia, a decadência provém da lei e visa impor uma tutela de interesse geral, o silêncio da parte não inibe o juiz de pronunciá-la, porque está em jogo o interesse público na certeza e na estabilidade das relações jurídicas. Esse tipo de decadência não comporta renúncia (art. 209) e, por isso mesmo, deve ser conhecida, de ofício, pelo juiz (art. 210)”.

Cf. Clito Fornaciari Júnior, *Reconhecimento jurídico do pedido*, p. 5. Tenha-se presente que o reconhecimento pelo réu pode ser feito por via indireta, como efeito, e. g. , de pagamento extrajudicial do montante que está sendo exigido em juízo. V., nesse sentido, STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.076.756-PR, 5ª Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, v. u., *DJe* 03.08.2015: “O pagamento no âmbito administrativo implica o reconhecimento do pedido, ensejando a extinção da execução, com o arbitramento de honorários em favor do advogado do exequente”; REsp. 729.021-RS, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, v. u., *DJe* 06.02.2015: “O reconhecimento pelo executado de que a transação importou o pagamento do montante total do débito executado, com todos os acréscimos legais decorrentes, equivale ao reconhecimento do pedido (...)”.

72

Cf., a respeito, Moacyr Lobo da Costa, *Confissão e reconhecimento do pedido* , p. 66-67.

73

V. u., *DJe* 05.02.2015.

74

Confissão e reconhecimento do pedido , p. 106-107.

75

V. u., *DJe* 20.08.2013.

76

Istituzioni del processo civile italiano , vol. 1, p. 61.

77

Tratado de direito privado , t. 25, p. 173.

78

Embora possa ser admitida alguma disponibilidade quanto à extensão de direitos indisponíveis, como, p. ex., ocorre nas causas de alimentos, no que se refere ao *quantum* .

79

Tratado de direito privado , t. 25, p. 117.

80

V. u., *DJe* 16.12.2009. V., contudo, STJ, AgRg. no REsp 1.282.641-RS, 1ª Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, v. u., *DJe* 04.08.2015: “I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II – É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.318.315/AL, segundo o qual a homologação em juízo da transação administrativa é obrigatória ao reconhecimento do direito à percepção das diferenças de vencimento, revelando-se, despicienda, contudo, quando ausente demanda judicial individual, porquanto a transação realizada entre servidores públicos e a Administração constitui ato jurídico perfeito e válido, dispensada, inclusive, a presença de advogado para sua celebração”.

81

Moacyr Amaral Santos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, p. 374; e, com ele, Rogério Lauria Tucci, *A nova fase saneadora do processo civil brasileiro*, p. 361.

82

V. u., *DJe* 28.10.2008. V., ainda, art. 844, §§ 1.º e 2.º, do CPC.

83

V., a propósito, Cruz e Tucci, *Direito processual civil inglês, Direito processual civil europeu*, p. 227 e ss.

84

Consulte-se, a propósito, Loïc Cadiet, *Les conventions relatives au procès en droit français. Sur la contractualisation du règlement des litiges*, *Accordi di parti e processo – suplemento da Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2008, p. 8 ss.; Remo Caponi, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, *Accordi di parti e processo*, p. 99 e ss.; Maria Francesca Ghirga, *Le novità sul calendario del processo: le sanzioni previste per il suo mancato rispetto*, *Rivista di diritto processuale*, 2012, p. 166 e ss.; e, na literatura pátria, Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, p. 114 e ss.

85

Instituições de direito processual civil, 2, p. 475.

86

V., sobre o tema, Robson Godinho, *Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil*.

87

Comentários ao Código de Processo Civil, p. 257.

Apesar de serem considerados institutos aparentemente similares, uma vez que, sob o aspecto prático, de um lado, a conciliação é causa da transação, e, de outro, esta constitui o “produto” da pacificação das partes, na verdade, sob o plano da história do direito, o instituto da conciliação (*amicabilis compositio*) não guarda qualquer identidade com a espécie de transação romana prevista na lei das XII tábuas (1.8-9). V. Emilio Valsecchi, *La transazione*, *Trat. dir. civ. comm.*, dir. Cicu-Messineo, p. 143. No Digesto (2.4.22, Gaio, *libro primo ad legem duodecim tabularum*) lê-se: “Aquele que é chamado a juízo, de dois modos pode se desobrigar: ou alguém toma a sua defesa ou ele próprio faz um acordo enquanto vai à juízo (...) *Et si, dum in ius venit, de re transactum fuerit*”). Assim, a transação é feita entre demandante e demandado, a caminho (*dum*) do fórum, ausente o magistrado. A conciliação pressupunha a presença de um conciliador e o objetivo que a motivava era religioso, ao contrário da transação que almejava exclusivamente bens materiais. Entre os cristãos, ainda que o objeto da lide fosse patrimonial, o objetivo da conciliação era espiritual. Mateus (18.15, 17 e 18): “Se teu irmão cometer uma falta contra si, vai e repreende-o, entre ti e ele só... se te ouvir, terás ganho o teu irmão... Se não te ouvir, toma uma ou duas testemunhas para que a

questão se ajuste sob a palavra delas... Se não te ouvir, dí-lo à Igreja...”. Desse modo, acorriam ambos ao juiz cristão, em regra às segundas-feiras, para que houvesse tempo de se reconciliarem, participando da eucaristia no domingo seguinte. Resultando então frustrada a conciliação, o chefe fazia-se juiz e, ato contínuo, proferia uma decisão (v. Aloísio Surgik , *A origem da conciliação*). Cf., nesse sentido, Cruz e Tucci e Azevedo, *Lições de processo civil canônico* , p. 19.

88

V., em sentido contrário, Araken de Assis, *Comentários ao Código de Processo Civil* , p. 151, ao asserir que o juiz depende de regra expressa para homologar o acordo das partes sobre questões estranhas ao objeto litigioso.

89

La transacción: su eficacia procesal , p. 72. Cf., ainda, Mario Alberto Fornaciari, *Transacción . Modos anormales de terminación del proceso* , t. 2, p. 26-27.

90

Tratado de direito privado , t. 25, p. 137.

91

Rel. Min. Waldemar Zveiter, v. u., *DJ* 29.10.1990.

92

La transazione è un contratto?, *Rivista di diritto processuale* , p. 187. Carnelutti entende, portanto, que o juiz deve desempenhar um papel proativo no exame intrínseco da transação, evitando o uso indevido do processo. Observe-se que, em trabalhos anteriores, Carnelutti seguia diferente posição, adotando a denominada tese “contratualista” da transação, de cunho mais privatista, admitindo a validade desta, independentemente de seu conteúdo.

93

Comentários ao Código de Processo Civil , p. 549.

94

V. u., *DJe* 01.07.2011.

95

Breves comentários ao novo Código de Processo Civil , p. 1.223.

96

Cf., nesse mesmo sentido, José Roberto dos Santos Bedaque, *Efetividade do processo e técnica processual*, p. 380-381.

97

Fernando Pereira Rodrigues, *O novo processo civil. Os princípios estruturantes*, p. 216-217.

98

Com a seguinte redação: “1 – Cumpre ao juiz, sem prejuízo do ônus de impulso especialmente imposto pela lei às partes, dirigir ativamente o processo e providenciar pelo seu andamento célere, promovendo oficiosamente as diligências necessárias ao normal prosseguimento da ação, recusando o que for impertinente ou meramente dilatório e, ouvidas as partes, adotando mecanismos de simplificação e agilização processual que garantam a justa composição do litígio em prazo razoável. 2 – O juiz providencia oficiosamente pelo suprimento da falta de pressupostos processuais suscetíveis de sanção, determinando a realização dos atos necessários à regularização da instância ou, quando a sanção dependa de ato que deva ser praticado pelas partes, convidando estas a praticá-lo”.

99

O novo processo civil. Os princípios estruturantes, p. 214.

100

Cf., a propósito, Leo Rosenberg, Karl Schwab, Peter Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 514, que citam Rimmelspacher como seu adepto.

101

As novas perspectivas da efetividade e do garantismo processual, *Processo civil – Estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira*, p. 275.

102

O futuro da justiça: alguns mitos, Temas de direito processual, 8.^a s., p. 5. V., em senso análogo, Paolo Comoglio, Giustizia (non) a tutti i costi. Significativo “update” delle Civil Procedure Rules inglesi e suggestioni sistematiche per la riforma del processo civile, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014:145 ss.

103

Cassio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil anotado*, p. 324.

104

Cf. José Roberto dos Santos Bedaque, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.224.

105

V., para um exame sob a ótica da comparação jurídica, Antonio Palermo, *Il processo di formazione della sentenza civile* , p. 170 ss.; e, mais recentemente, a coletânea *La sentenza in Europa – metodo, tecnica e stile* .

106

Cf. José Carlos Barbosa Moreira, *A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito* , p. 118.

107

La motivazione della sentenza civile , p. 406-407.

108

Cf., ainda, Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza civile* , p. 398; e, também, o precedente estudo de Rogério Lauria Tucci e Cruz e Tucci, *Constituição de 1988 e processo* , p. 77. V., mais recentemente, a respeito do dever de motivação, Jacques Normand, Le domaine du principe de motivation, *La motivation – Travaux de l'Association Henri Capitant* , p. 17 ss.; Augusto Chizzini, Sentenza nel diritto processuale civile , *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile* , 18, p. 256 ss.; Ignacio Colomer Hernández, *La motivación de las sentencias* , *passim* ; e, entre nós, Maria Thereza Gonçalves Pero, *A motivação da sentença civil* , *passim* ; Beclaute Oliveira Silva, *A garantia fundamental à motivação da decisão judicial* , *passim*.

109

Principio del contraddittorio e procedimenti speciali , p. 612.

110

Art. 93, IX, da CF: “ todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação ”.

111

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil* , vol. 3, p. 31.

112

Cf., com análise crítica, Cruz e Tucci, *A motivação da sentença no processo civil* , p. 109.

113

V., a propósito, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Poderes do juiz e visão cooperativa do processo , *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Lisboa* , p. 194-195.

114

Colaboração no processo civil , p. 136.

115

Cf. Tony Sauvel, Histoire du jugement motivé, *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger* , 61, p. 6.

116

Processo e democrazia , p. 664, e, em senso análogo, Cruz e Tucci, *A motivação da sentença no processo civil* , p. 22.

117

Elogio dei giudici scritto da un avvocato , p. 169.

118

V., a respeito, Stefano Evangelista, Motivazione della sentenza civile, *Enciclopedia del diritto* , 27:159, destacando a íntima correlação que há entre motivação e recorribilidade.

119

Cf., ainda, Barbosa Moreira, *A motivação das decisões judiciais* , p. 115.

120

A motivação das decisões judiciais , p. 116.

121

Eduardo Correia, Parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre o art. 653 do Projeto de alteração do CPC, *Boletim da Faculdade de Direito* , 37:184.

122

V., sob análogo aspecto, a respeito dos poderes do juiz, José Roberto dos Santos Bedaque, Discricionarietà judicial, *Revista Forense* , 354:187.

123

V., quanto à incongruência da expressão “conceitos indeterminados”, a importante obra de Michael Streck, *Generalklausel und unbestimmter Begriff im Recht der allgemeinen Ehwirkungen* , p. 21, que, inclusive, justifica constar ela do título de seu livro.

124

Precedente judicial como fonte do direito , p. 290-291. Consulte-se sobre o tema Canaris, *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito* , p. 273 ss.

125

V.u., *DJe* 16.04.2010.

126

V.u., *DJ* 14.10.1996.

127

Teoria da argumentação jurídica , p. 259.

128

Teoria da argumentação jurídica , p. 261.

129

A motivação da sentença no processo civil , p. 18. Criticando igualmente essa prática, v. o tópico específico na original monografia de Leonard Ziesemer Schmitz, *Fundamentação das decisões judiciais* , p. 242 ss.

130

V., a propósito, Nuno de Lemos Jorge, Notas sobre o regime processual experimental, *Novas exigências do processo civil* (obra coletiva), p. 199. Na Itália, o novo art. 118 das disposições de atuação do *Codice di Procedura Civile* autoriza também a motivação *per relationem* : “A motivação da sentença determinada no art. 132, n. 2.4, do CPC, consiste na sucinta exposição dos fatos relevantes da causa e dos fundamentos jurídicos da decisão, podendo ainda ser invocados precedentes convergentes”. Consulte-se, a respeito, o interessante estudo de Maria Acierno, La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* , 2012:437 ss.

131

Corte Especial, Emb. Div. 1.021.851-SP, rel. Min. Laurita Vaz, m. v., *DJe* 04.10.2012: “A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo de outras decisões atendem ao comando normativo, e também constitucional, que impõe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. O que não se tolera é a ausência de fundamentação” .

132

Breves comentários ao novo Código de Processo Civil , p. 1.236.

133

Cruz e Tucci, Ainda sobre a nulidade da sentença imotivada, *Temas polêmicos de processo civil* , p. 75 ss.

134

V., sobre os vícios dos atos processuais na novel legislação, Virgílio Mattos Felício, *As nulidades no novo Código de Processo Civil* , p. 30 ss.

135

Cf. Antonio Carlos de Araújo Cintra, *Sobre os limites objetivos da apelação civil* , p. 15-16. Com apoio em Machado Guimarães, explica Araújo Cintra que, no direito brasileiro, antes da modificação introduzida no CPC/1973 (art. 515, § 3.º), a apelação sofrera radical mudança conceptual, porquanto, de *novum iudicium* , amplo e pleno, em vigor no direito reinol de época filipina, transformou-se, por meio de longa evolução histórica, em *revisio prioris instantiae* , consagrada, em princípio, a partir do CPC de 1939. Assim, vedando a modificação da demanda e limitando rigorosamente a alegação de novas questões de fato, o legislador brasileiro conferiu à apelação as marcas características da simples revisão da matéria reunida no primeiro grau de jurisdição (p. 21).

136

Cf. Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, *Curso de direito processual civil* , 2, p. 355.

137

Teoria pura do direito , vol. 2, p. 284 (destaquei).

138

Instituições de direito processual civil , 3, p. 707-708.

139

Cf. Vittorio Denti, L'interpretazione della sentenza civile, *Studi delle scienze giuridiche e sociali* , t. 28, p. 47-48; A. Chizzini, Sentenza nel diritto processuale civile, *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile* , p. 274; Antonio Nasi, Interpretazione della sentenza, *Enciclopedia del diritto* , 22:301-302; Carlos Maximiliano, *Hermenêutica e aplicação do direito* , p. 67-68; Estevão Mallet, *Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais* .

140

STJ, REsp. 1.285.405-SP, 3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v. u., DJe 19.12.2014.

141

STJ, REsp 1.229.905-MS, 4ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v. u., *DJe* 02.09.2014.

142

STF, ED no ARE 674.231-RS, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, v. u., *DJe* 11.09.2013.

143

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, 3, p. 198.

144

Cumulação de ações, p. 231.

145

V., em senso praticamente idêntico, José Alberto dos Reis, *Comentário ao Código de Processo Civil*, vol. 3, p. 144; Milton Paulo de Carvalho, *Do pedido no processo civil*, p. 105 ss.

A literatura mais moderna tem empregado a expressão *cumulação subsidiária*, reputada mais técnica e científica do que *cumulação eventual* (utilizada pela doutrina alemã: *Eventuelle Klagenhäufung*): v., a propósito, a pertinente observação de Carolina Fons Rodríguez, *La acumulación objetiva de acciones en el proceso civil*, p. 78-9.

146

Capítulos da sentença, p. 9.

147

Leonardo Carneiro da Cunha destaca, com acuidade, que as expressões “capítulo da sentença” e “capítulo da decisão” são empregadas pelo novo diploma processual, destacando-se, por exemplo, o § 3.º do art. 966, os §§ 1.º e 5.º do art. 1.013, e o parágrafo único do art. 1.034 (*Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.238).

148

Capo di sentenza, *Rivista di diritto processuale civile*, 1933:119 e 126. Consulte-se, na literatura pátria, a original monografia de Dinamarco, *Capítulos da sentença*, *passim*.

149

V., a propósito, o disposto no subsequente art. 491.

Cf. Carlos Silveira Noronha, *Sentença civil*, p. 58.

Na verdade, a experiência jurídica romana de época clássica já externava preocupação com esta questão. O juiz que porventura atribuísse ao autor mais do que havia pedido “fazia sua a lide”. Há de fato um importante fragmento de Ulpiano (D. 5.1.15.1, *libro XXI ad edictum*), que aborda a questão do *iudex qui litem sua facere*, esclarecendo que o juiz que proovesse *ultra petita* sujeitava-se a severas sanções e não mais poderia exercer a atividade judicante (Tucci e Azevedo, *Lições de história do processo civil romano*, p. 104). Mais tarde, esse princípio é examinado pelos juristas medievais, sendo que o grande tratadista, Guilherme Durante, autor do famoso *Speculum iudiciale*, exortava, sob a rubrica *Sententia debet essere conformis libello*, que os aforismos *iudex ne procedat ex officio* e *nemo iudex sine auctore* foram cunhados pelos glosadores, a partir da concepção de que o juiz era mero espectador do duelo judiciário e de que a jurisdição necessitava ser provocada. E essa ideia foi, então, transmitida para a época moderna, uma vez que se afeiçoava com a vocação liberal e individual de processo. Não foi por outra razão que se disseminou, na dogmática contemporânea, a ideia de que o monopólio da ação é do jurisdicionado, ao passo que a hegemonia da decisão é do Estado.

V. u., DJ 16.05.1994.

V. u., DJ 25.02.1998.

V. u., DJ 18.02.2009.

Os elementos objetivos da demanda examinados à luz do contraditório, *Causa de pedir e pedido no processo civil*, p. 34. Cf., em senso análogo, Barbosa Moreira, *Correlação entre o pedido e a sentença*, *Revista de Processo*, 83:209.

A correlação no processo civil. Relações entre demanda e tutela jurisdicional, p. 198.

V. u., DJe 12.03.2013.

158

V. u., *DJe* 09.11.2010.

159

V. u., *DJe* 10.09.2010.

160

A causa petendi *no processo civil* , p. 152 e ss.

161

Cumulação de ações , p. 194.

162

Um triênio de judicatura , vol. 3, p. 312.

163

Comentários ao Código de Processo Civil , t. 5, p. 95. V., em senso contrário, com posição mais radical, Antonio Dall’Agnol Júnior, ao averbar que, afastando-se da pretensão do demandante ou do recorrente, e, portanto, *ultra petita* , a decisão emerge defeituosa. “Há, no caso, nulidade absoluta, a não permitir nenhuma providência de superação. O defeito tanto pode decorrer de desconsideração para com o pedido como para com a causa de pedir” (*Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 2, p. 134).

164

DJe 8.11.2010.

165

Temas de direito processual, 2ª s., p. 247.

166

Cf. Leonardo Carneiro da Cunha, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* , p. 1.242.

167

V. u., *DJ* 08.05.2000, BAASP, 2.191:1657-j, 25.12.2000.

168

V. u., *DJ* 14.12.2006. Secundando a mesma orientação, a 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 965.758-

RS (v. u., *DJe* 3.9.2008), da relatoria da Min. Nancy Andrighi, teve oportunidade de assentar que “Os arts. 1.059 e 1.060 do CC/1916 exigem dano ‘efetivo’ como pressuposto do dever de indenizar. O dano deve, por isso, ser certo, atual e subsistente. Incerto dano hipotético, eventual, que pode vir a ocorrer, ou não. A atualidade exige que o dano já tenha se verificado. Subsistente é o dano que ainda não foi ressarcido. Se o dano pode revelar-se inexistente, ele também não é certo e, portanto, não há indenização possível”.

169

Cf. Carnelutti, La sentenza condizionale, *Studi di diritto processuale* , 1, p. 310: “A minha negação da constitucionalidade da sentença condicional concerne à natureza e à função do julgamento, ou seja, em substância, à antítese entre a certeza, que é função da decisão, e a incerteza, que é função da condição” (trad. livre); e, entre nós, Moacyr Lobo da Costa, Sentença condicional, *Revista de direito processual civil* , vol. 1, p. 92 ss.

170

Cf. Moacyr Lobo da Costa, *Sentença condicional* , p. 95 e 99.

171

3.77.

172

Instituições de direito processual civil , vol. 3, p. 402.

173

V. u., *DJe* 11.11.2013.

174

A modificação do pedido e da causa de pedir no processo civil , p. 299.

175

V., por todos, Ricardo de Barros Leonel, *Causa de pedir e pedido. O direito superveniente, especialmente* , p. 223 e ss.

176

V. u., *DJe* 05.02.2015.

177

Condições da ação, *Revista de Processo* , 64:201.

178

STJ, REsp 1.109-MG, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., *DJ* 06.08.1990.

179

DJe 16.06.2014.

180

Consulte-se sobre esse tema Miguel Teixeira de Sousa, *O interesse processual na acção declarativa*, p. 37. V., para uma visão comparatista entre os dois sistemas, brasileiro e português, Leonardo Carneiro da Cunha, *A atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil*, p. 89 ss.

181

Causa de pedir e pedido, p. 253.

182

Cf. Milton Paulo de Carvalho, *Do pedido no processo civil*, p. 158.

183

V. U, *DJ* 02.04.2007.

184

Cf. Alcides de Mendonça Lima, Intransmissibilidade da ação, *Dicionário do Código de Processo Civil brasileiro*, p. 339.

185

V. u., *DJe* 14.09.2010.

186

V. u., *DJe* 11.12.2015.

187

V. u., *DJe* 06.11.2015.

188

V. u., *DJe* 28.10.2015.

189

STJ, 1.^a Turma, ED em ED no REsp. 199.970-DF, rel. Min. Garcia Vieira, *DJ* 04.02.2002: “O relator é competente para corrigir inexatidões materiais no acórdão, de ofício ou a requerimento das partes (art. 463, I, do CPC [1973])”.

190

V., nesse sentido, Fredie Didier Júnior, Rafael Alexandre de Oliveira e Paula Sarno Braga, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, p. 738.

191

Em senso análogo, preceitua o art. 138 do Regimento Interno Tribunal de Justiça paulista: “Os desembargadores poderão retificar ou modificar seus votos até a proclamação do resultado”.

192

V. u., *DJe* 10.02.2011.

193

STJ, 3.^a Turma, REsp. 351.881-PB, rel. Min. Castro Filho, v.u., *DJ* 07.06.2004.

194

STJ, 3.^a S., ED no MS 14.958-DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, v.u., *DJe* 01.10.2015: “1. Preliminarmente, constato que, efetivamente, o *decisum* embargado incorreu em erro material, pois, no item 8 do voto (e-STJ fl. 1.720), consta incorretamente digitado Ministro da Defesa. 2. Assim, merecem ser acolhidos os embargos opostos por Marcos José Veiga Soares para corrigir o erro material apontado. Onde se lê: Ministro da Defesa; leia-se: Ministro de Estado do Meio Ambiente (...)”.

195

V. u., *DJe* 16.11.2015.

196

V. u., *DJe* 24.08.2015.

197

V. u., *DJe* 04.12.2015.

198

DJe 16.10.2015.

199

V. u., DJe 11.12.2015.

200

V. u., DJe 23.10.2015.

201

V. u., DJe 19.11.2015.

202

Curso de direito civil – direito das coisas , p. 416.

203

Curso de direito civil brasileiro , vol. 4.º, p. 387.

204

V. Sílvio Rodrigues, *Direito civil – direito das coisas* , vol. 6, p. 388.

205

Instituições de direito civil , vol. 4, p. 283-284.

206

Comentários ao Código de Processo Civil , vol. 4, p. 455.

207

Sobre a hipoteca judiciária, *Revista de Processo* , 85:1997.

208

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor , p. 559, nt. 1c ao art. 466, com a invocação de inúmeros precedentes jurisprudenciais.

209

A hipoteca judiciária e sua importância como instrumento de garantia, *Revista dos Tribunais* , 674:86.

210

Fundamental Guarantees of the Litigants in Civil Proceedings: Italy, *Fundamental Guarantees of the Parties en Civil Litigation* , p. 548.

211

V., nesse sentido, Cruz e Tucci, Hipoteca judiciária e devido processo legal, *Revista Forense* , 341:159.

212

V. u., *DJ* 04.12.2006. V., criticando a orientação secundada pelo STJ, embora de modo não convincente, Leonardo Carneiro da Cunha, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* , p. 1.253.

213

V. u., *DJe* 18.03.2014.

214

V. u., *DJe* 28.06.2013.

215

Instituições de direito civil , vol. 4, p. 284.

216

Comentários ao Código de Processo Civil , vol. 3, p. 547.

217

V. u., *DJe* 10.06.2015.

218

Interessante notar que, excepcionalmente, uma liminar proferida no âmbito do processo penal é capaz de produzir prejuízo ao demandado. Com efeito, suponhamos que uma busca e apreensão, ajuizada como medida preparatória de futura queixa-crime fundada em concorrência desleal tenha sido deferida para o fim de retirar determinado produto do mercado. Mais tarde, a ação penal é rejeitada. Os eventuais danos causados ao querelado serão apurados perante o juízo cível.

219

Cf. Walter J. Habscheid, *Introduzione al diritto processuale comparato* , p. 136.

220

Da apelação ex officio no sistema do Código de Processo Civil , p. 58.

221

Cf. n. 34 da *Exposição de Motivos* do respectivo Anteprojeto do CPC/1973.

222

Cf. Tucci e Tucci, *Constituição de 1988 e processo* , p. 55-56.

223

Entendemos que essa regra inclui igualmente, na mesma circunstância, o procedência da objeção de pré-executividade. Continua, contudo, sendo inadmitido o reexame necessário na hipótese de sentença de improcedência proferida em embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda (v., a propósito, STJ, 2.^a Turma, REsp 1.467.426-SP, rel. Min. Og Fernandes, v. u., 18.3.1015; 6.^a Turma., AgRg no REsp 250.703-RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u, DJ 18.09.2000: “A sentença proferida em sede de embargos à execução não está sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no inc. III do art. 475 do CPC[1973], que o restringe, no processo de execução, à ‘sentença que julgar improcedente a execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI)’ (...)”.

224

V., a respeito, Sérgio Gilberto Porto , *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 6, p. 239-240.

225

V., a propósito do dissenso pretoriano, Theotonio Negrão *et alii* , *Código de Processo Civil e legislação processual em vigor* , nt. 3e ao art. 475 do CPC/1973. A posição atual do STJ encontra-se sintetizada no seguinte precedente: 2.^a Turma, AgRg. no AREsp. 557.716-MS, rel. Min. Humbeto Martis, v.u., DJe 06.10.2014: “1. ‘A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp. 905.771-CE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, pacificou o entendimento de que a ausência de recurso da Fazenda Pública contra sentença de 1.º grau que lhe tenha sido desfavorável, não impede, em razão da remessa necessária, que ela recorra do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Não se aplica, portanto, o instituto da preclusão lógica’ (EResp 1.072.946-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1.^a S., j. em 14.8.2014, DJe 26.08.2014)”.

226

V. u., DJ 18.06.2007.

227

Tutela específica , p. 70.

228

Cf. Talamini, *Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer* , p. 34.

229

Manual de direito processual civil , p. 357-358.

230

Dell'azione nascente dal contratto preliminare , Saggi di diritto processuale civile, vol. 1, p. 110.

231

V.u., *DJe* 06.11.2013.

232

A tutela específica do consumidor, *Revista de Direito do Consumidor* , 50:77.

233

Cf. Marinoni, *A tutela específica do consumidor* , p. 82-83; *Tutela inibitória* , p. 57.

234

Rinaldo Mouzalas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* , p. 1.269.

235

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado* , t. 22, p. 100.

236

As perdas e danos, ainda que o descumprimento resulte de dolo do devedor, segundo o art. 403 do CC, incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes da inexecução da obrigação.

237

V. u., *DJe* 13.10.2015.

238

V. u., *DJe* 21.9.2015.

239

240

Tratado de direito privado , t. 22, p. 78.

241

Curso de processo civil , vol. 3, p. 192. Não se descarta, contudo, a possibilidade de o demandante deduzir não apenas o provimento que lhe propicie a tutela específica, mas, em cumulação sucessiva, a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos ocasionados pela recusa na emissão da declaração de vontade, “atendendo-se sempre às repercussões de ordem procedimental que da cumulação possa resultar” (cf. Flávio Luiz Yarshell, *Tutela jurisdicional específica nas obrigações de declaração de vontade* , p. 85).

242

V. u., *DJe* 31.08.2010.

243

Cf. Theophilo Cavalcanti Filho, *O problema da segurança no direito* , p. 7-8.

244

Filosofía del derecho , p. 349.

245

“É de interesse público que o litígio tenha um fim”.

246

J. Baptista Machado, *Introdução ao direito e ao discurso legitimador* , p. 57. Saliente-se que, no âmbito da Administração, não se pode conceber a formação de coisa julgada material, uma vez que, mesmo encerrado o processo, pelo não cabimento de recurso na via administrativa, verifica-se a possibilidade de revisão *ex officio* dos atos revestidos de ilegalidade. Ademais, a decisão administrativa pode ser reexaminada em outro processo, não adquirindo imutabilidade como ocorre na esfera do processo judicial (cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, *Princípios do processo judicial no processo administrativo*, *Revista Conjur* , 10.12.2015).

247

Segurança jurídica no direito tributário , p. 382.

248

STF, decisão monocrática proferida em 29.06.2012.

249

Há, contudo, situações processuais, como, por exemplo, na revelia, nas quais, mesmo havendo cognição sumária, forma-se excepcionalmente coisa julgada material.

250

Observância à coisa julgada e enriquecimento ilícito – postura ética e jurídica dos magistrados e advogados, *Cadernos do Centro de Estudos Judiciários*, p. 297.

251

Sulla cosa giudicata, *Saggi di diritto processuale civile*, vol. 2, p. 400.

252

Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 6, p. 160.

253

Da natureza jurídica da sentença sujeita a recurso, *Doutrina e prática do processo civil contemporâneo*, p. 247-248.

254

Cf. Ugo Rocco, *L'autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi*, p. 437.

255

Commentaria in primam digesti novi partem, lib. 1 de re iudicata (D. 42.1.1), Venetiis, 1575.

256

Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada, *Ajuris – Revista da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul*, 28:18-20; *Temas de direito processual*, 3.^a s., p. 101-103.

257

Instituições de direito processual civil, 3, p. 300-301. V., quanto às razões determinantes da liberação da eficácia da sentença, Bedaque, *Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização)*, *passim*; Scarpinella Bueno, *Execução provisória e antecipação da tutela*, p. 160 ss.

258

V., a respeito, Piero Calamandrei, *Appunti sulla sentenza come fatto giuridico* , p. 15 ss.

259

Comentários ao Código de Processo Civil , vol. 4, p. 317.

260

Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada, *Ajuris – Revista da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul* , p. 26; *Temas de direito processual*, 3.^a s., p. 109.

261

Direito processual civil – ensaios e pareceres , p. 139.

262

Eficácias da sentença e coisa julgada , p. 106.

263

Instituições de direito processual civil , vol. 1, p. 372.

264

Cf. Botelho de Mesquita, *Coisa julgada* , *passim* ; e vários ensaios publicados em Teses, estudos e pareceres de processo civil, vol. 2, p. 97 e ss. Observo que, dentre tais escritos, encontra-se aquele intitulado *A autoridade da coisa julgada e a imutabilidade da motivação da sentença* , que constitui a tese de livre-docência do Prof. Botelho de Mesquita, defendida, em outubro/novembro de 1963, nas Arcadas de São Francisco, perante banca examinadora composta pelos Professores Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, Alfredo Buzaid, Moacyr Amaral Santos, Joaquim Canuto Mendes de Almeida e Washington de Barros Monteiro. Tive a feliz oportunidade de resumir a doutrina do saudoso Mestre no artigo , *Processo civil – Homenagem a José Ignacio Botelho de Mesquita* (obra coletiva), p. 29 ss.

265

Embora a lei não faça referência à contestação, entendo que o juiz não pode desprezar a resposta do réu e simplesmente extinguir o processo se não for interposto o recurso cabível. Ademais, escapa da eficácia preclusiva decorrente do transcurso *in albis* do prazo para a interposição do recurso, a teor do art. 485, § 3.º, do novo CPC, a matéria relativa aos pressupostos processuais e às condições de admissibilidade da ação por extravasarem do poder de disposição das partes, subordinando-se à investigação de ofício pelo juiz, ainda que se constate o silêncio do demandado.

266

Cruz e Tucci, *Ação monitória* , p. 101-102.

267

Doze problemas e onze soluções quanto à chamada “estabilização da tutela antecipada”, *Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro* , 55:94.

268

Ação rescisória contra acórdão em agravo de instrumento, *Revista de Processo* , 41:15 ss.

269

“ O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo ”.

270

Inspira-se, o legislador, na doutrina de Carnelutti sobre questões – dúvidas sobre pontos de fato e de direito – suscitadas pelas partes (*Istituzioni del processo civile italiano* , vol. 1, p. 12), entendendo-se como “questão principal”, o núcleo da lide, isto é, o objeto litigioso.

271

Limites objetivos da coisa julgada, *Informativo Incijur*, 10:6. Consulte-se, também acerca de situações que decorrem da união estável, Alexandre Alves Lazzarini, *A causa petendi nas ações de separação judicial e de dissolução da união estável* , p. 94-95.

272

Ação declaratória no direito brasileiro , p. 389.

273

A causa petendi no processo civil , p. 161.

274

Cf. Barbosa Moreira, *Questões prejudiciais e coisa julgada* , p. 62.

275

Extensão da coisa julgada à resolução da questão prejudicial incidental no novo CPC brasileiro , p. 84. V., a respeito, Clarisse Frechiani Lara Leite, *Prejudicialidade no processo civil* , p. 69 ss.

276

Questões prejudiciais e coisa julgada , p. 49-50.

277

Extensão da coisa julgada à resolução da questão prejudicial incidental no novo CPC brasileiro , p. 86. V., nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno, *Novo Código de Processo Civil anotado* , p. 335.

278

Objeto do processo, questões prejudiciais e coisa julgada , tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 2018, p. 495.

279

Extensão da coisa julgada à resolução da questão prejudicial incidental no novo CPC brasileiro , p. 93.

280

Teoria della retroattività delle leggi , vol. 1, p. 452.

281

Le droit transitoire – Conflits de lois dans le temps , p. 542.

282

Cf. Francesco Carnelutti, Mutamento della legge in tema di prescrizione, *Rivista di diritto processuale*, parte 1, p. 3, com alusão à importante obra de Gaetano Pace, *Il diritto transitorio con particolare riguardo al diritto privato* , p. 142.

283

Comentários ao Código de Processo Civil , t. 17, p. 28.

284

Robert Legros, *Considérations sur les motifs* , La motivation des décisions de justice, p. 12.

285

Chiovenda, *Instituições de direito processual civil* , vol. 1, p. 372.

286

Calamandrei, *Processo e democrazia* , p. 665.

287

Processo e democrazia , p. 668.

288

La genesi logica della sentenza civile , p. 15.

289

Botelho de Mesquita, *A autoridade da coisa julgada e a imutabilidade da motivação da sentença* , p. 43.

290

A autoridade da coisa julgada e a imutabilidade da motivação da sentença , p. 43.

291

Consulte-se, a propósito, os comentários ao art. 489, § 3.º, supra.

292

Questioni preliminari di merito e parti della sentenza , p. 1.607.

293

Limites objetivos do recurso de apelação , p. 83.

294

System des heutigen römischen Rechts , vol. 6, p. 358 ss.

295

Il giudicato civile , p. 18-19.

296

Cf., a propósito, Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza civile* , p. 213 ss.

297

Comentários ao Código de Processo Civil , t. 2, p. 354.

298

A autoridade da coisa julgada e a imutabilidade da motivação da sentença , p. 61-62.

299

Ronaldo Cunha Campos, *Limites objetivos da coisa julgada* , p. 87.

300

Novo Código de Processo Civil anotado , p. 336.

301

Ronaldo Cunha Campos, *Limites objetivos da coisa julgada* , p. 88-89.

302

Egas Moniz de Aragão, *Sentença e coisa julgada* , p. 253.

303

La prova civile: parte generale: il concetto giuridico della prova , p. 34-36.

304

DJe 20.03.2014.

305

V. u., *DJe* 27.06.2014.

306

Sentença e coisa julgada , p. 264.

307

Istituzioni del processo civile italiano , vol. 1, p. 255-256.

308

Comentários ao Código de Processo Civil , vol. 6, p. 206.

309

Curso de direito processual civil , 1, p. 699.

310

V. u., *DJe* 17.04.2015. Confirma-se, outrossim, STJ, 3.^a Turma , EDcl no Ag 1.378.731-PR, rel. Min. João Otávio

de Noronha, v. u., *DJe* 24.5.2013: “As matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo”.

311

DJe 27.11.2014. O STJ, por paradoxal que possa parecer e de forma injustificada, considera a arguição de prescrição como mera exceção, em afronta à letra do art. 487, II, do CPC: 4.^a Turma, AgRg no AREsp 411.528-MG, rel. Min. Raul Araújo, v. u., *DJe* 11.05.2015: “Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, ‘Afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, opera-se a preclusão, não sendo admissível a rediscussão da matéria no âmbito de apelação. Precedentes: AgREsp 1.013.225/SC, rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 04.02.2009; AgREsp 1.069.442-PR, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 03.11.2008; AgREsp 1.045.481-PR, rel. Min. Massami Uyeda, *DJe* 28.8.2008; REsp 706.754-RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 05.05.2008; REsp 595.776-MG, rel. Min. Denise Arruda, *DJU* 4.12.2006’ (2.^a Turma, REsp 1.147.112-PR, rel. Min. Castro Meira, *DJe* 19.08.2010)”; 2.^a Turma, REsp 1.276.048-SP, rel. Min. Assusete Magalhães, v.u., *DJe* 12.02.2015: “Hipótese em que o juiz de 1.^o grau, após afastar a tese de prescrição do direito de ação, no despacho saneador – contra o qual não foi interposto qualquer recurso –, novamente decidiu a questão, quando da prolação da sentença, acolhendo a referida prejudicial de mérito, reexaminando matéria preclusa, questão que já se encontrava acobertada pela preclusão também para o Tribunal de origem, em flagrante afronta ao art. 471 do CPC. ‘O art. 471 [CPC/1973] do CPC é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo as questões já decididas – precisamente por falar em nenhum juiz o texto dessa disposição abrange também o juiz da causa, manifestamente compreendido na generalidade do advérbio’. Esse artigo também se aplica às decisões interlocutórias (...) Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual, ‘afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria’(...)”.

312

Cruz e Tucci, Sobre a eficácia preclusiva da decisão declaratória de saneamento, *Temas polêmicos de processo civil*, p. 49 ss., com arrimo na obra de Galeno Lacerda, *Despacho saneador*, escrita sob a vigência do CPC de 1939.

313

Despacho saneador, p. 160-161.

314

V., em senso análogo, sob o regime do CPC/1973, Moacyr Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, vol. 2, p. 299.

315

V. u., *DJe* 17.11.2004.

316

Coisa julgada e sua revisão , p. 90.

317

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil* , t. 5, p. 148 ss. V., a propósito, por último, Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior, *O trato das relações jurídicas continuadas no NCPC, uma oportunidade perdida* , p. 185.

318

Cf., ainda, Talamini, *Coisa julgada e sua revisão* , p. 95.

319

Cf. Moacyr Lobo da Costa, *Cumulação de juízos na ação rescisória* , p. 2 (separata).

320

Consulte-se, a propósito da trajetória histórica da ação rescisória, a exaustiva exposição de Lobo da Costa, *A revogação da sentença* , *passim* .

321

Barbosa Moreira (*Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 5, p. 108-109) explica que se assimila à do anulável a condição jurídica da sentença rescindível, visto que a inexistência pode ser declarada por qualquer órgão jurisdicional, e a nulidade, após o trânsito em julgado, converte-se em simples rescindibilidade. E rescindir, como anular, é desconstituir.

322

Relativizar a coisa julgada material, *Revista da Escola Paulista da Magistratura* , 2:13 ss.; *Revista de Processo* , 109:22 ss.

323

Cf., por último, Talamini, *Coisa julgada e sua revisão* , especialmente, p. 392 ss.

324

V., nesse sentido, v.g . , STJ, 4.^a Turma, REsp. 330.172-RJ, v.u., *DJ* 18.12.2001; 1.^a Turma, REsp 240.712--SP, v.u., *DJ* 24.04.2000.

325

Foi, na verdade, da recepção do direito romano canônico que as fontes jurídicas da Península Ibérica

(incluídas aí as Ordenações do Reino lusitano) interpretaram erroneamente o direito romano. Os textos da época clássica não admitiam que a coisa julgada prejudicasse aquele que não tinha participado do processo; nada dispunham sobre o possível benefício ao terceiro.

326

Giovanni Pugliese, Giudicato civile (storia), *Enciclopedia del diritto* , 18:738.

327

Ulpiano, D. 44.2.3 (*l. 15 ad edictum*): “A exceção de coisa julgada sempre obsta a que entre as mesmas pessoas a mesma questão seja renovada”. V., a propósito desse texto, F. Carl von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale* , tr. it. Vittorio Scialoja, vol. 6, § 301.º, p. 498 ss.

328

Macro (*l. 2 de appellationibus*): “Muitas vezes se determinou que a coisa julgada em relação a uns não prejudica a outros”.

329

Ulpiano (*l. 2 ad edictum*): “Como as coisas julgadas entre uns não causam prejuízo a outros...”.

330

Paulo (*l. 3 quaestionum*): “... a coisa julgada entre uns não costuma aproveitar nem prejudicar a outrem”.

331

Modestino (*l. 12 responsorum*): “Modestino respondeu que a coisa julgada entre uns não prejudica a outros”.

332

Labeão (*l. 2 posteriorum a Iavoleno epitomarum*): “(...) não é possível, julgando entre outros, mudar o direito de terceiro”.

333

Emilio Betti, *Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano* , § 2.º, p. 9; § 5.º, p. 22-23. Betti bem apontou que, apesar de a maioria dos textos romanos atinentes à coisa julgada *inter partes* referir ao prejuízo (*lato oneroso*) que não poderia ser causado ao terceiro, a regra possuía o mesmo valor para a hipótese inversa, vale dizer, quando a *res iudicata* beneficiava terceiro. E isso, porque, “dada a incindibilidade dos efeitos jurídicos de um mesmo fato, negar, em relação a uma determinada pessoa, os efeitos prejudiciais de um fato jurídico, significa afirmar a total irrelevância jurídica desse fato em relação àquela pessoa considerada. Uma coisa julgada claudicante, *secundum eventum litis* , é um conceito absurdo” (§ 2º, p. 10-11).

334

José Frederico Marques, *Manual de direito processual civil* , vol. 1, p. 172.

335

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil* , vol. 2, p. 233.

336

Giuseppe Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile* , p. 579. A crítica é de Cândido Rangel Dinamarco, *Intervenção de terceiros* , p. 17. Cf., também, em senso assemelhado, Athos Gusmão Carneiro, *Intervenção de terceiros* , p. 4.

337

Edoardo Garbagnati, *La sostituzine processuale nel nuovo Codice di Procedura Civile* , p. 245-247.

338

Andrea Proto Pisani, Parte (dir. proc. civ.). *Enciclopedia del diritto*. 31:921; *Lezioni di diritto processuale civile* , p. 331.

339

Francesco Carnelluti, *Sistema di diritto processuale civile* , 1, p. 342-343. Cf., ainda, do mesmo autor, *Diritto e processo* , p. 92: “... considerando que a posição passiva das partes relaciona-se com a lide, enquanto a posição ativa diz com o processo, vem formulada a distinção entre partes *em senso material ou substancial* e partes *em senso formal ou processual* ”.

340

Fazzalari, *Istituzioni di diritto processuale* , p. 81, Cf., também, Liebman, *Manuale di diritto processuale civile* , 1, p. 85.

341

Efficacia ed autorità della sentenza , rist., p. 56 (*Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada* . (tradução para o português) 2.^a ed., p. 80).

342

Liebman. Giudicato – diritto processuale civile, *Enciclopedia giuridica treccani* , vol. 15, p. 14. V., na versão inglesa, The Notion of Res Judicata, *Italian Yearbook of Civil Procedure* , p. 236.

Cf. STJ, RMS n. 16.274-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v. u., DJ 02.08.2004: “O sócio alcançado pela desconconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária torna-se parte no processo e assim está legitimado a interpor, perante o Juízo de origem, os recursos tidos por cabíveis, visando a defesa de seus direitos”. Na verdade, na maioria das vezes, o sócio nestas condições, é litisconsorte passivo. V., a propósito, o documentado artigo de Sidnei Agostinho Beneti, Desconconsideração da sociedade e legitimidade ad causam: esboço de sistematização, *Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins* (obra coletiva), p. 1.005 ss.

Cândido Rangel Dinamarco, *Intervenção de terceiros*, p. 17. V., em sentido análogo, Lopes da Costa, ao esclarecer que a relação erigida no processo tem um conteúdo puramente processual e, assim, sob tal aspecto, “indiferente é que ela se forme entre os verdadeiros ou os pretensos titulares do direito trazido à lide. Autor e réu podem não ser os ‘sujeitos do direito’, mas se apresentam como os da ação; surgem, pois, como os ‘senhores do processo’” (*Da intervenção de terceiros no processo*, p. 11); Arruda Alvim, *Manual de direito processual civil*, vol. 2, p. 23: “O conceito de parte é eminentemente processual (...)”.

Não obstante, reporto-me ao que escrevi no livro *Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil*, no qual registrei que segmento considerável da doutrina estrangeira e nacional, em busca de um conceito de parte na esfera do processo coletivo, acaba se norteadando pela posição dos interessados no plano do direito material. V., e. g., Girolamo Monteleone, ao examinar o regime das *class actions* do sistema norte-americano, afirma que a decisão proferida nas demandas coletivas não é emitida apenas perante duas partes, e que vai influir na posição jurídica de outros sujeitos, titulares da relação de direito material, ausentes do processo, mas, ao contrário, é proferida em relação à categoria de pessoas, todas representadas perante o juiz por aqueles legitimados, que tomaram a iniciativa da ação. No processo, ademais, vem rigorosamente assegurado o direito de defesa de todos, impondo-se, num juízo essencial e preliminar de admissibilidade da ação, o controle da adequada representação (*I limiti soggettivi del giudicato civile*, p. 178). Na doutrina pátria, Nilton Luiz de Freitas Baziloni (*A coisa julgada nas ações coletivas*, p. 83) escreve: “tecnicamente não existe terceiros nas ações coletivas, posto que todas as pessoas estarão adequadamente representadas nos respectivos processos. Se terceiro é aquele que não participou da relação processual ou não fez parte da relação de direito material, segue-se que nas ações coletivas, de uma forma ou de outra, todos os interessados estarão ‘participando’”. Ao ver de Mancuso (*Jurisdição coletiva e coisa julgada*, p. 359): “a própria nomenclatura *terceiro* é questionável no plano coletivo, porque, se é inviável a presença efetiva dos sujeitos concernentes ao interesse judicializado e se esses sujeitos estão *adequadamente representados* no processo por um autor credenciado *ope legis*, então a rigor não se pode tê-los como *terceiros*, porque, de duas uma: ou bem os sujeitos concernem ao conflito judicializado, e nesse caso eles tecnicamente participam do processo coletivo através do autor ideológico; ou bem eles são estranhos ao *thema decidendum*, e então, enquanto *terceiros indiferentes*, não se lhes toca o trâmite da ação coletiva, inclusive a coisa julgada que aí se venha formar”.

Cf. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, 1, p. 86, que aduz: “A determinação do conceito de parte não tem qualquer imbricação com o problema da legitimação para agir; esse problema consiste na

identificação das *partes justas* , ou *legítimos contraditores* , em relação a um determinado objeto; são, pelo contrário, partes no processo aqueles que de fato são os sujeitos, com todas as consequências que daí resultam, e independentemente da circunstância de que sejam ou não, no tocante à ação proposta, também as partes legítimas”.

347

A atual doutrina processual francesa, inspirando-se no *princípio da relatividade do contrato* , continua empregando essa terminologia para designar a regra de que a coisa julgada material vale apenas *inter partes* : v., a propósito, por último, Christophe Lefort, *Procédure civile* , p. 312. Cf., ainda, Jacques Héron, *Droit judiciaire privé* , p. 214; Roger Perrot, La cosa giudicata: recenti sviluppi nel diritto francese, *Rivista di diritto processuale* , 1982, p. 5: “(...) A relatividade da coisa julgada, inserida no art. 1.351 do Código Civil francês, constitui um princípio de direito natural. Salvo casos excepcionais, como poderia um terceiro estar vinculado a uma sentença de cuja elaboração não participou? Por esse ponto de vista, a relatividade da coisa julgada é corolário necessário do princípio do contraditório”.

Note-se que Rudolf von Ihering, em ensaio que se tornou famoso (*Des effets réflexes ou de la réaction exercée sur les tiers par les faits juridiques, Études complémentaires de l'esprit du droit romain* , 5-9, p. 239 ss.), demonstrou que, no plano do direito material, muitos atos e negócios jurídicos acabam projetando eficácia reflexa na esfera de direitos de terceiros. Em época moderna, provêm da experiência do *common law* os subsídios que evidenciam a interdependência das relações jurídicas e suas respectivas implicações. O conhecido precedente da jurisprudência norte-americana *Mac Pherson v. Buick Motor Co.* [1916] é considerado o *leading case* em matéria de responsabilidade aquiliana, no qual se anteviu a falácia da relatividade dos efeitos contratuais (*privity of contract fallacy*), e que, depois, foi aos poucos sendo aplicado a um sem número de situações análogas, em que a vítima experimentou danos materiais (consulte-se, sobre esse instigante assunto, Patrick S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract* t, p. 374-376).

348

Liebman, Giudicato – diritto processuale civile, *Enciclopedia giuridica treccani* , vol. 15, p. 14.

349

Consulte-se, em senso análogo, Sergio Menchini, *Il giudicato civile* , p. 159-160.

350

Ovídio A. Baptista da Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil* , vol. 1, p. 214. Cf. Redenti , *Il giudizio civile con pluralità di parti* , p. 6: “ *In tutti questi casi il giudice non può provvedere sulla domanda (azione-pretesa) se non in quanto tutti i soggetti attivi e passivi dell'azione-pretesa partecipino o siano stati chiamati a partecipare al processo* ” (...) “ *questa è una conseguenza logica, naturale, necessaria e di tutta evidenza del principio del contraddittorio* ”.

351

V., nesse sentido, José Roberto dos Santos Bedaque, *Efetividade do processo e técnica processual* , p. 378-

352

Bedaque, *Efetividade do processo e técnica processual* , p. 378-379; com o esclarecimento, igualmente convincente, de que a mesma conclusão aplica-se à hipótese na qual o vício é flagrado em grau recursal. “Julgado improcedente o pedido, o autor apela e o tribunal verifica a ausência de litisconsorte necessário. Só deverá reconhecer a nulidade do processo ou a carência da ação se o resultado de mérito for favorável ao apelante. Caso contrário melhor será negar provimento ao recurso, ignorando as falhas de natureza processual”. Segue-se aqui trecho de precedente pesquisa que desenvolvi no livro *Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil* , p. 241 ss.

353

Bedaque, *Efetividade do processo e técnica processual* , p. 380-381.

354

Bedaque, *Efetividade do processo e técnica processual* , p. 379-380. V., nesse mesmo sentido, Pablo Grande Seara, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil* , p. 479.

355

V., a respeito, Silas Silva Santos, *Modificações subjetivas na execução e o objeto litigioso* , p. 111 ss.

Nota-se que, dentre muitas outras, o CC contém aí típica norma de processo. V., sobre o tema,, Fredie Didier Júnior, *Regras processuais no novo Código Civil* , p. 10 ss; José Carlos Barbosa Moreira, O novo Código Civil e o direito processual, *Revista Síntese de direito civil e processual civil* , 19:111 ss.

356

Eduardo Talamini, *Coisa julgada e sua revisão* , p. 106. Seria o caso de formular a seguinte indagação: se realmente fosse hipótese de sujeição à eficácia da sentença, o credor estranho poderia promover a respectiva execução provisória? Adianto-me a responder pela negativa.

357

Cf. Cassio Scarpinella Bueno, *Partes e terceiros no processo civil brasileiro* , p. 304: “(...) nos casos de solidariedade é que há regra de *legitimação extraordinária* e, por isto, mesmo que os devedores solidários não ajam ao lado do réu como *litisconsortes* , ficarão eles sujeitos à coisa julgada por imposição do sistema...”. Cf., também, à luz do direito italiano, Francesco Carnelutti, *Cosa giudicata e sostituzione processuale*, *Rivista di diritto processuale* , 1942, p. 25; *Sistema di diritto processuale civile* , 1, p. 381.

358

Eduardo Talamini, *Coisa julgada e sua revisão* , p. 106.

O problema que surge pela falta de correspondência entre os limites da coisa julgada e o cumprimento da sentença *ultra partes* tem sido objeto de atenção pela doutrina italiana, sobretudo porque o CPC peninsular não tem regras tão amplas quanto às dos arts. 778 e 779 do nosso novo CPC. Crisanto Mandrioli, embora entendendo viável, sustenta o caráter excepcional da assimetria entre as partes do processo de conhecimento e os legitimados ao processo de execução (In tema di rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo esecutivo, *Studi in onore di Enrico Allorio* , 1, p. 343 ss.). É importante deixar claro, com Francesco P. Luiso, que a eficácia do título executivo a favor ou contra terceiros não enseja quaisquer questionamentos quanto a possível ofensa ao direito de defesa. Tal situação não guarda similitude alguma com o fenômeno da extensão da coisa julgada a terceiros, que, como já ressaltado, constitui lesão ao princípio do contraditório: ninguém pode ser atingido por um ato decisório sem ter tido oportunidade de defender-se! Mas, na hipótese da eficácia do título executivo contra terceiro, segundo ainda escreve Luiso, aquele que pode se valer do título ou contra quem pode ser ele utilizado é um estranho, que não teve violado o seu direito de defesa. Ao executado cabe contestar a eficácia *ultra partes* do título executivo, sendo que o ônus da prova da higidez da eficácia é do exequente (*Diritto processuale civile* , 3, p. 41). V., ainda, sobre o assunto, o profundo estudo de Francesco P. Luiso, *L'esecuzione "ultra partes"* , p. 1 ss.

Barbosa Moreira, *Solidariedade ativa: efeitos da sentença e coisa julgada na ação de cobrança proposta por um único credor* , p. 72.

Cf., com o meu reparo de que a relação entre fiador e devedor não se insere no referido rol, Eduardo Talamini, *Coisa julgada e sua revisão* , p. 107; e, com apoio no mesmo ponto de vista, André de Albuquerque Cavalcanti Abbud, O conceito de terceiro no processo civil, *Revista da Faculdade de Direito da USP* , 99:865.

Moniz de Aragão, *Sentença e coisa julgada* , p. 320.

João Mendes de Almeida Júnior, *Direito judiciário brasileiro* , p. 298.

V., sobre este tema, a revisão crítica elaborada por Heitor Vitor Mendonça Sica, *Preclusão processual civil* , p. 109 ss.

Heitor Vitor Mendonça Sica, *Preclusão processual civil* , p. 277-279.

366

Barbosa Moreira, Temas de direito processual, 1.^a s., p. 97 ss.

367

Enrico Tullio Liebman, *Notas às Instituições de direito processual civil de Chiovenda*, vol. 3, p. 158.

368

Enrico Tullio Liebman, *Eficácia e autoridade da sentença*, p. 56, nt. i.

369

Eduardo Talamini, *Coisa julgada e sua revisão*, p. 85.

370

V. u., *DJe* 06.10.2009. Cf., ainda, STJ, REsp 469.211-SP, 1^a T., rel. Min. Luiz Fux, v. u., *DJ* 29.09.2003: “A desconstituição do título executivo pretendida resta protegida pelo manto da coisa julgada em face do julgamento dos embargos à execução. É evidente que a eficácia preclusiva da coisa julgada (*tantum judicatum quantum disputatum vel quantum disputari debebat*) impede que julgados os embargos à execução, com decisão trânsita, possa a parte, em ação anulatória, tentar infirmar o título executivo, sem rescindir a sentença proferida na oposição do executado. É assente na jurisprudência do STJ que: ‘Nos termos de precedente da Turma, ‘inocorre preclusão, e portanto a validade e eficácia do título executivo extrajudicial podem ser objeto de posterior ação de conhecimento, quando na execução não forem opostos embargos do devedor, e igualmente quando tais embargos, embora opostos, não foram recebidos ou apreciados em seu mérito. Inexistência de coisa julgada material, e da imutabilidade dela decorrente’. (AGA 176.552-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJ* 2.5.2000). Deveras, um dos meios de defesa da coisa julgada é a eficácia preclusiva prevista no art. 474, do CPC[1973], de sorte que, ainda que outro o rótulo da ação, veda-se-lhe o prosseguimento ao pálio da coisa julgada, se ela visa a infirmar o resultado a que se alcançou na ação anterior”.

371

V., a respeito, com detalhes, Cruz e Tucci, *A causa petendi no processo civil*, p. 103-105.

372

Ovídio A. Baptista da Silva, *Limites objetivos da coisa julgada no direito brasileiro atual*, p. 168, aduzindo, ainda, ser essa “sem dúvida, a fórmula correta para se interpretar as regras, aparentemente antinômicas dos arts. 468 e 474 do CPC”. Valho-me, no texto, de precedente pesquisa, desenvolvida no livro de Cruz e Tucci, *A causa petendi no processo civil*, p. 245-246.

373

Alguns aspectos da coisa julgada no direito processual civil brasileiro, *Revista de Processo*, 62:87.

374

João de Castro Mendes, *Limites objectivos do caso julgado em processo civil* , p. 178-179.

375

Albrecht Zeuner, *Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmem rechtlicher Sinnzusammenhänge* , p. 53 ss.

376

João de Castro Mendes, *Limites objectivos do caso julgado em processo civil* , p. 148. Passando em revista as várias posições da processualística alemã, Miguel Teixeira de Sousa concluiu que a eficácia preclusiva da coisa julgada (“preclusão fática extraprocessual”) não abrange os fatos indispensáveis para a individualização do objeto do processo: O objeto da sentença e o caso julgado material (estudo sobre a funcionalidade processual), *Revista Forense* , 291:31.

377

Cf. Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada* , p. 135.

378

Barbosa Moreira, *A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro* , p. 106.

Capítulo XIV. Da Liquidação de Sentença

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II – pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1.º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2.º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3.º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4.º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Correspondência: art. 475-A, 475-B, 475-C, 475-E, 475-F, 475-G e 475-I, § 2.º, do CPC/73

Comparação jurídica: art. 278 do CPC italiano, art. 716 do CPC português

1. Aspectos gerais: a sentença ilíquida é exceção

Nas ações relativas à obrigação de pagar quantia, segundo os termos do art. 491, antes examinado, o novo CPC estabelece, como regra, que a sentença deve ser líquida.

Todavia, em algumas situações, como também já frisado, delineia-se impossível determinar-se o valor da condenação, ou, ainda, a extensão da obrigação, mesmo que não se trate de fixação de quantia em dinheiro.

Nestes casos, constituindo exceção à regra, torna-se necessário efetivar-se a apuração do *quantum debeatur* ou a especificação do objeto da condenação por meio de liquidação.

A liquidação de sentença tem assim a finalidade de encontrar o montante de uma dívida preexistente ou a abrangência exata da obrigação, reconhecida por decisão judicial.

A exigência de liquidação decorre, pois, como destaca Luiz Rodrigues Wambier, da excepcionalíssima circunstância de ser proferida sentença genérica ou ilíquida, visto que impossível ao julgador determinar, desde logo, na sentença, o valor da condenação ou individuar o objeto da obrigação. Visa-se, pois, pela liquidação, eliminar a generalidade da condenação, de forma que a sentença se torne exequível.¹

2. Espécies de liquidação

Procede-se à liquidação da sentença por meio de arbitramento quando for exigida prova pericial, que será produzida nos autos do processo em que proferida a sentença genérica (art. 509, I).

A liquidação por arbitramento tem a natureza de incidente da fase decisória, cujo escopo é a integração da sentença condenatória.

Ressalte-se, por outro lado, que, havendo necessidade de alegar e provar fato novo, a liquidação será feita por meio de ação de conhecimento, incidental, regrada pelo procedimento comum (art. 509, II), que se identifica com a antiga “liquidação por artigos”.

3. Legitimidade para requerer a liquidação

Encerrada a fase de conhecimento, com a prolação de sentença condenatória, embora genérica, qualquer um dos litigantes, de acordo com o *caput* do art. 509, poderá requerer a liquidação para tornar líquido o pronunciamento judicial.

Não subsiste dúvida de que, tanto quanto o vencedor, o devedor também tem interesse na apuração do montante da condenação, a fim de que possa adimplir a obrigação ou, ainda, para que, no momento oportuno, possa oferecer bens à penhora na medida do *quantum debeatur*.

E isso vale, por certo, para qualquer uma das espécies de liquidação.

Na órbita das ações coletivas na defesa dos interesses homogêneos, cada um dos beneficiados tem legitimação para promover, individualmente, a liquidação da sentença. Nesse sentido, acórdão da 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 600.850-SC, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze: “Segundo a compreensão da 2.^a Seção e da Corte Especial, os poupadores do Banco réu, ou seus sucessores, por força da coisa julgada, possuem legitimidade ativa para ajuizarem liquidação de sentença coletiva promovida para percepção dos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança, no seu domicílio ou no Distrito Federal, independente de fazerem parte ou não dos quadros associativos da entidade. Incidência da Súmula 83/STJ”.²

4. Liquidação parcial

Reproduzindo regra constante do CPC revogado, o § 1.^o do art. 509, na hipótese de o dispositivo da sentença conter uma parte líquida e outra ilíquida, possibilita ao credor requerer o respectivo cumprimento em relação àquela e, ao mesmo tempo, a liquidação atinente à parte genérica.

A liquidação parcial, nessa hipótese, será processada em “autos apartados”, para evitar qualquer tumulto no desenvolvimento da fase de cumprimento da sentença, sobretudo quando se tratar de liquidação por meio de demanda própria.

5. Cálculo aritmético e imediato cumprimento de sentença

Tenha-se presente, por outro lado, que não se faz necessária a instauração de incidente de liquidação, quando a apuração do valor exato da condenação depender exclusivamente de cálculo aritmético. Nesse caso, o credor tem a faculdade de requerer o cumprimento do título judicial, aparelhando o pedido com a respectiva memória de cálculo (art. 509, § 2.^o).

Deverá, com efeito, formular o requerimento de cumprimento da sentença, instruindo-o “com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 CPC).

6. Inusitada diretriz dirigida ao CNJ

Muitos tribunais, em vários Estados da Federação, estabelecem diretrizes e critérios para a atualização monetária da condenação em dinheiro. Todavia, não há orientação uniforme para a elaboração dos respectivos cálculos, fato que, à evidência, conspira contra o princípio da igualdade de todos perante a lei.

Assim, embora de forma inusitada, o legislador processual, no § 3.º do art. 509, *atribui* ao Conselho Nacional de Justiça a tarefa de elaborar e disseminar programa de atualização financeira, o qual – imagina-se – deverá prevalecer em todo território nacional.

7. Simetria entre o título judicial e a liquidação

Aduza-se que, diante do título executivo judicial, mesmo provisório, não se faz possível alterar o seu respectivo conteúdo, quando da apuração do montante exato da obrigação, ainda que esta deva ser feita por mero cálculo do credor.

Invoque-se, a propósito, a regra do § 4.º do art. 509 (análoga à do velho art. 475-G CPC/1973), que tem a seguinte redação: “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Frisa, a propósito, Luiz Rodrigues Wambier que, independentemente da espécie de liquidação: “O respeito àquilo que foi objeto da sentença liquidanda é absolutamente inarredável, sob pena de desrespeito à coisa julgada já ocorrida no processo cuja sentença se vai liquidar, ou até mesmo à própria sentença, se ainda não tiver ocorrido o trânsito em julgado”.³

Anotam, nesse sentido, Theotonio Negrão *et alii*, invocando inclusive dois precedentes judiciais (RTRF 162/37 e RT 660/138): “Ainda que as partes hajam concordado com a liquidação, é lícito ao juiz deixar de homologá-la, desde que em desacordo com a coisa julgada, ‘para impedir que a execução ultrapasse os limites da pretensão a executar’...”.⁴

Na verdade, a demonstrar que a sentença toda deve ser examinada em seu conjunto, como já teve oportunidade de decidir a 4.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 206.946-PR, relatado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: “A liquidação de sentença deve guardar estrita consonância com o decidido no processo de conhecimento, para o que se impõe averiguar o sentido lógico da decisão liquidanda, por meio de análise integrada de seu conjunto. É defeso, na liquidação, modificar a sentença que julgou a lide, mas, na sua interpretação, compreende-se como expresso o que virtualmente nela se contém...”.

Assim, em toda liquidação de verbas decorrentes de condenação pecuniária o que se procura é a apuração – apenas e tão somente – do montante devido; jamais dos parâmetros e percentuais estabelecidos no título exequendo!

Com efeito, no âmbito estrito da liquidação de sentença – mesmo naquela efetivada por meio de ação de conhecimento –, não cabe rediscutir a causa, senão apurar o valor da condenação.

E isso porque o eventual debate deve cingir-se ao quanto foi decidido, como bem pontuou outro importante precedente da 3.ª Turma do referido pretório federal, de relatoria do Ministro Nilson Naves, no Recurso Especial 29.151-RJ, no sentido de que os limites da liquidação devem ater-se aos contornos da coisa julgada, pois: “se o tema não foi ventilado na decisão, não pode ser objeto da liquidação”.

Cumprе registrar que tal posicionamento continua atualmente prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça, como se colhe, e. g., de julgamento da 3.ª Turma, no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.307.939-MG, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “É vedado modificar na fase de execução o índice de correção monetária que já restou definido na decisão exequenda não impugnada em momento processual oportuno, sob pena de ofensa à coisa julgada”.⁵

A mesma 3.ª Turma, ao apreciar o Recurso Especial 1.410.891-MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, consignou que: “Na interpretação do título executivo judicial, deve-se adotar a que guarde conformidade com o objeto do processo e com as questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação. Ofende a coisa julgada a interpretação da sentença que conduz a resultado para além dos limites da lide”.⁶

Não há dúvida, pois, que essa sábia orientação pretoriana, prestigiando a garantia constitucional da coisa julgada, traduz-se em segurança jurídica aos litigantes!

8. Assimetria e cabimento de ação rescisória

Aduza-se que o vício decorrente da divergência entre o título judicial e o ato decisório que homologa ou que julga a liquidação é considerado tão grave que tem sido admitido o cabimento de ação rescisória para rescindi-lo.

Com efeito, julgado da 4.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 322.666-RS, relatado pelo Ministro Marco Buzzi, reconheceu, à unanimidade de votos, que a ação rescisória é a via processual adequada “para desconstituir decisão homologatória de liquidação de sentença quando esta não está em harmonia com a decisão proferida no processo de conhecimento”.⁷

A 3.^a Turma, a seu turno, no julgamento do Recurso Especial 1.513.261-RS, com voto condutor do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, deixou patenteado, na respectiva ementa, que: “1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido da possibilidade de rescisão de título judicial que homologa cálculos em fase de liquidação de sentença somente na hipótese de violação à coisa julgada (art. 485, V, CPC [1973]), havendo desarmonia entre os cálculos e os critérios fixados na sentença exequenda. 2. Inviável, contudo, ação rescisória contra sentença que homologa cálculos em fase de liquidação, sob o fundamento de violação a disposição literal de lei, quando a pretensão é a modificação dos critérios fixados na própria sentença liquidanda já protegida pelo manto da coisa julgada há mais de 2 anos”.⁸

9. Fungibilidade das formas de liquidação

Importa esclarecer, por fim, que nada obsta ao juiz, na fase de cumprimento da sentença, alterar a espécie de liquidação determinada no título judicial, visando a atender, de forma mais efetiva, as peculiaridades da demanda.

É nesse sentido o enunciado da Súmula 344/STJ: “A liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

A 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 657.476-MS, da relatoria da Ministra Nancy Andrigli, assentou, com clareza e precisão, que: “As formas de liquidação de sentença não ficam ao talante do juiz, pois fazem parte do devido processo legal e, como tal, são de ordem pública. As formas de liquidação especificadas na sentença cognitiva não transitam em julgado, razão pela qual, aplica-se, na hipótese de vício de inadequação da espécie de liquidação, o chamado princípio da fungibilidade das formas de liquidação, segundo o qual a fixação do *quantum debeatur* deve processar-se pela via adequada, independentemente do preceito expresso no título exequendo. A coisa julgada somente torna imutável a forma de liquidação depois do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de liquidação e não do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento”.⁹

Note-se que esta diretriz, no dizer de Luiz Rodrigues Wambier¹⁰, converge integralmente com o princípio do máximo aproveitamento dos autos processuais, visto que, em caso contrário, a solução seria de todo indesejável, qual seja a de se reconhecer a invalidade da sentença condenatória genérica que, por equívoco, tivesse determinado forma de liquidação inadequada para a situação concreta.

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Prova pré-constituída

A liquidação por arbitramento pressupõe a exigência de conhecimento técnico para que se possa apurar o diâmetro exato da obrigação que foi imposta, de modo genérico, pela condenação.

Assim, a parte que requerer a liquidação por arbitramento, como é curial, já deverá instruir o seu pedido com prova adequada (“pareceres ou documentos elucidativos”), apta a subsidiar a convicção do julgador.

É evidente que o outro demandante também terá a faculdade de apresentar elementos pertinentes, cooperando para a individuação da obrigação.

Não obstante, o art. 510, certamente para evitar qualquer celeuma, prevê a intimação dos litigantes para que, no prazo a ser fixado, apresentem subsídios que possam contribuir para a liquidação.

2. Produção de prova pericial

Caso o juiz não se sinta suficientemente esclarecido com a prova documental produzida pelos litigantes, não podendo, destarte, proferir decisão imediata, deverá deferir, de ofício, ou, até mesmo, a requerimento das partes, a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 464 e seguintes do CPC.

3. Adiantamento da remuneração do perito

Embora o art. 95 do novo estatuto processual determine que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados quando deferida de ofício ou pleiteada por ambas as partes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que este critério não deve prevalecer no âmbito da liquidação da sentença.

Realmente, a 2.^a Turma, no julgamento do Recurso Especial 1.354.760-DF, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, teve oportunidade de decidir que: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (recurso representativo da controvérsia REsp. 1.274.466-SC, 2.^a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.5.2014)”. ¹¹

Nessa mesma direção, julgado da 3.^a Turma, no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.382.842-SC, com voto condutor do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, textual: “Incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença. É cabível ao devedor a antecipação dos honorários periciais em sede de liquidação de sentença, ainda que os arts. 19 e 33 do CPC [1973] atribuam tal encargo ao autor da demanda. Isso porque os referidos dispositivos legais somente têm aplicabilidade até o trânsito em julgado da sentença. Após, incide a regra do art. 20 do CPC [1973], que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda”. ¹²

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Ação de conhecimento para a prova de fato novo

Cumprir observar, de início, que na redação desse dispositivo o legislador continua referindo-se a “fato novo” como sinônimo de “fato superveniente”. Não há de se confundir, entretanto, fato novo – que é aquele preexistente, mas que não foi ou não pode ser alegado nos autos no momento

da fase postulatória –, com fato superveniente – aquele que ocorreu posteriormente.

Seja como for, o “fato novo” que se pretende provar, após a prolação da sentença, não deve guardar qualquer pertinência com o *an debeatur*, vale dizer, com o reconhecimento da obrigação, já devidamente assentada no título judicial, mas, sim, com as circunstâncias objetivas tendentes a determinar o valor ou a abrangência da obrigação.

Desse modo, tem lugar a liquidação por meio de demanda cognitiva, visando então à prova do fato ou fatos que possam atingir aquele escopo.

O réu foi condenado a indenizar o autor por todos os danos decorrentes de acidente de veículos, inclusive no ressarcimento de despesas médicas, presentes e futuras, como, por exemplo, cirurgia reparatória, tratamento fisioterápico e aquisição de medicamentos.

A condenação pelo gasto com cirurgia, todavia, embora contemplada na sentença, não pode ter o seu valor estimado na fase de conhecimento, visto que a necessária comprovação de sua viabilidade e extensão (“fato novo”) deve ser feita em liquidação de sentença.

E isso, porque, como decidiu a 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.344.962-DF, com voto condutor do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: “Se as partes, no curso do processo de conhecimento, não logram demonstrar a extensão de todo o dano causado à vítima, o ordenamento jurídico pátrio permite que se prove fato novo na liquidação por artigos, desde que não se promova indevida alteração do julgado, nos termos dos arts. 475-E e 475-G do CPC[1973]”.¹³

Há situações, contudo, que se apresentam mais complexas, como, v. g., a que foi recentemente enfrentada pela 4.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 660.109-RJ, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, ao concluir que: “A liquidação por artigos, à luz do disposto no art. 475-E do CPC [1973], se revela adequada para a apuração do quantum devido quando há a necessidade de se alegar e provar fatos novos, ainda não discutidos na ação de conhecimento. Na espécie, ante a necessidade de se perquirir a culpa subjetiva de cada uma das partes em relação às prorrogações ocorridas nas execuções dos contratos firmados – consoante fixado no título executivo –, ressoa inequívoca a necessidade da liquidação por artigos, sendo certo que a aferição da responsabilidade deverá ser enfrentada no procedimento liquidatório especificamente em cada contrato, a fim de se apurar o quantum indenizatório”.¹⁴

2. Intimação da outra parte

Como já esclarecido, embora mais raro do que, em tese, pode ocorrer no âmbito da liquidação por arbitramento, nessa espécie de liquidação, ambas as partes também estão credenciadas ao ajuizamento da respectiva ação.

Aforada a demanda, o outro litigante será intimado (*rectius* : citado) na pessoa de seu advogado ou em nome da sociedade de advogados por ele integrada, independentemente de constar do instrumento de mandado poder expresso para receber citação. E isso, porque é a própria letra do art. 511 do CPC que investe o advogado ou a sociedade deste ônus.

Lembre-se que, em consonância com o art. 272, § 1.º, a intimação à sociedade de advogados somente será válida se o(s) advogado(s) da parte tiver(em) requerido que nas intimações a ele(s) dirigida(s), “figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil”.

• Contestação e recurso cabível

Efetivada a cientificação do requerido, abre-se-lhe então o prazo de 15 dias para a apresentação de contestação, regida, em todos os seus pormenores, pelo art. 335 e seguintes do CPC.

Na fase instrutória, embora, em princípio, sejam admitidos os meios de prova previstos na lei processual, o fato probando deve, à evidência, guardar nexos específicos com o objetivo da

demanda, qual seja a liquidação da condenação genérica.

O ato decisório que julga esta espécie de liquidação tem a natureza de sentença, que pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, segundo preceitua o parágrafo único do art. 1.015 do novo diploma processual: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Justifica-se esta exceção à regra de que a sentença desafia recurso de apelação (art. 1.009 CPC) para evitar os inconvenientes de um passado remoto, que tornava inatingível a efetividade do processo.

Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Compromisso com a duração razoável do processo

A presente norma legal, que fora introduzida há uma década em nosso sistema processual pela Lei 11.232/2005 (art. 475-A, § 2.º), inspira-se também no princípio da duração razoável.

Reproduzindo *ipsis verbis* o art. 475-A, § 2.º, do CPC revogado, vem autorizada a liquidação, ainda que tenha sido interposto recurso contra o ato decisório que definiu o montante da condenação.

2. Procedimento

Trata-se de “liquidação provisória”, que se processa em autos em apartado, perante o juízo de primeiro grau, por conta e risco do liquidante.

O respectivo requerimento, nesta hipótese, deverá ser instruído com o traslado de cópias das peças reputadas necessárias à apuração objetivada.

Tratando-se de ação de liquidação, igualmente, será aforada perante o juízo de origem, observando-se, no que for compatível, os requisitos legais que conotam o ajuizamento de qualquer demanda.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Luiz Rodrigues Wambier, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.313.

2

V. u., *DJe* 09.10.2015. V., em senso análogo, STJ, AgRg no AREsp 300.089-SP, 4.ª T., rel. Min. Marco Buzzi, v. u., *DJe* 09.11.2015: “Consoante assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, é necessária a prévia liquidação da sentença coletiva, mediante a formação de uma nova relação processual, pois somente com esse procedimento abrir-se-á um juízo cognitivo acerca do eventual direito material individual do exequente em relação ao executado”.

3

Luiz Rodrigues Wambier, *Liquidação de sentença*, São Paulo, p. 110.

4

Theotonio Negrão *et alii*, *Código de Processo Civil e legislação processual em vigor*, p. 582, nt. 4 ao art. 475-G.

5

V. u., *DJe* 31.03.2015.

6

V. u., *DJe* 16.03.2015.

7

DJe 20.03.2015.

8

V. u., *DJe* 28.09.2015.

9

V. u., *DJ* 12.06.2006.

10

Luiz Rodrigues Wambier, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.316.

11

M. v., com declaração de voto vencido do Min. Herman Benjamin, *DJe* 18.12.2014.

12

V. u., *DJe* 04.08.2015.

13

V. u., *DJe* 02.09.2015.

TÍTULO II - DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

Capítulo I. Disposições Gerais

1. Previsão da garantia da duração razoável do processo

A redação original de nossa Constituição Federal, como é notório, inseriu, no inc. LIV do art. 5.º, uma cláusula geral, assegurando, explicitamente, a garantia do *due process of law* : “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. E, ainda, para que ficasse extirpada de dúvidas, além dessa preceituação genérica, já suficiente para alcançar o fim por ela colimado, previu, em vários incisos do citado art. 5.º e, ainda, no art. 93, IX, incorrendo em manifesta redundância (porém, louvável...), inúmeros corolários da garantia constitucional do devido processo legal.

Não havia, contudo, qualquer disposição acerca do direito à tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável. A teor do § 2.º do mesmo art. 5.º: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Oportuno, nesse passo, lembrar que o nosso país é signatário do Pacto de San José de Costa Rica, que adquiriu eficácia internacional em 18 de julho de 1978. O Congresso Nacional, posteriormente, mediante o Dec. 27, de 26 de maio de 1992, aprovou o seu texto, sendo que o nosso Governo, em 25 de setembro do mesmo ano, depositou a respectiva carta de adesão à apontada convenção. Com a ulterior publicação do Dec. 678/1992, o Pacto de San José foi promulgado e, finalmente, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro.

Desse modo, apesar de a garantia do devido processo legal pressupor o rápido desfecho do litígio, o direito à duração razoável já estava contemplado, em nosso sistema jurídico, mesmo antes da alteração do texto constitucional, dada a evidente compatibilidade de regramentos, em particular, pelo art. 8.º, 1, do referido Pacto de San José: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável...”.

E, com efeito, a jurisprudência de nossos tribunais foi instada a apreciar alegada ofensa à garantia do jurisdicionado a um processo sem dilações indevidas. Ao inventariar as raras ocorrências de pedido de dano moral gerado pela demora do processo, pode ser colacionado o caso que teve curso perante a 7.ª Vara da Justiça Federal da seção judiciária de São Paulo (*proc. 89.0017372-3*), promovido contra a União, no qual a sentença de procedência do pedido considerou irrazoável a demora de 20 anos para o deslinde do processo trabalhista e, portanto, constatada a imperfeição do serviço público. A condenação foi fixada em quantia equivalente a 150 salários mínimos.

No plano do processo administrativo, a 6.ª Câm. Civ. do TJRS, no julgamento da Apelação 70006474233, relatado pelo saudoso Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, deu provimento ao recurso de apelação, para impor condenação ao Estado do Rio Grande do Sul, porque reconhecido o excesso de prazo no desenvolvimento da sindicância e do subsequente inquérito administrativo.

2. Adoção expressa e interpretação da garantia

A despeito dessa original orientação pretoriana, visando a espantar qualquer dúvida e afinando-se com as modernas tendências do direito processual, o legislador pátrio, por meio da Emenda Constitucional 45/2004, acabou inserindo o inc. LXXVIII no suprarreferido art. 5.º, com a seguinte redação: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Seguindo a mesma premissa que norteou as regras dos arts. 5.º, LV, e 93, IX e X, da Constituição Federal, no sentido de garantir, respectivamente, a ampla defesa e o contraditório, a motivação das decisões e a publicidade do procedimento tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o texto constitucional passou então a contemplar a garantia do processo, judicial e administrativo, sem dilações indevidas. Assegurou, outrossim, a implementação de meios que garantam a economia e a celeridade processual.

Observe-se, em primeiro lugar, que, dada a profunda diversidade da *performance* da justiça nos vários quadrantes do Brasil, a aferição do *prazo razoável* será absolutamente diferenciada de Estado para Estado, seja no âmbito da Justiça estadual, seja no dos tribunais federais. De um modo geral, pela inarredável falta constante de recursos materiais destinados ao Poder Judiciário, a justiça no Brasil é lenta.

Ademais, sem embargo da carência de dados estatísticos, pela exigência de metas imposta pelo Conselho Nacional de Justiça, não há dúvida de que, nas Cortes estaduais, tem ocorrido inegável encurtamento do tempo para julgamentos dos recursos e das ações originárias.

Recordo, por outro lado, o famoso art. 6.º, I, da Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita em Roma, no dia 4 de novembro de 1950, que tem a seguinte redação: “Toda pessoa tem direito a que sua causa seja examinada equitativa e publicamente num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial instituído por lei, que decidirá sobre seus direitos e obrigações civis ou sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal contra ela dirigida”.¹

Foi, sem dúvida, a partir da edição desse diploma legal supranacional, que o *direito ao processo sem dilações indevidas* passou a ser concebido como um direito subjetivo constitucional, de caráter autônomo, de todos os membros da coletividade (incluídas as pessoas jurídicas) à *tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável*, decorrente da proibição do *non liquet*, vale dizer, do dever que têm os agentes do Poder Judiciário de julgar as causas com estrita observância das normas de direito positivo.

Efetivou-se, outrossim, ao longo do tempo, a necessária exegese da abrangência do supratranscrito dispositivo, tendo-se, unanimemente, como *dilações indevidas*, os atrasos ou delongas que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das *etapas mortas* que separam a realização de um ato processual de outro, sem subordinação a um lapso temporal previamente fixado, e, sempre, sem que aludidas dilações dependam da vontade das partes ou de seus mandatários.

Todavia, torna-se impossível fixar *a priori* uma norma específica, determinante da violação à garantia da tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável.

E, por isso, consoante orientação jurisprudencial da Corte Europeia dos Direitos do Homem, consolidada em 1987, no famoso caso Capuano, três critérios, segundo as circunstâncias de cada caso concreto, devem ser levados em consideração para ser apreciado o limite temporal razoável de duração de um determinado processo. Por via de consequência, somente será possível verificar a ocorrência de uma indevida dilação processual a partir da análise: a) da complexidade do assunto; b) do comportamento dos litigantes e de seus procuradores; e c) da atuação do órgão jurisdicional.²

Esse expressivo precedente impôs condenação ao Estado italiano, fixando-a numa indenização

pelo dano moral “derivante do estado de prolongada ansiedade pelo êxito da demanda”, experimentado por uma litigante nos tribunais daquele país.

Escreve, a esse respeito, Jean-Pierre Marguénaud, que “l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure, elle se réalise au cas par cas eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes”.³

O reconhecimento de tais critérios, que exigem uma análise casuística, bem revela que as *dilações indevidas* não decorrem da simples inobservância dos prazos processuais pré-fixados.⁴

Assim, é evidente que se uma determinada questão envolve, por exemplo, a apuração de danos à natureza, a prova pericial a ser produzida poderá demandar muitas diligências que justificarão duração bem mais prolongada da fase instrutória.

O Tribunal europeu exige da parte reclamante “diligência normal” no desenrolar do processo, “não lhe sendo imputável a demora decorrente do exercício de direitos ou poderes processuais, como o de recorrer ou de suscitar incidentes...”.⁵

Desse modo, não poderão ser taxadas de *indevidas* as dilações proporcionadas pelo esforço das partes, as quais, valendo-se das próprias regras processuais, acabam causando um natural prolongamento do procedimento.⁶

É necessário, pois, que a morosidade, para ser reputada realmente inaceitável, decorra do comportamento doloso de um dos litigantes, ou, ainda, da inércia, pura e simples, do órgão jurisdicional encarregado de dirigir as diversas etapas do processo. É claro que a pleora de causas, o excesso de trabalho, não pode ser considerado, neste particular, justificativa plausível para a lentidão da tutela jurisdicional.

3. Duração razoável abrangente da “atividade satisfativa”

No que toca ao novo CPC, verifica-se que, apesar de intuitivo, a regra do art. 4.º, para não deixar margem a qualquer dúvida, estende-se, de forma expressa, à fase de cumprimento de sentença e, por certo, também ao processo de execução, vale dizer, a toda “atividade satisfativa” em prol da parte vencedora.

Daí a relevância da técnica aprimorada inserida no vigente estatuto processual, procurando minimizar o *calcanhar de Aquiles* da tutela jurisdicional, qual seja, as dificuldades clássicas para se alcançar a satisfação do direito reconhecido ao credor, tanto no título judicial, quanto no título extrajudicial.

Ademais, entre os poderes do juiz, o art. 139, II, preceitua que lhe incumbe: “velar pela duração razoável do processo”.

Diversos dispositivos do novo diploma processual concedem ao magistrado o poder de controlar e reprimir atos que possam colocar em risco a celeridade processual. Confira-se, e. g., arts. 113, § 1.º, 672, III e 685, parágrafo único.

Contudo, importa asseverar que a introdução de mecanismos aptos a assegurar a duração razoável do processo não deve, em qualquer situação, vulnerar o princípio fundamental do devido processo legal.

4. Técnicas de tutela executiva

No atual modelo processual brasileiro, a satisfação coativa do direito do credor se faz por meio de duas diferentes técnicas executivas predispostas, dependendo da proveniência material do crédito. Sendo portador de título executivo extrajudicial, o credor pode ajuizar diretamente ação de execução autônoma, seguindo as regras do livro II da parte especial, mais precisamente do art. 797 e seguintes do CPC.⁷ Tratando-se de título executivo judicial, por outro lado, após a fase de

conhecimento, a execução respectiva desenvolve-se nos próprios autos, legalmente designada fase de cumprimento de sentença, que vem disciplinada, em suas múltiplas variantes, nos arts. 513 a 538 do CPC.

Verifica-se claramente que o legislador continuou adotando a técnica do denominado processo sincrético,⁸ no qual, encerrada a fase cognitiva, o vencedor poderá, em continuação, no mesmo processo, pleitear o cumprimento do título judicial, com início dos atos executórios.

Com esta significativa alteração estrutural, restou superada, como se verifica, a dicotomia *processo de conhecimento / processo de execução*, visto que aglutinados como etapas de uma atividade jurisdicional sucessiva: uma etapa destinada ao reconhecimento do direito, e outra, tendente à sua realização concreta.⁹

Como bem lembra Araújo Cintra, na nossa doutrina mais antiga, Gabriel de Rezende Filho, defendia esse procedimento unívoco, ao asseverar que “sem a execução a sentença condenatória não teria eficácia alguma”, e, portanto, “a execução é a fase lógica e complementar da ação”, porque, “vindo a juízo, não pretende o interessado obter apenas a declaração ou reconhecimento de seu direito de um modo platônico, mas aspira à mais completa tutela jurídica com a efetiva manutenção ou restauração de seu direito”.¹⁰

A técnica acolhida pelo novo diploma processual para efetivar-se o cumprimento de sentença foi, na verdade, introduzida no CPC/1973 pela Lei 11.232/2005, que procurou minimizar um dos problemas mais alarmantes da nossa justiça civil, qual seja, a enorme dificuldade de realização da atividade satisfativa dentro de um prazo razoável. Na respectiva exposição de motivos desse texto legal, veio, de fato, destacado o lapso temporal intolerável entre a definição do direito material e a sua efetivação, nos seguintes termos: “a dicotomia atualmente existente, adverte a doutrina, importa a paralisação da prestação jurisdicional logo após a sentença e na complicada instauração de um novo procedimento, para que o vencedor finalmente tente impor ao vencido o comando soberano contido no ato decisório judicial. Há, destarte, um longo intervalo entre a definição do direito subjetivo lesado e sua necessária restauração, isso por pura imposição do sistema procedimental, sem nenhuma justificativa, quer de ordem lógica, quer teórica, quer de ordem prática”.

Buscando, pois, aligeirar a satisfação do credor, o legislador instituiu, no âmbito do procedimento do cumprimento de sentença: a) a desnecessidade de nova citação do devedor; b) a imposição de multa ao vencido caso não cumpra a obrigação; e c) a supressão do efeito suspensivo da impugnação oferecida pelo executado, que deixou de ter a natureza de embargos do devedor.

Importa ter ainda presente que nem todo título judicial determina a inauguração da fase de cumprimento de sentença, simplesmente porque pode ter sido ele produzido em processo no qual, sob a ótica formal, tal prolongamento se inviabiliza.

Assim, a exigência judicial do cumprimento da sentença penal condenatória transitada em julgado, da sentença estrangeira devidamente homologada e da sentença arbitral, deve ser provocada em processo autônomo, com requerimento de citação do executado (art. 515, § 1.º, CPC), “o que constitui seguríssimo sinal de que um novo processo está sendo iniciado, não apenas uma nova fase”.¹¹

Não obstante, qualquer que seja o método de efetivação processual do comando da sentença, não se confundem as atividades cognitivas e executivas, que guardam as suas respectivas identidades.

Ademais, a despeito da existência de determinadas discrepâncias procedimentais entre as duas formas de satisfação forçada do crédito, tanto o cumprimento de sentença quanto o processo autônomo de execução constituem técnicas de tutela executiva, que têm por finalidade realizar, no plano dos fatos, um dado preceito jurídico que o devedor deixou de cumprir de modo espontâneo.

¹²

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1.º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2.º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II – por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III – por meio eletrônico, quando, no caso do § 1.º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos;

IV – por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3.º Na hipótese do § 2.º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4.º Se o requerimento a que alude o § 1.º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3.º deste artigo.

§ 5.º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

Correspondência: arts. 475-I e 475-R do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Disciplina procedimental do cumprimento de sentença

Havendo duas espécies de execução forçada, é compreensível que o legislador tenha traçado dois diferentes grupos de normas, cada qual destinado a disciplinar cada uma daquelas.

O procedimento do cumprimento de sentença deve seguir o regramento estabelecido nos arts. 513 a 538 do CPC, que compõem, juntamente com as disposições atinentes ao processo de conhecimento, o Livro I da Parte Especial, sob a rubrica *Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença*.

A execução de títulos extrajudiciais, por sua vez, no recinto de processo autônomo, é regulamentada pelo Livro II (*Do Processo de Execução*) da Parte Especial do novo CPC, nos arts. 771 a 925.

Cumprir registrar que, a teor do disposto no art. 513 do CPC, estas disposições que disciplinam, de forma particularizada, a ação de execução, são também aplicáveis, no que for compatível, dependendo da natureza da prestação, ao procedimento do cumprimento de sentença. Na verdade, para evitar repetição no mesmo diploma legal, tais normas têm incidência direta e não propriamente subsidiária.

Desse modo, as regras sobre a penhora, por exemplo, previstas no art. 831 e seguintes do CPC, devem ser integralmente observadas na esfera da execução de título judicial, realizada por meio do denominado cumprimento de sentença.

2. Iniciativa do exequente

Sagrando-se vencedor, qualquer que seja a natureza e a extensão da obrigação reconhecida no respectivo título executivo judicial, é intuitivo que, na ausência de adimplemento voluntário pelo condenado, o credor pretenda exercer o seu direito por meio de atos coativos sobre o patrimônio ou sobre o ânimo do devedor.

Exatamente por esta razão, nos domínios do direito comum medieval, com o trânsito em julgado da sentença condenatória e, se fosse necessário, após a apuração do *quantum debeatur*, a execução se instaurava por autoridade do juiz, que impunha, ao devedor, considerando-se a natureza do julgado, um *facere*, *dare*, *exibere*. Foi somente bem mais tarde, na passagem do séc. XVII ao XVIII, que, norteando-se por um princípio nascido no ideário do Estado liberal, passou-se a tributar respeito à autonomia da vontade. É dizer que, em tese, o credor beneficiado pelo título executivo judicial, pode muito bem abdicar de seu direito à correspondente satisfação.¹³

Daí porque, no processo civil moderno, do mesmo modo como se inicia qualquer ação de conhecimento, sempre mediante provocação do autor, o portador do título judicial tem igualmente o ônus de requerer o seu cumprimento, ainda que provisório, nos termos do § 1.º do art. 513 do CPC.

Observe-se que, diante dessa regra expressa, o diploma processual em vigor, em boa hora, põe fim à prolongada polêmica doutrinária e jurisprudencial quanto à exigência ou não de manifestação do exequente para dar início ao cumprimento de sentença.

É certo que os tribunais já se inclinavam pela tese que predominava, de um modo geral, entre os processualistas,¹⁴ no sentido de que se fazia necessário requerimento do interessado para tal escopo, como se infere de precedente da Corte especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 940.274-MS, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, ao assentar que: “O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art. 475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do CPC [1973], cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada”.¹⁵

O cumprimento do título judicial, provisório ou definitivo, deverá então ser pleiteado em petição escrita, dirigida ao juízo competente.

Todavia, como prescreve, de forma original, o art. 526 do CPC, antes mesmo da intimação para o cumprimento da sentença, o devedor tem a prerrogativa de se antecipar, oferecendo em juízo a soma que entende devida, demonstrada em memória de cálculo.

3. Intimação do devedor

Apresentado requerimento para o cumprimento da sentença, o juiz deverá determinar a intimação do executado para adimplir a obrigação.

Nota-se que o novo CPC procura estabelecer, nas diversas situações previstas no rol do § 2.º do art. 513, um equilíbrio razoável entre celeridade e segurança, a evitar que o ato de intimação do devedor, revestido de garantias suficientes, atravanque o início da atividade satisfativa.

3.1. Diferentes formas de intimação

Dependendo das circunstâncias que emergem do caso concreto, diferente será o modo de intimação do devedor, devendo ser consideradas as disposições do art. 269 e seguintes do CPC.

A despeito do art. 272, que estabelece preferência, quando possível, pela intimação por meio eletrônico, nos quadrantes do cumprimento de sentença, de um modo geral, será o executado cientificado pela imprensa oficial, a teor do art. 513, § 2.º, I, na pessoa de seu advogado regularmente constituído nos autos, para que pague o débito no prazo de 15 dias. Esta certamente será a forma mais comum de intimação, sem prejuízo de ser ela implementada por via eletrônica.

Não obstante, quando representado por defensor público ou não tiver procurador constituído nos autos, o devedor será intimado por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2.º, II), cujo prazo terá início a partir da juntada deste aos autos.

Todavia, nessa derradeira situação, se a citação do executado foi realizada por edital no preâmbulo da fase de conhecimento e deixou-se ficar revel, a sua intimação também será editalícia, na forma do art. 256 do CPC (art. 513, § 2.º, II e IV).

Ressalte-se, outrossim, que se a devedora for empresa pública ou privada, não estando representada por advogado constituído nos autos, a intimação lhe será feita por meio eletrônico, uma vez que, segundo o art. 246, § 1.º, encontra-se ela obrigada a manter cadastro “nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações”. Cumpre lembrar que as microempresas e as empresas de pequeno porte, expressamente liberadas desta obrigação, não poderão ser intimadas por via eletrônica.

3.2. Intimação presumida

Constitui ônus das partes manter atualizados os seus endereços, físico e eletrônico, nos autos do processo (art. 274, parágrafo único, CPC).

E isso porque, a teor do art. 513, § 3.º, presume-se efetivado o ato de intimação, nas hipóteses do anterior § 2.º, II e III, ou seja, quando o devedor não estiver representado nos autos por advogado, mesmo que o seu atual endereço seja outro, não comunicado ao juízo em ocasião oportuna.

3.3. Exigência de intimação pessoal

Esclareça-se, ainda, que se o credor requerer o cumprimento somente depois de um ano do trânsito em julgado da sentença, o § 4.º do art. 513 exige que a intimação seja efetivada na pessoa do devedor, mediante carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço declinado nos autos. O parágrafo único do art. 274 do CPC dispõe que, nessa hipótese, considera-se realizada a intimação, ainda que o executado tenha passado a residir em outro local, não informado no processo. Como o ato de intimação é considerado válido, os prazos fluirão a partir da juntada aos autos do aviso de entrega da correspondência, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, no antigo endereço.

4. Delimitação subjetiva do cumprimento de sentença

Ao vetar expressamente, no § 5.º do art. 513, que o cumprimento de sentença seja direcionado contra o fiador, o coobrigado ou o corresponsável, que não tenha participado da fase de conhecimento, o legislador não fez mais do que atender à regra do art. 506, antes comentada, que estabelece os limites subjetivos da coisa julgada, circunscrevendo-a às partes, não podendo prejudicar terceiros.

E isso porque todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (*parte*) é considerado *terceiro* . Não integrando o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. Daí porque, por não terem participado dos atos que precedem e preparam o julgamento final, os terceiros não podem sofrer os efeitos da sentença de mérito e muito menos se vincularem à coisa julgada material.

Realmente, diante de princípios éticos e políticos, de tendência marcadamente democrática, repugna a ideia de que um sujeito de direitos, sem que se lhe seja assegurado “o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, para que possa, na condição de parte, apresentar as suas próprias razões, venha a ser privado de seus bens por força de decisão judicial transitada em julgado. Quando nada, haveria inarredável afronta à letra do art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Importa salientar, no entanto, que a regra do art. 513, § 5.º, CPC, não abrange os legitimados passivos supervenientes, enumerados no art. 790 do CPC, inclusive aquele que passa a ostentar a condição de parte, quando atingido pela desconsideração da personalidade jurídica (art. 137 CPC).

Art. 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.

Correspondência: art. 572 do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Relação jurídica sujeita a condição ou termo

Todo ato decisório deve ser certo. Pode-se, pois, dizer que *decisão certa* é aquela que expressa, no dispositivo, sem qualquer dificuldade de compreensão, a resposta à pretensão deduzida pelo autor, passível de ser exigida em imediata sequência.

Todavia, não se entreve óbice algum a que a eficácia do pronunciamento judicial fique condicionada à superveniência de um evento futuro e incerto, como, e. g., aquele previsto no art. 98, § 3.º, quando a sentença impuser condenação nas verbas de sucumbência ao beneficiário da gratuidade, a exigibilidade da prestação, isto é, o respectivo cumprimento, fica suspenso pelo interregno de cinco anos, até que aquele tenha recursos financeiros para arcar com a obrigação.

Outro exemplo de condenação proferida na esfera de relação jurídica sujeita a condição, comum nos manuais, é o da sentença proferida nas ações possessórias, ao também estabelecer medida necessária e adequada para a eventualidade de desrespeito à determinação judicial ou de reiteração de atos de turbacão ou esbulho, após o julgamento da causa (art. 555, parágrafo único, I, CPC). A condenação, em tal situação, somente se faz exequível se verificada a condição prevista na sentença.

Na verdade, a eficácia da sentença fica contida *si et in quantum*, até porque é absolutamente inoperante a exigência de cumprimento do ato decisório se não se verificar a condição ou o termo.

A 4.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou esta questão em aresto que se tornou conhecido pela sua reconhecida didática, no julgamento do Recurso Especial 164.110-SP, com voto condutor do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, com a seguinte ementa: “I – Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão. II – A sentença condicional mostra-se incompatível com a própria função estatal de dirimir conflitos, consubstanciada no exercício da jurisdição. III – Diferentemente da ‘sentença condicional’ (ou ‘com reservas’, como preferem Pontes de Miranda e Moacyr Amaral Santos), a que decide relação jurídica de direito material, pendente de condição, vem admitida no CPC[1973] (art. 460, par. ún.). IV – Na espécie, é possível declarar-se a existência ou não do direito de percepção de honorários, em ação de rito ordinário, e deixar a apuração do montante para a liquidação da sentença, quando se exigirá a verificação da condição contratada, como pressuposto para a execução”.¹⁷

2. Prova da ocorrência da condição ou termo

O legislador reiterou integralmente, no novo art. 514, a regra do art. 572 do CPC revogado, devendo o exequente demonstrar que a condição se implementou (arts. 121a 130 CC) ou que ocorreu o termo (art. 131 CC) para viabilizar o início do cumprimento de sentença, cabendo-lhe o ônus de produzir prova nesse sentido.

Dispõe, com efeito, o art. 803, III, do CPC, que é nula a execução quando for iniciada antes de se verificar a condição ou de sobrevir o termo. Ademais, caso seja desrespeitada essa norma, com atuação precipitada do exequente, responderá ele pelos possíveis prejuízos experimentados pelo devedor.

Nesse sentido, sob a égide do velho diploma, posicionou-se a 4.^a Turma do Superior Tribunal de

Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.680-PR, da relatoria do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, ao assentar que: “resta examinar a ocorrência ou não de negativa de vigência ao art. 618, III, da Lei instrumental [CPC/1973]. Expressa essa norma ser nula a execução se instaurada antes de ser verificada a condição ou de ocorrido o termo, nos casos do art. 572 do mesmo diploma... Não ocorrida a condição acordada, nula se apresentava a execução do que resulta negativa de vigência ao art. 618, III, pelo v. acórdão recorrido”.¹⁸

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II – a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III – a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V – o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI – a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII – a sentença arbitral;

VIII – a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX – a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X – (*Vetado.*)

§ 1.º Nos casos dos incisos VI a IX, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2.º A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

Correspondência: art. 475-N do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 501 do NCPC francês, art. 474 do CPC italiano, art. 517 da LEC espanhola, art. 703 do CPC português, § 704 do ZPO alemão

1. Rol de títulos executivos judiciais

Considerando-se as graves consequências que decorrem da execução coativa sobre o patrimônio do devedor bem como sobre a sua própria vontade, o início dos atos executivos pressupõe a existência de um título, judicial ou extrajudicial, apto a demonstrar, em princípio, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito, ou seja, do direito nele inserido.

É, pois, como enfatiza Arruda Alvim, a existência do título executivo que torna viável o caminho das vias executivas para a tutela de um determinado direito.¹⁹

O CPC, repetindo e aprimorando dispositivos que já se encontravam nos diplomas processuais anteriores, enumera, nos arts. 515 e 784, respectivamente, os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais, cabendo lembrar que se subordinam eles ao regime da tipicidade, vale dizer, não se admite execução aparelhada com um documento não especificado na legislação em vigor como título executivo.

No que concerne aos títulos executivos judiciais, produzidos no âmbito de precedente processo de natureza jurisdicional, encontram-se eles catalogados no art. 515, a saber:

1.1. Decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa

A sentença condenatória, desde as fontes romanas do processo arcaico, sempre foi o título executivo judicial por excelência. E assim, igualmente na dogmática moderna, é ela que representa, de forma marcante, o exemplo mais significativo desta espécie de título, a viabilizar o início dos atos de execução forçada.

Não é de hoje que um segmento significativo da doutrina processual pátria sustenta que a tripartição das eficácias das sentenças não encerra todas as situações enfrentadas no plano prático. Assim, ao lado da tradicional classificação dogmática dos provimentos finais nas sentenças declaratória, constitutiva e condenatória, acrescentam-se as sentenças mandamental e executiva.

Seja como for, é curial que toda e qualquer ação e, pois, todas as sentenças proferidas em processo de conhecimento contenham eficácia declaratória, em grau de intensidade mais ou menos acentuado.

No que ora interessa, devo registrar, de início, que as ações de cognição, objetivamente simples, são, sempre e apenas, declaratórias, porque têm como primordial escopo estabelecer a certeza objetiva acerca de uma determinada relação jurídica.

A literatura especializada, de um modo geral, muito debateu acerca da natureza da ação declaratória, procurando justificar a sua existência ao lado das demais.

A celeuma restou minimizada quando se deu conta de que a *certeza jurídica* é, em si mesma, um bem da vida, alcançável, como qualquer outro bem juridicamente relevante, por meio do processo.

Como, com acuidade, pontuou Chiovenda, a dificuldade que a doutrina anterior encontrava em arrolar a ação declaratória com as demais resultava de não se perceber que há bens que apenas o processo judicial pode atribuir, sendo um deles a *certeza jurídica* : até mesmo o reconhecimento pelo adversário jamais poderia produzi-la em igual grau, desde que nenhuma segurança se equipara à da coisa julgada.²⁰

Importa observar que, diante do princípio dispositivo, contemplado no art. 141 do CPC, não se pode negar ao autor a pretensão à simples declaração, mesmo quando já consumado o inadimplemento pelo réu, sendo, por via de consequência, também possível a propositura da ação condenatória. É a regra do art. 20: “É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito”.

Interpretando o nosso tradicional sistema, esclarece Alfredo Buzaid, com lastro em Liebman, que: “Certamente não se pode negar ao autor uma liberdade de escolha que a lei lhe conferiu. Naturalmente, se ele preferiu a ação declaratória, a sentença não lhe permitirá pedir a execução, para a qual será necessário que proponha uma nova ação e obtenha uma sentença condenatória”.²¹

Na pioneira e clássica monografia sobre o tema, Adolf Wach²² noticia que, igualmente, na esfera do processo alemão, no qual prevalece o mesmo princípio da disposição, “o titular do direito não está impedido de molestar o seu adversário com sucessivas ações parciais. Que pague o adversário a dívida total se preferir não se submeter a vários processos, ou se pretender uma decisão integral, que deduza a totalidade da lide mediante reconvenção”.

Examinando essa importante questão, Cernelutti assevera que sempre foi mais aconselhável, sob vários aspectos, dirimir em um único processo – *processo integral* – todo o litígio porventura existente entre as partes. Não obstante, por razões que somente dizem respeito à conveniência do demandante, o jurista italiano acabou admitindo o denominado *processo parcial* , no qual o autor

formula apenas pedido declaratório, relegando para um segundo momento, se for o caso, o ajuizamento de ação condenatória.²³

O processo civil de conotação liberal, como o adotado pela legislação pátria, é dispositivo por excelência, cabendo unicamente ao autor avaliar a estratégia de deduzir pedido de simples declaração, sendo-lhe lícito pedir tudo que lhe toca ou menos. E como a declaração está contida na sentença condenatória, seria naturalmente um contrasenso que se lhe negasse a faculdade de pedir apenas aquela, o que talvez responda à sua conveniência.

É possível, por exemplo, ocorrer que, ao escolher a via judicial, o autor entenda que a produção da prova do descumprimento contratual e da aferição do valor do dano sejam demoradas ou onerosas, ou que se sinta suficientemente garantido com a simples declaração de seu direito; pode-se dar, também, que o interesse precípua do demandante esteja na própria declaração, porquanto, por razões íntimas ou mesmo objetivas (como, e. g., a insolvência notória do réu), não pretenda proceder à cobrança do crédito.

Invoque-se, a propósito, emblemático precedente da 2.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 8.303-SP, de relatoria do Ministro Ari Pargendler, que, lastreado no parágrafo único do art. 4.^o do CPC revogado, assentou: “Ainda que a parte tenha tutela mais completa em outro tipo de demanda, nem por isso fica descaracterizado o seu interesse de agir mediante ação declaratória”.²⁴

Se por acaso o pedido do autor se restringe exclusivamente à tutela declaratória e o juiz “avança o sinal”, em desrespeito à congruência, concede mais, impondo condenação ao réu, e a decisão estará contaminada por vício de ultrapetição. A sentença é considerada *ultra petita*.

Assim, para a devida interpretação do ato decisório de mérito é necessário diagnosticar qual a real pretensão do autor, ou seja, o alcance do pedido, independentemente do sentido semântico das palavras deduzidas na petição inicial.

Exatamente por esta razão, o processualista Teori Albino Zavascki, ao relatar o julgamento do Recurso Especial 588.202-PR, perante a 1.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, desenvolveu interessante tese, ao admitir que a sentença declaratória encerra igualmente a potencialidade de ser exequível, quando contiver “definição de certeza a respeito do débito, não apenas da existência da relação jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, não há como negar-lhe, categoricamente, eficácia executiva. Conforme assinalado anteriormente, ao legislador ordinário não é dado negar executividade a norma jurídica concreta, certificada por sentença, se nela estiverem presentes todos os elementos identificadores da obrigação (sujeitos, prestação, liquidez, exigibilidade), pois isso representaria atentado ao direito constitucional à tutela executiva, que é inerente e complemento necessário do direito de ação”.²⁵

É certo que essa original construção influenciou o legislador pátrio. Com efeito, a Lei 11.232/2005, que alterou a clássica sistemática da execução de título judicial adotada pelo estatuto processual revogado, teria substituído a sentença condenatória”, constante do rol dos títulos executivos judiciais, pela “sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia” (art. 475-N, I, CPC/1973).

O novo CPC, seguindo a mesma orientação, prevê, no art. 515, I, entre os títulos executivos judiciais, “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação...”.

Seja sob a égide da Lei 11.232/2005, que introduziu o art. 475-N, I, no velho estatuto processual, seja agora, na vigência do CPC de 2015, não foi, na verdade, criado qualquer título judicial novo, visto que, a despeito da respectiva redação, antiga e atual, é sempre o provimento de natureza condenatória que é passível de execução; jamais a sentença meramente declaratória.²⁶

Impõem-se aqui duas observações: a) o novel texto legal alude à “exigibilidade da obrigação” e não mais à “existência da obrigação”, para evidenciar que não basta apenas o reconhecimento do débito, mas, para alcançar a via executiva, torna-se necessário que seja ele exigível; e, ainda, b) foi

também inserida, no lugar de “sentença”, o termo “decisão”, vocábulo “que melhor retrata o fenômeno, tendo em vista que, sendo atacada por recurso de apelação, a sentença muito provavelmente será substituída por acórdão ou decisão monocrática. Deve-se lembrar, ainda, que, no CPC/2015, está expressa a possibilidade de “julgamento antecipado parcial do mérito”, o que se faz através de decisão interlocutória (art. 356)”.²⁷

1.2. Decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial

Vale observar, de início, que, resultando frutífera a conciliação ou a mediação, o juiz deverá homologá-la, por meio de sentença equiparada ao julgamento com resolução do mérito, nos termos expressos do art. 487, III, *b*.

Mesmo que as partes tenham logrado chegar a um consenso fora dos tribunais, podem elas submeter as cláusulas do negócio extrajudicial ao Poder Judiciário visando obter a chancela de órgão jurisdicional, seguindo as regras do procedimento previsto no art. 725, VIII (“jurisdição voluntária”), sendo admitido, pelo art. 724, recurso de apelação contra a sentença homologatória.

Oportuna a lembrança de que esta decisão, formalmente jurisdicional, assemelha-se à sentença subjetivamente complexa, porque a sua construção decorre de múltiplos partícipes: “ato de inteligência das partes ‘somado’ à vontade estatal (homologação). Se não houvesse a homologação, tal ato de autocomposição poderia ser no máximo um título extrajudicial”.²⁸

A solução suasória da lide, obtida por meio de conciliação ou de mediação, em quaisquer circunstâncias, reclama, pois, segundo dispõe o art. 334, § 11.º, necessária homologação por sentença do respectivo termo de transação (que também pode ser materializada em petição conjunta).

Tal ato decisório consubstancia-se em título executivo judicial.

Dúvida não há de que a nova redação do art. 515, II e III, é bem mais aperfeiçoada, porque se refere respectivamente a autocomposição judicial e extrajudicial, de qualquer natureza.

1.3. Possibilidade de ampliação subjetiva e objetiva da autocomposição

O § 2.º do art. 515, ora comentado, autoriza a ampliação subjetiva e objetiva do acordo celebrado pelas partes, apesar desta previsão ser absolutamente desnecessária, visto que, tendo natureza de negócio jurídico bilateral, jamais se poderia questionar, no âmbito da transação judicial, a ampliação dos limites do objeto do processo.²⁹

Reiterando doutrina generalizada, como já tive oportunidade de lembrar, aduz, a propósito, Francisco J. Peláez, que na transação *mista* ou *complexa*, na qual se alarga o objeto quanto às recíprocas concessões, as partes podem também dar ou prometer alguma coisa diferente daquela que constitui objeto da situação ou relação controvertida, geralmente com o propósito de pôr fim ao litúgio.³⁰

Endossando esse ponto de vista, é preciso o pontual ensinamento de Pontes de Miranda: “a transação judicial tem conteúdo de direito material e só é processual o efeito de pôr termo ao processo, mas, para que tal efeito exista, é de mister que apanhe o objeto do litúgio em seu todo, ou em parte quantitativamente determinada. Não lhe é empecilho ter de regular matéria estranha ao processo, ainda que sujeita a outra lide, ou ter de estar presente ao ato pessoa estranha ao processo, que assuma dívida própria, ou alheia, ou consinta, ou assinta, ou anua, ou dê autorização ou permissão para algum dos pontos de transação”.³¹

1.4. Formal e certidão de partilha

Preceitua o art. 655 do CPC que, uma vez transitada em julgado a sentença que julgou a partilha, receberá o herdeiro o quinhão que lhe cabe, especificado no formal.

Formal de partilha constitui um documento, extraído de peças dos autos e expedido pelo juízo,

que comprova a divisão de bens deixados pelo autor da herança, discriminando os quinhões dos respectivos herdeiros. Se porventura o quinhão hereditário não ultrapassar o montante de cinco salários mínimos, o formal de partilha poderá ser substituído pela certidão de partilha (art. 655, parágrafo único).

O formal e a certidão de partilha também são considerados títulos executivos judiciais apenas em relação àqueles que, pelo aspecto subjetivo, são beneficiários das disposições constantes de tais referidos documentos, ou seja, “o inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal” (art. 515, IV, CPC), pessoas que participaram do contraditório no processo de inventário ou de arrolamento.

Cumprindo ressaltar que o legislador poderia ter aproveitado a oportunidade para inserir na mesma referida norma legal, ao lado da sentença homologatória de partilha no processo de inventário ou de arrolamento, outras situações nas quais também há partilha judicial, como, por exemplo, aquela observada na ação de divórcio, que, igualmente, tem eficácia de título executivo judicial, *ex vi* do disposto no art. 731, parágrafo único, c/c. art. 654.

1.5. Crédito de auxiliar da justiça

Corrigindo disposição do CPC revogado, o art. 515, V, transplantou, do rol de títulos executivos extrajudiciais para aqueles judiciais, o crédito de auxiliar da justiça, “quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial”.

Assim, por exemplo, a decisão judicial que fixa os honorários do perito consubstancia-se em título executivo judicial, razão pela qual o credor, auxiliar da justiça, poderá efetivar o cumprimento da respectiva obrigação relativa àquele crédito nos próprios autos em que aprovado, evitando o ajuizamento de ação específica para obter a satisfação de seu direito.

1.6. Sentença penal condenatória transitada em julgado

As relações entre a ação penal e a ação civil reparatória de danos, em nosso direito positivo, têm disciplina coordenada pelos arts. 935 do Código Civil, 515, VI, do CPC, 91, I, do Código Penal, e 63, 65, 66 e 67 do Código de Processo Penal, pela qual desponta o caráter autônomo da ação civil. A vítima poderá ajuizá-la imediatamente após a perpetração do crime ou aguardar o pronunciamento da Justiça criminal.

Aforada ou não a demanda de natureza civil, na medida em que os fundamentos da sentença penal condenatória coincidam com os que sejam necessários e suficientes no juízo cível para afirmar a obrigação de reparar os danos causados pelo ato criminoso, considera a lei, como efeito secundário da decisão penal, o reconhecimento da existência dessa obrigação. Esse reconhecimento ou, a teor do art. 91, I, Código Penal, o “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”, não se insere na motivação da sentença. Constitui parte que integra o seu dispositivo e, portanto, adquire a autoridade da coisa julgada. Com o trânsito em julgado do decreto condenatório verifica-se, como efeito deste, a produção de um título executivo judicial (art. 63, CPP e 515, VI, CPC).³²

Consoante notou Carnelutti, a coisa julgada penal produz duas espécies de eficácia: a) direta é aquela que concerne à responsabilidade civil do próprio condenado; e b) reflexa é a que atinge outrem (*ultra reum*), responsável civil, que não foi chamado como tal no processo penal.³³

É evidente que o devedor certificado no título somente pode ser o réu condenado, que participou do processo penal e contra quem se instaurará, na esfera cível, o incidente de liquidação (*ex vi* do art. 509, CPC) para apurar o *quantum debeatur* e, em seguida, a execução.

Saliente-se, por fim, que o reconhecimento da prescrição da ação penal (dita, equivocadamente, da pretensão punitiva), *antes* do trânsito em julgado, retira qualquer eficácia (principal ou secundária) da sentença penal condenatória e, portanto, não pode ser considerada título executivo judicial.

De conformidade com importante precedente da 2.^a Câm. do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 575.497-5: “A prescrição retroativa, no sistema da chamada Nova Parte Geral do Código Penal – Lei 7.209, de 11.07.1984 –, constitui modalidade de prescrição da pretensão punitiva [*rectius* : da ação penal], e, assim, não subsistindo os efeitos secundários da sentença condenatória, esta não corporifica o título executivo a que alude o art. 584, II, do CPC [1973]. A modificação introduzida... abriu mão da pretensão punitiva, e como na prescrição da pretensão punitiva inexistia condenação do réu, conseqüentemente todos os efeitos da sentença condenatória cessaram, quer principais ou secundários, quer penais ou civis, porque a prescrição da pretensão punitiva representando a renúncia ao direito de ação penal..., faz desaparecer o direito de punir do Estado, sem o qual enfim, não há direito à reparação do dano *ex delicto* , nem muito menos título executivo”.³⁴

1.7. Sentença arbitral

A arbitragem consiste numa técnica de heterocomposição de controvérsias mediante a intervenção de um ou mais árbitros, escolhidos pelas partes, a partir de uma convenção de natureza privada. Dentre as peculiaridades mais salientes da Lei 9.307/1996, destaca-se a equiparação da sentença arbitral à sentença judicial, como, com toda clareza, dispõe o art. 31: “A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”.

Infere-se, de logo, que se atribui natureza publicística ao juízo arbitral, consubstanciado em equivalente jurisdicional, por opção das partes. A despeito de ser instituído por meio de um instrumento negocial de cunho privado (convenção arbitral), o desenrolar do processo de arbitragem é tão jurisdicional quanto aquele que tramita perante a justiça estatal, fundamento suficiente para atribuir-se à sentença arbitral a natureza de título executivo judicial (art. 515, VII).

O diagnóstico da eficácia executiva do provimento emitido em processo de arbitragem deve ser feito à luz do inc. I do art. 515, considerando-se igualmente passível de excussão a sentença arbitral, parcial ou definitiva, “que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.

Ademais, o processo arbitral pode ser classificado como sendo de “jurisdição contenciosa”, cuja sentença, segundo o art. 26 da Lei de Arbitragem, deve ser elaborada seguindo a mesma estrutura formal exigida pela legislação processual (art. 489 CPC).

1.8. Sentença estrangeira homologada

Com redação imprecisa, o art. 515, VIII, arrola entre os títulos executivos judiciais, “a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça”, quando, na verdade, como bem flagrado por Marcelo Abelha,³⁵ , é a sentença homologatória que constitui o verdadeiro título judicial.

O processo objetivando o denominado *juízo de delibação* é da exclusiva competência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o art. 105, I, *i* , da CF (EC 45/2004), cujo procedimento encontra-se regido pelos arts. 960 a 965 do CPC, e, ainda, pelos arts. 216-A a 216-N, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, introduzidos pela Emenda Regimental de 17 de dezembro de 2014.

Após a devida homologação da sentença estrangeira, o seu cumprimento se efetiva perante a Justiça federal competente, por meio de carta de sentença e a requerimento da parte interessada (art. 965 CPC).

1.9. Decisão interlocutória estrangeira

O novo CPC acrescentou, na lista de títulos executivos judiciais, a decisão interlocutória estrangeira, assim como autorizou a execução provisória quando esta conceder medida de urgência, após a concessão do *exequatur* à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça.

O respectivo procedimento é regido pela Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, vigente em território brasileiro a partir do Dec. 1.899, de 9 de maio de 1996, pelo art. 36 do CPC, e, em particular, pelos arts. 216-O a 216-X do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a concessão do *exequatur* às cartas rogatórias se dará por decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, exceto quando houver impugnação, podendo a carta rogatória ser encaminhada para julgamento da Corte Especial. Reza, com efeito, o art. 216-T do Regimento Interno que: “Havendo impugnação ao pedido de concessão de *exequatur* a carta rogatória de ato decisório, o Presidente poderá determinar a distribuição dos autos do processo para julgamento pela Corte Especial”.

Concedido o *exequatur*, a carta rogatória será remetida ao Juízo Federal competente para a devida execução da decisão estrangeira.

2. Exigência de citação do executado

Como antes esclarecido, do ponto de vista formal, não são todos os títulos judiciais que ensejam a ulterior instauração da fase de cumprimento de sentença, uma vez que alguns dentre eles são produzidos em outra esfera processual, circunstância que inviabiliza o sincretismo.

Assim, guardando a devida coerência com o sistema, o § 1.º do art. 515 do CPC determina que o cumprimento da sentença penal condenatória transitada em julgado, da sentença arbitral, da sentença estrangeira devidamente homologada e da decisão interlocutória eficaz pelo *exequatur* deve ser provocado em processo autônomo, perante o juízo cível competente, com requerimento de citação do executado.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I – os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III – o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Correspondência: art. 475-P do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 16 e 17 do CPC italiano, art. 545 da LEC espanhola, arts. 85 a 89 do CPC português

1. Competência para o cumprimento de sentença

1.1. Juízo da sentença

A regra geral de competência para o cumprimento de sentença decorre do princípio processual da *perpetuatio iurisdictionis*, razão pela qual o procedimento, em fase sucessiva, desenrola-se, em princípio, perante o mesmo juízo no qual se produziu o título executivo judicial.

Seguindo esta orientação, o cumprimento de sentença será processado, nos tribunais, nas causas de sua competência originária. Isso significa, e. g., que se o acórdão proferido numa ação rescisória reconhecer a exigibilidade de obrigação de pagar quantia (art. 515, I, CPC), o respectivo cumprimento deve ser pleiteado perante o tribunal que o prolatou. Cumpre esclarecer, com Arruda Alvim, que “tal regra não se altera na hipótese de que, em virtude do recurso interposto, a decisão prolatada seja substituída por outra, proferida em tribunal de superposição”.³⁶ Nesse caso, no exemplo da ação rescisória, se foi ela ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,

caberá a este determinar o cumprimento do julgado de natureza condenatória, mesmo que, diante de recurso especial, o pronunciamento transitado em julgado, que constitui o título executivo, seja acórdão do Superior Tribunal de Justiça.

O mesmo ocorre na hipótese de a causa ter sido aforada em primeiro grau de jurisdição. O cumprimento da sentença se efetiva no juízo em que tramitou o processo e foi decidida a causa, independentemente da proveniência do título exequendo (art. 516, II), ou seja, ainda que a sentença seja substituída por acórdão, será sempre o juízo de primeiro grau o competente para proceder-se ao cumprimento da condenação.

1.2. Impossibilidade de incidência da regra geral

Tratando-se de sentença penal condenatória, de sentença arbitral e de sentença estrangeira, pelos motivos já expostos, não há como ser fixada a competência do juízo que as proferiu para o seu subsequente cumprimento.

Segundo o art. 516, III, a execução destes títulos judiciais será efetivada perante o juízo civil que for competente, com a instauração de um novo processo, iniciada por meio de petição inicial, devendo o exequente requerer a citação do devedor (art. 515, § 1.º, CPC).

São as normas gerais de competência, especificadas nos arts. 42 a 66 do CPC, que determinarão, nestas hipóteses, o foro para o cumprimento da sentença.

1.3. Opção concedida ao exequente

O parágrafo único do art. 516, inspirado por certo na premência de efetividade da atividade satisfativa, autoriza o exequente a eleger, em caráter excepcional, outro juízo para iniciar o cumprimento da sentença, podendo ser o atual domicílio do devedor, aquele no qual se encontram os seus bens, ou, ainda, o juízo em que deve ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.

Optando o credor por um destes juízos, deverá requerer ao juiz que dirigiu a fase de conhecimento e que proferiu a sentença a ser executada, isto é, o *juízo de origem*, a remessa dos autos do processo ao destinatário do pleito de cumprimento.

Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.

§ 1.º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão.

§ 2.º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.

§ 3.º O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado.

§ 4.º A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Protesto da decisão judicial transitada em julgado

O descumprimento das obrigações de um modo geral provoca, como é evidente, uma série de graves consequências ao devedor.

Dentre elas, o art. 517, agora examinado, autoriza que a decisão judicial coberta pela coisa julgada seja levada a protesto, uma vez constatado o inadimplemento no prazo de 15 dias, fixado no art. 523 do CPC.

O art. 1.º da Lei 9.492/1997 preceitua que o protesto é o “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”, a demonstrar que, consoante exegese da 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 750.805-RS, sob a relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, antes mesmo da edição do novel diploma processual, já se fazia possível o protesto de decisão judicial representativa de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, entendimento esse explicitado na seguinte ementa: “1. O protesto comprova o inadimplemento. Funciona, por isso, como poderoso instrumento a serviço do credor, pois alerta o devedor para cumprir sua obrigação. 2. O protesto é devido sempre que a obrigação estampada no título é líquida, certa e exigível. 3. Sentença condenatória transitada em julgado, é título representativo de dívida – tanto quanto qualquer título de crédito. 4. É possível o protesto da sentença condenatória, transitada em julgado, que represente obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. 5. Quem não cumpre espontaneamente a decisão judicial não pode reclamar porque a respectiva sentença foi levada a protesto”.³⁷

Aduza-se que, a teor da redação da norma ora comentada, qualquer ato decisório reconhecido como título judicial, que imponha obrigação de pagar quantia, pode ser levado a protesto, ou seja, decisões interlocutórias e acórdãos, transitados em julgado, desde que não se verifique o adimplemento voluntário no prazo legal.

A efetivação do protesto perante o tabelião competente somente se viabiliza se constatada a liquidez e certeza da obrigação e do trânsito em julgado da condenação, bem como verificado o inadimplemento no prazo legal.

2. Providências atinentes ao protesto e ao seu respectivo cancelamento

Pretendendo levar a protesto a decisão judicial condenatória, o credor deverá apresentar ao cartório de protesto certidão, que deve ser expedida pela serventia do juízo no qual tramita o processo no prazo de três dias, independentemente de ordem judicial.

Atendendo aos requisitos dos §§ 1.º e 2.º do art. 517, a lei exige que a certidão seja circunstanciada, contendo a íntegra do ato decisório exequendo, a especificação das partes e do processo, o montante do débito e, particularmente, a data do *dies ad quem* do prazo, já vencido, destinado ao pagamento voluntário pelo devedor.

Acrescenta Sérgio Shimura³⁸ que o devedor, certamente para evitar que seja tirado o protesto da decisão judicial, pode muito bem efetuar o pagamento do valor integral da dívida diretamente ao tabelionato de protesto, como inclusive autoriza o disposto no art. 3.º da referida Lei 9.492/1997.

3. Ação rescisória e anotação à margem do protesto

De forma um tanto casuística, o § 3.º do art. 517, na hipótese de o executado ter aforado ação rescisória almejando a impugnação (*rectius* : desconstituição) do título judicial, resguarda ao devedor a faculdade de requerer a certificação, à margem do protesto, do ajuizamento da referida demanda. Nesse caso, é o executado que arcará com todas as despesas decorrentes da indigitada averbação, além de ser de sua exclusiva responsabilidade o ressarcimento por eventuais prejuízos causados ao credor.

4. Cancelamento do protesto

Comprovada a satisfação integral da obrigação, o devedor pode requerer ao juiz a expedição de ofício dirigido ao cartório, determinando o cancelamento do protesto.

Esta ordem deverá ser atendida em três dias, a partir do protocolo do ofício (e não do requerimento, como consta da equivocada redação do § 4.º do art. 517).

5. Protesto da decisão que fixa alimentos provisórios ou definitivos

Importa ainda anotar que a decisão judicial que fixa alimentos provisórios ou definitivos também poderá ser levada a protesto, a teor do § 1º do art. 528 do CPC, razão pela qual esta nova providência coercitiva poderá ser tomada pelo credor.

6. “Negativação” do nome do devedor

Escreve, a propósito, Sérgio Shimura, que o protesto da decisão judicial não se confunde com a possibilidade de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, desde que se trate de cumprimento definitivo da sentença, segundo preceituam os §§ 3.º e 5.º do art. 782 do CPC.³⁹

Examinando essa temática, de modo original e bem analítico, a 4.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do provimento do Recurso Especial 1.533.206-MG, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, enfatizou, na respectiva ementa, que: “(...) 5. É plenamente possível que o magistrado, no âmbito da execução de alimentos, venha a adotar, em razão da urgência de que se reveste o referido crédito e sua relevância social, as medidas executivas do protesto e da inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, caso se revelem como meio eficaz para a sua obtenção, garantindo à parte o acesso à tutela jurisdicional efetiva. 6. Isso porque: i) o segredo de justiça não se sobrepõe, numa ponderação de valores, ao direito à sobrevivência e dignidade do menor; ii) o rito da execução de alimentos prevê medida mais gravosa, que é a prisão do devedor, não havendo justificativa para impedir meio menos oneroso de coerção; iii) a medida, até o momento, só é admitida mediante ordem judicial; e iv) não deve haver divulgação de dados do processo ou do alimentando envolvido, devendo o registro se dar de forma sucinta, com a publicação ao comércio e afins apenas que o genitor é devedor numa execução em curso. 7. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser ‘possível o protesto da sentença condenatória, transitada em julgado, que represente obrigação pecuniária líquida, certa e exigível’ (REsp 750.805-RS, 3.^a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, *DJe* 16.06.2009). 8. Trata-se de posicionamento já consagrado em legislações de direito comparado, sendo inclusive previsão do novo CPC, que estabeleceu expressamente a possibilidade do protesto e da negativação nos cadastros dos devedores de alimentos (arts. 528 e 782). 9. Na hipótese, o recorrido, executado na ação de alimentos, devidamente citado, não pagou o débito, sendo que, determinando-se diligências, não foram encontrados bens passíveis de penhora em seu nome. Portanto, considerando-se que os alimentos devidos exigem urgentes e imediatas soluções – a fome não espera –, mostram-se juridicamente possíveis os pedidos da recorrente, ora exequente, de protesto e de inclusão do nome do devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito (SPC e Serasa), como medida executiva a ser adotada pelo magistrado para garantir a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente”.⁴⁰

A inscrição em apreço pode ser deferida pelo juiz, mediante requerimento do exequente (art. 782, § 3.º).

O cancelamento do nome do devedor no cadastro de inadimplentes é determinada, consoante dispõe o § 4º do art. 782 do CPC, imediatamente após: a) o pagamento; b) a garantia da execução; ou c) a extinção da execução por qualquer outro fundamento.

Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Meios defensivos do executado

Depois de devidamente intimado (ou citado, quando a citação é exigida), deixando transcorrer o prazo de 15 dias, previsto no art. 523 do CPC, sem efetuar o pagamento, o devedor poderá: a) opor, a qualquer momento, a denominada exceção de preexecutividade, deduzindo questões de ordem pública, como ilegitimidade passiva, pagamento etc.; b) alegar, por meio de petição avulsa, fato superveniente ou invalidade de atos executivos subsequentes (art. 525, § 11); ou c) no prazo sucessivo de 15 dias, apresentar impugnação, podendo alegar as matérias arroladas no § 1.º do art. 525 do CPC.

A técnica de defesa por meio de exceção de preexecutividade, de consolidação pretoriana, restringe o seu cabimento para a arguição de questões que poderiam ser conhecidas *ex officio*, não exigindo dilação probatória para o seu julgamento.

Já a impugnação propriamente dita é o instrumento típico de defesa, pelo qual o executado, nos mesmos autos e, portanto, em caráter incidental, deduz a sua defesa formal, nos termos do apontado art. 525, § 1.º.

Ademais, apesar da imprecisa redação do art. 518, após o momento reservado à impugnação, o executado poderá ainda arguir qualquer vício atinente ao procedimento de cumprimento da sentença e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, como, por exemplo, a impenhorabilidade do bem constrito.

2. Arguição incidental mediante simples petição

Trata-se, como se observa, de arguição incidental, deduzível, apreciada e julgada nos próprios autos, até porque, mais adiante, no art. 525 do CPC, que disciplina o procedimento da impugnação do devedor, o § 11 reza que: “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato”.

Não é de se estranhar, portanto, a plenitude do contraditório em inúmeros incidentes que ocorrem no curso do procedimento do cumprimento de sentença.

Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.

Correspondência: art. 273, § 3.º, do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Cumprimento da decisão concessiva de tutela provisória

A tutela provisória, fundada na urgência ou na evidência, que contiver eficácia condenatória deve ser liquidada, se necessário for, e executada segundo a disciplina do art. 509 e seguintes do CPC. O legislador basicamente repetiu a regra do § 3.º do art. 273 do diploma revogado, determinando que as normas que disciplinam a liquidação e o cumprimento de sentença têm aplicação subsidiária às decisões que concedem tutela provisória. O preceito do art. 519 também é reiterado no parágrafo único do art. 297 do CPC, atinente às disposições gerais da tutela provisória: “A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”.

A tutela provisória pode ter por objeto obrigação de pagar quantia, de fazer ou não fazer ou de entrega de coisa. Assim, o cumprimento da decisão, provisória ou definitiva, seguirá o procedimento apropriado (de sub-rogação ou de coerção), predisposto para cada espécie de prestação. Fixada multa diária como medida de apoio ao cumprimento da tutela provisória de fazer, não fazer ou entrega de coisa, quando provisório o seu cumprimento, o levantamento do valor depositado somente poderá ocorrer se a decisão transitar em julgado (art. 537, § 3.º, CPC).

NOTAS DE RODAPÉ

1

V., especificamente, Patrick Grzybek, *Prozessuale Grundrechte im Europäischen Gemeinschaftsrecht* , p. 75-76.

2

Cf. José Antonio Tomé García, *Protección procesal de los derechos humanos ante los tribunales ordinarios* , p. 119, com lastro em José Almagro Nosete. V., a propósito, inclusive com a transcrição do acórdão proferido no caso Capuano, o meu livro *Tempo e processo* , p. 69 ss. Consulte-se, ainda, José M. Bandres Sanchez-Cruzat, *El tribunal europeo de los derechos del hombre* , p. 91; Vicente Gimeno Sendra, *Constitución y proceso* , p. 144 ss.; Cruz e Tucci, Garantia da prestação jurisdicional sem dilações indevidas como corolário do devido processo legal, *Devido processo legal e tutela jurisdicional* , p. 104; Duração razoável do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF), *O advogado, a jurisprudência e outros temas de processo civil* , p. 102

3

Jean-Pierre Marguénaud,. *La Cour européenne des droits de l’homme* , p. 94.

4

Cf. Mercedes García Arán, *La prevaricación judicial* , p. 156. V., ainda, Héctor Faúndez Ledesma, El derecho a un juicio justo, *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas* , 80:158.

5

José Lebre de Freitas, *Introdução ao processo civil – conceito e princípios gerais à luz do Código revisto* , p. 112, nt. 8.

6

Gimeno Sendra, Moreno Catena e Cortés Domínguez, *Derecho procesal – proceso penal* , p. 94-95.

7

Note-se que, consoante o art. 785 do CPC, a circunstância de o credor ser portador de título executivo extrajudicial não implica obrigação de ajuizamento de ação de execução, tornando-se possível, caso ele prefira, “optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.

8

Sincretismo tem o significado de fusão de dois ou mais corpos antagônicos em um único elemento. A

locução *processo sincrético* expressa o método pelo qual cognição e execução, em forma coordenada e sucessiva, efetivam-se nos mesmos autos, em benefício da otimização do tempo do processo. Esta técnica remonta às fontes do direito romano-canônico, de época medieval, revelada pelo princípio *sententia habet paratam executionem*, extraído da execução *per officium iudicis*, que consistia, segundo afirmação de Liebman, no “simples prosseguimento e complemento do ato de prolação da sentença”, uma vez que a sentença de natureza condenatória tem a eficácia “de ser, por si só, suficiente para permitir a execução, sem necessidade de nova ação e novo contraditório” (*Processo de execução*, p. 11 e 45).

9

Cassio Scarpinella Bueno, *Curso sistematizado de direito processual civil*, 2, t. 1, p. 330.

10

Antonio Carlos de Araújo Cintra, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 364.

11

Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, 4. ed., p. 456, lembrando ainda que a execução contra a Fazenda Pública e a execução de alimentos, igualmente, são processos distintos daqueles em que os respectivos títulos foram construídos.

12

Cf. Arruda Alvim, *Novo contencioso cível no CPC/2015*, p. 341.

13

Consulte-se, com precisa exposição do perfil histórico da execução, a clássica obra de Giuseppe Salvioli, *Storia del diritto italiano*, vol. 3, parte 2: Storia della procedura civile e criminale, p. 658.

14

V., p. ex., Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual de execução civil*, p. 46-47.

15

M. v., *DJe* 31.05.2010.

16

V., no mesmo sentido, Sérgio Seiji Shimura, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.322.

17

V. u., *DJ* 08.05.2000.

18

V. u., *DJ* 02.04.1990.

19

Novo contencioso cível no CPC/2015 , p. 360.

20

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil* , vol. 1, p. 222. V., seguindo esse posicionamento, Adroaldo Furtado Fabrício, *A ação declaratória incidental* , p. 30; Celso Agrícola Barbi, *Ação declaratória principal e incidente* , p. 70.

21

Alfredo Buzaid, *A ação declaratória no direito brasileiro* , p. 136.

22

Adolf Wach, *Der Feststellungsanspruch – La pretensión de declaración* , p. 120.

23

Francesco Carneluti, *Istituzioni del processo civile italiano* , vol. 1, p. 255.

24

V. u., *DJ* 27.05.1996.

25

V. u., *DJ* 25.02.2004.

26

V., a propósito, Eduardo Talamini, “Sentença que reconhece obrigação” como título executivo (CPC, art. 475-N, I, acrescido pela Lei 11.232/2005), *Execução civil e cumprimento de sentença* (obra coletiva), p. 159.

27

Cf. Arruda Alvim, *Novo contencioso cível no CPC/2015* , p. 364-365.

28

Marcelo Abelha Rodrigues, *Manual de execução civil* , p. 131.

29

V., em sentido contrário, Araken de Assis, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 6, p. 151, entendendo que o juiz depende de regra expressa para homologar o acordo das partes sobre questões estranhas ao objeto litigioso.

30

Francisco J. Peláez, *La transacción: su eficacia procesal*, p. 72.

31

Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, t. 25, p. 137.

32

Cf., no sentido do texto, Botelho de Mesquita, Da autoridade civil da coisa julgada penal, *Coisa julgada*, p. 43 ss.

33

Francesco Carnelutti, Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale, *Rivista di diritto processuale*, 1948:12. Sobre tal afirmação duas ressalvas são necessárias: a) Carnelutti escreveu esse ensaio sob a vigência do art. 28 do CPP italiano, que permitia a execução civil da sentença penal condenatória contra quem não participara do processo penal. Esta regra foi declarada inconstitucional, em 1971, pela Corte Constitucional italiana; e b) a “eficácia reflexa” da coisa julgada que atinge terceiro, na visão de Carnelutti, constituiria, na verdade, *eficácia da sentença penal*.

34

JTACrimSP, Lex, vol. 99, p. 377-379. V., em senso análogo, por último, Fabiano Oldoni, A prescrição da pretensão punitiva e a coisa julgada no cível, *Revista Jurídica*, 339:91 ss., que bem ressalva: “(...) caso a prescrição seja reconhecida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, aí, neste caso, ocorrerá a coisa julgada no âmbito civil” (p. 94).

35

Manual de execução civil, p. 132.

36

Arruda Alvim. *Novo contencioso cível no CPC/2015*, p. 356.

37

M. v., *DJe* 16.06.2009.

38

Sérgio Seiji Shimura. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* , p. 1.333.

39

Sérgio Seiji Shimura. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* , p. 1.333.

40

V. u., *DJe* 01.02.2016.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

CAPÍTULO II. DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

Capítulo II. Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I – corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II – fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III – se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1.º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.

§ 2.º A multa e os honorários a que se refere o § 1.º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3.º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

§ 4.º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

§ 5.º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.

Correspondência: art. 475-O do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 514 a 526 do NCPC francês, art. 282 do CPC italiano, arts. 524 a 537 da LEC espanhola, arts. 704 e 866 do CPC português, §§ 708 e 709 do ZPO alemão

1. Aspectos gerais

O título judicial estabiliza-se de forma definitiva quando a respectiva decisão transita em julgado.

Assim, enquanto for possível a modificação do ato decisório em decorrência de recurso pendente de julgamento, desprovido de efeito suspensivo, é ele provisório, podendo, no entanto, ser objeto de cumprimento forçado. O *status* do título é que determina a natureza da execução, se *provisória* ou *definitiva*.

O atual CPC insiste na mesma imprecisão técnica contida no diploma processual revogado, uma vez que continua denominando o cumprimento de sentença de provisório, olvidando-se que a interinidade caracteriza o próprio título executivo, e não, a evidência, a forma pela qual a obrigação por ele reconhecida pode ser judicialmente exigida.

Não é por outra razão que a precipitação ou antecipação do cumprimento da eficácia de uma sentença que ainda não transitou em julgado vem informado pelas normas que disciplinam a execução definitiva, ressaltando-se a possibilidade de reforma do título executivo provisório.

Incidem, portanto, no chamado cumprimento provisório os mesmos preceitos aplicáveis ao cumprimento definitivo, segundo o regime especial estabelecido no art. 520, ora comentado, cuja observância, no que for compatível, estende-se ao cumprimento provisório de obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa (art. 520, § 5.º).

Não tendo vingado a substancial alteração pretendida pela comissão de juristas encarregada de elaborar o anteprojeto do novo CPC, no sentido de suprimir, como regra, o efeito suspensivo da apelação, que acabou remanescendo no art. 1.012, *caput*, do CPC, não há novidade de grande relevo no diploma em vigor, a respeito desse tema, sendo certo que se faz “possível cumprir provisoriamente decisões sujeitas a apelo desprovido de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1.º, cujo rol nada tem de substancialmente novo quando lido a partir do que é possível – e correto – extrair do art. 520 do CPC/1973 e do seu sistema processual civil), a recursos ordinários (art. 995, *caput*), a recursos especiais e extraordinários (art. 995, *caput*) e também será possível cumprir decisões interlocutórias sujeitas a agravo de instrumento (art. 995, *caput*)”.¹

É oportuno observar que, em todas estas hipóteses, somente se viabiliza o cumprimento provisório desde que não tenha sido atribuído efeito suspensivo *ope iudicis* ao respectivo recurso.

Seja como for, importante é ainda ter-se presente que, em capítulo próprio (arts. 520 a 522), a matéria mereceu especial atenção do legislador, recebendo tratamento bem mais aperfeiçoado em relação ao CPC revogado.

2. Responsabilidade objetiva do credor

O cumprimento provisório da sentença também se subordina à iniciativa exclusiva do exequente, que assume o risco pelos eventuais danos causados ao executado, caso seja provido o recurso interposto. A responsabilidade assumida pelo credor, nesta hipótese, descortina-se objetiva, bastando que a execução seja considerada indevida, diante da reforma da decisão impugnada, para que os possíveis prejuízos, a serem ressarcidos, sejam liquidados e exigidos nos próprios autos pelo executado.

Acerca desta questão, verifica-se que a 4.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.252.470-RS, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que: “(...) pendente recurso ‘ao qual não foi atribuído efeito suspensivo’ (art. 475-I, § 1.º, do CPC [1973]), a lide ainda é evitável e a ‘causalidade’ para instauração do procedimento provisório deve recair sobre o exequente (...)”.²

3. Variações possíveis durante o cumprimento provisório

Sendo provido o recurso interposto pelo executado, de sorte a reformar a sentença, quando já incoado o cumprimento provisório, cessam todos os efeitos que então se produziam, circunstância que, a teor do art. 520, II, implica a restituição ao *status quo ante*, como se não tivesse havido execução alguma.

É lógico que se a decisão for apenas parcialmente modificada, alterando-se, por exemplo, para um valor menor o *quantum* devido, o objeto do cumprimento provisório sofrerá redução, adequando-se ao diâmetro da obrigação imposta pelo “novo” título judicial (art. 520, III).

Dependendo do momento em que estiver a fase do procedimento *in executivis*, é possível que o devedor executado não tenha sofrido qualquer prejuízo, nada havendo a ser ressarcido pelo exequente apressado. Todavia, pode ter-se verificado inclusive a transferência de domínio, como expressamente autorizam o inc. IV e o § 4.º do art. 520. Neste caso, a despeito de não ser mais viável a restituição ao estado anterior, só restará ao executado ser reembolsado pelo dano experimentado. Até mesmo quando a alienação ocorrer entre as próprias partes, como, e. g., em caso de adjudicação do bem pelo credor, o negócio deve subsistir, restando ao executado voltar-se contra o exequente para buscar indenização pelo prejuízo que lhe foi causado.³

É importante deixar claro que, em todas as situações que tendem à satisfação coercitiva da obrigação reconhecida no título judicial exequendo, em caráter provisório, a lei impõe ao credor a prestação de caução idônea, a ser fixada pelo próprio juiz, no bojo do processo (art. 520, IV).

Diante desta significativa exigência legal, ficam, em princípio, vedados atos de expropriação de bens do patrimônio do devedor sem que se tome a cautela de, em momento precedente, haver garantia consistente para assegurar o eventual ressarcimento daqueles referidos prejuízos.

A oportunidade para o oferecimento da caução é a que antecede a determinação judicial de levantamento de quantia em dinheiro ou de alienação da propriedade ou, ainda, de outro direito real do domínio, visto que, apenas nesse momento, é que, efetivamente, passa a haver risco de o executado sofrer dano irreparável.

4. Incidência de multa e de honorários

Acolhendo tendência que prevalecia na doutrina, embora não secundada pelo Superior Tribunal de Justiça,⁴ o § 2.º do art. 520, dirimindo qualquer dúvida, dispõe que, no cumprimento provisório incidem a multa de 10% e os honorários advocatícios, também de 10%, sobre o valor da soma devida, desde que o executado, depois de devidamente intimado, deixe de pagar a dívida no prazo de 15 dias.

O executado, contudo, segundo o art. 520, § 3.º, tem a prerrogativa de depositar o valor exigido, dentro daquele lapso temporal, visando afastar a incidência da multa, mesmo que tenha interposto recurso contra o ato decisório que é objeto da execução. É o próprio texto legal que admite a compatibilidade de ambas as atitudes do devedor.

5. Admissibilidade de impugnação

Como o cumprimento provisório processa-se, no que for compatível, de acordo com o regime reservado ao cumprimento definitivo, o art. 520, § 1.º, assegura ao executado o direito de oferecer impugnação ao cumprimento provisório da sentença, nos limites das matérias arroladas no art. 525 do CPC.

Veja-se que o texto legal em apreço utiliza a expressão “se quiser”, omitindo-se quanto às possíveis consequências da ausência de impugnação. A esse respeito, Cassio Scarpinella Bueno,⁵ pioneiro em enfrentar as balizas do novo CPC, sugere que a interpretação mais coerente, em tal situação, é a que considera perdido o prazo para apresentar impugnação, não sendo passível de devolução ou reabertura por ocasião do trânsito em julgado da decisão executada. E isso, sobretudo porque “os atos executivos praticados nada têm de *provisórios*, já que eles são mera ‘antecipação’ da eficácia executiva da decisão que fundamenta a sua prática”, restando ao executado valer-se da regra do art. 525, § 11 (fato superveniente ou invalidade de atos executivos subsequentes) e, outrossim, do art. 528, quando descortinar-se a hipótese de cabimento de exceção de preexecutividade.

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042 (redação dada pela Lei 13.256/2016);

IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Correspondência: art. 475-O, § 2.º, I e II, do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 517 do NCPC francês, art. 528 da LEC espanhola, art. 704 do CPC português, § 708 do ZPO alemão

1. Aspectos gerais

Como acima visto, os atos executivos que importam levantamento de quantia, transferência da posse, alienação da propriedade, podendo ensejar grave prejuízo ao executado, caso consiga reverter a decisão exequenda, ainda provisória, subordinam-se à prestação de garantia suficiente e idônea, estipulada pelo juiz e prestada, nos próprios autos, pelo exequente (art. 520, IV, CPC).

Assinale-se que a exigência de caução, em tais hipóteses, não se sujeita ao crivo subjetivo do julgador, uma vez que é a própria lei que determina, com a devida prudência, a prestação de caução pelo credor. O juiz, contudo, detém certa margem de ação para arbitrar o montante adequado da garantia.

Seja como for, é sempre aconselhável, nesse particular, colher-se a manifestação dos litigantes, para que este “incidente” seja prontamente resolvido, sem obstar a marcha normal do cumprimento provisório.

2. Garantia de acesso à justiça e dispensa de caução

Todavia, algumas hipóteses demarcadas no dispositivo agora interpretado, justificadas por diferentes motivos, admitem a dispensa de caução. O legislador procura aqui prestigiar a garantia de acesso à justiça. Atualmente, há um consenso generalizado entre os processualistas no sentido de que o acesso aos tribunais não deve ser obstado em hipótese alguma, especialmente naquela de insuficiência econômica, devendo ser possibilitada, de modo equânime, a participação dos litigantes em situação de paridade.

A primeira das exceções previstas no novo CPC se caracteriza quando o crédito executado for de natureza alimentar, “independentemente de sua origem” (art. 521, I).

Assim, toda e qualquer espécie de crédito que tenha como escopo suprir necessidades básicas e vitais da parte carente, de cunho alimentar, está englobada no art. 521, I, do CPC. Além dos alimentos decorrentes das relações de parentesco e do dever de mútua assistência entre cônjuges e companheiros, o art. 100, § 1.º-A, acrescentado ao texto da Constituição Federal pela Emenda 30/2000, define os demais créditos de natureza alimentar, vale dizer, “aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado”.

Os honorários também são considerados verba de natureza alimentar, uma vez que constituem, na verdade, “salários” dos profissionais liberais, como advogados, médicos, dentistas, psicólogos, contadores, entre outros. É retribuição, pagamento feito aos profissionais liberais. O profissional liberal vive do que recebe a título de honorários.

Segundo decisão da 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.066.431-SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi: “(...) a Corte Superior já vinha entendendo que, em se tratando de execução de verba de natureza alimentar (pensão mensal), a prestação de caução é dispensada, ainda que se trate de execução provisória. Essa dispensa decorreria do caráter social do instituto, que tem por finalidade manter as condições mínimas necessárias à continuidade das atividades exercidas pelo exequente e família.”.⁶

Identificando-se com a circunstância análoga que se verifica na concessão da gratuidade de justiça (art. 98 CPC), a mesma lógica determina a dispensa de caução quando o credor afirmar que não dispõe de condições econômicas para prestar a garantia exigida no art. 520, IV, comprometendo inclusive o seu próprio sustento ou de sua família, ou, quando se tratar de pessoa jurídica, a higidez financeira da empresa (art. 521, II).

É importante aduzir que, em especial, diante destas duas situações, arroladas no art. 521, I e II, o parágrafo único desta regra legal, inspirado nos critérios hermenêuticos da razoabilidade e da proporcionalidade, reza que, a despeito das referidas exceções, a exigência de caução será mantida, quando, presumivelmente, da dispensa surgir considerável receio de dano de difícil ou incerta reparação.

Assim, mesmo que se trate de crédito alimentar ou afirmada a insuficiência de meios, caso o juiz constate a probabilidade real de reversão da decisão recorrida, e, portanto, grande risco de prejuízo ao devedor-executado – por paradoxal que possa parecer –, deve prevalecer a regra, isto é, não será dispensada a prestação de caução pelo exequente! Considerados todos estes aspectos, o juiz tem o dever de fundamentar, com argumentos consistentes, a decisão que mantiver a exigência da apontada garantia.

A terceira exceção ao art. 520, IV, enumerada no art. 521, III, determina a dispensa da caução quando pendente o recurso de agravo, nos termos do art. 1.042, interposto “contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (...)”.

Cumprir lembrar que, alterando a redação original do novo CPC, a Lei 13.256/2016 reintroduziu a sistemática de que o juízo prévio de admissibilidade dos referidos meios de impugnação é efetivado perante os tribunais de justiça estaduais e os tribunais regionais federais. Inadmitido o trânsito do recurso extraordinário ou do recurso especial na origem, cabe agravo, dirigido, respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando o processamento daqueles.

Como os recursos extraordinário e especial – e muito menos o agravo contra decisão denegatória – não são dotados de efeito suspensivo (art. 995), justifica-se plenamente a dispensa da caução, pelo exequente, para a prática dos já referidos atos executivos.

Ademais, discutível ou não o regime de precedentes instituído, em particular, pelos arts. 926 a 928 do CPC, bem se compreende sem qualquer esforço o motivo pelo qual a caução vem igualmente afastada na hipótese do inc. IV do art. 521, ou seja, quando o título judicial provisório tiver sido fundamentado em súmula, vinculante ou persuasiva, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em enunciado sumulado do Superior Tribunal de Justiça, ou, ainda, em acórdão proferido no julgamento de incidente de recursos repetitivos.

E isso certamente porque há aí significativa presunção de que, com muita probabilidade, o executado não terá chance expressiva de êxito no julgamento de eventual recurso interposto. Seria, na verdade, sacrificar o credor com exigência praticamente inócua porque prejuízo algum será experimentado pelo executado.

3. Inusitada dispensa de caução

O art. 356 do CPC prevê o julgamento antecipado parcial do mérito quando um dos pedidos deduzidos pelo autor ou parcela deles for incontroverso, na hipótese de ser desnecessária a

produção de outras provas, ou, também, quando o réu for considerado revel e não houver requerimento de prova (art. 355, I e II).

Sendo líquida a decisão, o interessado, desde logo, tem a faculdade de requerer o respectivo cumprimento do ato decisório, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC, independentemente da prestação de garantia idônea, ainda que a outra parte tenha interposto recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC).

Salta aos olhos o disparate: a apelação contra sentença que julga antecipadamente a integralidade do mérito deve ser recebida, em regra, no duplo efeito (art. 1.012); o agravo de instrumento não!

Tal disposição, ademais, é de todo criticável, porque, além de não fazer qualquer sentido dispensar à decisão condenatória advinda do julgamento antecipado parcial do mérito tratamento diferenciado da normativa geral do cumprimento provisório da sentença, é manifesta a sua antinomia com o regime previsto nos arts. 520, IV, e 521.

Os juízes certamente terão a tarefa de interpretar o enunciado do art. 356, § 2.º, *cum grano salis*, ou seja, com muita ponderação, sobretudo para evitar prejuízo ao executado, na hipótese de ser provido o recurso por ele interposto.

Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:

I – decisão exequenda;

II – certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III – procurações outorgadas pelas partes;

IV – decisão de habilitação, se for o caso;

V – facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

Correspondência: art. 475-O, § 3.º, do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 515 do NCPC francês, art. 527 da LEC espanhola

1. Início da fase de cumprimento provisório

O cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, sempre se inicia por atuação do exequente, mediante requerimento apresentado ao juízo competente, considerando, nesse particular, o preceito do art. 516 do CPC.

Embora mais aperfeiçoado, preservou o estatuto processual em vigor, sem qualquer alteração, o princípio dispositivo para a instauração da fase de cumprimento do título judicial, ainda que de forma provisória.

Não há na lei prazo pré-fixado para que o credor promova o cumprimento de sentença, tornando-se possível o respectivo pleito, por força do art. 1.012, § 2.º, “depois de publicada a sentença”, sendo prescindível aguardar-se a interposição do recurso cabível contra o ato decisório passível de exigibilidade provisória. E isso porque a eficácia da decisão sujeita a impugnação despida de efeito suspensivo se produz de imediato, após a regular publicação da sentença.

Não sendo interposto o recurso adequado, a execução, como é curial, transforma-se em

definitiva.

2. Peças que devem instruir a petição

Afinado com os novos rumos do processo eletrônico, o parágrafo único do art. 522 deixa claro que apenas na hipótese de cumprimento de sentença em processo físico é que o exequente terá de instruir o respectivo requerimento com cópia das peças discriminadas na referida regra legal, obrigatórias e facultativas, uma vez que serão formados autos em apartado, enquanto o processo segue a sua sorte perante o grau recursal.

O exequente deverá então providenciar o traslado de cópia: i) do provimento judicial exequendo (acórdão, sentença ou decisão interlocutória), que constitui o título provisório; ii) da certidão de interposição do recurso recebido apenas no efeito devolutivo, sendo suficiente cópias dos autos demonstrativas do preenchimento desse requisito; iii) das procurações outorgadas pelas partes e, se houver, dos substabelecimentos, para comprovar a representação processual dos litigantes; iv) da decisão de habilitação dos sucessores (art. 687 e ss), quando a parte originária tiver falecido; e, ainda, de exibição facultativa; v) de “outras peças processuais” reputadas “necessárias para demonstrar a existência do crédito”, como, por exemplo, “documentos relativos à quantificação do valor da obrigação, observando-se, inclusive, se for o caso, o disposto no art. 524; do endereço do executado; de cópias relativas a eventual transferência do crédito, até para fins de aferição da legitimidade nos moldes dos arts. 778 e 779, que não se esgotam em problemas de sucessão processual por morte de alguma das partes, ou de decisão proferida em sede de embargos de declaração que tenham alterado em alguma medida o título executivo”.⁷

3. Responsabilidade do advogado e traslado incompleto

Saliente-se que o advogado é, como sói acontecer, importante protagonista para a concretização desta providência de natureza formal, consistente na extração das indigitadas cópias dos autos, inclusive porque a autenticidade das mesmas poderá ser atestada pelo próprio causídico, sob a responsabilidade de seu grau.

Contudo, diferentemente do risco que existia em decorrência de qualquer descuido em situações análogas, agora, sob a égide do novel CPC, a ausência de traslado de qualquer uma das aludidas peças, para instruir o requerimento de cumprimento provisório da sentença, poderá ser suprida, com a posterior juntada do documento reputado necessário, no prazo a ser fixado pelo juiz.

E isso, porque a filosofia implantada pela nova codificação, revelada em inúmeros dispositivos (v., p. ex., art. 1.007, § 7.º), repudia a supervalorização da forma em detrimento do direito da parte e, ao mesmo tempo, prestigia a celeridade processual.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Cassio Scapinella Bueno, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.340.

2

V. u., *DJe* 20.11.2013.

3

4

V., v. g., Corte Especial, REsp 1.059.478-RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, m. v., *DJe* 11.04.2011: “No caso de execução provisória, a parte está usando o direito constitucional de recorrer. Então, como se punir a parte com uma multa, porque não está fazendo o pagamento em uma execução provisória, que deveria aguardar a decisão definitiva e não está sendo aguardada, porque está exatamente se utilizando do direito constitucional de apelar, de recorrer extraordinariamente e recorrer especialmente. Acho isso, com a máxima vênia, incompatível. Quer dizer, criamos um incidente a mais e punimos o cidadão que usa do direito constitucional de recorrer? Então, apenas fazendo esta complementação, respeitando o entendimento do eminente Min. Relator, que também foi sufragado pelo judicioso voto do Sr. Min. Felix Fischer, estou cada vez mais convencido de que não cabe a multa do art. 475-J [CPC/1973] na execução provisória..., pelo entendimento da Corte Especial, não é censurável a postura do vencido que, em sede de execução provisória, não paga o que ficou decidido em sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo, por isso este colendo Órgão máximo do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não incidência da multa do art. 475-J do CPC [1973]... ”.

5

Cassio Scapinella Bueno, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.343.

6

DJe 22.09.2011.

7

Cf. Cassio Scapinella Bueno, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.352.

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

CAPÍTULO III. DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

Capítulo III. Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1.º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do *caput*, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2.º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no *caput*, a multa e os honorários previstos no § 1.º incidirão sobre o restante.

§ 3.º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Correspondência: art. 475-J do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

Formado o título executivo judicial, de natureza condenatória, que reconheça, portanto, a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, sobrevindo o trânsito em julgado, propicia-se ao vencedor a possibilidade de exigir, de forma definitiva, o cumprimento forçado da prestação.

Não importa se o título se consubstancie em sentença propriamente dita ou decisão interlocutória que tenha julgado um dos pedidos ou apenas parte da pretensão deduzida pelo demandante; basta que o provimento judicial explicita a obrigação de pagar quantia certa, a qual também poderá ser fixada em prévia liquidação.

Exclui-se do procedimento sob análise o cumprimento de sentença que tenha por objeto débito alimentar e dívida contra a Fazenda Pública, e, ainda, obrigação de fazer ou de não fazer e de entrega de coisa, uma vez que regrado por normas procedimentais específicas, respectivamente, nos arts. 528 a 533, 534 e 535, 536 a 538 do CPC.

Como já asseverado no comentário ao art. 513, o cumprimento definitivo da sentença é deflagrado por iniciativa do credor, seguindo-se a intimação do executado, para pagamento do débito no prazo de 15 dias, “acrescido de custas, se houver”.¹

Observe-se, pois, que o montante constante da intimação não inclui o valor de multa e de honorários advocatícios, porque indevidos se o devedor adimplir a dívida no interregno daqueles 15 dias.

2. Previsão legal de intimação do devedor

Deduzido requerimento expresso para o cumprimento de sentença, o juiz determina a intimação do executado para quitar a obrigação. O ato de intimação deve seguir determinadas formalidades, a garantir que atinja o seu objetivo de modo tanto quanto possível seguro.

Considerando a situação específica de cada caso concreto, diferente será o modo de intimação do devedor.

A hipótese mais comum é a que o executado vem cientificado pela imprensa oficial, a teor do art. 513, § 2.º, I, na pessoa de seu advogado regularmente constituído nos autos, para que pague o débito no prazo de 15 dias.

Todavia, quando representado por defensor público² ou não tiver procurador constituído nos autos, o devedor será intimado por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2.º, II), cujo prazo terá início a partir da juntada deste aos autos.

Se, por outro lado, o executado foi citado por edital na fase de conhecimento e foi considerado revel, a sua intimação também será editalícia, na forma do art. 256 do CPC (art. 513, § 2.º, II e IV).

Ressalte-se, outrossim, que se a devedora for empresa pública ou privada, não estando representada por advogado constituído nos autos, a intimação lhe será feita por meio eletrônico, uma vez que, segundo o art. 246, § 1.º, encontra-se ela obrigada a manter cadastro “nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações”.

Constitui ônus das partes manter atualizado os seus endereços, físico e eletrônico, nos autos do processo (art. 274, parágrafo único, CPC).

E isso porque, a teor do art. 513, § 3.º, presume-se efetivado o ato de intimação, nas hipóteses do anterior § 2.º, II e III, ou seja, quando o devedor não estiver representado nos autos por advogado, mesmo que o seu atual endereço seja outro, não comunicado ao juízo em ocasião oportuna.

Esclareça-se, ainda, que se o credor requerer o cumprimento somente depois de um ano do trânsito em julgado da sentença, o § 4.º do art. 513 exige que a intimação seja efetivada na pessoa do devedor, mediante carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço declinado nos autos. O parágrafo único do art. 274 dispõe que, nessa hipótese, considera-se realizada a intimação, ainda que o executado tenha passado a residir em outro local, não informado no processo. Como o ato de intimação é considerado válido, os prazos fluirão a partir da juntada aos autos do aviso de entrega da correspondência, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, no antigo endereço.

3. Incidência de multa e de honorários advocatícios

Decorrido o prazo de 15 dias, computados a partir da intimação, sem que tenha havido adimplemento voluntário do débito, em consonância com o disposto no § 1.º do art. 523, passa a incidir a multa de 10% e verba honorária, também fixada em 10% sobre a quantia devida.

Ressalte-se, a propósito, que, nesse particular, o novo CPC acabou adotando o entendimento sufragado na Súmula 517/STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Tratando-se de litisconsortes passivos, o acréscimo da multa e dos honorários somente ocorrerá depois da intimação e do inadimplemento de todos os devedores no prazo individual de 15 dias.

É evidente que se o devedor quitar parte do débito, a multa e os honorários do patrono do exequente incidirão apenas sobre o *quantum* inadimplido (art. 523, § 2.º, CPC).

Parece-me que procede a exortação de Sérgio Shimura, no sentido de que o prazo de 15 dias fixado para que o executado cumpra a determinação legal “há de fluir de modo ininterrupto, e não apenas nos dias úteis”, porque não há aí atividade técnica ou postulatória, que exija a intervenção de advogado, ficando prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, “quando o décimo quinto

dia cair em dia em que não haja expediente forense”.³

4. Prosseguimento ope legis do procedimento

Pois bem, descumprida a determinação judicial e, assim, não efetuado o pagamento no prazo de 15 dias, mesmo sem requerimento do exequente, será determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação.

Observar-se-á em sequência os demais atos de expropriação, consoante o preceituado no art. 876 e seguintes do CPC.

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I – o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II – o índice de correção monetária adotado;

III – os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV – o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V – a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI – especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII – indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1.º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2.º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3.º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4.º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5.º Se os dados adicionais a que se refere o § 4.º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Correspondência: art. 475-B do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 716 e 724 do CPC português

1. Aspectos gerais

A experiência revela que uma das questões que mais atravancam o processo é o interminável desentendimento das partes, ao ensejo da fase satisfativa, acerca do *quantum debeatur*.

Desse modo, procurando ainda uma vez instituir estratégia que possibilite minimizar tal problema, o art. 524 do CPC individualiza determinados dados que constarão do requerimento de cumprimento de sentença.

Assim, o exequente deve apresentar, em tal oportunidade, o demonstrativo de seu crédito, declinando, em primeiro lugar, a qualificação das partes, com os seus respectivos CPF ou CNPJ, sendo ainda possível ao credor requerer ao juiz diligências necessárias para a obtenção destas informações, a teor do art. 319, §§ 1.º a 3.º.

A memória do crédito deve ainda conter, de forma clara e precisa, a discriminação de todas as rubricas que compõem a dívida: a soma do principal, eventual multa contratual, índice de correção monetária, juros incidentes, termos inicial e final, a periodicidade da capitalização dos juros, quando for o caso, e eventuais descontos.

Ademais, constitui ainda ônus do exequente, sendo possível, declinar no próprio requerimento de instauração do cumprimento de sentença, bens passíveis de penhora.

2. Assimetria entre o valor pretendido e o aparente montante da dívida

Mesmo cuidando de especificar todos estes itens no demonstrativo do cálculo, representativo da soma da obrigação exigida, com a experiência haurida no cotidiano do exercício da judicatura, o juiz, presumindo que há excesso de execução, poderá fixar um valor menor a servir de parâmetro para a efetivação da constrição sobre o patrimônio do devedor.

Esta a razão pela qual bem se justifica a regra equânime do § 1.º do art. 524: “Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada”.

Para que a questão da exatidão do *quantum debeatur* não fique no campo da mera aparência, o juiz, além dos subsídios ministrados pelos litigantes, poderá como é cediço buscar auxílio do contador do juízo, que disporá de, no máximo, 30 dias (ou de outro prazo determinado pelo juiz) para checar a planilha de cálculo exibida pelo exequente (art. 524, § 2.º).

3. Requisição de informações e princípio da cooperação

Saliente-se, outrossim, que a norma legal ora examinada revela a importância do princípio da cooperação, assentado no art. 6.º do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Inspirando-se na moderna doutrina que já adotara entre os princípios éticos que informam a ciência processual o denominado “dever de cooperação recíproca em prol da efetividade”, o novel diploma processual procura desarmar todos os participantes do processo, infundindo em cada qual um comportamento pautado pela boa-fé, para atingir-se uma profícua comunidade de trabalho.

Verifica-se, destarte, que o novo CPC ampliou o sentido do art. 339 do velho estatuto agora repetido no art. 378: “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. Afirma-se que, nesta hipótese, a lei prevê a *cooperação em sentido material*, uma vez que faz recair sobre as partes e terceiros o dever de prestarem a sua colaboração para a descoberta da verdade. A abrangência da regra em apreço, que dispõe sobre a boa-fé processual, engloba deveres anexos, que exigem respeito recíproco das partes, como o da proteção da confiança e o da proibição de *venire contra factum proprium*.

É de ter-se presente que, além de situações de natureza técnica, que impõem a cooperação, valores de deontologia forense, sobrelevados pelos operadores do direito – juízes, promotores e advogados –, também se inserem na esperada conduta participativa.

Pelo denominado *dever de esclarecimento*, cabe ao juiz determinar às partes que prestem esclarecimentos e informações quanto a alegações obscuras ou circunstâncias que demandem complementações.

Desse modo, na hipótese de haver dados importantes para a elaboração do demonstrativo da

dívida em poder de terceiros ou do próprio executado, poderão eles ser requisitados pelo juízo, sob pena de responder por crime de desobediência, tipificado no art. 330 do CP (art. 524, § 3.º, CPC).

Se, por outro lado, a complementação da memória de cálculo depender de informações adicionais em poder do executado, o juiz poderá, “*a requerimento do exequente*”, determinar a sua exibição no prazo de até 30 dias (art. 524, § 4.º).

Desatendida a ordem judicial, sem qualquer justificação aceitável, o demonstrativo apresentado pelo credor será reputado correto, mesmo que embasado apenas nos dados que estiverem ao seu alcance.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1.º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2.º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

§ 3.º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4.º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5.º Na hipótese do § 4.º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6.º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7.º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6.º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens

§ 8.º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9.º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1.º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12.º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12.º deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12.º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Correspondência: art. 475-L do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 615 e 617 do CPC italiano, art. 556 da LEC espanhola, art. 729 do CPC português, § 767 do ZPO alemão

1. Aspectos gerais

Se, de um lado, o credor, em busca da satisfação de seu direito pode requerer o cumprimento forçado do comando judicial, que o alça em privilegiada posição processual, não se pode esquecer que, de outro, devem ser preservadas, em prol do executado, as prerrogativas do devido processo legal, em toda sua dimensão, inclusive com a assecuração de um de seus corolários, qual seja a garantia de amplo acesso à justiça.

A despeito de objetivar a realização das aludidas operações práticas, a fase reservada ao cumprimento da sentença, no desenrolar de seus atos, não fica imune à dialética que marca, de forma indelével, a fase cognitiva.

Com efeito, embora não se possa dizer que haja cognição acerca de *meritum causae*, a preparação, no cumprimento, por meio de inúmeras providências instrumentais, do ato final de satisfação do exequente, caracteriza-se pela inafastável atuação do juiz e cooperação das partes. Exequente e executado, ao suscitarem incidentes, postularem, recorrerem, enfim, ao participarem de modo efetivo, no ambiente da fase de cumprimento de sentença, travam (ou, pelo menos, têm a possibilidade de travar) efetivo contraditório e, com isso, influem diretamente no desfecho do processo.

Todavia – talvez seja óbvio afirmar –, o contraditório não deve e nem pode, no âmbito da fase de cumprimento de sentença, ser articulado com a mesma conotação que o caracteriza na fase de conhecimento, uma vez que os fins de cada uma delas são consideravelmente diferentes.

Pois bem, regular e validamente intimado (ou citado, quando a citação for exigida), abre-se ao executado o prazo de 15 dias para adimplir a prestação perseguida (art. 523 CPC). Não atendendo ao comando judicial, o devedor terá de avaliar qual o instrumento processual mais compatível com a sua estratégia de defesa. Poderá, como já adiantado: a) opor, a qualquer momento, a

denominada exceção de preexecutividade, deduzindo questões de ordem pública, como ilegitimidade passiva, pagamento, etc.; b) alegar, por meio de petição avulsa, no prazo de 15 dias da ciência, fato superveniente ou invalidade de atos executivos subsequentes (art. 525, § 11); ou c) no prazo sucessivo de 15 dias, apresentar impugnação, podendo alegar as matérias arroladas no § 1.º do art. 525.

A técnica de defesa por meio de exceção de preexecutividade, reconhecida pelos tribunais, restringe o seu cabimento à arguição de questões que poderiam ser conhecidas *ex officio*, não exigindo dilação probatória para o seu julgamento.

Apesar da imprecisa redação do art. 518 do CPC, depois do momento destinado à apresentação da impugnação, o executado dispõe ainda da faculdade de arguir qualquer vício atinente ao procedimento de cumprimento da sentença e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, como, por exemplo, falta de intimação da penhora.

Ademais, a impugnação, a seu turno, constitui o instrumento típico de defesa, pelo qual o executado, nos mesmos autos e, portanto, em caráter incidental, deduz os seus argumentos de defesa, nos termos do apontado art. 525, § 1.º. Os fundamentos da reação do executado podem ser de duas ordens, quais sejam, objeções processuais e exceções substanciais (art. 525, § 1.º, VII).

Esmiuçando os elementos dogmáticos da atuação defensiva do executado, Araken de Assis destaca que, à semelhança dos embargos, a impugnação ao cumprimento de sentença consubstancia-se numa ação de oposição à execução, pela qual o devedor pleiteia uma tutela jurídica visando a corrigir os rumos da atividade executiva ou a extinguir a pretensão a executar.⁴

Na verdade, apesar da diferente nomenclatura, do ponto de vista substancial, a impugnação em tudo se identifica aos embargos à execução lastreada em título extrajudicial. A impugnação e os embargos constituem instrumentos formais análogos, ostentam a mesma natureza e desempenham idêntica função sistemática: “tanto os embargos quanto a impugnação têm a natureza de *processos incidentes, mas autônomos*, não meros incidentes executivos”.⁵

A impugnação deverá ser oferecida, no juízo em que tramita a execução ou naquele do foro da situação dos bens do executado (art. 516, parágrafo único), em petição escrita e autônoma, atendendo aos requisitos enumerados no art. 319.

Inicia-se o prazo de 15 dias para apresentação da impugnação no primeiro dia útil após o término do prazo de cumprimento voluntário (art. 523).

Consoante o disposto no art. 525, § 3.º, aplica-se o art. 229 do CPC à impugnação, e, assim, há de computar-se em dobro o prazo para o seu oferecimento, quando os litisconsortes executados tiverem outorgado mandato a advogados diferentes, integrantes de escritórios distintos.

2. Elenco da matéria deduzível na impugnação

Em certas situações, sobretudo naquelas que se afastam do procedimento comum, por imposição de determinadas peculiaridades decorrentes do direito material a ser tutelado, a própria legislação processual, reduzindo o horizonte de cognição, estabelece alguns cortes quanto à matéria que pode ser deduzida como defesa.

As demandas possessórias e os embargos de terceiro são exemplos típicos de ações cujo objeto se sujeita a limitação legal. A cognição sumária, que individualiza tais demandas, obsta a que o autor deduza causa de pedir fundada, respectivamente, em domínio e em fraude contra credores.

Esta técnica de sumarização também caracteriza a impugnação ao cumprimento da sentença. Por razões sabidas, a defesa passível de ser alegada contra a força inerente aos títulos executivos judiciais, construídos em ambiente de cognição exauriente, vem circunscrita, no art. 525, às seguintes matérias de natureza processual e substancial: i) falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ii) ilegitimidade de parte; iii) inexecutabilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; iv) penhora incorreta ou avaliação errônea; v) excesso de

execução ou cumulação indevida de execuções; vi) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e, ainda, de forma genérica, vii) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Nota-se, sem qualquer dificuldade, que não se cuidou de preservar uma ordem técnica para a arguição de tais matérias. Encontram-se entremeadas as defesas processuais e aquelas de natureza substancial, sem qualquer critério lógico. Vejamos como o executado pode organizar a sua impugnação.

2.1. Falta ou nulidade de citação

Como ato formal de comunicação ao réu do ajuizamento de ação judicial que lhe é promovida, a citação – a velha e sempre necessária *in ius vocatio* da Lei das XII tábuas – consubstancia-se num ato processual solene, revestido de formalidades próprias, qualquer que seja a modalidade legal empregada para a sua efetivação.

Os arts. 238 e seguintes do CPC estabelecem, de modo minucioso, as normas que regem o procedimento da citação, cuja higidez constitui pressuposto de validade do processo (art. 239). Ao dispor sobre a validade da citação, continua sendo adotada uma postura formalista, a fim de que sejam observadas as prescrições previstas em lei para validar o ato citatório, sob pena de nulidade (art. 280). Preteridas solenidades essenciais, a mácula nesse terreno é fulminante.

Tão grave é o vício de citação que os tribunais pátrios, ainda hoje, prestigiam memorável voto proferido há mais de 30 anos pelo Ministro Moreira Alves, em julgado do Supremo Tribunal Federal, sustentando como única hipótese de cabimento da *querela nullitatis insanabilis*, em nosso ordenamento jurídico, exatamente a de citação inexistente ou nula, cujo ajuizamento não se subordina a qualquer prazo.⁶

Esta orientação, inclusive com supedâneo naquele referido aresto, veio recentemente sufragada no julgamento Recurso Especial 1.358.931-PR, pela 2.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, com a seguinte ementa: “1. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes: REsp 1.449.208-RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.^a T., DJe 27.11.2014; AR 569-PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1.^a S., DJe 18.2.2011; REsp 1.015.133-MT, rel. Min. Eliana Calmon, rel. p/ acórdão Min. Castro Meira, 2.^a T., DJe 23.4.2010; HC 92.569, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.^a T., DJe 25.4.2008; RE 96.374, rel. Min. Moreira Alves, 2.^a T., DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de *querela nullitatis*, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência.”⁷

É reputado juridicamente inexistente o ato citatório quando lhe faltar requisito intrínseco, como, por exemplo, recair sobre pessoa diversa daquela que está sendo demandada, ou, ainda, quando a carta de citação tiver como destinatário pessoa certa, mas endereço equivocado. Considera-se, pois, despida de qualquer eficácia a citação na hipótese de ser dirigida contra réu já falecido. Nesse sentido, a 2.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 987.201-RJ, relatado pelo Ministro Humberto Martins, decidiu que: “A relação jurídica processual só se constitui e validamente se desenvolve com a citação. Por conseguinte, a pessoa indicada como ré somente será parte no processo depois de regularmente citada. Se o executado faleceu antes do despacho de citação, mesmo que venham a ser realizados os movimentos citatórios, nos termos do comando judicial, não há como se configurar perfeição do ato citatório na medida em que uma pessoa somente poderá ser citada se viva estiver. Trata-se de fato inadmissível juridicamente; portanto, a hipótese é de citação inexistente, pois nem sequer há falar em citação dos sucessores universais, uma vez que dessa hipótese o acórdão recorrido não trata.”⁸

Seja como for, ainda que o chamamento do réu esteja visceralmente contaminado, processo sempre existe. Não há de se confundir, assim, a inexistência (*rectius* : invalidade) da citação com a pendência do processo. É verdade que, reconhecida a falha de citação, todos os atos processuais praticados, a partir do momento em que o réu deveria intervir, deverão ser reputados ineficazes, inclusive a sentença de mérito transitada em julgado. Desse modo, a citação nula poderá ser arguida na fase de cumprimento de sentença, por meio de impugnação, como, aliás, preveem expressamente os arts. 525, § 1.º, I, e 535, I.

Com efeito, o primeiro fundamento que pode embasar a impugnação concerne à falta ou nulidade do ato citatório, de sorte a acarretar inarredável prejuízo ao executado. Assim, para ser reconhecida a ausência ou o defeito formal da citação, é imprescindível que esteja caracterizada a revelia do réu, com a falta de oferta de contestação.

Contudo, se, de alguma forma, a invalidade foi suprida já na fase preambular do processo, não há se falar em nulidade e, portanto, inconsistente se torna a referida arguição.

Partindo-se da premissa de que o rol das matérias passíveis de serem invocadas na impugnação admite certa extensão a hipóteses correlatas, tive de enfrentar recentemente questão relativa à falta de intimação do advogado de uma das partes para o julgamento da apelação. Na verdade, o equívoco se deu no cadastramento do recurso no tribunal, uma vez que apenas um dos litisconsortes passivos é que foi cadastrado. Neste caso, também se faz possível a arguição de nulidade do título, dada a inarredável ofensa às garantias da ampla defesa e do contraditório.

2.2. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução

Em sequência, *ex vi* do disposto no art. 525, VI, o executado pode arguir, na mesma peça da impugnação, a incompetência absoluta ou relativa do juízo em que se processa o cumprimento de sentença, sobretudo naquela hipótese, autorizada pelo parágrafo único do art. 516, em que o exequente elege *sponte propria* juízo diferente daquele perante o qual se formou o título judicial.

Segue-se, neste particular, o regime que se aplica à arguição de incompetência na esfera da fase de conhecimento.

Com efeito, alterando, em boa hora, o tradicional regime bifforme de arguição da incompetência, a nova codificação determina que tanto uma quanto outra, vale dizer, a incompetência absoluta ou a incompetência relativa pode ser arguida, por força do disposto no art. 64 do CPC, como “questão preliminar”, sem provocar, em qualquer uma das hipóteses, a suspensão do processo.

Reserva-se, contudo, à incompetência absoluta a prerrogativa de ser suscetível em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser conhecida de ofício pelo órgão jurisdicional (art. 64, § 1.º).

A incompetência relativa, pelo contrário, caso não arguida pelo requerido, é prorrogada (art. 65), ou seja, sedimenta-se o curso da execução perante o juízo eleito pelo exequente.

Ademais, de forma deslocada do contexto da defesa do executado, o § 2.º do art. 525 determina que a alegação de impedimento ou de suspeição, de conformidade com os arts. 146 e 148, atentando-se inclusive para o prazo de 15 dias, deve ser efetivada mediante petição específica, dirigida ao mesmo juiz do cumprimento de sentença.

2.3. Ilegitimidade de parte

Toda demanda deve guardar estrita simetria entre a causa de pedir e os sujeitos da relação de direito material. Caso contrário, haverá manifesta impertinência subjetiva ativa e/ou passiva, impedindo que o processo prossiga rumo ao julgamento do mérito. Desponta, nesta situação, inarredável carência da ação proposta.

O mesmo requisito, como é curial, é exigido nos domínios da fase de cumprimento da sentença. A iniciativa desta deve ser provocada exclusivamente pelo credor assim reconhecido no título

executivo judicial, em face do devedor vencido. Ressalve-se ser possível, em caráter excepcional, a alteração subjetiva da obrigação pelos sucessores legais dos referidos protagonistas. Desse modo, se houver, por exemplo, cessão do crédito (art. 296 CC), reconhecido em sentença judicial, o novo titular – o cessionário – é legitimado a requerer o cumprimento forçado em face do devedor.

Caso contrário, quando não houver identidade entre o título executivo e pelo menos um dos participantes do contraditório da fase de conhecimento, o executado poderá arguir, em sede de impugnação, a ilegitimidade de parte.

2.4. Penhora incorreta ou avaliação errônea

Embora a oferta de impugnação não seja condicionada à efetivação da penhora (art. 525, *caput*), caso tenha sido realizada, qualquer vício relativo à constrição ou à respectiva avaliação do bem ou bens penhorados pode ser suscitado na impugnação.

Assim, por exemplo, se porventura a penhora recair sobre bem gravado com usufruto, o devedor usufrutuário pode perfeitamente arguir a incorreção da constrição. A 2.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental do Agravo em Recurso Especial 611.843-RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sobre esta questão, decidiu que: “O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, que é no sentido de que o usufruto não é penhorável, mas apenas o seu exercício, circunstância que possibilita a penhora sobre os frutos advindos desse exercício, desde que tenham expressão econômica imediata.”⁹

Aduza-se, por outro lado, que se o ato de constrição for efetivado em momento posterior àquele destinado à apresentação da impugnação, o executado ainda pode arguir o vício por meio de simples petição, nos termos do já mencionado art. 525, § 11, do CPC. A esse respeito, já teve oportunidade de pronunciar-se a 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido no Recurso Especial 555.968-PR, cujo voto condutor é da lavra do Ministro Menezes Direito, assentando que: “As questões relativas à nulidade da penhora podem ser apresentadas por simples petição.”¹⁰

2.5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções

Já no que concerne ao mérito da pretensão executiva, o executado pode suscitar o excesso de execução ou a cumulação indevida de execuções. Tratando-se do primeiro fundamento, isto é, de cobrança de valor exagerado, preceitua o § 4.^o do art. 525, que cabe ao devedor afirmar – e certamente comprovar por meio de demonstrativo atualizado da dívida – a soma que entende correta, sob pena de desconsideração da impugnação, que será “liminarmente rejeitada”, quando aquele for o único argumento deduzido. Na hipótese de haver outro, ou outros, fundamentos de defesa, o juiz desprezará a arguição de excesso de execução (art. 525, § 5.^o).

Se, por outro lado, a executada alegar o descabimento da cumulação, deve deixar evidente que o cúmulo objetivo de execuções delinea-se inapropriado porque, por exemplo, os respectivos títulos contêm obrigações de diferente natureza ou, ainda – possivelmente por força desta mesma alegação –, porque há incompatibilidade procedimental entre as respectivas formas de cumprimento das decisões judiciais exequendas.

Pela sua inequívoca didática, vale, a propósito, transcrever trecho de paradigmático julgado da 1.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 871.617-SP, relatado pelo Ministro Luiz Fux, ao patentear, à unanimidade de votos, que: “A cumulação de execuções é possível desde que respeitados os requisitos previstos no art. 573 do CPC [1973 – atual art. 780]. Verifica-se, pela leitura do artigo de lei acima transcrito, que a cumulação de demandas executivas é possível quando são as mesmas as partes em todas as demandas. Não deve o intérprete, porém, se impressionar com o fato de a lei fazer referência a que seja o ‘mesmo o devedor’. Não significa isto dizer que fica proibida a cumulação nos processos em que haja litisconsórcio. Basta pensar, por exemplo, num caso em que alguém seja credor de dois títulos executivos, em que figuram como devedoras (ou como responsáveis) as mesmas pessoas (Estado e Município, por exemplo). O

segundo requisito da cumulação de demandas executivas é a competência do juízo. Isto porque, obviamente, só se pode admitir a cumulação quando o mesmo juízo é competente para todas as execuções... Além disso, é perfeitamente possível a cumulação de demandas executivas fundadas em títulos extrajudiciais, ou ainda a cumulação de uma demanda fundada em título judicial com outra que tenha por base título extrajudicial (e, também aqui, será competente o juízo onde se formou o título executivo judicial). O terceiro requisito de admissibilidade da cumulação de demandas executivas é, nos expressos termos do art. 573 do CPC [1973], que seja ‘idêntica a forma do processo’. Significa isto dizer que ‘só darão origem a uma mesma espécie de execução’ (Alexandre Freitas Câmara, in *Lições de direito processual civil*, vol. I-2, Ed. Lumen Juris, p. 433-434). Destarte, verifica-se que, *in casu*, todos os requisitos legais foram devidamente observados...”.¹¹

2.6. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação

Mais aperfeiçoada do que a regra contida na legislação revogada (art. 475-L), a hipótese desenhada nos §§ 12 a 15 do art. 525 merece especial atenção. O executado pode também arguir como matéria de defesa de mérito a “inexequibilidade do título” ou a “inexigibilidade da obrigação”, em particular, quando esta estiver reconhecida em título executivo lastreado “em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”, ou, ainda, “em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” (art. 525, § 12).

Para que o executado possa suscitar esta exceção, no bojo da impugnação, é necessário que, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, a inconstitucionalidade já tenha sido pronunciada em controle concentrado ou difuso pela Suprema Corte (§ 14). É fundamental, nesta situação, que a lei ou o ato normativo já declarado inconstitucional tenha sido essencial para determinar a procedência do pedido. Assim, ainda que abstraído o texto legal inconstitucional, persistir a conclusão a que chegara o órgão julgador, não deve ser acolhida a impugnação.¹²

Ressalva o § 15 do mesmo art. 525 que, se o aludido pronunciamento do Supremo sobrevier ao trânsito em julgado da sentença exequenda, configura-se hipótese de cabimento da ação rescisória, “cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.

Desse modo, apresentando-se como exceção à regra do art. 975 do CPC, o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória não se conta do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas, sim, da que reconhecer a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo no qual aquela se estribou. É claro que, como bem flagrou prestigiosa doutrina, que, nesta situação, coloca-se em xeque a segurança jurídica, uma vez que o pronunciamento da excelsa Corte pode sobrevir depois de muitos anos do trânsito em julgado, de modo que “toda coisa julgada seria intrinsecamente *instável*”, já que há sempre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal vir a reconhecer a inconstitucionalidade do ato normativo em que se funda a decisão que transitou em julgado”.¹³

Já sob outro enfoque, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal acarretar potencial prejuízo a terceiros, violando o princípio da confiança e, conseqüentemente, conspirar contra a segurança jurídica, poderá haver modulação dos efeitos pretéritos da declaração de inconstitucionalidade (art. 525, § 13).

Nesse sentido, o mecanismo hermenêutico da modulação dos efeitos constitui importantíssimo instrumento técnico, a ser prestigiado pelo legislador e pelos tribunais.

2.7. Causa superveniente modificativa ou extintiva da obrigação

Como derradeiro argumento passível de ser arguido na impugnação, o inc. VII do art. 525 admite a alegação de “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

Torna-se, pois, possível ao executado deduzir os efeitos modificativos ou extintivos produzidos por uma norma jurídica superveniente, seja de direito material, seja de direito processual, que tenha incidência sobre a eficácia do título judicial, objeto do cumprimento de sentença.

Assim, quando sobrevier direito atribuindo ao crédito executado efeito modificativo ou extintivo, ou ocorrer um fato, também posterior à prolação da sentença, que tenha o condão de modificar ou extinguir a prestação exigida – pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição (enfim, que coloque em crise a eficácia do título) –, poderá ser invocado na impugnação.

3. Impugnação e prosseguimento da execução

A despeito da oferta de impugnação, não haverá sobrestamento do procedimento de cumprimento da sentença, provisório ou definitivo. É o que preceitua o § 6.º do art. 525: “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação”.

A regra, portanto, é a de que a impugnação não determina a suspensão da atividade satisfativa.

4. Atribuição de efeito suspensivo

O juiz, não obstante, tem o poder de atribuir efeito suspensivo à impugnação, mediante requerimento do executado e desde que o juízo esteja suficientemente garantido com penhora, caução ou depósito.

Mas isso não basta. O § 6.º do art. 525 ainda condiciona o deferimento da suspensão dos atos executivos à relevância dos fundamentos revelados pelo devedor (*fumus boni iuris*) e à possibilidade da produção de dano de difícil ou incerta reparação decorrente do prosseguimento da execução (*periculum in mora*).

Inovando em relação ao regime anterior, o § 7.º do mesmo art. 525 determina que, a despeito da concessão de efeito suspensivo, podem ser praticados atos de “substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação de bens”. Tais providências, que se restringem a aperfeiçoar ou adequar a garantia do juízo e a avaliação do bem ou bens constrictos, por si só, não acarretam quaisquer prejuízos irreparáveis ao executado.

É evidente que se o efeito suspensivo se estender a apenas a parte do objeto do cumprimento de sentença, na hipótese, por exemplo, de cumulação objetiva de execuções, os atos expropriatórios prosseguirão em relação à outra parte (art. 525, § 8.º).

Havendo litisconsortes passivos, a teor do § 9.º do art. 525, a atribuição *ope iudicis* de efeito suspensivo, em atendimento a requerimento formulado por um dos executados, não suspende a execução contra aqueles que não ofereceram impugnação, a menos que o fundamento deduzido pelo litisconsorte que pleiteou a suspensão seja comum aos demais.

5. Ausência da impugnação

O não oferecimento de impugnação produzirá preclusão para posterior questionamento, em sede de cumprimento de sentença, das matérias arroladas no art. 525, ressalvadas as questões de ordem pública e aquelas supervenientes que possam influir na higidez do título judicial que é objeto da execução.

Escapa, pois, da eficácia preclusiva decorrente do transcurso *in albis* do prazo para a oposição de impugnação a matéria relativa aos pressupostos processuais e às condições de admissibilidade do cumprimento de sentença por extravasarem do poder de disposição das partes, podendo ser conhecidas *ex officio* em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3.º, CPC).

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1.º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2.º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

§ 3.º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

Transitado em julgado o título executivo judicial, como se infere do art. 523 do CPC, cabe ao vencedor pleitear, em caráter definitivo, o cumprimento coativo da obrigação de pagar quantia certa.

Regularmente intimado, o executado, como já visto, terá o prazo de 15 dias para pagar a dívida.

Todavia, antes que se efetive a sua intimação e até mesmo antes que o credor formule o pedido de cumprimento da sentença, é permitido ao devedor depositar em juízo o valor da prestação considerada devida, de conformidade com planilha de cálculo discriminado do *quantum debeatur*, por ele apresentada.

Não é preciso enfatizar que este, sem dúvida, é o melhor cenário que se descortina no terreno da atividade satisfativa, uma vez que, com a resignação do devedor, a obrigação é adimplida e, conseqüentemente, o processo é extinto nos termos do art. 924, II, do CPC (art. 526, § 3.º, CPC).

2. Exigência do devido contraditório

Efetuada o depósito judicial, abre-se vista ao credor para que se manifeste no prazo de cinco dias. Duas opções se lhe oferecem: a) deixa de se manifestar ou concorda expressamente com a soma depositada, ensejando a declaração judicial de que se encontra satisfeita a obrigação e a imediata extinção do processo; ou b) impugna o valor do depósito, sem prejuízo da possibilidade de requerer o levantamento da quantia exibida, porque incontroversa (art. 526, § 1.º).

Determinada a conclusão dos autos, se o juiz entender que o montante depositado desponta suficiente, uma vez que corresponde, com exatidão, ao valor devido, proferirá decisão de extinção do processo, determinando o levantamento daquele pelo credor.

3. Prosseguimento do cumprimento de sentença

Contudo, reputado insuficiente o depósito efetuado pelo devedor, o cumprimento de sentença prossegue, com a expedição do mandado de penhora e avaliação, sendo certo que sobre a diferença entre o valor depositado e aquele devido incidirão multa de 10% e honorários advocatícios fixados também em 10% (art. 526, § 2.º).

Sérgio Shimura escreve que, na hipótese em tela, “se o devedor tomar a iniciativa do pagamento e ficar apurado que ainda existe diferença a ser paga, fica afastada a possibilidade de o executado ofertar impugnação ao cumprimento de sentença”.¹⁴

Tenho para mim que tal posição não se sustenta, uma vez que o pagamento a menor, pelo executado, deve ser justificado exatamente na impugnação, instrumento pelo qual, à luz do disposto no art. 525, V, cumpre ao devedor impugnante arguir o excesso de execução.

O prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação, nesse caso, inicia-se da intimação da decisão que declarar insuficiente a quantia oferecida pelo executado.

Note-se que o excesso de execução, na situação identificada no art. 526, decorre da rejeição manifestada pelo credor quanto ao valor depositado.

Art. 527. Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Correspondência: art. 475-O do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

Como já ressaltado, ao ensejo dos comentários ao anterior art. 520, em consonância com o disposto no *caput* do art. 995, a interposição de recurso não obsta, em regra, a imediata produção de efeitos do ato decisório impugnado, ressalvando-se “disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.

Faltou coragem ao legislador para dotar a apelação apenas de efeito devolutivo, uma vez que manteve, no art. 1.012, como indesejada exceção, a tradicional orientação secundada pelo art. 520, *caput*, do velho diploma, qual seja, a de que o recurso de apelação deve também ser recebido no efeito suspensivo, salvo as exceções constantes do respectivo § 1.º do art. 1.012.

Seja como for, nas hipóteses nas quais a decisão, embora tenha eficácia imediata, ainda não transitou em julgado, porque pendente recurso revestido apenas de efeito meramente devolutivo, faculta-se, em princípio, ao vencedor requerer o “cumprimento provisório” do título judicial, perante o juízo de origem.

Após o trânsito em julgado, verifica-se, como é curial, o “cumprimento definitivo” da sentença.

O título II do livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença) do novo CPC contém exatamente as normas de regência do *cumprimento da sentença*.

2. Disciplina procedimental do cumprimento de sentença

Em primeiro lugar, deve ser observado que o art. 513 prevê a aplicação subsidiária ao procedimento de cumprimento da sentença (provisório e definitivo) das regras do processo de execução, como, por exemplo, as que concernem à penhora, avaliação, suspensão e extinção do processo.

Os arts. 520 a 522 traçam o procedimento do cumprimento provisório da sentença. O art. 520 preceitua que o cumprimento provisório será realizado de forma análoga ao cumprimento definitivo.

O presente capítulo tem como rubrica Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, cujos atos procedimentais são disciplinados pelos arts. 523 a 526.

O art. 527 estabelece, de forma até repetitiva, que estas incidem subsidiariamente no cumprimento provisório da sentença.

3. Diferenças entre o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo

A rigor, os procedimentos do cumprimento provisório e do cumprimento definitivo não possuem discrepâncias muito acentuadas.

Heitor Sica, em abordagem específica sobre esse ponto, enumera as diferenças mais significativas entre os dois procedimentos, salientando que o cumprimento provisório difere do definitivo nos seguintes aspectos: “a) corre por conta e risco do exequente e, em caso de reforma ou anulação da decisão provisoriamente executada, os atos executivos ficam sem efeito (salvo os

que importam transferência de propriedade e domínio), implicando responsabilidade objetiva do exequente na indenização de todos os prejuízos causados ao executado (art. 520, I, II e § 4.º); b) o levantamento de dinheiro ou a prática de atos que implicam alteração dominial ou de outros direitos reais depende da prestação prévia de caução suficiente e idônea, salvo em casos excepcionais (art. 521); c) não é cabível tratando-se de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira e decisão interlocutória estrangeira (salvo na hipótese de execução de sentença penal condenatória na pendência de recurso sem efeito suspensivo interposto contra a decisão que julgar sua liquidação); d) faz-se por petição que deve ser instruída com as cópias listadas no art. 522, salvo no caso de serem eletrônicos os autos em que proferida a decisão a ser provisoriamente executada; e) para afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, basta que o executado deposite o valor objeto da execução por quantia certa, mesmo que seja para ofertar impugnação nos termos do art. 520, § 1.º, c.c. o art. 525.”¹⁵

NOTAS DE RODAPÉ

1

Os enunciados dos arts. 513 e 523 do CPC eliminaram de uma vez por todas qualquer dúvida quanto à iniciativa do exequente para o cumprimento de sentença, seguindo, aliás, a orientação que vingara sob a vigência do CPC revogado, assentada pela Corte Especial, no julgamento do REsp 940.274-MS, sob a relatoria do Min. João Otávio de Noronha, m. v., *DJe* 31.05.2010: “O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art. 475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do CPC [1973], cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada”.

2

“Locação de imóveis – Ação de despejo c.c. cobrança de aluguéis – Intimação pessoal da Defensoria Pública inobservada - Decreto de nulidade da certidão de trânsito em julgado” (TJSP – 26ª CDPrivado - Apelação n. 0138014-72.2011.8.26.0100 – rel. Des. Alfredo Attié – julg. 25.05.2018).

3

Sérgio Seiji Shimura, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.356.

4

Araken de Assis, *Manual da execução*, p. 1.644.

5

Cf. Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, 4, p. 742.

6

STF, pleno, RE 97.589-SC, v. u., *DJ* 03.06.1983. V., a respeito, Eduardo Arruda Alvim, *Direito processual civil*,

p. 280.

7

M. v., *DJe* 01.07.2015.

8

V. u., *DJe* 17.04.2008.

9

V. u., *DJe* 12.02.2015.

10

V. u., *DJ* 23.08.2004, in Theotonio Negrão *et alii*, *Código de Processo Civil e legislação processual em vigor*, p. 565.

11

DJe 14.04.2008.

12

Cf., nesse sentido, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, *Curso de direito processual civil*, 3, p. 466.

13

Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, *Curso de direito processual civil*, 3, p. 467.

14

Sérgio Seiji Shimura, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.368.

15

Heitor Vitor Mendonça Sica, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, p. 837.

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

CAPÍTULO IV. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS

Capítulo IV. Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Prestar Alimentos

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo.

§ 1.º Caso o executado, no prazo referido no *caput*, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuar-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2.º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3.º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1.º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4.º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5.º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§ 6.º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§ 7.º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8.º O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaiando a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

§ 9.º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.

Correspondência: arts. 732 e 733 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 933 do CPC português

1. Aspectos gerais

A execução de alimentos era disciplinada pelos arts. 732 a 735 do CPC/1973 e pelos arts. 16 a 19 da Lei 5.478/1968. Desde as reformas processuais introduzidas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, a denominada execução de alimentos sofreu inúmeras alterações, deslocando-se de um plano preponderantemente dogmático, para uma vertente mais funcional e efetiva do processo, com a flexibilização de algumas regras clássicas da ciência processual.

Logo após as aludidas reformas, muito se discutiu acerca da aplicação do mecanismo técnico do cumprimento de sentença às execuções de alimentos, tendo em vista o fato de que não fora revogado, naquela ocasião, o art. 732 do velho CPC, cuja redação determinava a instauração de processo de execução forçada em busca da satisfação do crédito de alimentos definitivos ou provisórios.

Diversificadas posições surgiram na doutrina a respeito da incidência do art. 475-J do diploma processual anterior, ao cumprimento de sentença cujo objeto fossem dívidas de alimentos, especialmente nas hipóteses em que a execução se instaurava *ex intervallo*, vale dizer, sempre que o inadimplemento ocorresse após o decurso de algum tempo a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, fazendo presumir que a mera intimação do advogado, constituído nos autos do processo de conhecimento, não seria suficiente para atender às regras do devido processo legal.

A celeuma fica definitivamente superada pela nova regulamentação da matéria no CPC, que incluiu expressamente o Capítulo IV, do Título II, do Livro II, sob a rubrica *Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos*, disciplinando toda a matéria, nos arts. 528 a 533, com revogação expressa dos arts. 16 a 18 da supra referida Lei de Alimentos (art. 1.072, V, CPC).

Ademais, sobre outra importante questão andou bem o novel legislador. O art. 531 estatui que não existe qualquer diferença procedimental para a exigibilidade de alimentos provisórios ou definitivos.¹ Desse modo, o cumprimento de sentença a que se refere o art. 528 aplica-se indistintamente a alimentos definitivos, fixados em sentença, ou a alimentos provisórios, estabelecidos no âmbito da tutela de urgência. Preveniu-se, assim, enorme discussão que surgiu após a promulgação do CPC revogado, acerca da interpretação do então vigente art. 733.

A obrigação alimentar do direito de família, dada a sua inegável importância, exige regras tendentes a preservar o seu cumprimento, o que se evidencia claramente nas técnicas processuais executórias colocadas à disposição da sua efetividade, inclusive a prisão civil, autorizada pelo art. 5.º, LXVII, da Constituição Federal, de inegável caráter excepcional. A regra geral é a da impossibilidade de prisão decorrente de dívida de cunho civil. Tal exceção deve ser, portanto, interpretada restritivamente, abrangendo apenas os alimentos inseridos no direito de família, excluídos os de índole indenizatória, cuja exigibilidade é regulada pelo art. 533.

2. Competência

A execução de alimentos provisórios e a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado serão processadas em autos apartados e a execução de alimentos definitivos nos mesmos autos no qual proferida a sentença (art. 531, §§ 1.º e 2.º), estabelecida a competência funcional do prolator da decisão exequenda, a teor do já examinado art. 516.

Como antes frisado, a despeito da inderrogabilidade dessa competência funcional, para garantir maior efetividade ao cumprimento de sentença, favorecendo-se a posição do exequente, a introdução, em 2005, no velho CPC, do art. 475-P, ensejara o que Cândido Rangel Dinamarco antevia como um alargamento das regras sobre a competência para as execuções por título judicial.²

Desse modo, e nos termos do § 9.º do art. 528, vem ratificada a possibilidade, já examinada, da denominada “execução itinerante”, de modo que o credor poderá escolher entre o foro do domicílio do executado, ou o foro do local dos bens do devedor, ou, ainda, o juízo no qual deva ser cumprida a obrigação (art. 516, parágrafo único), podendo requerer ao juízo de origem a remessa àquele dos autos do processo. Especialmente em matéria de cumprimento de sentença de

alimentos, além destas opções, o exequente poderá ainda eleger o foro do seu domicílio, cabendo-lhe, igualmente, a faculdade de pleitear ao juízo perante o qual tramitou a ação de alimentos, se for o caso, o envio dos autos ao referido juízo.

Essa prerrogativa se refere apenas ao cumprimento de sentença³. O cumprimento da decisão de antecipação de tutela há de ser promovido em autos apartados, mas se processa perante o mesmo foro em que ainda tramita o processo. Nessa hipótese, nem poderia ser requisitada a remessa dos autos ao juízo de origem, prevista pelo parágrafo único do art. 516, uma vez que a fase de conhecimento, a rigor, ainda não se encontra ultimada, devendo o processo continuar tramitando no juízo originário.

3. Adequação da prisão civil

A primeira questão polêmica que veio a ser resolvida pelo novo Código diz respeito justamente à execução de prestações alimentares lastreadas em títulos executivos extrajudiciais.

Com base no art. 784, extrai-se a possibilidade da celebração de inúmeros instrumentos particulares de transação contendo cláusulas que estabeleçam obrigação alimentar, desde que referendados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador devidamente credenciado pelo tribunal. Ainda, o art. 733 do novo estatuto processual, repetindo a norma do art. 1.124-A do CPC/1973 (introduzida pela Lei 11.441/2007), possibilita a formalização extrajudicial da separação e do divórcio consensuais, e agora também a instrumentalização da dissolução consensual de união estável, de casais sem filhos incapazes e não havendo nascituros, o que pode ensejar, como é curial, a inclusão, no ato notarial, de disposições relativas à pensão alimentícia devida em favor de um dos cônjuges ou companheiros.

Em todas estas hipóteses, caso haja inadimplência da obrigação alimentar, o título executivo se consubstancia na própria escritura pública de transação, separação, divórcio ou dissolução de união estável.

Diante dessa evidência, o legislador de 2015 cuidou separadamente do cumprimento de sentenças que reconheçam a obrigação de prestar alimentos nos arts. 528 e seguintes e reservou a disciplina da execução de alimentos, fundada em título extrajudicial, nos arts. 911 e seguintes.

Vale destacar, todavia, que a discrepância de tratamento entre o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial revela-se apenas aparente. Apesar de a regulamentação de ambos encontrar-se em capítulos diferentes do novo diploma, receberam basicamente o mesmo regramento, tanto o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos, quanto a execução do título extrajudicial que prevê prestação alimentar. E isso porque o parágrafo único do art. 911 remete expressamente aos §§ 2.º a 7.º do art. 528, ora comentado, tornando inequívoco o entendimento de que nas duas diversificadas situações é cabível a aplicação do meio coercitivo da prisão civil.

Não havia motivo para entendimento em sentido contrário. Mesmo sob a regência do CPC/1973, doutrina e jurisprudência já haviam se posicionado⁴ prevalentemente, no sentido de permitir a execução de alimentos sob pena de prisão, mesmo quando fundada em título executivo extrajudicial. Segundo aduz Fredie Didier,⁵, “a possibilidade de prisão ou adoção do rito próprio do art. 733 do CPC [1973] não decorre da espécie de título executivo (se judicial ou extrajudicial), mas resulta da natureza da obrigação a ser cumprida pelo devedor. Estando o devedor obrigado a pagar alimentos legítimos, revela-se adequado adotar o rito próprio da execução de alimentos, com todas as medidas executivas que lhe são inerentes, independente de a obrigação estar prevista em título judicial ou extrajudicial”.

Se não fosse admitido o cumprimento do acordo que versa sobre alimentos, pelo procedimento contemplado nos §§ 2.º a 7.º do art. 528 do CPC, estaria inteiramente desprestigiada a extinção extrajudicial dos casamentos e uniões estáveis, uma vez que a dissolução perante o Poder Judiciário produziria um instrumento muito mais eficaz do que o ato notarial equivalente. A

distorção seria enorme e sem fundamento.

Assim, e por força da remissão expressa do art. 911 do CPC aos §§ 2.º a 7.º do art. 528, é inarredável a conclusão de que todos os meios executivos preordenados para o cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de natureza alimentar são aplicáveis às obrigações decorrentes de títulos executivos extrajudiciais que imponham obrigação de pagar alimentos do direito de família.

4. Cumprimento de sentença sob pena de prisão e outras medidas coercitivas

No cumprimento de sentença ou decisão antecipatória, que tenha por objeto obrigação alimentar, sempre a requerimento do exequente, o juiz determinará a intimação pessoal do executado para, em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Para a execução de prestações alimentares, prevista no art. 528, com a possibilidade do decreto de prisão, exige-se a intimação pessoal do devedor, não bastando a mera intimação na pessoa de seu advogado. A observância desta determinação é inafastável sempre que a execução de alimentos definitivos se der *ex intervallo*, com a prévia extinção do processo de conhecimento, ainda que não tenha transcorrido o prazo de um ano a contar do trânsito em julgado, de acordo com a previsão do art. 513, § 4.º. Fica, pois, excluída a aplicação da regra geral do art. 513, § 2.º, I, que contempla a intimação pela imprensa oficial, na pessoa do advogado, para as execuções de alimentos definitivos, sob pena de prisão. A necessidade da intimação pessoal na situação em apreço, como é evidente, decorre da gravidade da imposição da pena de prisão, que não pode surpreender o devedor em circunstância alguma. A intimação do devedor será feita por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço constante dos autos, sendo ônus das partes mantê-lo atualizado.⁶

Todavia, se o cumprimento não for de sentença, mas de decisão antecipatória de tutela, instaurado em autos suplementares, forçosamente perante o mesmo juízo no qual ainda tramita o processo, entendo que é dispensável a intimação pessoal do devedor que tem procurador constituído nos autos. É suficiente que a intimação se aperfeiçoe na pessoa do advogado que representa o executado, o que propicia enorme economia de esforços e garante maior efetividade ao processo, dispensando atos e termos desnecessários.

Caso o executado não cumpra o comando judicial, o respectivo ato decisório poderá ser levado a protesto, incumbindo ao exequente apresentar certidão de inteiro teor do provimento condenatório ao cartório de protesto (art. 517). A previsão de protesto do pronunciamento judicial confere maior efetividade à execução de alimentos, sendo ainda possível, como já afirmado no comentário ao precedente art. 517, a inscrição do nome de devedor de alimentos no cadastro de proteção ao crédito, segundo preceituam os §§ 3.º e 5.º do art. 782.⁷

Consoante o disposto no art. 517, §§ 1.º e 2.º, expressamente referido pelo § 1.º do art. 528, como já antes frisado, caberá ao exequente apresentar ao tabelionato de protesto a certidão que indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.

Independentemente do protesto, no cumprimento que se processa sob pena de prisão, a execução de alimentos não comporta o acréscimo da multa prevista no art. 523.

Acerca da incidência da multa em débito alimentar executado por meio do procedimento previsto no revogado art. 733, pontuava Maria Berenice Dias que: “Sobre o valor do débito não se incorpora a multa. Embora a lei diga que o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, art. 475-J), tal encargo não integra a obrigação alimentar quando o pagamento é exigido sob pena de prisão. Descabe dupla sanção. No entanto, cumprida a prisão e não feito o pagamento, como a execução prossegue pelo rito do cumprimento de sentença (CPC, art. 475-J), a multa incide sobre a totalidade do débito.”⁸

Tal entendimento é ainda sustentável, sob a vigência do atual CPC, porque, se o cumprimento de sentença se iniciar pelo procedimento do art. 528, sob pena de prisão, mas se frustrar mesmo após a imposição da pena, o exequente poderá requerer o prosseguimento da execução por meio da sub-rogação de bens, nos termos do que dispõe o subsequente art. 530. E, nesta hipótese, são perfeitamente cabíveis os acréscimos de multa e honorários previstos no § 1.º do art. 523.

Consoante o § 7.º do art. 528, só é cabível a execução sob pena de prisão em relação às três prestações anteriores à instauração do cumprimento de sentença e a todas as demais que se vencerem no curso da execução. Trata-se da positivação de construção pretoriana que já havia sido consolidada no enunciado da Súmula 309/STJ ⁹, o que implica significativa distinção legislativa no tratamento concedido aos alimentos presentes e aos pretéritos. Diante da considerável efetividade advinda do receio da pena de prisão, verifica-se que, ao restringir a possibilidade do seu decreto às três últimas prestações, o legislador praticamente retira a natureza alimentar das dívidas mais antigas, que só podem ser exigidas como débito comum, pelo procedimento previsto no Livro II, Título II, Capítulo III, do novel diploma, com temperamento das demais regras aplicáveis à execução de alimentos (excetuando-se, obviamente, a possibilidade do decreto de prisão do devedor).

Se esse entendimento era questionável à vista da apontada Súmula 309 do STJ, deixa de sê-lo a partir da entrada em vigor do novo diploma, consoante o § 7.º do art. 528.

Assim, tratando-se de prestações vencidas há menos de três meses, o exequente pode optar pelo procedimento previsto no art. 528, requerendo que o cumprimento da sentença ou decisão antecipatória se faça sob pena de prisão. Alternativamente, o devedor pode requerer o cumprimento de sentença previsto nos arts. 523 e seguintes do mesmo diploma, caso em que não será admissível o pedido de prisão do executado. Os meios executórios, nesta hipótese, devem recair sobre o patrimônio do devedor, com a penhora de bens suficientes à satisfação do crédito alimentar e, se não houver o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, a dívida pode sofrer acréscimos de multa e honorários.

Não cabe a fixação de honorários advocatícios se no prazo de três dias o devedor proceder ao pagamento do débito alimentar. Primeiramente, porque não poderia haver decreto de prisão por dívida diversa da alimentar. Mas, além disso, há de se outorgar tratamento simétrico à questão, seja no cumprimento processado pelo art. 528, seja naquele disciplinado pelo art. 523. E o § 1.º do art. 523 não deixa margem para dúvidas: só cabe a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, na fase de cumprimento de sentença, se o devedor intimado não proceder ao pagamento da dívida, acrescida de custas, no prazo que para tanto lhe for assinado.

5. Cumprimento de sentença sob pena de penhora

O procedimento previsto pelos arts. 523 e seguintes será alternativo para as prestações recentes (vencidas há menos de três meses) e será o único aplicável sempre que a dívida de alimentos for composta de prestações vencidas há mais de três meses a contar retroativamente da instauração da fase de cumprimento de sentença.

Nada impede que o exequente resolva dividir o cumprimento de sentença em dois diversificados procedimentos de respectivo cumprimento, sendo um deles sob pena de prisão, relativo à dívida mais recente, vencida há menos de três meses e todas as demais que se vencerem no curso do processo, e outro, sob pena de penhora, referente à parte mais antiga da dívida alimentar, ou seja, prestações vencidas há mais de três meses.

Peculiaridade da execução processada pelo procedimento do art. 523, que decorre da natureza alimentar da dívida, repousa justamente na previsão do § 8.º do art. 528, instituindo a possibilidade de o credor providenciar o levantamento periódico das prestações alimentares futuras, independentemente de prestar caução (art. 521, I), ainda que tenha sido concedido efeito suspensivo à impugnação oferecida pelo devedor que sofreu a penhora de dinheiro. Parece evidente que o levantamento só pode ser feito quanto às prestações futuras, vale dizer, aquelas que se vencerem após a efetivação da penhora de dinheiro. Assim, o credor de alimentos que

penhorou dinheiro pode efetuar o levantamento periódico de valor necessário ao seu sustento, sendo-lhe vedado proceder àquele de toda a dívida pretérita, devendo aguardar que seja julgada a impugnação do devedor, à qual se concedeu efeito suspensivo.

Nos termos do que estatuem os arts. 523 e seguintes, se não houver pagamento voluntário no prazo de 15 dias, as prestações de alimentos serão acrescidas de multa de 10% e de honorários advocatícios, também de 10%, sobre o valor exigido. Trata-se de uma técnica desenhada pelo legislador para incentivar o pagamento voluntário, outorgando enorme concessão: multa e honorários reunidos ensejam um incremento de 20% da dívida, dos quais o devedor pode se livrar se adimplir a soma principal no prazo legal de 15 dias.

Não é necessária a intimação pessoal do executado para se instaurar a fase do cumprimento de sentença pelo procedimento previsto no art. 523 do CPC.

Assim, como ocorre na maioria das situações, será o executado cientificado pela imprensa oficial, a teor do art. 513, § 2.º, I, na pessoa de seu advogado regularmente constituído nos autos, para que pague o débito no prazo de 15 dias. Esta certamente será a hipótese mais comum.

Não obstante, quando representado por defensor público ou não tiver procurador constituído nos autos, o devedor será intimado por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2.º, II), cujo prazo terá início a partir da juntada desta aos autos.

Todavia, nessa derradeira situação, se a citação do executado foi realizada por edital no preâmbulo da fase de conhecimento e deixou-se ficar revel, a sua intimação também será editalícia, na forma do art. 256 do CPC (art. 513, § 2.º, II e IV).

Constitui ônus das partes manter atualizado os seus endereços, físico e eletrônico, nos autos do processo (art. 274, parágrafo único).

E isso porque, a teor do art. 513, § 3.º, presume-se efetivado o ato de intimação, nas hipóteses do anterior § 2.º, II e III, ou seja, quando o devedor não estiver representado nos autos por advogado, mesmo que o seu atual endereço seja outro, não comunicado ao juízo em ocasião oportuna.

Se, todavia, o inadimplemento das prestações de alimentos vincendas vier a ocorrer após um ano, a contar do trânsito em julgado de decisão exequenda, não é possível garantir que o advogado constituído nos autos do processo findo ainda tenha poderes para representar o seu constituinte. Nessa circunstância, e com base no disposto no art. 513, § 4.º, a intimação do devedor será feita por via postal com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço constante dos autos, o qual deve ser mantido atualizado pela própria parte interessada.

6. Justificativa do executado

A justificativa do executado deverá ficar adstrita à prova do pagamento ou à comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, não sendo admissível questionar-se a quantificação da pensão alimentícia, a justiça da decisão condenatória ou a higidez do negócio jurídico em que pactuada a obrigação alimentar, como se de uma ação revisional, anulatória ou exoneratória se tratasse.

A exegese do § 2.º do art. 528 não deixa margem a dúvidas: “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”. *In claris cessat interpretatio* !

A justificativa de que cuida o § 2.º do art. 528 não se confunde com a impugnação que pode ser apresentada pelo devedor, quando o cumprimento for regido pelos arts. 523 e seguintes. Na impugnação, o devedor pode lançar mão de toda a matéria de defesa de que dispuser, não ficando adstrito a demonstrar o pagamento ou a impossibilidade absoluta de efetuar-lo.

Já se o cumprimento for referente a prestações vencidas há menos de três meses, sendo o devedor cientificado para justificar o inadimplemento dos alimentos, sob pena de prisão, há de

convencer que não dispõe de quaisquer meios para efetivar o pagamento da dívida de natureza alimentar ou se sujeitará a medida coercitiva, para ser convencido a adimplir.

7. Decreto de prisão

Se o executado não pagar e se a sua justificativa não for aceita, o juiz decretará a sua prisão pelo prazo de um a três meses. Inicialmente, poder-se-ia cogitar de que a não revogação do art. 19 da Lei de Alimentos ensejaria o ressurgimento da antiga discussão sobre o prazo máximo da prisão civil (60 ou 90 dias).

O art. 19 da Lei de Alimentos prevê o prazo máximo de 60 dias para a prisão por inadimplemento de obrigação alimentar. Após a entrada em vigor do CPC/1973, como a Lei 6.014/1973 manteve inalterada a redação de referido dispositivo, entendeu-se que estava derogado em parte o prazo máximo de três meses previsto no art. 733 do velho diploma, uma vez que lei posterior (Lei 6.014/1973) o derogara. Esse entendimento era minoritário, mas subsistia a dúvida.

O legislador de 2015 perdeu excelente oportunidade para encerrar de uma vez a celeuma, eis que fixou o prazo de três meses, no art. 528, § 3.º, do CPC, ao mesmo tempo em que manteve em vigor o art. 19 da Lei de Alimentos, que prevê o prazo de 60 dias.

Entendo que esta norma não foi revogada, porque a matéria ali versada é mais ampla do que o cumprimento de sentença ou a execução de alimentos fundada em título extrajudicial, contendo comandos que se aplicam à ação de alimentos propriamente dita. Todavia, deve prevalecer o entendimento de que a referida regra legal está, em parte (quanto ao prazo máximo de 60 dias) tacitamente derogada pelo diploma posterior, respeitados os critérios de hierarquia, cronologia e especialidade. Assim, prevalece o prazo máximo de três meses fixado pelo § 3.º do art. 528.

A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o executado ficar separado dos presos comuns. O § 4.º do art. 528 foi objeto de alentadas discussões durante a tramitação do projeto, uma vez que duas correntes se polarizaram em sentidos opostos. A primeira preconizava a necessidade de o cumprimento da pena ser em regime fechado, sob pena de se desprestigiar inteiramente o mecanismo de coerção do devedor. A outra corrente enxergava no remédio radical da prisão um mal necessário, que deveria ser mitigado com a possibilidade de prisão domiciliar do devedor de alimentos. Acabou vencendo a primeira, em prestígio da tese de que a possibilidade do decreto de prisão, especialmente, a prisão em regime fechado, constitui importante elemento de coação, que, em regra, outorga enorme efetividade ao cumprimento da obrigação alimentar.

A prisão consiste num meio de restrição da liberdade destinado a interferir na vontade do executado. Não se trata de sanção pela conduta ilícita do não pagamento. A ordem de prisão não tem o objetivo de punir o devedor faltoso, mas sim o de conscientizá-lo de suas obrigações, convencendo-o a adimpli-las. A severidade do remédio é diretamente proporcional à gravidade do bem tutelado: o pagamento de alimentos é essencial à sobrevivência do alimentando.

Só a dívida de alimentos pode ensejar o decreto de prisão. O devedor não pode ser preso por ter deixado de pagar as verbas consectárias da mora, tais como juros, custas judiciais e honorários advocatícios. O depósito que elide o decreto de prisão é o do principal monetariamente corrigido.

O caráter de coerção de que se reveste a prisão civil do devedor de alimentos transparece evidente nos §§ 5.º e 6.º do art. 528. Primeiramente, porque, segundo o § 5.º, o cumprimento da pena de prisão não exime o executado do pagamento da dívida. Não se admite a ideia de que o cumprimento da pena redime a obrigação de pagar alimentos. A mesma dívida vencida, que fora causa do decreto da prisão, subsiste hígida após o cumprimento da pena, cujo decreto, todavia, só poderá ser renovado quanto a outras prestações de natureza alimentar, jamais as mesmas.

Em sentido oposto, nos termos do § 6.º do art. 528, sendo efetuado o pagamento da pensão alimentícia mesmo antes do cumprimento da ordem de prisão, a finalidade do risco de segregação pessoal terá sido alcançada, razão pela qual deve ser afastado o seu cumprimento.

Ressalte-se, finalmente, que, a despeito do leque de meios executivos colocados à disposição do credor de alimentos, tais como o desconto em folha previsto pelo art. 529, a expropriação patrimonial dos arts. 523 e seguintes e a coerção pessoal do art. 528, todos do CPC, não existe necessidade de exaurimento dos demais meios executórios antes de ser decretada a prisão do devedor de alimentos. A opção pelo procedimento do art. 528, quando cabível, compete única e exclusivamente ao credor, que a exerce no momento apropriado ao cumprimento de sentença. Por isso mesmo – contrariamente à orientação jurisprudencial que se fez majoritária sob a égide do diploma processual revogado –, entendo que o decreto de prisão independe da reiteração do pedido já feito pelo exequente. Constatado que o devedor não procedeu ao pagamento e não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo, não há porque se exigir que o exequente renove o pedido de prisão inicialmente formulado: o juiz deve decretá-la em atendimento ao pleito preambular do credor.

Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

§ 1.º Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício.

§ 2.º O ofício conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito.

§ 3.º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do *caput* deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.

Correspondência: art. 734 do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 933 do CPC português

1. Exceção à regra da impenhorabilidade do salário

O art. 529 prevê o cumprimento de sentença mediante desconto em folha de pagamento. Verifica-se que em razão de sua enorme relevância jurídica, o crédito alimentar dá ensejo à exceção à regra da impenhorabilidade dos rendimentos do trabalho ditada pelo art. 833, IV e X, do CPC. Segundo esta norma, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo, os honorários de profissional liberal e o saldo de caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Todavia, por força do § 2.º do art. 528, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Sempre que houver como deduzir o valor da prestação alimentícia diretamente dos rendimentos do executado, o exequente poderá requerer ao juiz, que o determinará na própria decisão que reconhece a exigibilidade da obrigação de natureza alimentar ou na decisão que determina a intimação do devedor para o cumprimento da sentença. O empregador será oficiado para que proceda ao desconto a partir da primeira remuneração posterior ao protocolo da ordem judicial, sob pena de responder por crime de desobediência, nos termos dos arts. 22 da Lei 5.478/1968 e 330 do Código Penal.

O ofício em tela, segundo o art. 529, § 2.º, deve especificar o nome ou nomes dos exequentes e do executado, o montante a ser descontado, o período de duração e os dados bancários para o respectivo depósito.

1.1. Pagamento de prestações vencidas e vincendas

O mecanismo do desconto em folha destina-se, primeiramente, ao pagamento das prestações vincendas, prevenindo o inadimplemento de uma obrigação tão importante, quanto a dívida alimentar. Todavia, o § 3.º do art. 529 veio para dirimir qualquer dúvida que ainda pudesse subsistir acerca de possibilidade de se aplicar o mesmo mecanismo do desconto em folha para quitação de prestações vencidas, o que já vinha sendo amplamente admitido pela doutrina especializada. Ainda sob a égide do diploma revogado, Araken de Assis afirmou que, “em princípio, sendo o montante do salário, dos vencimentos ou dos créditos suficiente à ablação, total ou parcial, e reservada parte dos mesmos à sobrevivência do alimentante, nenhum obstáculo prático ou jurídico se opõe ao desconto de alimentos já vencidos e há muito acumulados. Em outras palavras, não cabem descontos retroativos – que, eventualmente, abrangeriam toda a dívida do terceiro e, nessas condições negariam recursos à subsistência do alimentante –, mas o desconto futuro poderá se referir a alimentos pretéritos e vincendos”.¹⁰

É evidente que se o saldo devedor em aberto for tão elevado a ponto de comprometer todo o rendimento do executado, inviabilizando o seu próprio sustento, o desconto em folha para pagamento das prestações vencidas deverá ser feito de maneira parcelada, restringindo-se a um percentual razoável dos ganhos líquidos do executado.

1.2. Limite máximo para o desconto em folha

O § 3.º do art. 529 estabeleceu os limites máximos desse desconto em folha para pagamento das prestações vencidas, especialmente quando cumulado com aquele destinado ao pagamento das prestações vincendas. Essa questão, que muita dúvida suscitava no passado, recebeu agora tratamento eficiente e justo, que positivou, a respeito, o posicionamento jurisprudencial dominante, ou seja, a soma da prestação vincenda, com a parcela relativa à dívida vencida não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado, assegurando também a ele os meios necessários à sua própria subsistência.

Por rendimentos líquidos há de se entender todas as parcelas devidas ao executado no mês, podendo incidir sobre verbas rescisórias, horas extras, comissões, bônus e décimo terceiro salário, dentre outras rubricas devidas pelo empregador. É esse o entendimento que inequivocamente se extrai da locução “rendimentos ou rendas do executado” (art. 529, § 3.º). O que se busca assegurar é, no mínimo, 50% dos ganhos líquidos mensais para o executado.

Art. 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos arts. 831 e seguintes.

Correspondência: art. 732 do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

Estatui o CPC, no dispositivo ora comentado, verba legal que poderia parecer intuitiva, mas que tem a sua importância, devendo ser interpretada com a devida cautela. É evidente que não cumprida a obrigação, o credor pode requerer a expropriação patrimonial prevista nos arts. 831 e seguintes do CPC. O que o art. 530 coloca a salvo de qualquer dúvida é que, se o exequente optar pelo procedimento do art. 528, dando início ao cumprimento de sentença sob pena de prisão, sem obter o necessário êxito, pode prosseguir no mesmo processo buscando, no patrimônio do devedor, bens passíveis de penhora, suficientes para a satisfação do seu crédito.

Nessa hipótese, com o prosseguimento do processo por meio da técnica de sub-rogação, não há motivo para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no antigo art. 523 do CPC. A tal propósito, Maria Berenice Dias já advertia, sob a égide do diploma revogado, que: “Sobre o valor do débito não se incorpora a multa. Embora a lei diga que o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (CPC [1973], art. 475-J), tal encargo não integra a obrigação alimentar quando o pagamento é exigido sob pena de prisão. Descabe dupla sanção. No

entanto, cumprida a prisão e não feito o pagamento, como a execução prossegue pelo rito do cumprimento de sentença (CPC, art. 475-J), a multa incide sobre a totalidade do débito.”¹¹

Esse entendimento mantém-se como a melhor exegese do art. 530 do CPC. Se a execução iniciada sob pena de prisão vai prosseguir, visando à penhora de bens, nos termos do art. 831 e seguintes, passam a incidir multa e honorários sobre a dívida. Não haveria mesmo porque premiar o devedor recalcitrante, que não se intimidou com o decreto de sua prisão, eximindo-o do pagamento de multa e honorários fixados para a fase de cumprimento de sentença, apenas em razão da opção inicial do credor, que preferiu requerer o cumprimento pela disciplina do art. 528 e, não obstante, restou frustrada.

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.

§ 1.º A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.

§ 2.º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.

Correspondência: art. 735 do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

Dúvida não há, a despeito da regra do art. 531, de que o capítulo IV do título II do livro I do CPC aplica-se tanto aos alimentos definitivos quanto aos provisórios. O que os distingue, em resumo, é o momento da sua concessão, no *iter* procedimental. Enquanto os alimentos provisórios são concedidos no âmbito de antecipação da tutela, os alimentos definitivos são aqueles fixados por sentença transitada em julgado.

Resulta evidente que o procedimento destinado ao cumprimento da decisão antecipatória, que concede alimentos provisórios, assim como o cumprimento da sentença ainda sujeita a recurso, não são marcados pela definitividade. Eventual cumprimento forçado de tais decisões deve-se processar em autos apartados, justamente para evitar tumulto que decorreria da autuação conjunta de petições, termos e atos relativos à cognição exauriente ou ao julgamento do recurso e outras postulações, atos e termos de natureza executória, relativos ao cumprimento da decisão antecipatória.

Já o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos pode e deve ser processado nos mesmos autos em que tenha sido proferido o ato decisório transitado em julgado, exatamente porque o processo de conhecimento já se encontra encerrado. Ainda quando remetido a juízo diverso daquele em que se encerrou a fase de conhecimento, o processamento do cumprimento de sentença dar-se-á nos mesmos autos, os quais serão requisitados ao juízo de origem, nas hipóteses do art. 516, parágrafo único, o que resulta providência deveras simples nos domínios do processo eletrônico.

Art. 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material.

Sem correspondência

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Conduta procrastinatória e caracterização de crime de abandono material

O crime de abandono material é previsto pelo art. 244 do Código Penal.¹² Em caso de conduta procrastinatória do devedor de alimentos, o art. 532 estabelece que o juiz deve dar ciência ao Ministério Público para as providências cabíveis.

A regra, que não tem correspondência no diploma revogado, outorga ainda mais efetividade à execução de alimentos. A simples possibilidade de a autoridade judicial encaminhar informação ao Ministério Público, por ter encontrado indícios de prática do crime de abandono material, já resulta meio indireto de coerção mais do que eficiente.

A denúncia do Ministério Público, nos casos em que vier a ser apresentada, enseja gravíssimo entrave à vida do devedor, do qual ele não poderá ser livrar pelo simples pagamento posterior da prestação alimentar. Muito mais grave do que a imposição de prisão civil, o recebimento da denúncia por crime de abandono material é irreversível e certamente constituirá séria ameaça ao devedor recalcitrante.

A prática evidencia que, em algumas circunstâncias, apesar de inegáveis sinais exteriores de riqueza, sendo desacolhida a justificativa ou a impugnação, por vezes o devedor assume conduta procrastinatória, seja ocultando bens, seja desviando-os do seu patrimônio, ou ainda abandonando o emprego ou a atividade que exerce, mudando o seu domicílio, encerrando contas bancárias, enfim, apagando os rastros que permitam a satisfação do crédito alimentar, circunstâncias que tornam evidente a intenção de deixar desamparado o alimentando.

Nestas hipóteses, nas quais a falta de justa causa para os atos desencadeados leva a suspeita da prática de ilícito penal, é imperativa a letra da lei ao determinar que o juiz deve dar ciência ao Ministério Público.

Atendendo ao delineamento do tipo penal, o legislador processual restringiu a aplicação da norma aos alimentos fixados em título executivo judicial, excluídos os alimentos previstos em títulos extrajudiciais. Mas não há imposição de um limite temporal para a prática do crime de abandono material, de modo que tanto no procedimento incoado sob pena de prisão (art. 528 e ss.) quanto naquele que se processa por meio de sub-rogação de bens (art. 523 e ss.) podem ser extraídas peças para serem encaminhadas ao Ministério Público contendo indícios da conduta ilícita.

Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1.º O capital a que se refere o *caput*, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 2.º O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

§ 3.º Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação.

§ 4.º A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário-mínimo.

§ 5.º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.

Correspondência: art. 475-Q do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

O agente de ato ilícito pode ser condenado a indenizar a vítima ou a família desta. É o que ocorre, por exemplo, nas situações previstas nos arts. 948, II, e 950 do Código Civil, atinentes,

respectivamente, à indenização por homicídio e por lesão ou outra ofensa à saúde de alguém que resulte defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão ou tenha diminuída a sua capacidade de trabalho. A obrigação que é então imposta ao autor da ilicitude, nestes casos, pode ter por objeto prestação alimentar.

Escreve, a propósito, Araújo Cintra que, normalmente, as indenizações são adimplidas de uma única vez, mas a lei assegura à vítima de ato ilícito uma forma contínua de subsistência, ao prever a fixação de prestação alimentar periódica, até um determinado momento, a ser especificado na sentença que imponha tal espécie de ressarcimento.

A esse respeito, a 3.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.968-DF, com voto condutor do Ministro Marco Aurélio Bellizze, assentou que: “A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Na espécie, a fim de assegurar o efetivo pagamento das prestações mensais estipuladas, faz-se necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para esse fim, nos termos da Súmula 313 deste Tribunal.” ¹³

Alterando a redação do revogado art. 475-Q, o novo CPC estabelece que, mediante requerimento do exequente, o juiz deve determinar a constituição de capital suficiente, para que o executado possa garantir o pagamento do valor mensal da respectiva pensão. Em outras palavras, se a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz deverá, considerando, a um só tempo, o *quantum* do desembolso que caberia ao devedor e a proteção do credor, e, ainda, o disposto no art. 805 do CPC, determinar ao executado a constituição de capital, cujo rendimento assegure o pagamento do valor mensal da respectiva prestação. ¹⁴

Ao que tudo indica, a norma do *caput* do art. 533 mais se equipara àquela do velho art. 602, que impunha ao juiz, de forma peremptória, o dever de ordenar a constituição de capital, toda vez que a sentença fixasse, a título de indenização por ato ilícito, prestação de alimentos. Esta interpretação foi consagrada na Súmula 313/STJ, com o seguinte enunciado: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento de pensão, independentemente da situação financeira do demandado”, que vem agora ressuscitada, dado o caráter cogente da regra ora comentada.

Cumprindo esclarecer que o § 4.º do art. 533 permite que a prestação alimentícia seja estipulada tomando-se como parâmetro – não como indexador – o salário mínimo. E isso, certamente “viabiliza uma maior segurança em relação aos valores devidos a este título, abstração feita das discussões no plano nacional acerca do poder aquisitivo do valor nominal do salário mínimo. O mais importante, já que se trata de obrigação alimentar, é o firmamento de critérios seguros quanto aos limites da obrigação imposta, o que sem dúvida é importante tanto sob a ótica do credor quanto do devedor”. ¹⁵

Procurando compatibilizar o cumprimento de sentença com a real situação das partes revelada nos autos, inclusive para que se proceda do modo menos gravoso para o executado, o juiz pode, de ofício, substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento, quando o devedor for pessoa jurídica de notória capacidade econômica, ou, ainda, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em montante a ser arbitrado pelo juiz, tão logo seja iniciado o cumprimento da sentença (art. 533, § 2.º).

É o que sucede geralmente quando a devedora é a Fazenda Pública, como deixou patenteado a 1.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do Recurso Especial 1.168.831-SP, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, *in verbis* : “Quanto ao termo *ad quem*, tendo em vista ser a própria vítima quem reclama o pensionamento, e, levando-se em conta que a sua lesão, embora parcial, é permanente, acompanhando-o até o fim dos seus dias, a pensão deve ser vitalícia. Mostra-se desnecessária a constituição de capital garantidor, tendo em vista ser a Fazenda Pública a demandada. Entretanto, deve incluir o nome do autor em sua folha de

pagamento.”¹⁶

Esclareça-se que, uma vez comprovado nos autos o integral adimplemento da obrigação de prestar alimentos, preceitua o § 5.º do art. 533 que, dependendo da natureza da garantia constituída pelo executado, o juiz ordenará a liberação do capital, a cessação do desconto em folha de pagamento, ou o cancelamento da garantia prestada.

2. Constituição e objeto do capital

De modo assemelhado ao que sucede na especificação da hipoteca judicial (art. 495 CPC), quando o juiz ordenar a constituição de capital, o executado deve ser intimado a oferecer, com a devida identificação, os imóveis, os direitos reais sobre imóveis passíveis de alienação, os títulos da dívida pública, ou as aplicações financeiras em banco oficial com que pretende estabelecer o capital necessário àquela finalidade. Colhida a manifestação do exequente, o juiz decidirá, determinando a constituição do capital sobre o ativo oferecido ou, caso não seja ele idôneo ou suficiente, ordenará que o executado apresente outros bens.

Importa salientar que: “É cabível a cominação de multa diária (*astreintes*) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na constituição de capital garantidor ou caução fidejussória.”¹⁷

Constituído o capital, será então expedido mandado judicial para que o cartório de Registro de Imóveis competente (art. 167, II, 11, Lei 6.015/1973) providencie a averbação na matrícula do imóvel do gravame de inalienabilidade e impenhorabilidade, enquanto durar a obrigação (art. 533, § 1.º).

Inova o diploma processual nesse tema, visto que, para evitar qualquer risco de esvaziamento posterior da situação financeira do executado, o § 1.º do art. 533 determina que o capital deve constituir-se em patrimônio de afetação.

Entende-se por “patrimônio de afetação” a segregação de bens do devedor para uma finalidade específica, com o precípuo escopo de assegurar a continuidade do cumprimento da prestação, mesmo em caso de ulterior insolvência do executado. Este tem o ônus de lavrar escritura pública com tal escopo e averbá-la na matrícula do imóvel.

Tratando-se de títulos da dívida pública e de aplicações financeiras em banco oficial, deverá ser feita a devida comunicação ao órgão responsável pela custódia ou depositário dos títulos, para que preserve/bloqueie aqueles em nome do devedor até que haja determinação em sentido contrário.¹⁸

3. Revisão do valor da prestação

Exatamente como ocorre com as outras espécies de obrigação alimentar, na situação aqui examinada, havendo alteração do binômio necessidade-possibilidade, em decorrência de modificação das condições econômicas, o exequente poderá requerer, nos próprios autos, o aumento e o executado, a redução da prestação.

Eis o que prescreve *in verbis* o § 3.º do art. 533: “Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação”.

Esta regra, por certo, tem como fonte imediata o disposto no art. 1.699 do Código Civil: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Assim, por exemplo, se, com o passar do tempo, o ofendido passa a não mais necessitar de sessões de fisioterapia, os gastos com esse tratamento podem perfeitamente ser abatidos do valor da pensão.

Tenha-se presente, aliás, como já se observou no comentário ao art. 505, I, do CPC, que no âmbito das demandas que têm por objeto relações jurídicas de trato continuado a coisa julgada material não oferece qualquer peculiaridade.

Com efeito, diante da alteração fática verificada na situação econômica das partes, a revisão do valor da indenização fixado na sentença transitada em julgado não significa, de modo algum, que se está diante do fenômeno da “flexibilização” da coisa julgada.

Com a alteração das circunstâncias, outra será a causa de pedir próxima, a justificar o pedido de nova tutela jurisdicional (e, na verdade, não de revisão da anterior), ainda que nos próprios autos do processo. Alterado em substância o respectivo fundamento jurídico, não se estará, à evidência, diante de ação idêntica. É exatamente por esta razão que os limites objetivos da precedente coisa julgada não se estendem à “nova questão”.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Não existe mais a categoria dos alimentos provisionais, então previstos no art. 852 do CPC/1973.

2

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, 4, p. 104.

3

Tratando-se do cumprimento de sentença sujeita a recurso, a execução far-se-á em autos apartados mediante extração de cópias do processo remetido ao tribunal *ad quem*.

4

REsp 1.117.639-MG, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, v. u., DJe 21.2.2011; REsp 1.285.254-DF, 4ª T., rel. Min. Marco Buzzi, m. v., DJe 1.8.2013: “Execução de alimentos lastreada em título executivo extrajudicial, consubstanciado em acordo firmado perante órgão do Ministério Público (art. 585, II, CPC[1973]), derivado de obrigação alimentar em sentido estrito - dever de sustento dos pais a bem dos filhos. Documento hábil a permitir a cominação de prisão civil ao devedor inadimplente, mediante interpretação sistêmica dos art. 19 da Lei 5.478/68 e art. 733 do CPC[1973]”; REsp. 1.487.472-DF, decisão monocrática, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 3.11.2015.

5

Fredie Didier Júnior. *Curso de direito processual civil*, 5, p. 695. V., no mesmo sentido, Paulo Henrique dos Santos Lucon, *Código de Processo Civil interpretado* (obra coletiva), p. 2.303-2.304.

6

De conformidade com o art. 274, parágrafo único, são reputadas válidas as intimações dirigidas aos endereços constantes dos autos, ainda que tenha havido mudança definitiva ou temporária. Salta aos

olhos a falta de acuidade do legislador quando determina que, mesmo se houver passado mais de um ano a contar do trânsito em julgado, deve ser realizada a intimação por carta encaminhada ao endereço antigo. Ora, após um ano de interregno, presume-se que o processo permaneceu paralisado, ou porque as prestações vincendas vinham sendo pagas pelo devedor, ou porque o credor manteve-se inerte quanto ao débito em atraso, deixando que o processo fosse remetido ao arquivo. É justamente nessas hipóteses que o endereço do devedor – aquele constante dos autos – pode estar desatualizado, e não seria razoável exigir que as partes ficassem atualizando sempre os seus respectivos endereços em processos findos ou arquivados. É claro que a interpretação do art. 513, § 4.º, deve ser feita *cum grano salis*, de modo a permitir ao devedor que não recebeu intimação do cumprimento de sentença, que apresente justificativa razoável para não ter mantido atualizado o seu endereço nos autos, depois de mais de um ano, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

7

Nesse sentido, de todo elogiável a decisão proferida, já sob a vigência do CPC/2015, pela magistrada Margot Chrisostomo Corrêa, da 2.ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã, da capital paulista, do seguinte teor: “Vistos. Fls. 411: A prisão civil já fora decretada às fls. 339/341, razão pela qual, ante o silêncio do executado à intimação das decisões de fls. 396 e 403, determino o cumprimento da ordem de prisão, devendo constar no mandado o valor atualizado do débito indicado, qual seja, R\$ 22.805,90 (vinte e dois mil, oitocentos e cinco reais e noventa centavos). Ademais, nos termos do art. 528, § 1.º, do CPC, proceda-se ao protesto do pronunciamento judicial, negativando-se o CPF do executado junto aos órgãos de proteção ao crédito”.

8

Maria Berenice Dias, Execução dos alimentos e as reformas do Código de Processo Civil, *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, 16:36.

9

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

10

Araken de Assis. *Manual da execução*, p. 1.355.

11

Maria Berenice Dias, *Execução dos alimentos e as reformas do Código de Processo Civil*, p. 36.

12

“Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente,

gravemente enfermo. Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País. Parágrafo único – Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada”.

13

V. u., *DJe* 04.05.2015.

14

Antonio Carlos de Araújo Cintra, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 403.

15

Cf. Glauco Gumerato Ramos, Cumprimento da sentença condenatória de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito, *Execução civil e cumprimento da sentença* (obra coletiva), p. 255.

16

V. u., *DJe* 13.09.2010.

17

STJ, 4.^a T., EDcl no REsp 1.281.742-SP, rel. Min. Marco Buzzi, v. u., *DJe* 11.09.2014.

18

Cf., ainda, Antonio Carlos de Araújo Cintra, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 4, p. 403.

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

CAPÍTULO V. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA

Capítulo V. Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa Pela Fazenda Pública

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I – o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II – o índice de correção monetária adotado;

III – os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV – o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V – a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI – a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1.º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 113.

§ 2.º A multa prevista no § 1.º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

Correspondência: art. 730 do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

Como já adiantado, o cumprimento da sentença que impõe prestação alimentar e daquela que é proferida contra a Fazenda Pública, condenando-a em obrigação de pagar quantia certa, tem regime procedimental especial.

A dicção *Fazenda Pública* engloba as entidades da administração direta e indireta dotadas de personalidade de direito público, excetuando-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ficam, destarte, excluídas da sistemática excepcional as sociedades nas quais o Poder Público figura como acionista.

Examinando esta questão, a 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 473.310-PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, deixou patente que “os bens das empresas públicas, porque pessoas jurídicas de direito privado, não podem ser enquadrados como bens públicos. Conclusão diversa implica a incongruência, dando-se ênfase maior ao acessório, em detrimento do principal, e olvidando-se, mais do que isso, o sistema

pátrio, no que distingue pessoa jurídica de direito privado das pessoas jurídicas de direito público. Nota-se, portanto, sem mesmo perquirir-se o teor do art. 100 da Constituição Federal, a impropriedade de reconhecer-se quer às sociedades de economia mista, quer às empresas públicas, ambas pessoas jurídicas de direito privado, a prerrogativa de execução via precatório. A razão maior de contemplar a Carta a adoção de tal sistema de execução está no envolvimento de bens públicos. Daí o art. 100 em comentário aludir a ‘...pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária...’, não se podendo dizer que débitos de sociedades de economia mista e de empresas públicas, federais, estaduais ou municipais, sejam débitos das respectivas Fazendas. Portanto, ainda que se abandone a interpretação sistemática dos diversos preceitos que compõem o arcabouço normativo constitucional, tomando-se de forma isolada o que se contém nos artigos envolvidos, chega-se, fatalmente, à conclusão de não se aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução prevista no art. 100 da Carta da República”.¹

A Fazenda Pública, sob a perspectiva da história do direito, sempre se beneficiou de privilégios substanciais e processuais, que remanescem inclusive na experiência jurídica contemporânea. Anote-se, por ilustração, que em pleno regime republicano, o direito brasileiro não atribuía responsabilidade ao Estado, visto que prevalecia, no art. 82 da Constituição de 1891, a denominada tese *regalista*.² A execução de sentença contra o patrimônio da Coroa também recebia, em época medieval, tratamento diferenciado, vulnerando o princípio da isonomia.³

Atualmente, em nosso sistema jurídico, no que se refere à dívida da Fazenda Pública, o art. 100 da Constituição Federal determina a observância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios, excetuando-se apenas os créditos de natureza alimentícia e as requisições de pequeno valor.

Tratando-se de título executivo judicial, procede-se então por meio de cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública, segundo o disposto nos arts. 534 e 535 do CPC. A ação de execução, a teor do art. 910 do CPC (*Da execução contra a Fazenda Pública*), fica reservada aos títulos extrajudiciais.⁴

Ainda que o título judicial seja provisório, nada obsta a que o credor requeira a instauração do cumprimento, visando a adiantar os atos executivos, não sendo contudo possível a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado.⁵ O texto do art. 100, § 5.º, da Constituição Federal exige, de fato, que a sentença tenha transitado em julgado para que o crédito possa ser incluído no orçamento da respectiva entidade devedora de direito público.

Considere-se que tão somente a execução das prestações em atraso, alimentícias ou não, está sujeita ao requisito do trânsito em julgado. Tratando-se, no entanto, de decisão determinativa de correção de critério de cálculo de vencimentos ou de cancelamento de algum desconto irregular, a respectiva execução dessa obrigação de fazer não está condicionada ao trânsito em julgado, isto é, nada impede que seja provisório o cumprimento do pronunciamento judicial.⁶

Na verdade, de forma coerente, tratando-se de cumprimento de sentença que determine à Fazenda Pública “um fazer ou um não fazer, ou, ainda, entregar algo que não seja dinheiro, inexistem normas constitucionais a serem observadas quanto ao procedimento de sua implementação concreta, prevalecendo, no que diz respeito às técnicas executivas e aos seus correspondentes processo e procedimento, o disposto na legislação infraconstitucional (e o mandado de segurança é notório exemplo), ou nos arts. 536 a 538 do CPC”.⁷

2. Iniciativa do exequente

O cumprimento da sentença que reconhece a obrigação de a Fazenda Pública pagar quantia certa depende de expresse requerimento do exequente.

À exemplo do que sucede no âmbito do cumprimento de sentença que se processa pelo procedimento padrão, no caso específico aqui examinado, o exequente deve igualmente apresentar memória discriminada do valor atualizado do crédito, contendo praticamente os

mesmos elementos exigidos nos incs. I a VI do art. 524 do CPC.

Embora omisso o art. 534, entendo que, se a elaboração ou a complementação do demonstrativo depende de informações que se encontrem em poder da Fazenda Pública, o juiz também poderá requisitá-las, ancorando-se no disposto no aludido art. 524, §§ 3.º e 4.º.

3. *Litisconsórcio ativo no cumprimento de sentença*

Na hipótese de litisconsórcio ativo, todos os credores têm a faculdade de agir de comum acordo, pleiteando em conjunto o cumprimento de sentença. Se litigarem individualmente, cada qual, segundo o § 1.º do art. 534, deve deduzir seu próprio requerimento, acompanhado da planilha de cálculo.

Acrescente-se que incide também no terreno do cumprimento de sentença a regra do art. 113, § 1.º, do CPC, podendo ser decotado o denominado litisconsórcio multitudinário facultativo, em situação limite, na qual expressivo número de litigantes apresentar obstáculos que comprometam a efetividade da garantia fundamental da duração razoável do processo, especialmente da atividade satisfativa, no que toca à expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, ou, ainda, venha a dificultar o exercício do direito de defesa da executada.

4. *Isenção da incidência da multa*

Considerando a natureza do patrimônio que compõe os ativos da Fazenda Pública, não há penhora e tampouco expropriação de bens públicos.

Ademais, no âmbito do procedimento especial de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não é ela intimada a atender, de pronto, ao comando judicial, mas sim para oferecer impugnação. Desse modo, como mais um privilégio de que desfruta a executada, não se sujeita ela à multa de 10% decorrente do inadimplemento. Reza, com efeito, o art. 534, § 2.º: “A multa prevista no § 1.º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública”.

No entanto, pela sua inegável relevância didática, vale a transcrição de trecho de julgado da 1.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 784.188-RS, com voto condutor do Ministro Teori Albino Zavascki, que admite, “inclusive contra a Fazenda Pública, a aplicação de multa diária (*astreintes*) como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos arts. 461 e 461-A do CPC [1973]. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar, por exemplo, nos seguintes precedentes: Agravo Regimental no Agravo 646.240-RS, 1.ª Turma, Ministro José Delgado, *DJ* de 13.6.2005; Recurso Especial 592.132-RS, 5.ª Turma, Ministro José Arnaldo da Fonseca, *DJ* de 16.5.2005; Agravo Regimental no Recurso Especial 554.776-SP, 6.ª Turma, Ministro Paulo Medina, *DJ* de 6.10.2003; Agravo Regimental no Recurso Especial 718.011-TO, 1.ª Turma, Ministro José Delgado, *DJ* de 30.5.2005. 2. Todavia, não se pode confundir multa diária (*astreintes*), com bloqueio ou sequestro de verbas públicas. A multa é meio executivo de coação, não aplicável a obrigações de pagar quantia, que atua sobre a vontade do demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação decorrente da decisão judicial. Já o sequestro (ou bloqueio) de dinheiro é meio executivo de sub-rogação, adequado a obrigação de pagar quantia, por meio do qual o Judiciário obtém diretamente a satisfação da obrigação, independentemente de participação e, portanto, da vontade do obrigado. 3. Em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC [1973], e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (*v. g.* , desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciais), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis”.⁸

Observa-se, pois, que é admitida a aplicação de multa cominatória ao devedor, desde que se trate de obrigação de fazer ou de não fazer, “ainda que o mesmo seja a Fazenda Pública”.⁹

5. Descabimento de honorários de advogado

O art. 85, § 7.º, preceitua que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que propicia a expedição de precatório, não são devidos honorários advocatícios, quando não impugnado pela devedora.

Tal verba legal adota a orientação perfilada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 420.816-PR, que reconheceu a constitucionalidade do art. 1.º-D da Lei 9.494/1997 (“Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”), “conferindo-lhe, porém, interpretação conforme a Constituição para reduzir seu campo de incidência, de modo a excluir ‘os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor’.”¹⁰ Significa que, nos cumprimentos de sentença que tenham a Fazenda Pública como *executada* e que acarretem a expedição de *precatório*, não haverá condenação em honorários sucumbenciais caso não haja impugnação”.¹¹

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexecutabilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1.º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

§ 2.º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

§ 3.º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

§ 4.º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

§ 5.º Para efeito do disposto no inciso III do *caput* deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6.º No caso do § 5.º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7.º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5.º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8.º Se a decisão referida no § 5.º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Correspondência: art. 730 do CPC/1973

Comparação jurídica: sem correspondência

1. Aspectos gerais

De conformidade com o procedimento especial do cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa, proferida contra a Fazenda Pública, é ela intimada para, se for de seu desejo, oferecer impugnação no prazo de 30 dias.

A ciência à Fazenda Pública tem, pois, o único objetivo de estabelecer o termo inicial para a apresentação de impugnação, uma vez que, de um lado, não se viabiliza a possibilidade de pronto pagamento e, de outro, o patrimônio público não é passível de constrição judicial.

O ato de intimação afasta-se da regra geral, prevista no art. 513, § 2.º, do CPC, podendo ser efetivado no momento em que é providenciada a carga dos autos, se naturalmente forem eles físicos, ou por meio eletrônico. Dispõe ainda o § 3.º do art. 269 do diploma processual que a intimação da Fazenda Pública “será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial”.

O art. 535, cuidando apenas de suprimir qualquer referência a atos de constrição e de expropriação, praticamente repete o anterior art. 525, que disciplina o conteúdo das matérias, preliminares e substanciais, que podem ser suscitadas na peça de defesa a ser apresentada.

A petição de impugnação deve ser dirigida ao juízo perante o qual se desenrola o cumprimento, para ser entranhada nos próprios autos do processo, consubstanciando-se em verdadeira manifestação defensiva, tendente a aperfeiçoar o contraditório também nessa derradeira fase processual.

2. Elenco da matéria deduzível na impugnação

Considere-se que, em algumas situações pontuais, mormente naquelas referentes às espécies de tutela jurisdicional diferenciada, que se afastam do procedimento comum, a própria lei impõe restrições à liberdade de iniciativa do autor quanto à demarcação da *causa petendi*.

As possessórias, como acima lembrado, configuram um exemplo típico de demandas cujo conteúdo objetivo sofre limitação *ex lege*. A cognição sumária, que caracteriza tais ações, obsta a que o autor deduza causa de pedir fundada em domínio.

Na seara do cumprimento de sentença, o art. 525 do CPC, que, como já asseverado, cataloga o rol de fundamentos passíveis de alegação em sede de impugnação, também delimita acentuadamente o diâmetro da *causa petendi* deduzível pelo devedor.

Repetindo, em substância, esta técnica de sumarização, análoga lista de questões suscetíveis pela Fazenda Pública, em sede de impugnação, vem disposta no art. 535, aqui examinado.

Fica excluída, como é evidente, a exigência de indicação de bens passíveis de penhora (prevista no art. 524, VII), visto que o cumprimento encetado contra a Fazenda Pública objetiva a expedição do precatório ou o levantamento de quantia depositada em conta específica a disposição do Poder

Judiciário.

Desse modo, cabe à Fazenda Pública, seguindo ordem lógica, arguir o gravíssimo vício de citação, no início da demanda, pondo tudo a perder, uma vez que, quando acolhida essa alegação, o processo será declarado nulo *ex radice*, simplesmente porque não se caracteriza revelia quando o réu não foi citado de forma válida e eficaz.

Com a manifesta ofensa ao contraditório, o título judicial será reputado *inutiliter datur* em decorrência da inevitável procedência do pedido (“constitutivo negativo”) formulado na impugnação.

Em sequência, *ex vi* do disposto no art. 535, V, a Fazenda Pública pode arguir, no bojo da própria impugnação, a incompetência absoluta ou relativa do juízo em que se processa o cumprimento de sentença, sobretudo naquela hipótese, autorizada pelo parágrafo único do art. 516, em que o exequente elege *sponte propria* juízo diferente daquele perante o qual se formou o título judicial.

Embora de todo prescindível, o § 1.º do art. 535 autoriza a Fazenda Pública a alegar impedimento ou suspeição, observando-se os termos dos arts. 146 e 148 do CPC, inclusive o prazo de 15 dias, sempre por meio de petição específica, dirigida ao mesmo juiz do cumprimento de sentença.

Ademais, se não debatida e enfrentada na decisão que se consubstancia no título executivo transitado em julgado, é mais do que justificável a arguição de ilegitimidade ativa e/ou passiva pela Fazenda Pública, quando não houver simetria entre pelo menos um dos sujeitos da relação jurídica emergente do título judicial exequendo e a parte – exequente ou a Fazenda Pública – que estiver atuando no processo.

Passando a enfrentar o mérito da pretensão executiva, a executada pode suscitar o excesso de execução ou a cumulação indevida de execuções. Tratando-se do primeiro fundamento, isto é, de cobrança a maior, dispõe o § 2.º do art. 535, que a Fazenda Pública tem o ônus de declarar – e certamente de demonstrar por meio de planilha de cálculo – a soma que entende correta, sob pena de desconsideração da impugnação, quando aquele for o único argumento deduzido.

Se, por outro lado, a executada alegar o descabimento da cumulação, deve deixar evidente que o cúmulo objetivo de execuções delinea-se inapropriado porque, por exemplo, os respectivos títulos contêm obrigações de diferente natureza ou, ainda – possivelmente por força desta mesma alegação –, porque há incompatibilidade procedimental entre as respectivas formas de cumprimento das decisões judiciais exequendas.

Constitui, também, matéria de defesa de mérito da executada, a “inexequibilidade do título” ou a “inexigibilidade da obrigação”, inclusive na situação descrita no § 5.º do art. 535 do CPC (§ 12 do art. 525), que também tem por inexigível a prestação imposta por título executivo judicial, *antes de transitado em julgado* (§ 7.º), lastreado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo reputado pela Excelsa Corte incompatível com a Constituição Federal, no exercício do controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

Quando a decisão do Supremo Tribunal Federal acarretar potencial prejuízo a terceiros, violando o princípio da confiança e, conseqüentemente, conspirar contra a segurança jurídica, poderá haver modulação dos efeitos pretéritos da declaração de inconstitucionalidade (art. 535, § 6.º).

Ressalva, a propósito, o § 8.º desse mesmo art. 535, que se o aludido pronunciamento do Supremo sobrevier ao trânsito em julgado da sentença exequenda, configura-se hipótese de cabimento da ação rescisória, “cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.

Por fim, admite-se outrossim que a Fazenda Pública, a teor do inc. VI do art. 535, alegue

“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença”.

Faz-se possível, pois, à executada invocar os efeitos modificativos ou extintivos produzidos por uma norma jurídica superveniente, seja de direito material, seja de direito processual, que tenha incidência sobre a eficácia do título judicial, objeto do cumprimento de sentença.

Assim, quando sobrevier direito atribuindo ao crédito executado efeito modificativo ou extintivo, ou ocorrer um fato, também posterior ao trânsito em julgado, que tenha o condão de modificar ou extinguir a prestação exigida – pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição (enfim, que coloque em crise a eficácia do título), poderá ser arguido na impugnação.

3. Impugnação parcial

Se a Fazenda Pública oferecer impugnação parcial, ou seja, abrangente apenas de uma parcela da quantia executada, em relação à parte intangida, resultando incontroversa, procede-se da forma especificada no § 4.º do art. 535, com a expedição do precatório no valor proporcional.

Nesse caso, como se observa, o montante não impugnado passa a ser objeto de cumprimento autônomo.

4. Ausência ou rejeição da impugnação

Não oferecida impugnação ou sendo ela rejeitada, com o respectivo trânsito em julgado, será expedido, por ordem do presidente do tribunal recursal competente, precatório em favor do exequente, sempre com observância do disposto no art. 100 da Constituição Federal, para ser pago na forma indicada em seu § 5.º.

Tratando-se, por outro lado, de requisição de pequeno valor, o próprio juiz da causa é que tem competência para determinar ao representante do órgão público executado o pagamento da obrigação, no prazo de dois meses, a partir do recebimento da requisição, “mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente” (art. 535, § 3.º, II).

NOTAS DE RODAPÉ

1

M. v., *DJe* 02.06.2016. Tenha-se presente, contudo, importante precedente sobre esta questão: STF, 2.ª T., Agr. Reg. no RE 852.302-AL, rel. Min. Dias Toffoli, v. u., *DJe* 29.02.2015: “1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do Estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”.

2

O art. 82 tinha a seguinte redação: “Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões que incorrerem no exercício dos seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos”. V., a respeito, Priscilla Petereit de Paola

Gonçalves, Responsabilidade civil do Estado: doutrina e jurisprudência na Primeira República, *Brasileiros e cidadãos* (obra coletiva), p. 439 ss.

3

V., e. g., Ord. Fil., 3.90.

4

Cabe lembrar que o novo CPC admite expressamente o ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública, quando o documento representativo do crédito, embora líquido e exigível, não ostentar o predicado da certeza (art. 700, § 6.º, CPC).

5

Leonardo Carneiro da Cunha, *Código de Processo Civil anotado*, AASP–OAB/PR.

6

Cf. Fernão Borba Franco, *Execução em face da Fazenda Pública*, p. 211.

7

Cf. Cassio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 418.

8

V. u., *DJ* 14.11.2005.

9

STJ, 5.ª T., REsp 490.228-RS, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, v. u., *DJ* 31.05.2004.

10

Rel. Min. Sepúlveda Pertence, m. v., *DJ* 10.12.2006. Cf., também, nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 422.

11

Leonardo Carneiro da Cunha, *Código de Processo Civil anotado*, AASP-OAB/PR. Tenha-se ainda presente a Súmula 345/STJ: “São devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.

Comentários ao CPC - v. VIII - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

CAPÍTULO VI. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA

Capítulo VI. Do cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer, de Não Fazer ou de Entregar Coisa

Seção I

Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer

Art. 536 . No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1.º Para atender ao disposto no *caput* , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2.º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3.º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4.º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5.º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Correspondência: art. 461, §§ 4.º e 5.º, do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 612 do CPC italiano, arts. 709 a 712 da LEC espanhola, arts. 868 e 876 do CPC português

1. Aspectos gerais

Adotando a mesma técnica que fora introduzida ao longo das múltiplas reformas do Código revogado, o novo diploma, em capítulo independente, regulamenta, de forma detalhada, o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa.

No que toca às prestações de fazer ou de não fazer, além da força do próprio comando contido no ato decisório, a lei processual autoriza o emprego de medidas atípicas, de cunho executivo,

inibitório ou coercitivo, que visam à satisfação integral do credor, ou seja, para lhe assegurar, em princípio, a concretização da tutela específica, ou, quando não, de resultado prático similar. Assim, por exemplo, o juiz que reconhece a exigibilidade de obrigação de não fazer, consistente na cessação de ruído nocivo à vizinhança de casa de espetáculo, tem a seu alcance um arsenal de meios que vai desde a fixação de multa até a determinação de lacração do estabelecimento do executado recalcitrante. Tais medidas atuam sobre a vontade do executado objetivando impeli-lo a adimplir a obrigação que emana do título judicial.

A propósito dessa temática, chamando a atenção para as dificuldades práticas da execução da tutela específica, vale transcrever esclarecedora síntese de Arruda Alvim, ao invocar a classificação que “subdivide as obrigações de fazer em *fungíveis* e *infungíveis* : naquelas, a prestação devida pode ser efetivada por terceiro em caso de inadimplemento do devedor, sem qualquer prejuízo à satisfação dos interesses do credor. Nessas, por outro lado, apenas a realização da conduta pelo próprio devedor é capaz de satisfazer o interesse do credor, seja em virtude da natureza da obrigação, seja porque as partes assim convencionaram. Por tal razão também são chamadas de obrigações *personalíssimas* ou *intuitu personae* . Diante do inadimplemento de uma obrigação de fazer fungível, é viável se cogitar da satisfação do direito do credor ainda que inexista qualquer colaboração do obrigado, por meio das chamadas medidas sub-rogatórias, em que a conduta do devedor é substituída pela de terceiro. Basta que o juiz autorize a realização da atividade por outrem, à custa do devedor, como, aliás, permite o art. 249 do Código Civil. Como exemplo, pode-se pensar na determinação de que, ante o inadimplemento de contrato de empreitada por parte da empreiteira, seja autorizado que outra empresa realize a obra, cabendo, àquela originalmente contratada, arcar com os respectivos custos, além de eventuais perdas e danos. O problema maior reside, todavia, nas obrigações de fazer infungíveis, em que a satisfação do direito do credor depende, necessariamente, da colaboração do devedor. Nestes casos, têm grande utilidade as medidas *coercitivas* , como a multa periódica (art. 537 CPC), que são impostas em desfavor do requerido com objetivo de pressioná-lo psicologicamente a realizar a conduta devida, sob pena de sofrer alguma espécie de gravame. Ainda assim, todavia, caso o obrigado opte por não realizar a prestação que lhe cabe, ficará frustrada a obtenção da tutela específica, restando, ao credor, o direito às perdas e danos”.¹

Como procurei esclarecer, ao ensejo da exegese do art. 497 do CPC, uma vez acolhida a pretensão do demandante, consubstanciada na imposição de prestação específica, o provimento judicial deve recair exatamente sobre o bem da vida a que se obrigou o réu. Desrespeitado o comando, entram em cena as denominadas “medidas ou providências de apoio”, incluindo-se entre elas os meios coercitivos de pressão a fim de que seja cumprido o dever então imposto ao demandado.

Daí porque a técnica coercitiva, como corolário ínsito à tutela específica, torna-se “primordial à certeza e à segurança do direito”. A legitimidade deste mecanismo processual sempre pressupõe: a) o reconhecimento do dever cuja observância ele visa a assegurar; e b) a proporcionalidade entre a medida de coerção e o valor jurídico que se busca proteger.²

Observa-se, pois, que a regra ora comentada prevê a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento do demandante, tomar providências tendentes ao cumprimento da sentença, quando, embora regular e validamente intimado, o executado deixa de acatar ordem judicial.

Aduza-se que apenas na hipótese de se tornar impossível alcançar a tutela específica ou o resultado prático equivalente, ou mesmo, quando o próprio credor preferir, é que então será convertida a obrigação em perdas e danos (art. 499 CPC), “caso em que, após a liquidação do valor destes (arts. 509 a 512 CPC) será seguido o procedimento das sentenças que reconhecerem a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (arts. 523 a 527 CPC)”.³

2. Medidas necessárias em prol do cumprimento da obrigação

Diante do inadimplemento injustificado, o § 1.º do art. 536 sugere alguns mecanismos que podem ser empregados pelo juiz, cuja tarefa é a de amoldá-los ao caso concreto, na confiante expectativa de conseguir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de resultado prático

equivalente.

Na verdade, estes meios aos quais o credor e o juiz podem recorrer constituem técnicas de tutela executiva, que não se encontram exauridas na apontada regra legal.

2.1. Fixação de multa

A primeira delas, de ampla incidência prática na atualidade, é a imposição de multa (*astreintes*) periódica ou estimada em valor fixo, dependendo da espécie de obrigação de fazer ou de não fazer, se de cumprimento instantâneo ou protraído no tempo.

Assinala, sobre o tema, Guilherme Rizzo Amaral,⁴ que “em relação à sistemática anterior, a única diferença está no ajuste de redação, retirando-se a expressão *por tempo de atraso* ao se tratar da multa. Tal se deve ao fato de que a multa pode ser estipulada tanto por tempo de atraso quanto em caráter fixo, a depender da natureza do descumprimento. Caso este se protraia no tempo, a multa há de ser periódica, de modo que o réu a todo o momento sofra pressão para cessar o descumprimento. Caso, contudo, estejamos diante de descumprimento imediato e irreversível (por exemplo, a não veiculação de matéria difamatória em telejornal ou a proibição de demolição de sobrado tombado pelo patrimônio histórico), a multa deverá incidir uma vez só, quando do descumprimento, devendo por isso ser fixada em valor unitário que supere significativamente o benefício econômico que o réu auferiria com o descumprimento da decisão”.

A despeito da possibilidade desta medida excepcional de coerção patrimonial, o seu respectivo deferimento norteia-se pelas garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Instada a enfrentar essa questão, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 758.048-RS, da relatoria do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu que, igualmente, em relação à constrição eletrônica de ativos financeiros: “deve prevalecer o princípio da menor onerosidade [art. 805], podendo ser invocado para relativizar o seu rigorismo, amoldando-o às peculiaridades do caso concreto”.

Em senso análogo, a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo de Instrumento 0070870-90.2011.8.26.0000, assentou, à unanimidade de votos, que deve ser repudiado “o bloqueio abrupto de numerário que, ante o elevado valor, caracterizaria inegável limitação à atividade da empresa, o que é vedado pelo inc. XIII do art. 5.º da Constituição Federal”.

Ademais, o débito decorrente da multa coercitiva imposta ao devedor, além de certo e líquido, deve ser exigível, *ex vi* do art. 537, §3.º, apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Em suma: qualquer iniciativa judicial abrupta e *inaudita altera parte* descortina-se visceralmente ilegal!

2.2. Busca e apreensão

Tratando-se de prestação consistente na entrega de determinada coisa ao credor, não sendo ela atendida no prazo fixado na sentença, pode ser exigida mediante cumprimento coercitivo, regido pelo art. 538 do CPC, aplicando-se, no que for compatível com o respectivo procedimento, as normas específicas sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC.

Inadimplida a obrigação, a medida que se presume mais eficaz é a busca e apreensão a ser executada por dois oficiais auxiliares do juízo (art. 536, § 2.º). Levando-se em consideração o princípio universal da inviolabilidade do domicílio⁵, a busca e apreensão poderá ser deferida, inclusive *inaudita altera parte*, apenas em situações excepcionais e sempre com redobrada cautela, exigindo-se que a decisão determinante da medida esteja devidamente fundamentada.

O mandado de busca e apreensão do objeto da obrigação deve seguir rigorosamente as

diretrizes especificadas no art. 846 do CPC, inserido em capítulo que disciplina a *Execução por quantia certa*, na seção que regulamenta a penhora. Ademais, para evitar qualquer atuação abusiva, em detrimento do direito do devedor, o mandado deve indicar com absoluta precisão o endereço da busca e o objeto a ser apreendido.

Se o executado impedir a efetividade da diligência, o juiz será informado pelos oficiais de justiça, que poderão solicitar-lhe o deferimento de ordem de arrombamento, inclusive com requisição de força policial, para a consumação da busca e da apreensão (art. 846, § 2.º).

Deferido o pleito, o local ou locais (“cômodos e móveis” na dicção legal) em que porventura se presuma encontrar-se o bem objeto da diligência poderão ser arrombados pelos oficiais. De tudo será lavrado auto circunstanciado, a ser assinado por duas testemunhas presenciais (§ 1.º).

Os oficiais de justiça, para complementarem a diligência, terão ainda a incumbência de certificar, de forma pormenorizada, todas as vicissitudes da diligência, em auto próprio (“auto da ocorrência”), lavrado em duas vias, uma destinada ao escrivão, para ser juntada nos autos e outra a ser enviada à autoridade policial, para a apuração de possível crime de desobediência ou de resistência (art. 846, § 3.º). Desse auto de ocorrência constará ainda o rol de testemunhas com a devida qualificação (§ 4.º).

2.3. Previsão de outras medidas atípicas

O art. 536, § 1.º, do CPC, como já frisado, ainda prevê, de forma exemplificativa, outras técnicas executivas, tais como a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, que podem incidir em hipóteses específicas, nas quais o executado venha a descumprir a ordem judicial, consistente em prestação de fazer ou de não fazer.

É o que se extrai de ilustrativo precedente da 2.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 403.190-SP, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, que, sobrelevando o interesse da coletividade, reconheceu a procedência de pedido, deduzido em ação civil pública, de remoção de pessoas e de demolição de obras realizadas em loteamento clandestino às margens da represa Billings, para cessar a degradação ambiental.⁶

Ademais, sob diferente enfoque, o art. 139, na linha de outras disposições do CPC, dilata os poderes do juiz na direção do processo. Na verdade, do ponto de vista dogmático, nada há de surpreendente nesta opção do legislador, uma vez que tal tendência tem caracterizado as legislações processuais mais modernas.

O Codice di Procedura Civile de 1942, marcado pela ideologia fascista, também outorgou amplos poderes ao juiz. Convocado pelo Ministro da Justiça Dino Grandi para proceder à revisão final do texto legal, Piero Calamandrei procurou conciliar os poderes discricionários do juiz nos quadrantes do princípio da legalidade, ao afirmar que não se deveria criticar a tomada de posição do diploma italiano, uma vez que a atuação judicial sempre estaria delimitada pelo princípio da legalidade. É dizer: o juiz pode muito, mas não pode tudo!

Com efeito, embora reforçados os poderes do órgão diretor do processo em nosso vigente diploma processual, encontram-se eles freados pelo contraditório e, em particular, pelo dever de motivação dos atos decisórios. Dentre as questões que têm suscitado atenção na praxe forense desponta aquela concernente à determinação de medidas coercitivas visando ao cumprimento das decisões judiciais.

Além das sanções típicas, expressamente disciplinadas no Código de Processo Civil, como, por exemplo, a imposição de astreintes, o art. 536, § 1.º, afina-se com a regra do art. 139, IV, que prevê a atipicidade dos meios executivos, como uma regra geral do sistema em prol da efetivação das decisões judiciais, ao dispor que: “*O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária*”.

E isso, porque em decorrência de novas exigências e do consequente aperfeiçoamento que permeia a ciência processual, os especialistas concluíram que o tradicional modelo da execução por meio de subrogação enseja, em muitas situações, enorme frustração ao credor vitorioso. E, por esta razão, já há alguns anos, a nossa melhor doutrina influenciou o legislador pátrio a adotar, com maior ênfase, a técnica da tutela específica, para satisfazer, de forma efetiva, o interesse do credor.

Assim, uma vez acolhida a pretensão do demandante, consubstanciada na imposição de prestação específica, o provimento judicial deve recair exatamente sobre o bem da vida a que se obrigou o réu. Desrespeitado o comando, entram em cena as denominadas “medidas ou providências de apoio”, incluindo-se entre elas os meios coercitivos atípicos de pressão, a fim de que seja cumprido o dever então imposto ao demandado.

Diante da recalcitrância do condenado, que não se curva de modo espontâneo, aos termos da decisão, o CPC atribui, pois, ao juiz, diante de uma determinada situação concreta, o poder de impor medida de coerção atípica, que possa propiciar o atendimento ao comando judicial.

A atuação judicial nesse sentido, no entanto, sempre deverá se desenvolver à luz das normas do devido processo legal, proporcionando ao obrigado, de forma incisiva, clara e expressa, as garantias da ampla defesa!

A questão interessante, que tem gerado acentuada polêmica em nosso meio jurídico, decorre da notícia de atos decisórios impositivos, como medida indutiva atípica, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da restrição ao passaporte e, outrossim, do cancelamento dos cartões de crédito do executado, até a comprovação do cumprimento da respectiva obrigação. E isso, independentemente da natureza do dever, inclusive na esfera de dívida alimentar e até mesmo de outras espécies de obrigação de pagar quantia certa.

Assim, como ocorre, por exemplo, nas situações nas quais se viabiliza a desconsideração da personalidade jurídica, tenho sustentado, após a devida reflexão, que tais medidas excepcionais procedem, desde que se possibilite ao obrigado o contraditório, facultando-lhe justificar as razões do descumprimento da sentença. E isso tudo, não apenas em homenagem ao *due process of law*, mas também em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e da regra da menor onerosidade, agora repetida no art. 805 do CPC.

Norteando-se, portanto, pela legalidade estrita, apenas depois de terem sido esgotados todos os meios executivos possíveis e de dar oportunidade à manifestação do executado, é que o juiz, com inarredável fundamentação, poderá então deferir aquelas providências atípicas, especialmente no campo das relações de direito de família. E tudo, no exame do caso concreto, sem olvidar a proporcionalidade entre o meio processual de coerção imposto e o valor jurídico que se busca proteger!

3. Configuração de litigância de má-fé e de crime de desobediência

Saliente-se, por outro lado, que é exatamente o comportamento recalcitrante, vale dizer, o descumprimento pelo devedor, de forma injustificada, da obrigação que lhe foi imposta, que determina, segundo previsão do § 3.º do art. 536 do CPC, a aplicação da sanção por litigância de má-fé ao executado, “sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência”.

Bem é de ver que, nesse particular, a imposição da penalidade ao *improbis litigator*, contemplada no art. 81 do CPC, já vem preestabelecida na própria lei, não ficando, portanto, a sua aplicação subordinada ao critério subjetivo do juiz: basta, para a respectiva incidência, que o inadimplemento do devedor seja injustificado!

4. Contraditório exercido por meio de oferta de impugnação

As regras que disciplinam o cumprimento da sentença impositiva de obrigação de pagar quantia certa também deverão nortear, subsidiariamente, os procedimentos especiais de cumprimento de título judicial atinentes às outras espécies de prestação.

É exatamente por esta razão que, v. g., o § 4.º do art. 536 estabelece: “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber”.

O novo CPC supre assim a lacuna existente no velho diploma, ao prever, de forma expressa, a possibilidade de o réu impugnar a pretensão executiva do exequente.⁷

Daí, porque, uma vez transcorrido o prazo de 15 dias sem que o executado tenha atendido à ordem judicial, disporá ele de igual prazo para apresentar, nos próprios autos, impugnação.

Assegura-se, assim, ao devedor a plenitude do contraditório, podendo arguir toda a matéria de defesa delineada no § 1.º do art. 525 do CPC.

5. Deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional

A derradeira regra do dispositivo ora comentado determina a sua aplicação, no que for possível, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional.

Mesmo sem haver um vínculo jurídico obrigacional com outro sujeito, há deveres de comportamento que são legalmente impostos a todos os membros da comunhão social, como, por exemplo, o dever de abstenção de atos que tipificam conduta criminosa, ou o dever de respeito ao direito de propriedade.

Como o direito material depende, sob a perspectiva da efetividade, do processo, é fácil concluir que a ação preventiva é consequência lógica das necessidades do direito material. Basta pensar, e.g., na regra que proíbe algum ato visando a proteger determinado direito, ou em direito que possui natureza absolutamente inviolável, como o direito à honra ou o direito ao meio ambiente. Tenha-se presente, aliás, que várias normas constitucionais garantem a inviolabilidade de direitos, exigindo, portanto, a correspondente tutela jurisdicional, que somente pode ser aquela destinada a evitar a violação.

Segue-se, pois, em tais hipóteses, o mesmo procedimento e as mesmas medidas atípicas regradados no art. 536 do CPC para inibir ou cessar a prática de tais atos, ou, ainda, para remover o ilícito, consistente, por exemplo, na emissão de fumaça poluente.⁸

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1.º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2.º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3.º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (redação dada pela Lei 13.256/2016)

§ 4.º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5.º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que

reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Correspondência: art. 461, §§ 4.º, 5.º e 6.º, do CPC/1973

Comparação jurídica: art. 711 da LEC espanhola, art. 868 do CPC português

1. Aspectos gerais

A multa, como medida coercitiva de natureza patrimonial, passou a ter reconhecida relevância na sistemática processual brasileira, sobretudo na esfera das obrigações de fazer infungíveis, a ponto de o novel legislador lhe dedicar, de forma particularizada, o texto legal aqui comentado, procurando eliminar as principais dúvidas suscitadas sob a vigência do CPC revogado.

Destaca-se, em primeiro lugar, a determinação de que a multa pode ser imposta independentemente de pedido da parte. E, assim também, o juiz encontra-se autorizado a agravá-la, quando considerada insuficiente para o fim a que se destina, reduzi-la ou, ainda, suprimi-la, na hipótese de o devedor ter adimplido parte da obrigação ou ter apresentado justificação plausível para o seu descumprimento (art. 537, § 1.º, I e II).

O juiz detém ainda o poder de revogar a incidência da multa quando se tornar impossível atender-se à ordem judicial. Esta, com efeito, a orientação dominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere, e.g., de julgamento da 4.ª Turma, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 431.294-RS, da relatoria do Ministro Raul Araújo, ao patentear que: “é cabível a aplicação de *astreintes* como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial”.⁹

Já quanto à sua oportunidade, a teor do art. 497 do CPC, ao deferir o pleito de antecipação de tutela ou reconhecer a procedência de pedido, atinente a uma obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz, de ofício ou provocado pelo autor, poderá determinar, no próprio ato decisório, eventual medida reputada adequada para que se cumpra a tutela específica. Nada obsta, portanto, que a multa já venha fixada na fase de conhecimento, seja na decisão antecipatória, seja na sentença. Não determinada a sua incidência nesse momento processual, o exequente poderá pleitear a aplicação da multa ou de outras medidas de reforço quando formular o pedido de cumprimento de sentença.

Pacificando outra celeuma, que chegou a ser debatida no Superior Tribunal de Justiça, o § 2.º do art. 537 dispõe, com todas as letras, que a multa fixada tem como beneficiário o exequente. É de ter-se presente, contudo, que esta regra não desfigura a natureza de técnica executiva da aplicação das *astreintes*, não se podendo admitir que tenha cunho indenizatório, até porque, como esclarece Arruda Alvim, esta perspectiva é de suma importância, “para a correta compreensão da possibilidade de majoração, redução, ou, mesmo, supressão da multa”.¹⁰

Cumprasse asseverar que, seguindo a orientação que prevalecia sob a vigência do CPC/1973, o atual diploma não admite, ao menos expressamente, a incidência de multa para a tutela da obrigação de pagar quantia certa. Embora a tese em sentido contrário, ancorada no art. 139, IV, e sustentada por segmento considerável da doutrina nacional,¹¹ convide à reflexão, mostra-se ela deveras discutível, diante do natural e interminável círculo vicioso que se criaria.

2. Critério norteador para a fixação da multa

A multa, como medida coercitiva, repercute sobre a vontade do executado, visando a forçá-lo, de forma indireta, a cumprir a prestação determinada na sentença. Mas é evidente que “o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica”.¹²

O *caput* do art. 537 dispõe que a multa deve ser “compatível com a obrigação”.

É certo, porém, que a multa goza de total autonomia em relação à obrigação principal, podendo ser cumulada com eventual multa contratual ou mesmo com indenização por perdas e danos.

À luz do critério da razoabilidade, o valor a ser fixado a título de multa deve considerar as condições subjetivas e objetivas da causa, não podendo ser nem incipiente, a gerar total ineficácia em relação ao escopo a que se destina, e tampouco exorbitante, capaz de distorcer o significado da examinada técnica processual de coerção.

Ao enfrentar esta questão, a 4.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 511.410-RJ, com voto condutor da Ministra Maria Isabel Gallotti, assentou que, embora, em princípio, faz-se inviável o reexame do contexto fático-probatório do processo, “é possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 CPC [1973]), quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que não ocorre no caso dos autos”.¹³

Em senso análogo, a 3.^a Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 615.051-PE, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, decidiu, à unanimidade de votos, que: “Em consonância com o art. 461, § 6.º, do CPC [1973], na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o valor da multa diária (*astreintes*) pode ser alterado quando se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. O exame da razoabilidade e proporcionalidade realizado acerca da fixação do valor de multa diária (*astreintes*) deve recair sobre o valor inicialmente fixado, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida, de modo a servir de estímulo ao cumprimento da obrigação. Na espécie, razoável se mostra a redução da multa diária para R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), mantida a correção monetária e os juros como fixados na origem, bem como o lapso temporal em que persistiu o descumprimento da tutela antecipatória deferida (de 06.02.2004 a 19.06.2004).”¹⁴

Resulta outrossim importante que, ao estipular as *astreintes* , o juiz estabeleça a periodicidade ou, dependendo da natureza da obrigação, uma multa fixa. Em qualquer hipótese, a respectiva decisão deve conceder ao executado um prazo razoável, adequado à situação concreta, para o cumprimento da prestação.

3. Momento de incidência da multa

Superando também divergência que persistia no regime anterior, preceitua o art. 537, § 4.º, do CPC, que a multa passa a ser devida desde o dia em que se constatar o inadimplemento da obrigação estabelecida no ato decisório, até quando for cumprido o comando judicial.

Na situação em que a multa for periódica, normalmente fixada por dia de atraso, o *dies a quo* de sua incidência é o primeiro dia após o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação.

Assim, intimado regularmente da decisão, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 513, § 2.º, I, do CPC, o executado dispõe de um prazo, geralmente 15 dias, para adimplir ou iniciar o adimplemento da prestação.¹⁵ Descumprida a determinação nesse lapso temporal, a multa terá incidência imediata.

Com isso, entende-se revogada a Súmula 410/STJ, que exigia a intimação pessoal do devedor, para que a multa pudesse incidir.¹⁶

4. Exigibilidade da multa

O novo CPC recepcionou posicionamento pretoriano que admitia a execução autônoma e imediata do montante devido a título de multa. O art. 537, § 3.º, autoriza o cumprimento provisório desta dívida, mas condiciona o levantamento de qualquer quantia ao trânsito em julgado da sentença favorável ao exequente.

Ressalta, a propósito, Guilherme Rizzo Amaral que, desse modo, “o legislador esclarece de uma vez por todas que o crédito resultante da incidência da multa somente será definitivamente devido à parte caso a obrigação a cujo cumprimento a multa estiver a serviço venha a ser reconhecida em caráter definitivo pela sentença”, porque, diferentemente da regra geral para as execuções provisórias, que admite a prestação de caução idônea, na execução provisória da multa, o valor depositado somente poderá ser levantado ao ensejo do trânsito em julgado. Ademais, “transitando em julgado sentença (ou acórdão) de *improcedência*, o crédito resultante da incidência da multa extingue-se, independentemente de ter havido incidência anterior da multa por descumprimento de decisão interlocutória ou final”.¹⁷

Por fim, entendo que a mesma orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao cabimento de atualização monetária da soma devida a título de multa, remanesce sob a vigência do novo CPC, valendo, portanto, em todos os seus aspectos, o precedente construído no julgamento da 3.^a Turma, no Recurso Especial 1.327.199-RJ, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, com a seguinte fundamentação: “A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4.º do art. 461 do CPC [1973] incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4.º do art. 461 do CPC [1973], deve ser preservado ao longo do tempo – e, portanto, corrigido – a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4.º do art. 461 do CPC [1973] deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar *bis in idem*.”¹⁸

5. Deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional

Incorrendo em flagrante pleonismo, o § 5.º do art. 536 do CPC encontra-se repetido *ipsis litteris* no subsequente art. 537, § 5.º. Tudo quanto escrito naquele comentário presta-se a interpretar o presente texto legal, sobretudo no que se refere ao emprego de multa coercitiva como importante mecanismo para induzir o executado a cumprir um dever que lhe é imposto.

Seção II

Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1.º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2.º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

§ 3.º Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Correspondência: art. 461-A do CPC/1973

Comparação jurídica: arts. 605 a 608 do CPC italiano, arts. 701 a 703 da LEC espanhola, arts. 859 a 862 do CPC português

1. Aspectos gerais

Como acima esclarecido, inadimplida a obrigação de entregar determinado bem ao credor, no prazo fixado na sentença, torna-se possível exigi-la por meio de cumprimento coercitivo, disciplinado no art. 538, aplicando-se, no que for compatível com o respectivo procedimento, as regras específicas sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537.

A rigor, não houve alteração substancial desta técnica, anteriormente regradada no § 3.º do art. 461 do CPC/1973.

Importa também deixar claro que, a despeito da diferença conceitual, no plano do direito material, entre direitos reais e direitos pessoais, no que concerne à sua exigência judicial, não se verificam discrepâncias entre os direitos que decorrem de obrigação de entregar coisa e os direitos absolutos, uma vez que, em nosso sistema processual, as técnicas predispostas para ambas as situações são as mesmas, cabendo ao juiz buscar meios para retirar o bem da posse do executado e efetivamente entregá-lo ao exequente.

É verdade, contudo, que, na esfera da obrigação de entrega de coisa, não se depara com certos obstáculos inerentes às obrigações de fazer e não fazer, que advém da possibilidade de o executado se recusar, de forma peremptória, a efetivar a prestação que lhe toca, sendo então necessária a adoção de medidas sub-rogatórias, visando a substituir a atuação do devedor inadimplente.¹⁹

Ademais, o regime do cumprimento de sentença na situação ora analisada deve ser complementado pelo art. 498 do CPC, tendo-se presente que, na esfera de tutela específica, consistente na entrega da coisa objetivada pelo demandante, a decisão deverá conceder determinado prazo para que o réu possa adimplir a obrigação.

Tratando-se de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o parágrafo único do novo art. 498, aperfeiçoando a redação do § 1.º do revogado art. 461-A, coerente com a exigência de que o pedido deve ser determinado (art. 324, impõe ao autor, cabendo-lhe a escolha, o ônus de individualizar, com a devida precisão, o bem pretendido.

Lembre-se que o art. 498 do CPC refere-se à coisa incerta, indicada apenas pelo gênero e pela quantidade ao ensejo da celebração do negócio (art. 243 do CC), que se torna determinada por escolha no momento do pagamento. Coisa incerta, portanto, é aquela sujeita a determinação futura.

Tornando-se impossível a entrega da coisa, seja pelo seu perecimento, seja por outra razão justificável, deve-se buscar o resultado prático equivalente, pela substituição por coisa similar, que satisfaça o credor, ou, então, em último caso, a requerimento do interessado, pela reparação em perdas e danos (art. 499).

Pois bem, descumprida a prestação no prazo e forma fixados na sentença para a entrega da coisa pretendida, a lei autoriza a efetivação de meios coercitivos, devendo ser expedido mandado de busca e apreensão ou mandado de imissão na posse, dependendo da natureza do bem, se móvel ou imóvel.

Anote-se, com Arruda Alvim, que não são estas as únicas técnicas admissíveis no cumprimento de sentença atinente à obrigação de entrega de coisa, uma vez que o art. 139, IV, CPC, prevê a atipicidade dos meios executivos, “como princípio geral do sistema de efetivação das decisões judiciais”.²⁰

Aplicam-se, também, *ex vi* do disposto no § 3.º do art. 538, as medidas previstas para o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, como, por exemplo, a fixação de multa coercitiva independentemente de requerimento do exequente (art. 537).

2. Retenção por benfeitorias

Primando pelo cunho didático, preceitua o § 1.º do art. 538, que o demandado tem o ônus de

alegar a existência de benfeitorias necessárias e úteis, por ele introduzidas no bem que possui, na fase de conhecimento, mais precisamente, ao ensejo da contestação. Mas não basta apenas a informação de que há benfeitorias indenizáveis. É necessário que as especifique de forma pormenorizada, com a atribuição, desde que possível, do valor de cada uma delas, inclusive com a produção da prova de que foram por ele erigidas.

Caso o réu cumpra tal determinação legal, tem o direito de reter a coisa, segundo os arts. 1.219 e 1.222 do Código Civil, até que lhe sejam devidamente indenizadas.

No entanto, deixando de arguir a existência de tais benfeitorias no momento processual oportuno, a questão restará preclusa, não podendo ser suscitada na fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, sufragando exatamente esta orientação, teve oportunidade de manifestar-se a 2.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 385.662-DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, ao decidir que: “O acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que, tratando-se de ação de reintegração de posse – como no caso dos autos –, o pedido de retenção das benfeitorias deve ser formulado no processo de conhecimento, no bojo da própria contestação (CPC [1973], art. 922), sob pena de preclusão.” ²¹

NOTAS DE RODAPÉ

1

Arruda Alvim, *Novo contencioso cível no CPC/2015*, p. 398.

2

Cf. Talamini, *Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer*, p. 34.

3

Arruda Alvim, *Novo contencioso cível no CPC/2015*, p. 400.

4

Guilherme Rizzo Amaral, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.401.

5

O art. 5.º, XI, da CF, preceitua que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

6

V. u., *DJ* 14.08.2006.

7

Cf., também, Guilherme Rizzo Amaral, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.402.

8

Cf., por todos, Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito*, Academia Brasileira de Direito Processual Civil, disponível em [www.abdpc.org.br]: “Quando a tutela inibitória objetiva evitar um fazer, o ideal é o uso da multa como medida destinada a convencer o demandado a não praticar o ato temido. Entretanto, não se descarta a possibilidade de utilização de medida de execução direta para impedir a prática de ilícito. Pense-se na nomeação de administrador para atuar no seio de uma pessoa jurídica com o objetivo de impedir a violação de direito. No caso em que se teme a repetição de uma omissão, a multa, em princípio, também é mais eficaz do que a execução direta. De qualquer maneira, diante da situação concreta, o juiz poderá optar por uma medida de execução direta para garantir o fazer, e assim impedir o ilícito omissivo”.

9

V. u., *DJe* 03.12.2014. Em senso análogo: STJ, 3.^a T., REsp 1.230.174-PR, rel. Min. Nancy Andrighi, v. u., 13.12.2012: “Revelando-se impossível o cumprimento específico da obrigação, esta se converte em perdas e danos, afastando-se a incidência da multa cominatória do art. 461, § 4.º, do CPC [1973]”.

10

José Manoel de Arruda Alvim, *Novo contencioso cível no CPC/2015*, p. 401.

11

V., a respeito, dentre outros, Luiz Guilherme Marinoni, *A efetividade da multa na execução da sentença que condena a pagar dinheiro*, disponível em: [www.egov.ufsc.br]; Guilherme Rizzo Amaral, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.405. Confira-se, em sentido contrário, Eduardo Talamini, *Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer*, p. 465 ss.

12

STJ, 2.^a S., REsp 1.512.647-MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v. u., *DJe* 05.08.2015.

13

V. u., *DJe* 25.04.2016.

14

DJe 01.03.2016. Consulte-se, ainda, STJ, AgRg no AREsp 787.425-SP, 4.^a T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v. u., *DJe* 21.03.2016: “a jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art. 461, § 6º, do CPC[1973], pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos

parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido”; EDcl no AgRg no AREsp 726.554-BA, 1.ª T., rel. Min. Sérgio Kukina, v. u., *DJe* 02.06.2016.

15

V., já sob a vigência do CPC/2015: STJ, AgRg no REsp 1.548.553-RJ, 1.ª T., rel. Min. Sérgio Kukina, *DJe* 27.04.2016.

16

Cf. Guilherme Rizzo Amaral, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.407.

17

Guilherme Rizzo Amaral, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 1.408.

18

V. u., *DJe* 02.05.2014.

19

Cf. Arruda Alvim, *Novo contencioso cível no CPC/2015*, p. 410.

20

Arruda Alvim, *Novo contencioso cível no CPC/2015*, p. 411.

21

V. u., *DJe* 06.04.2015.

Referências bibliográficas

ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. O conceito de terceiro no processo civil, *Revista da Faculdade de Direito da USP*, 99, 2004.

ACIERNO, Maria. La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2012.

ALEXY, Robert e DREIER, Ralf. Precedent in the Federal Republic of Germany, *Interpreting Precedents – A Comparative Study*, obra coletiva dir. Neil MacCormick e Robert Summers, Adershot: Ashgate, 1997.

_____. *Teoria da argumentação jurídica*, tr. port. Zilda Hutchinson Schild Silva, São Paulo: Landy, 2001.

ALMADA, Roberto José Ferreira de. *A garantia processual da publicidade*, coord. Bedaque e Cruz e Tucci, São Paulo: Ed. RT, 2005.

ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. *Direito judiciário brasileiro*, 2. ed., Rio de Janeiro, Tip. Baptista de Souza, 1918.

AMARAL, Guilherme Rizzo. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier *et alii*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, *Revista dos Tribunais*, 300, 1960.

ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de. *Abandono da causa no novo Código de Processo Civil*, *Revista Forense*, 254, 1976.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008. vol. 4.

_____. *Sobre os limites objetivos da apelação civil*, São Paulo, tese de titularidade, Faculdade de Direito da USP, 1986.

ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. *Curso de processo civil*, São Paulo: Ed. RT, 2007. vol. 3: execução.

ARMELIN, Donaldo. Observância à coisa julgada e enriquecimento ilícito – postura ética e jurídica dos magistrados e advogados, *Cadernos do Centro de Estudos Judiciários*, Conselho da Justiça Federal, 23, Brasília, 2003.

ARRUDA ALVIM, Eduardo. *Direito processual civil*, 2. ed., São Paulo, Ed. RT, 2008.

ARRUDA ALVIM, José Manoel de. *Manual de direito processual civil*, 6. ed., São Paulo: Ed. RT, 1997. vol. 2.

_____. *Novo contencioso cível no CPC/2015*, São Paulo: Ed. RT, 2016.

- ASSIS, Araken de. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1999. vol. 6.
- _____. *Cumulação de ações*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1995.
- _____. *Da natureza jurídica da sentença sujeita a recurso*, Doutrina e prática do processo civil contemporâneo, São Paulo: Ed. RT, 2001.
- _____. *Manual da execução*, 18. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016.
- ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. O trato das relações jurídicas continuadas no NCPC, uma oportunidade perdida, *Novo CPC e o processo tributário*, obra coletiva coord. Antonio Carlos F. de Souza Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, São Paulo: Focofiscal, 2015.
- ATYIAH, P. *An Introduction to the Law of Contract*, 5. ed., Oxford: Clarendon, 2000.
- _____; SUMMERS, R. *Form and Substance in Anglo-American Law*, Oxford: Clarendon, 2002 (reed.).
- ÁVILA, Humberto. *Segurança jurídica no direito tributário*, São Paulo: Malheiros, 2014.
- AZEVEDO, Luiz Carlos de; CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Lições de história do processo civil romano*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____; _____. *Lições de processo civil canônico*, São Paulo: Ed. RT, 2001.
- AZEVEDO, Philadelpho de. *Um triênio de judicatura*, São Paulo: Max Limonad, 1955. vol. 3.
- BARBI, Celso Agrícola. *Ação declaratória principal e incidente*, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro, *Temas de direito processual*, 1.^a série, São Paulo: Saraiva, 1977.
- _____. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito, *Revista Brasileira de Direito Processual*, 16, 1978.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008. vol. 5.
- _____. Correlação entre o pedido e a sentença, *Revista de Processo*, 83, 1996.
- _____. *Direito processual civil – ensaios e pareceres*, Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.
- _____. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada, *Ajuris – Revista da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul*, 28, 1983; *Temas de direito processual*, 3.^a série, São Paulo: Saraiva, 1984.
- _____. Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. *Temas de direito processual*, 2.^a série, São Paulo: Saraiva, 1980.
- _____. O futuro da justiça: alguns mitos, *Temas de direito processual*, 8.^a série, São Paulo: Saraiva, 2004.
- _____. O novo Código Civil e o direito processual, *Revista Síntese de direito civil e processual civil*, 19, 2002.
- _____. *Questões prejudiciais e coisa julgada*, tese, Rio de Janeiro, 1967.
- _____. Solidariedade ativa: efeitos da sentença e coisa julgada na ação de cobrança proposta por um único credor, *Revista do Advogado*, n. 84, AASP, 2005.
- BAZILONI, Nilton Luiz de Freitas. *A coisa julgada nas ações coletivas*, São Paulo: Juarez de

Oliveira, 2004.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et alii, São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. Discricionariedade judicial, *Revista Forense*, vol. 354, 2001.

_____. *Efetividade do processo e técnica processual*, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2010.

_____. Os elementos objetivos da demanda examinados à luz do contraditório, *Causa de pedir e pedido no processo civil (questões polêmicas)*, coord. Cruz e Tucci e Bedaque, São Paulo: Ed. RT, 2002.

_____. *Poderes instrutórios do juiz*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011.

_____. *Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização)*, São Paulo: Malheiros, 1998.

BENETI, Sidnei Agostinho. Desconsideração da sociedade e legitimidade ad causam: esboço de sistematização, *Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins* (obra coletiva), coord. Fredie Didier Júnior e Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Ed. RT, 2004.

BETTI, Emilio. *D. 42.1.63 – Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Macerata: Tip. Bianchini, 1922.

BONACCORSO, Liborio C. *Il giudicato civile*, Napoli: Jovene, 1955.

BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio. *A autoridade da coisa julgada e a imutabilidade da motivação da sentença*, São Paulo, tese, 1963.

_____. *Coisa julgada*, São Paulo: Forense, 2004.

_____. *Teses, estudos e pareceres de processo civil*, São Paulo: Ed. RT, 2005. vol. 2.

BRAGA, Paula Sarno; DIDIER JÚNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael. *Curso de direito processual civil*, 2, 10. ed., Salvador: JusPodivm, 2015.

BUENO, Cassio Scarpinella, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et alii, São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. *Curso sistematizado de direito processual civil*, 2, 7. ed., São Paulo, Saraiva, 2014. t. 1.

_____. *Execução provisória e antecipação da tutela*, São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. *Manual de direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 2015.

_____. *Novo Código de Processo Civil anotado*, São Paulo: Saraiva, 2015.

_____. *Partes e terceiros no processo civil brasileiro*, São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. *Projetos de novo Código de Processo Civil comparados e anotados*, São Paulo: Saraiva, 2014.

BUSTAMANTE, Thomas da Rosa. *Teoria do precedente judicial*, São Paulo: Noeses, 2012.

BUZAID, Alfredo. *A ação declaratória no direito brasileiro*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1986.

_____. *Da apelação ex-officio no sistema do Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 1951.

_____. *Uniformização da jurisprudência*, *Ajuris*, 34, 1985.

- CABRAL, Antonio do Passo. *Convenções processuais*, Salvador: JusPodivm, 2016.
- CADIET, Loïc. Les conventions relatives au procès en droit français. Sur la contractualisation du règlement des litiges, Accordi di parti e processo – suplemento da *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2008.
- CALAMANDREI, Piero. Appunti sulla sentenza come fatto giuridico, *Rivista di diritto processuale civile*, 1932.
- _____. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 4. ed. (rist.), Milano: Ponte alle Grazie, 2012.
- _____. La genesi logica della sentenza civile, *Opere giuridiche*, Napoli: Morano, 1965. vol. 1.
- _____. Processo e democrazia, *Opere giuridiche*, Napoli: Morano, 1965. vol. 1.
- CAMPOS, Ronaldo Cunha. *Limites objetivos da coisa julgada*, São Paulo, Leud, 1976.
- CANARIS, Claus-Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*, trad. A. Menezes Cordeiro, 2. ed., Lisboa: Fundação C. Gulbenkian, 1996.
- CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali, Accordi di parti e processo – suplemento da *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2008.
- CAPPELLETTI, Mauro; VIGORITI, Vincenzo. Fundamental guarantees of the litigants in civil proceedings: Italy, *Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation*, Milano: Giuffrè, 1973.
- _____. *Le grandi tendenze evolutive del processo civile nel diritto comparato*, Processo e ideologie, Bologna, Mulino, 1969.
- CARDOZO, Benjamin Nathan. *A natureza do processo judicial*, 3. ed., tr. port. Lêda Boechat Rodrigues, Porto Alegre: Ajuris, 1978.
- CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo*, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2009.
- CARNEIRO, Athos Gusmão. *Intervenção de terceiros*, 12. ed., São Paulo: Saraiva, 2001.
- CARNELLUTI, Francesco. Capo di sentenza, *Rivista di diritto processuale civile*, 1933.
- _____. *Diritto e processo*, Napoli: Morano, 1958.
- _____. Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale, *Rivista di diritto processuale*, 1948.
- _____. *Intorno al progetto preliminare del Codice di Procedura Civile*: Milano: Giuffrè, 1937.
- _____. *Istituzioni del processo civile italiano*, 5. ed., Roma: Foro Italiano, 1956. vol. 1.
- _____. *La prova civile – parte generale: il concetto giuridico della prova*, Roma: Athenaeum, 1915.
- _____. La sentenza condizionale, *Studi di diritto processuale*, 1, Padova: Cedam, 1925.
- _____. La transazione è un contratto?, *Rivista di diritto processuale*, 1953.
- _____. Mutamento della legge in tema di prescrizione, *Rivista di diritto processuale*, 1952.
- _____. *Sistema di diritto processuale civile*, 1, Padova: Cedam, 1936.
- _____. *Sistema di diritto processuale civile*, 3, Padova: Cedam, 1939.
- CARVALHO, Milton Paulo de. *Do pedido no processo civil*, Porto Alegre: Sérgio Fabris-FIEO, 1992.
- CAVALCANTI FILHO, Theophilo. *O problema da segurança no direito*, tese, São Paulo, 1964.

CHIASSONI, Pierluigi. Il precedente giudiziale: tre esercizi di disincanto, *Analisi e diritto*, Firenze, 2004.

CHIOVENDA, Giuseppe. Dell'azione nascente dal contratto preliminare, *Saggi di diritto processuale civile*, Roma: Foro Italiano, 1930. vol. 1.

_____. *Instituições de direito processual civil*, 2. ed., tr. port. J. Guimarães Menegale, São Paulo, Saraiva, 1965. vol. 1 e 2.

_____. *Principii di diritto processuale civile*, 3. ed., Napoli: Jovene, 1923.

_____. Sulla cosa giudicata, *Saggi di diritto processuale civile*, Roma: Foro Italiano, 1931. vol. 2.

CHIZZINI, Augusto. Sentenza nel diritto processuale civile, *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, 18, 4. ed., Torino, Utet, 2008.

COLESANTI, Vittorio. Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, *Rivista di diritto processuale*, 1975.

COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. *La motivación de las sentencias*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.

COMOGLIO, Paolo. Giustizia (non) a tutti i costi. Significativo “update” delle *Civil Procedure Rules* inglesi e suggestioni sistematiche per la riforma del processo civile, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014.

CONSOLO, Claudio. *Dieci anni di riforme della giustizia civile (la trattazione della causa nella fase introduttiva del processo)*, Rassegna Forense, 2001.

CORREIA, Eduardo. *Parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre o art. 653 do Projeto de alteração do CPC*, Boletim da Faculdade de Direito, 37, Coimbra, 1961.

COSTA, Moacyr Lobo da. *A revogação da sentença*, São Paulo: Edusp-Ícone, 1995.

_____. *Confissão e reconhecimento do pedido*, São Paulo: Saraiva, 1983.

_____. *Cumulação de juízos na ação rescisória*, separata, São Paulo, 1986.

_____. Sentença condicional, *Revista de direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1960. vol. 1,

COSTA, Susana Henriques da. *Condições da ação*, São Paulo: Quartier Latin, 2005.

COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del derecho procesal civil*, 3. ed., Buenos Aires: Depalma, 1966.

CRUZ E TUCCI, José Rogério; AZEVEDO, Luiz Carlos de. *Lições de história do processo civil romano*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____; _____. *Lições de processo civil canônico*, São Paulo: Ed. RT, 2001.

_____; TUCCI, Rogério Lauria. *Constituição de 1988 e processo*, São Paulo: Saraiva, 1989.

_____. Abandono do processo, *Temas polêmicos de processo civil*, São Paulo: Saraiva, 1990.

_____. *Ação monitoria*, 3. ed., São Paulo; Ed. RT, 2001.

_____. *A causa petendi no processo civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2009.

_____. A fenomenologia da coisa julgada no pensamento de Botelho de Mesquita, *Processo civil – Homenagem a José Ignacio Botelho de Mesquita* (obra coletiva), coord. José Rogério Cruz e Tucci, Walter Piva Rodrigues e Rodolfo Costa Manso Real Amadeo, São Paulo: Quartier Latin, 2013.

- _____. Ainda sobre a nulidade da sentença imotivada, *Temas polêmicos de processo civil*, São Paulo: Saraiva, 1990.
- _____. *A motivação da sentença no processo civil*, São Paulo: Saraiva, 1987.
- _____. *Desistência da ação*, São Paulo: Saraiva, 1988.
- _____. Direito processual civil inglês, *Direito processual civil europeu* (obra coletiva), São Paulo: Lex, 2010.
- _____. Duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), *O advogado, a jurisprudência e outros temas de processo civil*, São Paulo: Quartier Latin, 2010.
- _____. Garantia da prestação jurisdicional sem dilações indevidas como corolário do devido processo legal, *Devido processo legal e tutela jurisdicional*, São Paulo: Ed. RT, 1993.
- _____. Hipoteca judiciária e devido processo legal, *Revista Forense*, 341, 1998.
- _____. *Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil*, São Paulo: Ed. RT, 2006.
- _____. *Precedente judicial como fonte do direito*, São Paulo: Ed. RT, 2004.
- _____. Sobre a eficácia preclusiva da decisão declaratória de saneamento, *Temas polêmicos de processo civil*, São Paulo: Saraiva, 1990.
- _____. *Tempo e processo. Uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual (civil e penal)*, São Paulo: Ed. RT, 1997.
- CUETO RUA, Julio. *Fuentes del derecho*, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JÚNIOR, Fredie. *Curso de direito processual civil*, 3, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016.
- _____. *A atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil*, Coimbra: Almedina, 2012.
- _____. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier *et alii*, São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. *Código de Processo Civil anotado*, AASP-OAB/PR, 2015.
- DALL'AGNOL JÚNIOR, Antonio Janyr. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2007. vol. 2.
- _____. *Da desistência do processo*, *Ajuris*, 19, 1980.
- DE FRANCISCI, Pietro. *La prova giudiziale* (a proposito di Gellio, *N. A.*, 14.2), *Helikon*, 4, 1961.
- DENTI, Vittorio. L'interpretazione della sentenza civile, *Studi delle scienze giuridiche e sociali*, Pavia: A. Garzanti, 1946. t. 28.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Princípios do processo judicial no processo administrativo, *Revista Conjur*, 2015.
- DIAS, Maria Berenice. Execução dos alimentos e as reformas do Código de Processo Civil, *Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil*, 16, 2007.
- DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Curso de direito processual civil*, 3, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016.
- _____; OLIVEIRA, Rafael Alexandre de; BRAGA, Paula Sarno. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Gen/Forense,

2015.

_____.; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandre de. *Curso de direito processual civil*, 2, 10. ed., Salvador, JusPodivm, 2015.

_____. *Curso de direito processual civil*, 5, 2. ed., Salvador: JusPodivm, 2010.

_____. Extensão da coisa julgada à resolução da questão prejudicial incidental no novo CPC brasileiro, *Civil Procedure Review*, 6, 2015.

_____. *Pressupostos processuais e condições da ação*, São Paulo: Saraiva, 2005.

_____. *Regras processuais no novo Código Civil*, São Paulo: Saraiva, 2004.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Capítulos da sentença*, 4. ed., São Paulo: Malheiros, 2009.

_____. *Instituições de direito processual civil*, 2 e 3, 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2009.

_____. *Instituições de direito processual civil*, 4, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2009.

_____. *Intervenção de terceiros*, 2. ed., São Paulo: Malheiros, 2000.

_____. *Nova era do processo civil*, São Paulo: Malheiros, 2003.

_____. Relativizar a coisa julgada material, *Revista da Escola Paulista da Magistratura*, 2, 2001; *Revista de Processo*, 109, 2003.

_____. Súmulas vinculantes, *Revista Forense*, 347, 1999.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro, Direito das coisas*, 10. ed., São Paulo: Saraiva, 1995. vol. 4.

DUFF, P. W. Non liquet, *Butterworths South African Law Review*, Durban, 1956.

EVANGELISTA, Stefano. Motivazione della sentenza civile, *Enciclopedia del diritto*, 27, 1977.

FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. *A ação declaratória incidental*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995.

FAIRÉN GUILLÉN, Victor. Los principios procesales de oralidad y de publicidad general y su carácter técnico o político, *RDPrIA*, 1975 (2-3).

_____. Un proceso actual, oral, concentrado y económico: el del Tribunal de las Aguas de Valencia, *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, Milano: Giuffrè, 1979. vol. 4.

FAZZALARI, Elio. *Istituzioni di diritto processuale*, 4. ed., Padova: Cedam, 1986.

FELÍCIO, Virgílio Mattos. *As nulidades no novo Código de Processo Civil*, Belo Horizonte: Del Rey, 2015.

FERNANDES, Sérgio Ricardo de Arruda. Alguns aspectos da coisa julgada no direito processual civil brasileiro, *Revista de Processo*, 62, 1991.

FERRI, Corrado. *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova: Cedam, 1975.

FONS RODRÍGUEZ, Carolina. *La acumulación objetiva de acciones en el proceso civil*, Barcelona: J. M. Bosch, 1998.

FORNACIARI JÚNIOR, Clito. *Reconhecimento jurídico do pedido*, São Paulo: Ed. RT, 1977.

FORNACIARI, Mario Alberto. *Transacción. Modos anormales de terminación del proceso*, Buenos

Aires: Depalma, 1988. t. 2.

FRANÇA, Rubens Limongi. Jurisprudência, *Enciclopédia Saraiva do Direito*, 47, 1980.

_____. *O direito, a lei e a jurisprudência*, São Paulo: Ed. RT, 1974.

FRANCO, Fernão Borba. *Execução em face da Fazenda Pública*, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.

FREITAS, José Lebre de. *Introdução ao processo civil – conceito e princípios gerais à luz do Código revisto*, 3. ed., Coimbra: Coimbra Ed., 2013.

GABBA, Carlo Francesco. *Teoria della retroattività delle leggi*, 2. ed., Torino: Unione Tip. Ed., 1884. vol. 1.

GALGANO, Francesco. Il precedente giudiziario in civil law, *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna: Zanichelli, 1999.

GALLARDO, Alma Wilson. *Del abandono del proceso*, Santiago de Chile: Jurídica, 1962.

GARBAGNATI, Edoardo. *La sostituzine processuale nel nuovo Codice di Procedura Civile*, Milano: Giuffrè, 1942.

_____. Questioni preliminari di merito e parti della sentenza, *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, Milano: Giuffrè, 1979. vol. 3.

GARCÍA ARÁN, Mercedes. *La prevaricación judicial*, Madrid: Tecnos, 1990.

GASCÓN ABELLÁN, Marina. *La técnica del precedente y la argumentación racional*, Madrid: Tecnos, 1993.

GHIRGA, Maria Francesca. Le novità sul calendario del processo: le sanzioni previste per il suo mancato rispetto, *Rivista di diritto processuale*, 2012.

GIMENO SENDRA, Vicente. *Constitución y proceso*, Madrid: Tecnos, 1988.

GODINHO, Robson. *Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

GONÇALVES, Priscilla Petereit de Paola. Responsabilidade civil do Estado: doutrina e jurisprudência na Primeira República, *Brasileiros e cidadãos* (obra coletiva), org. Gladys Sabina Ribeiro, São Paulo: Alameda, 2008.

GÖNNER, Nicolaus T. *Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses*, 2. ed., Erlangen, 1804. vol. 1.

GORLA, Gino. Precedente giudiziale, *Enciclopedia giuridica treccani*, 1990. vol. 23.

GOTTWALD, Peter; ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz. *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München, C. H. Beck, 2010.

GRANDE SEARA, Pablo. *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2008.

GRECO, Leonardo. As novas perspectivas da efetividade e do garantismo processual, *Processo civil – Estudos em homenagem ao Professor Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira*, coord. Daniel Mitidiero e Guilherme Rizzo Amaral, São Paulo: Atlas, 2012.

GRILLO LONGORIA, Rafael. *Derecho procesal civil – I* (Teoría general del proceso civil), 2. ed., Habana: Pueblo y Educación, 1986.

- GRINOVER, Ada P.; LUCON, Paulo H. dos Santos; CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Em defesa das inovações introduzidas no novo CPC*, Consultor Jurídico, 2015.
- _____. *Limites objetivos da coisa julgada*, Informativo Incijur, 10, 2000.
- GRZYBEK, Patrick. *Prozessuale Grundrechte im Europäischen Gemeinschaftsrecht*, Baden-Baden: Nomos, 1993.
- GUIMARÃES, Luiz Machado. Carência de ação, *Estudos de direito processual civil*, Rio de Janeiro: Ed. Jur. e Univ., 1969.
- _____. *Limites objetivos do recurso de apelação*, Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, 1961.
- GUIMARÃES, Mário. *O juiz e a função jurisdicional*, Rio de Janeiro: Forense, 1958.
- GURVICH, M. A. Profili generali del processo civile sovietico, *Ricerche sul processo – 1. Il processo civile sovietico*, Padova: Cedam, 1976.
- HABSCHEID, Walter J. *Introduzione al diritto processuale comparato*, Rimini: Maggioli, 1985.
- HÉRON, Jacques. *Droit judiciaire privé*, Paris: Montchrestien, 1991.
- HOFF, Luiz Alberto. A hipoteca judiciária e sua importância como instrumento de garantia, *Revista dos Tribunais*, vol. 674, 1991.
- IHERING, Rudolf von. Des effets réflexes ou de la réaction exercée sur les tiers par les faits juridiques, *Études complémentaires de l'esprit du droit romain*, 5-9, tr. fr. Octave de Meulenaere, Paris: Libr. A. Maresq, 1903. t. 4.
- J. PELÁEZ, Francisco. *La transacción: su eficacia procesal*, Barcelona: Bosch, 1987.
- JOLOWICZ, J. A. The Active Role of the Court in Civil Litigation, *Public Interest Parties and the Active Role of the Judge in Civil Litigation*, Milano/New York: Giuffrè-Oceana, 1975.
- JORGE, Nuno de Lemos. Notas sobre o regime processual experimental, *Novas exigências do processo civil* (obra coletiva), Coimbra: Coimbra Ed., 2007.
- JUSTEN FILHO, Marçal; TALAMINI, Eduardo; MOREIRA, Egon Bockmann. Sobre a hipoteca judiciária, *Revista de Processo*, 1997. vol. 85.
- KAUFMANN, Arthur. *Filosofía del derecho*, tr. cast. Luis Villar Borda e Ana Maria Montoya da 2. ed. alemã de 1997, Bogotá: Univ. Ext. de Colombia, 1999.
- KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*, Coimbra: Armênio Amado, 1962. vol. 2.
- KRIELE, Martin. Il precedente nell'ambito giuridico europeo-continentale e angloamericano, *La sentenza in Europa – método, tecnica e stile* (obra coletiva), Padova: Cedam, 1988.
- LACERDA, Galeno. *Despacho saneador*, Canoas: La Salle, 1953.
- LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*, 3. ed., tr. port. José Lamago, Lisboa: Fundação C. Gulbenkian, 1997.
- LAZZARINI, Alexandre Alves. *A causa petendi nas ações de separação judicial e de dissolução da união estável*, São Paulo: Ed. RT, 1999.
- LEDESMA, Héctor Faúndez. El derecho a un juicio justo, *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, 80, 1991.

- LEFORT, Christophe. *Procédure civile*, Paris: Dalloz, 2005.
- LEGROS, Robert. Considérations sur les motifs, *La motivation des décisions de justice* (obra coletiva), Bruxelles: É. Bruylant, 1978.
- LEITE, Clarisse Frechiani Lara. *Prejudicialidade no processo civil*, São Paulo: Saraiva, 2008.
- LEONEL, Ricardo de Barros. *Causa de pedir e pedido. O direito superveniente*, São Paulo: Método, 2006.
- LIEBMAN, Enrico Tullio. *Efficacia ed autorità della sentenza*, rist., Milano: Giuffrè, 1962 [*Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada*. (tradução para o português). 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981].
- _____. Giudicato – diritto processuale civile, *Enciclopedia giuridica treccani*, 1989. vol. 15. [The Notion of Res Judicata, *Italian Yearbook of Civil Procedure*, ed. Elio Fazzalari e Maurice Sheridan, Milano: Giuffrè, 1991].
- _____. *Manuale di diritto processuale civile*, 1, 6. ed., Milano: Giuffrè, 2002.
- _____. *Notas às Instituições de direito processual civil de Chiovenda*, 2. ed., tr. port. J. Guimarães Menegale, São Paulo: Saraiva, 1965. vol. 3.
- _____. *Processo de execução*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1980.
- LIMA, Alcides de Mendonça. Ação rescisória contra acórdão em agravo de instrumento, *Revista de Processo*, 41, 1986.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1990. vol. 6.
- _____. Intransmissibilidade da ação, *Dicionário do Código de Processo Civil brasileiro*, São Paulo, Ed. RT, 1986.
- LIMA, Tiago Asfor Rocha. *Precedentes judiciais civis no Brasil*, São Paulo: Saraiva, 2013.
- LOPES DA COSTA, Alfredo de Araújo. *Da intervenção de terceiros no processo*, São Paulo: Teixeira, 1930.
- LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. *Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada*, São Paulo: Saraiva, 2012.
- LUCON, Paulo Henrique dos Santos. *Código de Processo Civil interpretado*, 3. ed., obra coletiva, São Paulo: Atlas, 2008.
- LUISO, Francesco P. *Diritto processuale civile*, 3, 3. ed., Milano: Giuffrè, 2000.
- _____. *L'esecuzione "ultra partes"*, Milano: Giuffrè, 1984.
- MACHADO, J. Baptista. *Introdução ao direito e ao discurso legitimador*, Coimbra: Almedina, 1997.
- MACHADO, Marcelo Pacheco. *A correlação no processo civil. Relações entre demanda e tutela jurisdicional*, Salvador JusPodivm, 2015.
- MALLET, Estevão. Breves notas sobre a interpretação das decisões judiciais, *Revista do TST*, 74, jan./fev., 2008.
- _____. *Ensaio sobre a interpretação das decisões judiciais*, São Paulo: LTr, 2009.
- MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Jurisdição coletiva e coisa julgada*, tese, São Paulo, 2005.

- MANDRIOLI, Crisanto. In tema di rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo esecutivo, *Studi in onore di Enrico Allorio*, 1, Milano: Giuffrè, 1989.
- MARGUÉNAUD, Jean-Pierre. *La Cour européenne des droits de l'homme*, Paris: Dalloz, 1997.
- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Curso de processo civil*, São Paulo: Ed. RT, 2007. vol. 3: execução.
- _____. MITIDIERO, Daniel. *O Projeto do CPC – críticas e propostas*, São Paulo: Ed. RT, 2010.
- _____. *A efetividade da multa na execução da sentença que condena a pagar dinheiro*. Disponível em: [www.egov.ufsc.br].
- _____. *A ética dos precedentes*, São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. A tutela específica do consumidor, *Revista de Direito do Consumidor*, 50, 2004.
- _____. Eficácia temporal da revogação da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, *Revista dos Tribunais*, 906, 2011.
- _____. *Novas linhas do processo civil*, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1999.
- _____. *Tutela específica*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2001.
- _____. *Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito*, Academia Brasileira de Direito Processual Civil, Disponível em [www.abdpc.org.br].
- MARQUES, José Frederico. *Instituições de direito processual civil*, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1972. vol. 3.
- _____. *Manual de direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1974. vol. 1.
- _____. *Manual de direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1975. vol. 3.
- MASSARI, Alberto. Rinunzia agli atti del giudizio, *Novissimo digesto italiano*, 15, 1968.
- MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*, 6. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1957.
- MELLO, Patrícia Perrone Campos. *Precedentes*, Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- MENCHINI, Sergio. *Il giudicato civile*, Torino: Utet, 1988.
- MENDES, João de Castro. *Limites objectivos do caso julgado em processo civil*, Lisboa: Ática, 1968.
- MICHELI, Gian Antonio. *La rinuncia agli atti del giudizio*, Padova: Cedam, 1937.
- MILLAR, Robert Wyness. The formative principles of civil procedure, *A history of continental civil procedure*, coord. Arthur Engelmann, New York: Augustus Kelley, 1969.
- MITIDIERO, Daniel. *Colaboração no processo civil*, São Paulo: Ed. RT, 2009.
- MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983. vol. 2.
- _____. *Sentença e coisa julgada – Exegese do Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Aide, 1992.
- MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de direito civil – direito das coisas*, 31. ed., São Paulo: Saraiva, 1994.

- MONTELEONE, Girolamo. *I limiti soggettivi del giudicato civile*, Padova: Cedam, 1978.
- MONTESANO, Luigi. “Pubblico” e “privato” in norme del Codice Civile sulla tutela giurisdizionale dei diritti, *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Milano, Giuffrè, 1993. vol. 2.
- MOREIRA, Egon Bockmann; JUSTEN FILHO, Marçal; TALAMINI, Eduardo. Sobre a hipoteca judiciária, *Revista de Processo*, vol. 85, 1997.
- MORETTI, G. La dottrina del precedente giudiziario nel sistema inglese, *Contratto e impresa* (obra coletiva), dir. F. Galgano, Padova: Cedam, 1990.
- MOUZALAS, Rinaldo. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier *et alii*, São Paulo: Ed. RT, 2015
- NASI, Antonio. Interpretazione della sentenza, *Enciclopedia del diritto*, 22, 1972.
- NEGRÃO, Theotonio *et alii*. *Código de Processo Civil e legislação processual em vigor*, 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014.
- NERY JUNIOR, Nelson. Condições da ação, *Revista de Processo*, 64, 1991.
- NORMAND, Jacques. Le domaine du principe de motivation, *La motivation – Travaux de l'Association Henri Capitant*, Paris, LGDJ, 2000.
- NORONHA, Carlos Silveira, *Sentença civil*, São Paulo: Ed. RT, 1995.
- OLDONI, Fabiano. A prescrição da pretensão punitiva e a coisa julgada no cível, *Revista Jurídica*, 339, 2005.
- OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. *O direito. Introdução e teoria geral – uma perspectiva luso-brasileira*, 11. ed., Coimbra: Almedina, 2001.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Poderes do juiz e visão cooperativa do processo, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Lisboa*, 2003. vol. 44.
- OLIVEIRA, Rafael Alexandre de, BRAGA, Paula Sarno; DIDIER JÚNIOR, Fredie. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2015.
- _____, DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno. *Curso de direito processual civil*, 2, 10. ed., Salvador: JusPodivm, 2015.
- PACE, Gaetano. *Il diritto transitorio con particolare riguardo al diritto privato*, Milano: Ambrosiana, 1944.
- PALERMO, Antonio. *Il processo di formazione della sentenza civile*, Milano: Giuffrè, 1956.
- PEIXOTO, Ravi. *Superação do precedente e segurança jurídica*, Salvador: JusPodivm, 2015.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*, 11. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1994. vol. 4.
- PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. *Tratado da argumentação. A nova retórica*, tr. port. Maria Ermantina Galvão, São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- PERO, Maria Thereza Gonçalves. *A motivação da sentença civil*, São Paulo: Saraiva, 2001.
- PERROT, Roger. La cosa giudicata: recenti sviluppi nel diritto francese, *Rivista di diritto processuale*, 1982.

- PICÓ I JUNOY, Joan. *Las garantías constitucionales del proceso*, Barcelona: Bosch, 1997.
- PIMENTEL, Wellington Moreira. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 1975. vol. 3.
- PONTES DE MIRANDA, F. C. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1979. t. 3.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1947. t. 2.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1974. t. 5.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1978. t. 17.
- _____. *Tratado de direito privado*, 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. t. 22.
- _____. *Tratado de direito privado*, 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1959. t. 25.
- PORTO, Sérgio Gilberto. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 6.
- POUTCHINSKI, V. K. *Princípios de processo civil da URSS e das Repúblicas Federadas*, trad. port. Soveral Martins, Coimbra: Centelha, 1978.
- PROTO PISANI, Andrea. *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli: Jovene, 1994.
- _____. Parte (dir. proc. civ.), *Enciclopedia del diritto*, 31, 1981,
- PUGLIESE, Giovanni. Giudicato civile (storia), *Enciclopedia del diritto*, 18, 1968.
- RAGGI, Luigi. Unilateralità delle renuncie processuali, *Rivista di diritto processuale*, 1925.
- RAMOS, Glauco Gumerato. Cumprimento da sentença condenatória de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito, *Execução civil e cumprimento da sentença* (obra coletiva), coord. Gilberto Gomes Bruschi, São Paulo: Método, 2006.
- REALE, Miguel. *Fontes e modelos do direito*, São Paulo: Saraiva, 1994.
- REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, rist., Milano: Giuffrè, 1960.
- REIS, José Alberto dos. *Comentário ao Código de Processo Civil*, Coimbra Ed., Coimbra, 1946. vol. 3.
- ROCCO, Alfredo. *La sentenza civile*, Milano: Giuffrè, 1962.
- ROCCO, Ugo. *L'autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi*, Roma: Athenaeum, 1917.
- RODRIGUES, Fernando Pereira. *O novo processo civil. Os princípios estruturantes*, Coimbra: Almedina, 2013.
- RODRIGUES, Marcelo Abelha. *Manual de execução civil*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. *A modificação do pedido e da causa de pedir no processo civil*, Rio de Janeiro: GZ Ed., 2014.
- RODRIGUES, Sílvio. *Direito civil – direito das coisas*, 21. ed., São Paulo: Saraiva, 1994. vol. 6.
- ROSAS, Roberto. *Direito sumular*, 14. ed., São Paulo: Malheiros, 2012.
- ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz; GOTTWALD, Peter. *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C. H. Beck, 2010.

- RUBIER, Paul. *Le droit transitoire – Conflits de lois dans le temps*, 2. ed., Paris: Dalloz, 2008 (reimpr.).
- SALVIOLI, Giuseppe. *Storia del diritto italiano, parte 2: Storia della procedura civile e criminale*, Sauer & Auvermann-Gozzini, Frankfurt-Firenze, 1969 (reed. 1927). vol. 3.
- SANCHEZ-CRUZAT, José M. Bandres. *El tribunal europeo de los derechos del hombre*, Barcelona: Bosch, 1983.
- SANTOS, Moacyr Amaral. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 3. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1982. vol. 4.
- _____. *Primeiras linhas de direito processual civil*, 26. ed., São Paulo: Saraiva, 2010. vol. 2.
- SANTOS, Silas Silva. *Modificações subjetivas na execução e o objeto litigioso*, tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 2016.
- SARNO BRAGA, Paula; DIDIER JÚNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandre de. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2015.
- SARTOR, G. Precedente giudiziale, *Contratto e impresa* (obra coletiva dir. F. Galgano), Padova: Cedam, 1995.
- SAUVEL, Tony. Histoire du jugement motivé, *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 61, 1955.
- SAVIGNY, F. Carl von. *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin: Veit und Comp., 1847. vol. 6 [*Sistema del diritto romano attuale*, tr. it. Vittorio Scialoja, vol. 6, Torino, Utet, 1896].
- SCHAUER, Frederick. *Thinking like a Lawyer*, 1. reed. Indiana/Nova Deli: Universal, 2010.
- SCHMITZ, Leonard Ziesemer. *Fundamentação das decisões judiciais*, São Paulo: Ed. RT, 2015.
- SCHWAB, Karl Heinz; ROSENBERG, Leo; GOTTWALD, Peter. *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C. H. Beck, 2010.
- SHIMURA, Sérgio Seiji. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier *et alii*, São Paulo: Ed. RT, 2015.
- SICA, Heitor Vitor Mendonça. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2015.
- _____. Doze problemas e onze soluções quanto à chamada “estabilização da tutela antecipada”, *Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro*, 55, 2015.
- _____. *Preclusão processual civil*, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2008.
- SILVA, Beclaute Oliveira. *A garantia fundamental à motivação da decisão judicial*, Salvador: JusPodivm, 2007.
- SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*, 16. ed., São Paulo: Malheiros, 1999.
- SILVA, Ovídio A. Baptista da. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 1.
- _____. Eficácias da sentença e coisa julgada, *Sentença e coisa julgada – ensaios*, Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1979.

- _____. Limites objetivos da coisa julgada no direito brasileiro atual, *Sentença e coisa julgada – ensaios*, Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1979.
- SIQUEIRA, Thiago Ferreira. *Objeto do processo, questões prejudiciais e coisa julgada*, tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 2018.
- SOUSA, Miguel Teixeira de. *O interesse processual na acção declarativa*, Lisboa: AAFDL, 1989.
- _____. O objeto da sentença e o caso julgado material (estudo sobre a funcionalidade processual), *Revista Forense*, 291, 1985.
- SOUZA, Paulo Roberto Pereira de. Abandono da causa, *Revista de Processo*, 24, 1981.
- STALEV, Zhivko. Fundamental Guarantees of Litigation in Civil Proceedings: A Survey of the Laws of the European People's Democracies, *Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation*, org. Cappelletti e Vigoriti, Milano/New York: Giuffrè-Oceana, 1973.
- STRECK, Lenio Luiz. *Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica do direito*, Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2002.
- STRECK, Michael. *Generalklausel und unbestimmter Begriff im Recht der allgemeinen Ehwirkungen*, Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1969.
- SURGIK, Aloísio. *A origem da conciliação*, tese de doutoramento, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 1984.
- TALAMINI, Eduardo, JUSTEN FILHO, Marçal; MOREIRA, Egon Bockmann. Sobre a hipoteca judiciária, *Revista de Processo*, 1997. vol. 85.
- _____. *Coisa julgada e sua revisão*, São Paulo: Ed. RT, 2005.
- _____. “Sentença que reconhece obrigação” como título executivo (CPC, art. 475-N, I, acrescido pela Lei 11.232/2005), *Execução civil e cumprimento de sentença* (obra coletiva), coord. Gilberto Gomes Bruschi, São Paulo: Método, 2006.
- _____. *Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2003.
- TARUFFO, Michele. Precedent in Italy, *Interpreting Precedents – A Comparative Study*, obra coletiva dir. Neil MacCormick e Robert. Summers, Adershot, Ashgate, 1997.
- _____. *Dimensioni del precedente giudiziario, Scintillae iuris – Studi in memoria di Gino Gorla*, Milano, Giuffrè, 1994. t. 1.
- _____. *La motivazione della sentenza civile*, Padova: Cedam, 1975.
- _____. Las funciones de las Cortes Supremas: entre uniformidad y justicia, *Proceso y Constitución – El rol de las Altas Cortes y el derecho a la impugnación*, Lima: Palestra, 2015.
- _____. Precedente e giurisprudenza, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2007.
- THEODORO JÚNIOR, Humberto. A exceção de prescrição: aspectos substanciais e processuais, *As novas reformas do Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- _____. *Comentários ao novo Código Civil*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005. vol. 3, t. 2.
- TOME GARCÍA, José Antonio. *Protección procesal de los derechos humanos ante los tribunales ordinarios*, Madrid: Montecorvo, 1987.
- TORNAGHI, Hélio, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 1974. vol. 1.

TROCKER, Nicolò. Poderes del juez y derechos de las partes en el proceso civil: las enseñanzas de Calamandrei y las reformas procesales en Europa, *Teoría & derecho – Revista de Pensamiento Jurídico*, trad. esp. de Laura Volpe, Valencia: Tirant lo Blanch, 7, 2010.

TUCCI, Rogério Lauria; CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Constituição de 1988 e processo*, São Paulo: Saraiva, 1989.

_____. A nova fase saneadora do processo civil brasileiro, *Reforma do Código de Processo Civil* (obra coletiva), coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva, 1996.

_____. *Do julgamento conforme o estado do processo*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1988.

VV.AA. *La sentenza in Europa – metodo, tecnica e stile*, Padova: Cedam, 1988.

VALSECCHI, Emilio. *La transazione*, Trat. dir. civ. comm., dir. Cicu-Messineo, Milano: Giuffrè, 1954.

VIGORITI, Vincenzo; CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the Litigants in Civil Proceedings: Italy, *Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation*, Milano: Giuffrè, 1973.

VINCENTI, Umberto. *Duo genera sunt testium. Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova: Cedam, 1976.

WACH, Adolf. *Der Feststellungsanspruch – La pretensión de declaración*, tr. cast. Juan M. Semon, Buenos Aires: Ejea, 1962.

WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier *et alii*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. *Liquidação de sentença*, São Paulo: Ed. RT, 1997.

YARSHELL, Flávio Luiz. *Tutela jurisdicional específica nas obrigações de declaração de vontade*, São Paulo: Malheiros, 1993.

ZEUNER, Albrecht. *Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmem rechtlicher Sinnzusammenhänge*, Tübingen: Mohr, 1959.

Índice Alfabético-remissivo

Abandono do processo, **485**, 5, 5.1

– e comportamento do réu, **485**, 5.3

– e consequência da extinção do processo, **485**, 5.5

– e correção de equivocada analogia construída pela jurisprudência, **485**, 5.2

– e inatividade das partes, **485**, 4

– e ineficácia, **485**, 5.4

Ação

– de conhecimento, **511**, 114

– Declaratória incidental, **503**, 84

– Intransmissibilidade, **485**, 11, 12

Ação rescisória

– e liquidação, **509**, 109

– e protesto, **517**, 134

Adimplemento voluntário

– e prazo, **498**, 63

Arbitragem, **485**, 9

– Competência, **485**, 9

Arguição incidental

– de falsidade de documento, **503**, 83

– por petição simples, **518**, 139

Autocomposição

– Ampliação subjetiva e objetiva, **515**, 129.2.1

– Decisão homologatória, **515**, 129.1

Caução, **521**, 146

- Dispensa, **521**, 148
- Garantia de acesso à justiça, **521**, 147

Citação

- Executado, **515**, 130

Coisa julgada

- e decisões parciais de mérito e inconstitucionalidade (art. 975), **502**, 76
- e eficácia da sentença, **501**, 72
- e eficácia preclusiva, **508**, 101
- e estabilidade da tutela antecipada, **502**, 75
- e flexibilização, **505**, 94
- e questão prejudicial, **503**, 80
- e relação jurídica de trato continuado, **505**, 92
- e revisão, **505**, 93
- Material, **485**, 7, 7.1, 7.4, **501**, 73

Condenação

- e impossibilidade de quantificação, **491**, 34
- na prestação específica, **497**, 60

Condição ou termo

- no cumprimento de sentença, **514**, 127, 128

Contraditório

- e cognição ex officio, **495**, 44
- e hipoteca judiciária, **495**, 53

Correção de inexatidões materiais ou de erro de cálculo, **494**, 47

Cumprimento de sentença

- e competência, **516**, 131, 131.1, 131.2, 131.3
- e delimitação subjetiva, **513**, 126
- e disciplina procedimental, **513**, 123
- e duração razoável do processo, **512**, 119, 120, 121,
- e iniciativa do exequente, **513**, 124
- e intimação do devedor, **513**, 125, 125.1, 125.2, 125.3
- e meios defensivos do executado, **518**, 138

– e sujeição à condição ou termo, **514**, 127, 128

– e tutela executiva, **512**, 122

– e tutela provisória, **519**, 140

Cumprimento de sentença contra a fazenda pública

– Demonstrativo discriminado, **534**, 184

– Litisconsórcio ativo, **534**, 185

– Isenção da incidência de multa, **534**, 187

– Descabimento de honorários de advogado, **534**, 188

– Impugnação, **535**, 189, 190, 191, 192

Cumprimento de sentença obrigacional, **536**, 193

– Medidas necessárias para o cumprimento da obrigação, **536**, 194, 194.1, 195.2, 194.3

– Litigância de má-fé e crime de desobediência, **536**, 195

– Contraditório, **536**, 196

– Deveres de fazer ou de não fazer de natureza não obrigacional, **536**, 197, 537, 202

– Multa, **537**, 198, 199, 200, 201

Cumprimento de sentença de entrega de coisa, **538**, 203

– Retenção por benfeitorias, **538**, 204

Cumprimento de sentença de alimentos, **528**, 170

– Alimentos definitivos e provisórios, **531**, 179

– Competência, **528**, 171

– Conduta procrastinatória, **532**, 180

– Constituição e objeto do capital, **533**, 182

– Crime de abandono material, **532**, 180

– Indenização por ato ilícito, **533**, 181

– Justificativa do executado, **528**, 176

– Outras medidas coercitivas, **528**, 173

– Penhorabilidade de salário, **529**, 177, 177.1, 177.2

– Prisão civil, **528**, 172, 173, 176

– Revisão do valor da prestação, **533**, 183

– sob pena de penhora, **528**, 174

Cumprimento definitivo da sentença de pagar quantia certa, **523**, 152, 155, **524**, 156

- Atribuição de efeito suspensivo, **525**, 162
- Cumprimento provisório, **527**, 167, 168, 169
- Depósito, **526**, 164, 165, 166
- Impugnação, **525**, 159, 160, 161, 163
- Incidência de multa e de honorários advocatícios, **523**, 154
- Intimação do devedor, **523**, 152
- Requisição de informações e princípio da cooperação, **524**, 158
- Valor, **524**, 157

Cumprimento provisório da sentença de quantia certa, **520**, 141, 143

- Admissibilidade de impugnação, **520**, 145
- Cumprimento definitivo, **527**, 167, 168, 169
- Incidência de multa e honorários, **520**, 144
- Peças, **522**, 150
- Responsabilidade do advogado, **522**, 151
- Responsabilidade objetiva do credor, **520**, 142

Decadência e prescrição

- Prescrição intercorrente no processo de execução, **487**, 21.1
- Reconhecimento, **487**, 21

Decisão

- Certeza e relação jurídica condicional, **492**, 38
- de mérito, **488**, 23, 24, 25

Declaração de vontade

- Ação de conhecimento para a prova de fato novo, **511**, 114
- Descumprimento de obrigação de prestar, **501**, 69
- Substituição de vontade não declarada, **501**, 70
- Veracidade, **504**, 89

Desistência da ação, **485**, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7

- e sucumbência, **485**, 10.7

Duração razoável do processo

- e cumprimento de sentença, **512**, 119
- e liquidação de sentença, **512**, 117

Eficácia preclusiva

– e coisa julgada, **508**, 101

Embargos de declaração, **494**, 48

– Equívoco processual, **494**, 49

Falta de legitimidade ou de interesse processual, **485**, 8

– e inexistência de preclusão pro judicato , **485**, 8.3

– e teoria da asserção/julgamento de mérito, **485**, 8.2

Fato

– e influência no julgamento da causa, **493**, 43

– e superveniência de efeitos por nova norma jurídica, **493**, 41

– novo, **493**, 40, **511**, 114

– superveniente, **493**, 40, 41

Hipoteca judiciária, **495**, 50

– e devido processo legal, **495**, 53

– e efeito da sentença condenatória, **495**, 51

– Procedimento, **495**, 52

Improcedência liminar do pedido, **487**, 20.1

Incidência imediata das regras de direito processual, **503**, 85

Indenização e cumulação com multa coercitiva, **500**, 68

Individualização de coisa incerta, **498**, 64

Inibição ou remoção de ilícito

– e irrelevância da prova de dano, culpa ou dolo, **497**, 62

Intimação

– na liquidação da sentença. **511**, 115

– no cumprimento de sentença, **513**, 125, 125.1, 125.2, 125.3

Intransmissibilidade da ação, **485**, 11, 12

– pela parte falecida, **485**, 11

Julgamento de mérito propriamente dito, **487**, 20

Liquidação de sentença

– Assimetria e cabimento de rescisória, **509**, 109

– Cálculo aritmético e imediato cumprimento de sentença, **509**, 106

- Contestação e recurso cabível, **511**, 116
- de sentença parcial, **509**, 105
- e diretriz CNJ, **509**, 107
- e duração razoável do processo, **512**, 117
- Espécies, **509**, 103
- Exceção, **509**, 102
- Fungibilidade, **509**, 110
- Intimação, **511**, 115
- Legitimidade, **509**, 104
- Simetria com o título judicial, **509**, 108

Litispendência, **485**, 7, 7.1, 7.3

- e identidade dos elementos da demanda, **485**, 7.3.4
- no processo coletivo, **485**, 7.3.2
- no STJ, **485**, 7.3.5

Matéria cognoscível de ofício, **485**, 13

- e contraditório, **495**, 44
- perante as instâncias ordinárias, **485**, 13.1
- perante os tribunais superiores, **485**, 13.2

Motivação, **489**, 28

- Colisão de normas, **489**, 28.5
- como garantia constitucional, **489**, 28.1
- e nulidade, **489**, 28.4
- Escopos, **489**, 28.3
- Significado e conteúdo, **489**, 28.2

Multa coercitiva

- Cumulação com indenização, **500**, 68
- Imposição, **500**, 67

Nulidade

- por desrespeito injustificado à súmula, jurisprudência ou precedente, **489**, 28.4.6
- por fundamentação genérica, **489**, 28.4.2
- por fundamentação padronizada, **489**, 28.4.3

- por invocação impertinente de súmula ou precedente, **489**, 28.4.5
- por mera reprodução de fundamento legal, **489**, 28.4.1
- Motivação, **489**, 28.4
- por motivação aliunde ou per relationem, **489**, 28.4.7
- por motivação insuficiente, **489**, 28.4.4

Parte, **506**, 96

Perdas e danos

- Conversão em, **499**, 66
- Tutela específica, **499**, 65

Perempção, **485**, 7, 7.1, 7.2, **486**, 17,

Petição inicial

- Indeferimento, **485**, 3

Preclusão

- pro judicato sobre questão de ordem pública, **505**, 91

Pressupostos processuais

- Ausência, **485**, 6
- Classificação, **485**, 6.
- Correção do defeito, **485**, 6.
- Repropositura da demanda, **485**, 6.

Processo

- Abandono, **485**, 5, 5.1

Protesto

- Cancelamento, **517**, 133, 135
- da decisão judicial transitada em julgado, **517**, 132
- da decisão que fixa alimentos provisórios e definitivos, **517**, 136
- e ação rescisória, **517**, 134
- Negativação do nome do devedor, **517**, 137
- Providências, **517**, 133

Prova

- Adiantamento da remuneração do perito, **510**, 113
- Pericial, **510**, 112

– Pré-constituída, **510**, 111

Questão

– Autônoma, **503**, 78

– e coisa julgada, **503**, 79, 80

– Indiscutibilidade, **507**, 99

– Prejudicial, **503**, 78, 79

– Principal, **503**, 78

Reconhecimento da procedência do pedido, **487**, 22.1

Recurso/impugnação

– na liquidação da sentença, **511**, 116

– no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, **535**, 189, 190, 191, 192

– no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, **536**, 196

– no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, **528**, 175

– no cumprimento de sentença, **518**, 138

– no cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, **525**, 159, 160, 161, 163

– no cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, **520**, 145

Reformatio in pejus, **496**, 58

Relação jurídica de trato continuado

– e coisa julgada, **505**, 92

Relatório, **489**, 27

Remessa necessária

– Alterações, **496**, 57

– Isonomia processual, **496**, 55

– Omissão quanto à reformatio in pejus, **496**, 58

– Reforma, **496**, 56

Renúncia à pretensão, **487**, 22.3

Responsabilidade

– do advogado e traslado incompleto, **522**, 151

– na hipoteca judiciária, **495**, 54

– por desistência da ação, **485**, 10.7

Resultado prático equivalente, **497**, 61

Retratação judicial no quinquídio, **485**, 14

Sentença

– arbitral, **515**, 129.6

– Capítulos, **490**, 31, 32

– Correlação entre pedido e sentença, **492**, 35

– Dispositivo, **489**, 29

– Distinção entre motivos e dispositivo, **504**, 86

– estrangeira, **515**, 129.7

– Homologatória, **487**, 22

– Interpretação a partir da boa-fé, **489**, 30

– Motivação, **489**, 28, 28.2, 28.3, 28.4, **504**, 87, 88

– penal, **515**, 129.5

– Publicação, **494**, 46

– Relatório, **489**, 27

– terminativa, **486**, 18

– Vícios, **492**, 37

Sucumbência, **486**, 16

– Comprovação do pagamento, **486**, 16

– Desistência da ação, **485**, 10.7

Terceiro

– Beneficiado pela eficácia da sentença transitada em julgado, **506**, 97

– Conceito, **506**, 96

Títulos executivos judiciais, **515**, 129

– Crédito de auxiliar de justiça, **515**, 129.4

– Decisão interlocutória estrangeira, **515**, 129.8

– Exigência de citação, **515**, 130

– Formal e certidão de partilha, **515**, 129.3

– Homologatória de autocomposição, **515**, 129.1

– Reconhecimento da exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, **515**, 129.1

Transação, **487**, 22.2,

– Conceito, requisitos e espécies, **487**, 22.2.1,

– como categoria dos negócios jurídicos processuais, **487**, 22.2.2

– Efeitos e objeto, **487**, 22.2.3

Tutela específica

– Perdas e danos, **499**, 65

Vícios

– Embargos de declaração, **494**, 48

– Equívoco processual, **494**, 49

– na sentença, **492**, 37

© desta edição [2018]